FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 1 DEL 02/10/2024

Come fate a sapere che esiste il diritto?

Cioè vi siete iscritti a questa università con l'idea di studiare il diritto, ma come fate a sapere che esiste il diritto?

(DOMANDA METAFISICA): Esiste il diritto?

Risposta: Ogni giorno ci interfacciamo con le leggi.

-Quando ti interfacci con le leggi?

Risposta: In qualsiasi cosa, per esempio quando entro in un ufficio pubblico so che ci sono delle leggi.

-E come fai a rispondermi che esiste il diritto?

Mettiamo il caso che tu non sappia nulla, poniamo un velo di ignoranza totale, grado zero di conoscenza e io ti chiedo come fai a sapere che esiste il diritto, come lo conosci il diritto?

Risposta: L'uomo quando è nato migliaia di anni fa non conosceva il diritto però viveva attribuendo a sé stesso dei diritti come, ad esempio, il diritto di mangiare e di cacciare. Questi inizialmente sono dei bisogni poi li ha costruiti come diritti. Noi dobbiamo ragionare con la prospettiva dei filosofi inglesi, ci sono filosofi che studiano il linguaggio e affermano che per fare buona filosofia bisognerebbe rispondere al playman, ovvero l'uomo comune. Facciamo finta che noi che non stiamo qui per studiare filosofia, ma stiamo passeggiando tra amici e vi state confidando con alcuni vostri amici dicendo:

-A che facoltà ti iscriverai?

-Alla facoltà di giurisprudenza

-Perché?

-Perché mi piace studiare il diritto

-Che ne sai del diritto? Come lo conosci il diritto? Come ti accorgi che esiste il diritto? Come lo percepisci?

Utilizzando termini più tecnici possiamo dire:

Come abbiamo la percezione che il nostro mondo sia un mondo essere piuttosto che il nulla? perché c'è l'ordine, piuttosto che il caos? Intorno a noi non c'è del caos primordiale; ma percepite un senso di ordine, come lo percepite questo senso di ordine, da dove ve ne rendete conto?

Risposta: **Le regole**

Domanda: Come le percepite le regole?

Risposta: I nostri comportamenti sono condizionati dalle regole.

Domanda: E le regole tu come le conosci?

Distinguiamo due piani: esistono delle regole? Forse sì, perché ci rendiamo conto che intorno a noi **c'è l'ordine e non il caos,** un certo livello di caos c'è, ma quello direbbe un giurista novecentesco è conseguenza del fatto che ci sono delle regole. Quindi primo livello, c'è l'ordine e non il caos. Quest'ordine lo si percepisce attraverso i sensi, ma quali utilizzate? Non voglio né la cultura né la tradizione né la testa, ma il senso fisico: come percepite che esistono delle regole e che intorno a voi c'è ordine e non il caos?

Stamattina siete usciti di casa per venire qui, cosa avete fatto per venire qui a seguire le lezioni? Molti di voi hanno preso i mezzi e durante il tragitto come vi siete comportati, cosa avete fatto? Cosa avete incontrato?

Risposta: I segnali stradali

Vi siete resi immediatamente conto che nel momento stesso in cui siete usciti di casa, il mondo intorno a voi era un mondo che vi diceva qualcosa, non era trasparente il mondo intorno a voi e, una volta usciti di casa, avete l'auto parcheggiata nel marciapiede di fronte e dovete attraversare, come attraverso? Ci sono altre macchine che sfrecciano e avete pensato a tre possibilità:

1. tento la fortuna;
2. cerco dei segnali bianchi orizzontali che sono dipinti sull'asfalto perché vedo che molti che attraversano passano da lì, non so cosa significhino però mi rendo conto che tutti vanno lì e ci sarà un motivo; mi uniformo al comportamento degli altri perché io non sono nulla;
3. mi rendo conto che ci sono delle strane luci che lampeggiano sia rispetto agli autoveicoli sia rispetto a me e anche qui mi rendo conto che per salvarmi la vita e giungere dall'altra parte del marciapiede devo ben interpretare cosa mi dicono quelle luci che si accendono e spengono;

Tutte queste attività sono tutte attività che voi percepite attraverso che cosa?

Risposta: Attraverso lo sguardo, attraverso gli occhi, attraverso la vista che vi suggerisco una serie di informazioni che non sono informazioni puramente descrittive, sono tutte informazioni che vi obbligano a comportarvi in un certo modo piuttosto che in un altro; e lì che si inizia a costruire un certo tipo di ordine.

E allora, iniziate a pensare che intorno a voi vige l'ordine e non c'è il caos più totale.

Poi vi fate un'altra domanda, qual è la domanda successiva che vi dovete porre? Sappiamo che qualcosa c'è, abbiamo intuito che qualcosa c'è, esistono delle regolarità comportamentali che noi osserviamo. Ci sono delle immagini, queste immagini, questi segni visivi ci restituiscono informazioni che tutto sommato ci suggeriscono come ci dobbiamo comportare e come non ci dobbiamo comportare. E dunque, la domanda successiva è: **se c'è qualcosa, questo qualcosa che cos'è?** è espressione di che? Che significato ha questo qualcosa? Cioè le strisce bianche o le luci che si illuminano, sono espressione di che cosa? Se le persone seguono o non seguono ciò che indicano questi segnali vuol dire che quest'ultimi esprimeranno qualcosa; dunque, saranno espressione di regole o di regolarità (la regolarità anzi è un effetto della regola).

La domanda successiva qual è?

Che cosa sono le regole? Come facciamo a conoscere le regole? Hanno un corpo le regole? Che tipo di oggetti sono le regole?

Risposta: Astratti

Sono come gli oggetti matematici? Sono come i numeri le regole? Che tipo di oggetti astratti sono le regole?

Risposta: A me viene in mente il Limes romano, quindi un confine artificiale.

Pensate ai semafori, alle strisce pedonali, hanno effetti nei nostri confronti?

Risposta: Plasmano la nostra realtà.

Dunque, sono oggetti astratti un po' particolari, tanti pensieri sono oggetti astratti; anche i numeri sono oggetti astratti, ma i numeri sono oggetti astratti che hanno una realtà. Ma tutti questi oggetti astratti funzionano perché producono nei nostri confronti effetti diversi; e dunque **le regole** non sono oggetti astratti neutri, **sono oggetti astratti che hanno una loro forza che si esprime nei nostri confronti.**

E allora possiamo meglio definire questa categoria di oggetti astratti?

-Oggettivi

Moltissimi filosofi contemporanei del diritto affermano che il diritto ha una realtà spettrale, cioè è costruito da regole che noi non tocchiamo, non vediamo, cioè astratto ma è capace di condizionare continuamente i nostri comportamenti. D'altronde se pensate alla traduzione francese di spettro significa letteralmente ciò che ritorna sempre da un altro mondo.

Le regole dicono ossessivamente sempre la stessa cosa: È VIETATO FUMARE. In questo caso ti ricordano continuamente che qui non puoi fumare. Tornano sempre a dirti la stessa cosa, ripetendo ciò che noi dobbiamo fare e il modo in cui dobbiamo comportarci.

Che tipo di segni sono le regole giuridiche, che tipo di forza esprimono? Direbbero i semiotici che **esprimono una forza deontica che riguarda il dover essere** cioè sono oggetti astratti che esprimono il dover essere, **non ciò che esiste, ma ciò che deve essere**, il modo in cui noi dobbiamo essere, il modo in cui noi dobbiamo comportarci. Dunque, sono oggetti non neutri, ma astratti che hanno una forza deontica nei nostri confronti.

Se volete utilizzare un termine meno filosofico di forza deontica, **esprimono nei nostri confronti una forza normativa che condiziona continuamente il nostro modo di vivere**.

Qual è il corpo delle regole? Noi abbiamo un corpo fisico attraverso cui veniamo percepiti dagli altri; voi come le percepite le regole? A primo acchito attraverso lo sguardo (le indicazioni stradali), ma andando nello specifico come esistono le regole? Qual è il corpo di una regola?

Risposta: Il codice.

Domanda: E il codice che cos'è? Da un punto di vista esclusivamente linguistico, come si presenta un codice?

Risposta: Una raccolta con tutte le regole.

Domanda: Queste regole dal punto di vista logico-grammaticale cosa sono?

Risposta: Sono proposizioni linguistiche che possono assumere anche veste visiva, pensate ad esempio alle indicazioni stradali.

Domanda: Queste proposizioni linguistiche esprimono una loro forza, dunque che tipo di proposizioni sono? come le potremmo definire?

Risposta: **Proposizioni linguistiche che parlano un determinato linguaggio**.

Domanda: Che tipo di linguaggio parlano queste proposizioni, questi segni linguistici?

Risposta: Un linguaggio che ha una sua forza sono oggetti deontici, oggetti normativi; quindi, si parla di **proposizioni linguistiche prescrittive che esprimono prescrizioni, cioè esprimono obblighi, divieti o permessi**.

Abbiamo una prima definizione basilare: il diritto parla un linguaggio.

Questo linguaggio è un **linguaggio prescrittivo**. Dunque, il diritto è un insieme di regole, ovvero di proposizioni linguistiche prescrittive, cioè proposizioni che ci dicono cosa dobbiamo fare o cosa non dobbiamo fare.

Qual è secondo voi adesso la domanda da porsi? Ora che noi sappiamo che queste proposizioni sono linguistiche e prescrittive; ci sono due questioni che balzano ai nostri occhi:

1) Cercare di capire come si comportano queste proposizioni, come funzionano e una volta che avremo capito come funzionano, potremmo cercare di capire quali sono gli effetti che effettivamente producono nei nostri confronti e quindi farci la domanda considerata LA MADRE DI TUTTE LE DOMANDE.

Prima questione:

Facciamo un esempio di una regola; quale può essere una proposizione linguistica che esprime una regola.

E.S: È vietato attraversare con il semaforo rosso.

È una regola di comportamento, quindi questa è una proposizione di tipo linguistica di carattere prescrittivo perché impone un obbligo. (siamo obbligati ad attraversare solo quando c'è il semaforo verde.)

Ora vi faccio un controesempio e vediamo se la proposizione che vi sto dicendo adesso secondo voi è simile o no alla proposizione sul semaforo.

E.S: Oggi è una bella giornata

Questa non è prescrittiva, è un'affermazione, è descrittiva.

La proposizione prescrittiva prescrive un comportamento, la proposizione descrittiva rappresenta uno stato di fatto. In questo caso sto constatando uno stato di fatto, cioè che oggi è una bella giornata.

Domanda: Della proposizione descrittiva dal punto di vista logico cosa possiamo predicare?

Risposta: È concreta.

E.S: Ragazzi oggi piove tantissimo.

Domanda: Che proposizione è questa?

Risposta: Proposizione descrittiva, sto descrivendo fuori, è una **proposizione descrittiva falsa** perché fuori non sta piovendo.

E.S: Oggi è una bella giornata

È una **proposizione descrittiva vera** perché sto descrivendo in maniera corretta lo stato di fatto attraverso la proposizione.

Dunque, le proposizioni descrittive sono proposizioni in cui si predica la verità o la falsità; o sono vere o sono false.

E.S: Ragazzi è vietato attraversare con la luce rossa, è una proposizione vera o falsa?

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 2 DEL 02/10/2024

È vera? Voi potete attraversare quando la luce del semaforo è rossa? Materialmente si può fare?

Non si deve fare ma forse lo avete fatto, questo che significa? Significa che quella proposizione è vera ma se voi attraversate quella proposizione è falsa perché dipende se noi seguiamo o meno quello che ci dice la regola.

Questo significa che le proposizioni prescrittive non funzionano come quelle descrittive. E come funzionano secondo voi? Qual è la domanda che ci dobbiamo porre dinanzi ad una regola? COSA SUCCEDE SE NON LE RISPETTO?

Ad esempio se io vi dicessi "durante le mie lezioni è vietato alzarsi in piedi ed uscire dall'aula altrimenti non si può più rientrare", voi che pensiero vi fate? Vi chiedete ovviamente il perché. Se invece io dicessi "oggi piove" (e non sta piovendo) voi capite chiaramente che si tratta di una proposizione falsa, ma se io vi dicessi "non potete aprire le finestre" il primo pensiero che vi fate è "Perché il professore mi impone questa regola?".

Torniamo all'inizio, le proposizioni prescrittive cosa fanno? Sono proposizioni che non sono mai indifferenti nei nostri confronti perché ci limitano gli spazi di libertà. Per creare l'ordine che ci circonda è organizzato da una ragnatela di regole, ognuno di noi vive incastrato in una rete di obblighi e di divieti. Sono proposizioni che quindi incidono profondamente sui nostri comportamenti.

Se tu vieni a limitare, a dirmi cosa fare? Mi dici la ragione per questa limitazione della mia libertà.

La domanda filosofica che sta alla base di tutte le concezioni filosofiche è "perché mai io devo seguire le regole?" quale ragione legittima le regole?

"per il bene comune" è una possibile risposta, Kant direbbe perchè la natura dell'essere umano prevede un livello di razionalità tale per cui, evidentemente, fondo sulla ragione umana una coesistenza comune che mi sopperisce di limitare i miei diritti in favore ovviamente del diritto dell'altro.

È una domanda terribile, inquietante. Se ci pensate il nostro mondo naturale è un mondo in cui non esistono più gli spazi normati.

Adesso si tende a normare qualsiasi cosa, dalla sessualità, dalle teorie sul gender, al tema dello spazio virtuale, al tema dell'intelligenza artificiale, al tema dell'eutanasia, dell'aborto, c'è bisogno

che tutto sia normato. Gli spazi di libertà quindi secondo alcuni è un mondo sempre più normato, per altri è un bene che ci siano queste regolamentazioni perché creano nuovi spazi di libertà condivisa.

Però è vero anche che il nostro è un mondo completamento normato, c'è un filosofo contemporaneo tedesco che recentemente ha parlato di colonizzazione del diritto sul mondo della vita, una colonizzazione totale delle regole giuridiche che hanno omologato ogni nostro spazio.

Quindi la nostra evoluzione nella società ha portato ad un livello di ipernormazione dei nostri spazi sociali, quindi la domanda si connota in maniera diversa ma rimane una domanda provocante e provocatoria, "perché devo seguire queste regole?" "chi me le impone?" "come si giustifica questo tipo di imposizione?" a questa domanda la filosofia del diritto dalla nascita della riflessione filosofica fino ai tempi più moderni ha dato mille risposte diverse, queste risposte però si possono classificare in due grandi correnti che hanno segnato il dibattito filosofico giuridico: la corrente giusnaturalista e la corrente del positivismo giuridico o giuspositivismo.

Per adesso possiamo dire che il giusnaturalismo da un punto di vista logico non si tenga in piedi.

Tutto passa dalla differenza tra la differenza tra proposizioni descrittive e proposizioni prescrittive

giusnaturalismo, che cosa vi dice la parola? Dice tutto la parola, "il diritto naturale", ci si rende conto che abbiamo delle necessità nostre: mangiare, sopravvivere, allevare dei propri animali, allevare dei propri campi, e quindi quando si allevano dei propri campi non si vuole che il nostro vicino prenda dai nostri campi e quindi si costruisce un confine. Perciò il diritto è connaturato alla nostra esperienza sensibile di vivere insieme. In quanto esseri umani noi ci diamo delle regole poiché queste regole scaturiscono dalla nostra natura. E quindi dove sarà Il problema del giusnaturalismo, o anche la bellezza del giusnaturalismo, il giusnaturalismo giustifica la creazione di regole col nostro vivere in comune basandole sulla natura dell'uomo, dice che è l'uomo che naturalmente ha bisogno di crearsi delle regole per poter vivere insieme. Ogni filosofia del diritto però ha assegnato a questo concetto di natura un significato diverso, la natura per gli storici è diversa da quella di Kant, come ad esempio anche la natura di Spinoza è radicalmente diversa dalla natura razionale di Kant. Tutti i pensatori hanno giustificato, hanno risposto alla nostra domanda "perché devo seguire le regole?" spiegando la necessità della regola partendo dal concetto di natura, questo concetto di natura però è tutt'altro che univoco nella storia del pensiero gius-filosofico ma è mutato a seconda delle concezioni e delle ideologie. Un concetto utilizzato ideologicamente nel passato anche per arginare lo strapotere del sovrano di turno, ad esempio l'appello divino di John Locke che si appella alla natura umana per fermare la strapotenza del sovrano. Attenzione però che la giustificazione naturale però può essere utilizzato anche a parti inverse, infatti il potere regale si è sempre giustificato in quanto fondato sulla natura divina. Qui il concetto di natura viene usato in maniera opposta rispetto a Locke, qua ci si concentra sulla natura divina del sovrano.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 3 DEL 07/10/2024

Le proposizioni descrittive (o constative) sono quelle proposizioni attraverso cui è possibile descrivere. Attraverso queste si può predicare la verità, se la proposizione rispecchia lo stato dei fatti che si sta constatando, o la falsità. Le regole sono espressione di proposizioni più delicate, nel senso che sono espressione di proposizioni prescrittive, ovvero quelle prescrizioni che ci dicono che cosa dobbiamo/possiamo o non dobbiamo fare, cioè di proposizioni che non descrivono un essere ma prescrivono il dover essere. Queste, dunque, sono proposizioni che incidono sui nostri comportamenti, condizionandoli costantemente. Condizionando costantemente i nostri comportamenti, sono proposizioni che producono effetti nei nostri confronti e, dunque, che chiedono un regime di predicabilità diverso. (ESEMPIO: "è vietato fumare!". Di questa proposizione non ci importa sapere se è vera o falsa, ma il problema di questa proposizione è se devo comportarmi secondo quello che prescrive quella proposizione, oppure no. La domanda che ci si pone dinanzi a questo tipo di proposizione è ben diversa, infatti non ci si chiede se queste siano adeguate a descrivere uno stato di fatto, ma essendo proposizioni che prescrivono qualcosa, ci si chiede se si debba seguire il precetto imposto da quella proposizione.) Il problema della filosofia del diritto, dai pre-socratici in poi, è rispondere alla domanda "perchè devo seguire le regole? chi limita la mia libertà personale? come giustifica ai miei occhi l'imposizione di un comando? in base a quale criterio si permette di darmi degli obblighi? e perchè io devo seguire quei determinati obblighi? in base a quale ragione e giustificazione?". L'interrogativo che alimenta tutto il dibattito in filosofia del diritto è proprio questo. A questa domanda è possibile rispondere in tanti modi diversi. La risposta che ha affollato le teorie giusfilosofiche fino al 19 sec. sono tutte quelle risposte che vengono definite giusnaturalistiche, ovvero la giustificazione della regola si fonda sul fatto che quella regola è conforme alla natura di qualcosa o di qualcuno. Si deve seguire una regola, perchè questa è basata e deriva dalla ragione dell'uomo, dall'immagine dell'infinita bontà di Dio. In tutti questi casi delle teorie giusnaturalistiche, le quali sono state le più variegate, nella storia della filosofia del diritto si fa una divisione dalle teorie dei giuristi alle teorie dei filosofi. Questi ultimi nascono come filosofi ma si sono occupati anche della filosofia del diritto. I primi, invece, nascono come giuristi e hanno elaborato anche delle teorie che riguardano la giustificazione delle regole giuridiche. In entrambi i casi, ciò che deve attirare la nostra attenzione è il modo di pensare di questi filosofi e giuristi.

COME RAGIONA UN GIUSNATURALISTA? QUAL È IL SISTEMA DI RAGIONAMENTO DI UN PENSATORE?

"Dio è infinitamente buono, le regole sono conformi quando emanate da Dio, dunque io devo seguirle in quanto le regole sono profondamente giuste."

"La natura dell'uomo è infallibile; le regole giuridiche derivano dalla natura dell'uomo, dunque io sono obbligato a seguire le regole perchè queste regole si giustificano all'interno di un sistema di regole fondato sulla razionalità."

"La natura è un sistema infinitamente giusto, dunque le regole che derivano da questo sistema sono giuste. Io mi sento obbligato a seguire queste regole in quanto giuste poichè fondate sulla natura umana."

“Dio è l’ente più perfetto e il sommo bene. Le regole derivano da Dio. Dunque io sono obbligato a seguire quelle regole in quanto regole sommamente giuste” (S. Anselmo)
Dal punto di vista logico-grammaticale, un giusnaturalista per giustificare l’obbligatorietà delle regole effettua una deduzione. Essi, infatti, deducono da una proposizione generale e universale, una proposizione particolare, attraverso un ragionamento chiamato SILLOGISMO. Queste proposizioni sono ipotetiche, ma dal punto di vista logico-grammaticale, le proposizioni generali sono descrittive, riguardante l’essere, in quanto ci descrive ciò che è un modo di esistenza. La proposizione finale, invece, è una proposizione prescrittiva, in quanto assodati i due presupposti, si giunge alla conclusione che sulla base del primo e del secondo presupposto, si è tenuti a seguire le regole. La giustificazione dell’obbligatorietà di una proposizione prescrittiva, qualsiasi essa sia, è dedotto da un altro sistema di valori cui la regola deve conformarsi. Il giusnaturalista afferma, infatti, che esiste un altro sistema di valori (sia rappresentato da Dio, dal sovrano o dalla natura delle cose, non è importante, ognuna di queste 3 presupposizioni genererà 3 diverse teorie giusnaturalistiche) e se la regola è conforme ai valori espressi da Dio, dalla natura dell’uomo o dalla natura delle cose, tale regola è giustificata, dunque è giusta e pertanto si è tenuti a seguirla. Il giusnaturalista fonda l’obbligatorietà della regola sulla conformità della regola a un sistema di valori che è sempre extragiuridico. Ciò è devastante perchè significa che è necessario seguire le regole se queste sono conformi alla volontà di Dio, alla volontà del sovrano o alla natura delle cose così come noi la riusciamo a dedurre. Ciò significa che per 2000 anni, la risposta alla domanda “perchè devo seguire le regole?” è dipesa da un altro sistema di valori, quale è la teologia. Il giusnaturalismo è stata un’arma fortissima per subordinare la domanda fondamentale alla base di ogni sistema di regole. Si seguivano le regole in quanto conformi a un sistema di valori in cui si crede in quanto cristiano, cattolico o musulmano. Subordinare la giustizia e, quindi, la legittimità del potere che può limitare la mia sfera di libertà personale, a un sistema di valori che è sempre extragiuridico. L’obbligatorietà della regola dipende sempre e soltanto dalla conformità di quella regola ad un sistema di valori extragiuridico. L’operazione che compie il giusnaturalista ha implicazioni filosofiche e metafisiche pesantissime perchè l’obbligatorietà del diritto, fino al positivismo giuridico, era sempre giustificato da sistemi di credenze e valori extragiuridici. Si è sempre autodefinito, dunque, come una scienza della religione, della teologia e talvolta della metafisica, ma mai in maniera autonoma ed indipendente è stato capace di giustificare la forza delle proprie azioni. Questo è un problema di carattere logico. Il positivismo giuridico si fonda sulla constatazione del sillogismo esaminato fino ad ora.
ESEMPIO: X è una porta. Tutte le porte sono o aperte o chiuse. X deve essere o aperta o chiusa.
Questo sillogismo non funziona perchè il dover essere di X non è giustificabile in relazione alle due premesse. Non è, infatti possibile ricavare il dover essere in nessun caso
ESEMPIO: La natura di Dio è massimamente buona. Le regole sono espresse dalla natura di Dio. Devo seguire le regole perchè si deducono dalla natura di Dio.
Anche in questo caso il sillogismo non funziona. Il problema in entrambi gli esempi è che dal punto di vista logico, questi sillogismi si definiscono FALLACI, in quanto rappresentano una fallacia. Ciò si verifica quando entrambe le premesse sono entrambe valide, ma la conclusione è contraddittoria rispetto alle due premesse. Di questo problema se ne era reso conto già un pensatore scozzese, Hume, che nelle sue ricerche sull’intelletto umano, ad un certo punto si interroga e si rende conto che in tutti i trattati si inizia dicendo ciò che è buono, bello e santo, ma ad un certo punto spunta e in base a tutto ciò che è bello, buono e santo, ci si deve comportare di conseguenza. Hume, però, afferma che non vi è consequenzialità tra questi elementi. I logici del tardo ‘800 inizio ‘900, rileggendo Hume, ricavano quella che è la legge di Hume, secondo la quale dall’essere non si dedurrà mai il dover essere. Nei primi del ‘900, un filosofo inglese, prende la legge di Hume e la formalizza, sviluppandola nella stesura di un libro in cui tutta la sua concezione etica e morale si fonda sulla fallacia naturalistica. Egli, infatti, afferma che fino a quel momento, tutti i filosofi escluso Hume, hanno sbagliato nel giustificare l’obbligatorietà delle regole perchè non si sono accorti che quel sillogismo non regge, poichè se formalizzato dal punto di vista logico, dà origine ad una fallacia, ad un ragionamento sbagliato, non sostenibile logicamente. La possibilità di derivare la

norma dalla natura, quindi il dover essere dall'essere, FALLACIA NATURALISTICA. Se si pensa di derivare il dover essere di qualcosa dalla sua natura, si sta commettendo un errore dal punto di vista logico. Questo errore è il presupposto logico filosofico per cui siamo tenuti a spezzare la deduzione e la dipendenza logica della giustificazione dell'obbligatorietà delle regole dalla conformità del contenuto della regola a contenuto di valori extragiuridici rispetto alla regola stessa. Questo è il meccanismo di pensiero che ci ha permesso di emancipare la morale (in quanto le regole sono anche morali e non solo giuridiche) da un sistema di pensiero. Da qui nasce il positivismo giuridico, ovvero l'idea di costruire un diritto come scienza autonoma, in grado di giustificare da sola il perchè è necessario seguire le regole senza la necessità di ricorre alla teologia, sociologia o all'etica. Ora il diritto diviene scienza autonoma e costruisce un proprio sapere analogamente alle altre scienze che, nel corso dell'800 tramite il positivismo giuridico, avevano costruito i propri oggetti e sistemi di pensiero in maniera indipendente dalla teologia e da altri sistemi tradizionalmente accettati.
La fallacia naturalistica indica che dal punto di vista grammaticale è impossibile derivare una proposizione prescrittiva da una proposizione descrittiva. Dal punto di vista logico, invece, afferma che non è possibile derivare una proposizione valida da una proposizione vera. Ci siamo spostati sul piano logico, in quanto la logica è la predicabilità degli enunciati delle preposizioni. Sappiamo che le proposizioni descrittive possono dirsi vere o false. Le proposizioni prescrittive, invece, possono dirsi valide o non valide. Vige, dunque, dal punto di vista logico-formale che non è possibile derivare una posposizione valide da una proporzione vera. Verità e validità sono due predicati che non hanno nulla in comune. Dal punto di vista metafisico, la fallacia afferma che non si deriva mai il dover essere dall'essere, non si deriva mai il deontico dall'ontico. Ciò che deve essere non dipende mai per nessuna ragione da ciò che è. Si dice che le teorie giusnaturalistiche sono quelle teorie che appartengono al cognitivismo etico. Per cognitivismo etico intendiamo il fatto che il giusto e l'ingiusto lo si può dedurre conoscendo la natura di ciò che è e ciò che non è. Il non cognitivismo etico è proprio quella parte della filosofia etica, morale e giuridica la quale afferma che tra la natura e la non natura non vi è alcun tipo di rapporto, per cui non è possibile conoscere ciò che è giusto dalla bontà della natura umana. La fallacia naturalistica è quell'argomento che segna in filosofia la grande divisione fra coloro i quali predicano di poter conoscere il dover essere partendo dall'essere (giusnaturalisti o cognitivisti etici) da coloro i quali invece affermano che tra essere e dover essere non c'è alcun tipo di rapporto logico, infatti dall'esistenza di qualcosa non si deriverà mai ciò che è o ciò che bisogna fare rispetto alla constatazione dell'esistenza. Non vi è, infatti, alcuna consequenzialità logica di nessun tipo. A partire da questo tipo di ragionamento che si costruisce il pensiero giuridico.
Tornando indietro, abbiamo visto che il giusnaturalista opera confrontando il contenuto della regola con il contenuto del sistema dei valori. Ragionare sul contenuto della norma, significa chiederci se la norma sia giusta o non giusta rispetto al sistema dei valori. Tuttavia, noi cerchiamo una giustificazione più universale possibile che non si appigli ad un sistema di valori extragiuridico. Per ottenere ciò, bisogna escludere il contenuto. A questo punto, dunque, ci resta la forma. Se togliamo il contenuto, perchè questo è passibile di soggettività, ci resta la forma. Il positivismo giuridico, rispetto al giusnaturalismo, fonda l'obbligatorietà della regola giuridica esclusivamente sulla sua forma. Una regola è obbligatoria sulla base della sua forma. Esistono un'infinità di tipi di regole. Tuttavia non tutte sono regole giuridiche. Vi è un filosofo, Hans Kelsen, che afferma che una regola è giuridica quando ha la forma tipica di una norma, ovvero quando nei confronti dell'individuo può esercitare una forza particolare perchè quella proposizione prescrittiva è munita di sanzione. Se quella prescrizione non viene rispettata, nei confronti dell'individuo che la trasgredisce potrebbe essere applicata una sanzione, quindi ci potrebbero essere conseguenze che non ci sarebbero mai se la regola non fosse di tipo giuridico. (ESEMPIO: usciamo dall'università con la nostra auto e fermiamo un vigile urbano per chiedergli dove imboccare l'autostrada. Con la stessa dinamica non siamo noi a fermare il vigile urbano, ma è il vigile urbano a fermarci intimandoci di non proseguire per quella strada perchè è a senso vietato. Queste sono entrambe indicazioni, ma tra le due vi è una differenza. Se non si dovesse seguire la prima indicazione, non succederebbe niente; al contrario, se

non si dovesse seguire la seconda, ci sarebbe la sanzione. La seconda, infatti, è espressione di una norma giuridica perchè nei miei confronti può esercitare una forza particolare perchè quella proposizione prescrittiva è munita di sanzione. In questo caso, infatti, il "tu devi", non ammette il mio "non volere", perchè devo e basta. Quindi queste sono entrambi proposizioni prescrittive ma la seconda ha una forza nei miei confronti radicalmente diversa perchè essa ha la forma tipica di una norma giuridica, in quanto munita di sanzione ed è una norma giuridica VALIDA). Come già anticipato precedentemente, la proposizione prescrittiva può essere VALIDA o NON VALIDA. Per capire ciò, si verifica se quella preposizione ha la forma tipica di una norma, ovvero se si tratta di una proposizione prescrittiva sanzionatoria valide. Dalla verità di una proposizione prescrittiva non dedurremo mai la validità di una preposizione prescrittiva. Le proposizioni valide prescrittive sono solo quelle che esistono all'interno dell'ordinamento giuridico. Una proposizione prescrittiva ha forma di una norma giuridica quando è una proposizione prescrittiva sanzionatoria valida. Se la norma codificata appartiene all'ordinamento giuridico, indipendentemente dal contenuto, è una norma giuridica.
CHE COS'È LA VALIDITÀ DI UNA NORMA? La validità di una norma giuridica è la sua esistenza specifica all'interno di un ordinamento giuridico. Ciò significa che la norma esiste IN e PER un ordinamento giuridico, ossia che esiste solo all'interno dell'ordinamento e solo in sua funzione.
(ESEMPIO: perchè nessuno si è mai interrogato sul peso e sull'altezza di Cappuccetto rosso? ontologicamente Cappuccetto rosso esiste dipendentemente da un sistema di valori, ovvero dalla favola. L'ontologia, dunque, è completamente dipendente da un altro oggetto, ovvero dalla favola. Cappuccetto rosso, dunque, esiste IN, ovvero nella favola. Il peso e l'altezza non sono funzionali al sistema ontologico di dipendenza di collocazione di Cappuccetto rosso. Il concetto di validità è esattamente il concetto di Cappuccetto rosso.) Da questo esempio, dunque, è possibile capire come le norme esistano esclusivamente IN e PER l'ordinamento giuridico. Le norme vivono in un mondo immaginario, quale l'ordinamento giuridico. Non esistono norme giuridiche al di fuori di esso. Le norme esistono e sono valide solo quando appartengono ad un sistema di riferimento, quale è l'ordinamento giuridico. Questo è il primo presupposto di una teoria positivista. Non esistono regole giuridiche che non hanno la forma tipica di una norma, ovvero di quelle regole valide che hanno un'esistenza specifica, ossia che esistono in e per un ordinamento giuridico, ovvero cache esistono all'interno dell'ordinamento giuridico e in funzione dello stesso. L'ordinamento giuridico è condizione necessaria per l'esistenza di ogni regola che voglia definirsi norma giuridica. In questa visione non è pensabile una norma giuridica esterna all'ordinamento giuridico perché la norma non sarebbe valida in quanto avremmo un precetto che appartiene ad un altro sistema di riferimento. Non esiste diritto al di fuori del sistema giuridico. L'ordinamento giuridico è il sistema di norme. Le norme scritte sono proposizioni prescrittive munite di sanzioni valide e che esistono specificamente rispetto ad un sistema che noi definiamo ORDINAMENTO GIURIDICO.
ESISTONO NORME GIURIDICHE NON VALIDE? no, perchè se non è valida non è norma.

FILOSOFIA DEL DIRITTO
Prof. Siniscalchi
LEZIONE 4 DEL 09/10/2024

Che cosa dicano le teorie del giusnaturalismo? Perché abbiamo fatto e come siamo riusciti tutto sommato a effettuare il cambiamento di operazione?
Ci siamo riusciti esaminando semplicemente il modo di ragionare di un giusnaturalista: abbiamo detto che qualsiasi teoria giusnaturalista, a prescindere dal concetto di natura che prende come pietra angolare del proprio pensiero, ragiona allo stesso modo.
Come ragiona in questo caso un giusnaturalista?
Un giusnaturalista ragiona **postulando una certa idea di natura e deriva da quella idea la giustificazione dell'obbligatorietà delle regole giuridiche (**in linea di massima), noi però abbiamo analizzato questo schema di pensiero in maniera logico-formale, ovvero lo abbiamo **formalizzato**.
Come lo abbiamo formalizzato questo sistema di ragionamento?
Il giusnaturalista ha sempre ragionato in questo modo: esiste Dio. Dio è l'ente/la natura, la razionalità umana in Kant, i diritti dell'uomo in Locke; abbiamo poi analizzato tutte le possibili accezioni e concezioni di natura, ma abbiamo visto che lo schema con cui si ragiona è sempre lo stesso:

1. C'è una premessa, questa **premessa maggiore** è una proposizione descrittiva, ovvero che descrive l'esistenza di qualche cosa: Dio esiste, Dio è sommamente giusto e perfetto;
2. Seconda proposizione o **premessa minore**: le regole sono conformi a Dio, sono dunque giuste;
3. Conclusione: devo seguire le regole conformi a Dio perché si tratta di regole giuste emanate secondo giustizia.

Che tipo di schema di ragionamento è questo?
È un **sillogismo aristotelico** dove ci sono due premesse: una premessa maggiore e una premessa minore e c'è una conclusione. Ci siamo interrogati anche su che tipo di giudizio si costruisce all'interno di questo sillogismo, cioè come si fa ad affermare che io debba giustificare l'obbligatorietà delle regole giuridiche sulla base dell'esistenza della natura di Dio, della razionalità umana? Si opera un giudizio di conformità. Che dice la seconda premessa minore? Tutte le regole che sono conformi a Dio, alla natura, alla razionalità umana sono giuste. Questo tipo di giudizio di conformità come opera? Com'è possibile svolgere questo giudizio di conformità, valutando che cosa? Come faccio a stabilire se una cosa è conforme ad un'altra cosa?
Ne valuto il significato o il contenuto. Quindi fra premessa maggiore e premessa minore operano un giudizio di conformità, questo giudizio di conformità è un giudizio che verte sul contenuto o sul significato delle singole regole. Una volta che io ho operato il giudizio di conformità e ho riscontrato che le regole rispettano le premesse della premessa maggiore, ho la mia conclusione, quella per cui è giustificata l'obbligatorietà di quelle regole perché quelle regole sono giuste e dunque io devo seguile.
Allora alla domanda da cui siamo partiti nella prima lezione: perché devo seguire le regole? Risposta di un giusnaturalista: devo seguire solo le regole che sono giuste in quanto sono

conformi a che cosa? A un valore che sia questo Dio, questa natura, questa razionalità umana extragiuridico. Il giusnaturalista fonda la legittimità, che per il giusnaturalista è la giustizia della regola, nella conformità del significato di quella regola a un sistema di valori extragiuridico, sia questo un sistema etico, un sistema morale, un sistema teologico.
Qual è la giustificazione "ideologica" di questo modo di giustificare, di fondare il ragionamento giuridico? Cioè di rispondere poi alla domanda: perché devo seguire le regole?
Quello è far dipendere il diritto, cioè la forza del diritto, l'obbligatorietà del diritto che è la sua forza, cioè, è il potere del diritto quello di imporci determinati comportamenti.
Dunque, la forza del diritto, la sua obbligatorietà dipende sempre dal fatto che il diritto rispecchi un altro sistema di valori, inutile dire come la tradizione giusnaturalista, ad esempio quella occidentale, ma in particolar modo quella europea, ha quasi sempre fatto dipendere la conformità di valori all'affermazione di una certa fede religiosa o di una certa visione teologica.
Dunque, **per il giusnaturalista** sia questo un sistema etico, morale o teologico, l'**obbligatorietà della regola giuridica non è mai autonoma** e, per rispondere alla nostra domanda, bisogna andare a frugare in altri sistemi e a verificare se il diritto rispetta i valori di quell'altro sistema, allora è giusta e dunque se è giusto io devo seguirlo (conclusione del sillogismo aristotelico).
Dicevamo che questo schema di ragionamento non ci porta a che cosa noi imponiamo nella premessa principale che è il grande vantaggio di adottare un metodo logico-formale. Ad un certo punto abbandoneremo la prospettiva logico formale e ci tufferemo invece nel magma metodologico della post-modernità, però per ora la logica e la nostra ancora di salvezza.
Ricordavo la volta scorsa che il filosofo del diritto più famoso del 900 cioè Norberto Bobbio attaccava le teorie giusnaturaliste dicendo che queste teorie giusnaturaliste non andavano bene e non sono accettabili perché nella storia del pensiero filosofico ogni filosofo ha detto la sua su cosa si intende per natura, perciò diceva Bobbio che non abbiamo un fondamento oggettivo, ma ognuno secondo la sua visione soggettiva del mondo ha dipinto la natura i suoi fini, secondo la sua visione, secondo la sua ideologia. Infatti, la natura di San Tommaso è lontana anni luce dal giusnaturalismo di Kant, ma anche fra il "deus sive natura" di Spinoza e la razionalità di Kant c'è un abisso, eppure entrambi i filosofi fondano la loro concezione giusnaturalistica partendo da un concetto di natura.
Quindi in realtà Bobbio tutti i torti non aveva, è vero ricerchiamo un fondamento oggettivo e perché lo ricerchiamo? Le preposizioni descrittive presentano un problema, quello di limitare gli spazi della nostra libertà personale, allora se tu domani vieni da me e mi dici che da domani qui dentro è vietato fumare, mi devi giustificare sul perché è vietato fumare; l'obbligatorietà, l'imposizione di un obbligo chiede sempre una giustificazione dell'obbligatorietà, questa giustificazione deve essere la più oggettiva possibile, altrimenti sarebbe l'atto della volontà più forte, alla Hobbes, homo omini lupus: io te lo impongo perché sono più forte di te, ma qui non siamo più nel campo giuridico ma siamo già nel campo della prepotenza fra esseri umani. Noi però siamo andati oltre la critica di Bobbio, abbiamo detto che non ci interessa tutto sommato cosa definiamo natura, la natura per noi è una x, ci possiamo mettere qualsiasi valore; andiamo a vedere come ragionano però i giusnaturalisti. Qui ci accorgiamo che lo schema di ragionamento è comune a tutti, tutti ragionano allo stesso modo: riempiono la casella di x come meglio credono ma poi l'operazione logica che fanno è sempre la stessa, derivano da due premesse entrambe descrittive, una conclusione prescrittiva. Facemmo l'esempio della porta per esemplificare: tutte le porte sono o aperte o chiuse; x è una porta; x è aperto o chiusa. X deve essere o aperta o chiusa.
Dov'è il problema?
Il problema è che questo sillogismo è un sillogismo, si dice in logica, **fallace**. Sin dai tempi di Hume, lo stesso Hume si è accorto che nei trattati di morale e di etica si passa da preposizioni descrittive (esiste una volontà buona) a una serie di preposizioni in cui si dice che dobbiamo seguire una serie di regole, egli è il primo che se ne accorge. George Edward Moore nel 1903 formalizza, invece, il ragionamento; costruisce il sillogismo e dimostra che effettivamente che premessa maggiore, di carattere universale descrittiva, premessa minore, carattere particolare descrittiva, conclusione prescrittiva (ovvero il dover essere) non è giustificabile logicamente in nessun caso. Se le due premesse sono entrambe descrittive non è possibile una conclusione prescrittiva.

L'errore si chiama fallacia naturalistica, che cos'è questo errore? È un errore logico ma che ha delle implicazioni, dicevamo la volta scorsa metafisiche enormi.
La fallacia naturalistica sente l'impossibilità di dedurre una proposizione prescrittiva da una proposizione descrittiva, opera quindi su tre paini:

- in un piano linguistico, prettamente logico-formale, dice che dalla verità non è mai possibile derivare la validità, che da preposizioni descrittive non è mai possibile derivare preposizioni prescrittive;
- piano ontologico che dall'essere non è mai possibile derivare il dover essere;
- piano sub logico dalla verità non è possibile dedurre la validità.

Dicevamo la volta scorsa che è inutile che si elaborino strategie logico-formali per cercare di giustificare il passaggio, perché dall'essere al dover essere dal punto di vista strettamente logico non si passa, non c'è mezzo per poter derivare obblighi, prescrizioni, imperativi da proposizioni esistenziali, descrittive, cioè proposizioni da cui noi possiamo predicare la verità o la falsità.
Che cosa dice la fallacia naturalistica?
La fallacia naturalistica è il primo passo logico-formale per spazzare via tutte le teorie giusnaturaliste, almeno nel loro modo di ragionare. La fallacia ha delle implicazioni devastanti: la prima implicazione è il modo di fondare l'obbligatorietà del discorso giuridico sulla natura di qualche cosa è insostenibile, non sostenibile dal punto di vista logico; questo che significa però? Facciamo un passetto successivo che è quello ideologicamente devastante della fallacia naturalistica, perché fin qui qualcuno potrebbe dire "si tratta alla fine di un errore logico; la fallacia in logica è proprio il sillogismo con due premesse entrambe valide e si trae una conclusione che è contraddittoria alle due premesse". Ma le implicazioni filosofico giuridiche sono le norme, abbiamo vantaggi enormi e abbiamo lo svantaggio enorme, dicevamo la volta scorsa. Se dimostriamo l'infondatezza del modo di ragionare di un giusnaturalista, abbiamo dimostrato che cosa? Che il diritto non ha bisogno di fondare la propria obbligatorietà, anzi non può fondare legittimamente la propria obbligatorietà, la propria forza su un sistema di valori extragiuridico. Abbiamo liberato il diritto dalle influenze etiche, morali, teologiche, sociologiche… Il diritto è una scienza autonoma, d'altronde positivismo. Cos'è il positivismo nell'ambito della storia del pensiero filosofico? È la costruzione del sapere come scienza autonoma, formale, rigorosa. Vi sono le scienze naturali, i positivisti giuridici hanno la stessa idea; dicono che cosa abbiamo noi di meno rispetto gli scienziati che studiano la natura, noi studiamo la società e i comportamenti della società, perché dobbiamo sempre rivolgerci al prete di turno per sapere se le cose che diciamo sono fondate o non fondate. Ma no! Noi facciamo i giuristi, i filosofi del diritto, emancipiamo il nostro sapere, costruiamo anche noi il nostro sapere come una scienza rigorosa, astratta, formale con gli strumenti del positivismo. D'altronde lo vedremo, questo sarà uno degli scopi del corso come in realtà la conoscenza giuridica sia strettamente collegata allo spirito del tempo, quello che i tedeschi chiamano zeitgeist. Ci hanno insegnato per troppo tempo il diritto esclusivamente in termine tecnico, il diritto è anche una forma tecnica, ma è soprattutto una forma del sapere, fortemente connesso allo spirito del tempo, ai momenti culturali che ci sono all'interno di un'epoca. Vedremo che il positivismo giuridico nasce nel circolo di Vienna, a contatto con il sapere logico-formale che nasce proprio in quegli anni. Prima costruiremo la nostra cassetta logico-formale, poi la capovolgeremo dal punto di vista storico, filosofico, sociale; perché vedremo il pensiero neoliberista come incide sulle costruzioni di pensiero del diritto. Cioè, il diritto non nasce mai come un cavolo a merenda, è sempre il risultato di tanti processi culturali che si incrociano e si intersecano fra di loro, è un sapere contaminato.
Il problema in questo cosa era liberare il fondamento dell'obbligatorietà del diritto da altre influenze, che in quel momento erano schiaccianti e hanno sempre condizionato il diritto alla conformità ad altri. La fallacia naturalistica è l'argomento logico-formale che permette di spezzare questo nesso, di emancipare il sapere giuridico e di costruire il sapere giuridico come una scienza logico formale astratta: positivismo giuridico. Cosa dicevamo la volta scorsa però, che la fallacia naturalistica è la pars destruens del nostro ragionamento, resta aperta la risposta alla nostra domanda: Perché devo seguire le regole? Ora, la fallacia naturalistica ci dice come non dobbiamo risolvere. Vedremo come in questo corso daremo tantissime risposte e ogni volta che avremo raggiunto una certezza, la confuteremo e ci porremo nuove domande. C'è un

filosofo del 900 che ricorda tacitamente le lezioni del nostro corso che dice che la filosofia non serve mai a darci risposte, serve a insegnarci a costruire le domande giuste. Se ci si pone la domanda giusta, non si ha bisogno delle risposte, la domanda dice già la risposta, il problema svanisce con la costruzione della giusta domanda. È questo che faremo noi, una volta che risponderemo ad una domanda cereremo la domanda successiva che ci mostra il superamento di quel problema e l'apertura di un nuovo problema.
E dunque la fallacia naturalistica ci ha detto che cosa? Ci dice che non possiamo rispondere alla nostra domanda, dal punto di vista logico formale se rispondiamo a quella domanda stiamo dicendo una sciocchezza perché la nostra risposta è infondata dal punto di vista logico formale. Lo dice il problema della fallacia naturalistica. Ma la domanda resta lì e noi come rispondiamo alla prossima domanda? Perché c'è un'implicazione filosofico giuridica di una gravità assurda che ci porta alla fallacia naturalistica. Come ragiona un giusnaturalista? Dice segui le regole, se le regole sono giuste, ma la giustizia è un concetto di conformità rispetto ad un'altra cosa, oppure è giusta in assoluto, ma in questo caso è conforme a un valore assoluto rappresentativo. Date prove dell'esistenza di Dio da lì ne derivano tutti dei corollari logico deduttivi su come costruire anche la provvidenza sociale. Ma il problema qual è? Che con la fallacia naturalista diciamo al nostro uomo comune "guarda che la giustizia non ha nulla a che vedere con il diritto", perché noi stiamo dicendo anche questo, stiamo dicendo che non serve rispondere "io seguo le regole perché sono giuste", ma il giudizio sulla giustizia implica un giudizio di conformità di che cosa? Del contenuto della regola rispetto al contenuto extragiuridico. Noi sappiamo che questa operazione è illegittima dal punto di vista logico formale; dunque, la giustizia del contenuto della regola non va bene, non possiamo utilizzare per decidere sulla forza, sulla giustificazione di obbligatorietà di quella regola. Andatelo a dire alle persone che giustizia e diritto non c'entrano nulla l'uno con l'altro, che la forza del diritto non c'entra nulla con la giustizia. Come facciamo a costruire una teoria del diritto che dice guardate che il diritto e la giustizia non sono su piani paralleli, non si intersecano mai. La fallacia naturalistica dice proprio questo: il giudizio di giustizia non serve a fondare e a giustificare l'obbligatorietà della regola giuridica, perché il contenuto è irrilevante nel momento in cui consideriamo il contenuto della regola creiamo inevitabilmente una fallacia naturalistica perché deriviamo dall'essere al dover essere prescrittivo. Quindi da un lato emancipiamo il diritto dall'altra parte vi sbarazziamo dal concetto di giustizia.
Dicevamo la volta scorsa la norma giuridica è vietato fumare, se non giustificare l'obbligatorietà della regola, ci possiamo chiedere se la regola è più o meno giusta; dunque, non possiamo fare riferimento al contenuto. Che cosa ci resta? La **forma**. La risposta alla nostra domanda e d'ora in poi ci occuperemo di questa risposta nelle lezioni successive. La risposta di un giuspositivista è: **una regola è obbligatoria dal punto di vista giuridico, se ha la forma tipica di una norma giuridica** (il contenuto per noi è irrilevante). Noi guardiamo solo il modo in cui la norma si presenta e che significa che deve avere la forma tipica di una norma giuridica? Significa che quel**la regola deve essere valida**. Torniamo al tema di validità e verità. **Dalla verità non si ricava la validità**, perché la validità è proprio il predicato esistenziale di una norma giuridica, ovvero una preposizione prescrittiva valida. *Che cos'è la validità di una norma?* È la sua esistenza specifica, significa che quel**la norma esiste in e per un ordinamento**. Dicevamo che le norme funzionano come cappuccio rosso, nessuno sa quanto pesa, quanto è alta, perché sono tutti elementi che non sono funzionali alla questione. L'esistenza di Cappuccetto Rosso e un'esistenza limitata, dipendente ontologicamente dalla fiaba. Le norme sono ontologicamente dipendenti dall'ordinamento, esistono solo e soltanto se vengono inserite all'interno di un ordinamento giuridico e funzionano in quell'ordinamento, cioè sono poste in funzione dell'ordinamento giuridico. Dunque, cos'è la validità? La validità è l'esistenza specifica di una norma e la sua forma biblica. Che intendiamo per esistenza specifica? Che quella norma esiste in e per un ordinamento. Da qui alcune considerazioni: possono esistere norme fuori dall'ordinamento giuridico? No, perché non sarebbero delle norme. Quindi possono esistere norme invalide? No, le norme o sono valide o non sono valide. La validità è il predicato ontologico o esistenziale. *(Tutte queste parti le vuole sapere all'esame così come le sta dicendo, punto per punto)*. Quante preposizioni prescrittive possiamo avere? Un'infinità e c'è un'infinità di tipi di preposizioni di carattere prescrittivo, facevamo l'esempio la volta scorsa del rimprovero dei vostri genitori "dovete sedervi con posti", è una preposizione

prescrittiva ma non è una norma giuridica in quanto non ha la forma di una norma giuridica. Se però io dicessi durante le mie lezioni è vietato fumare senza che la mia prescrizione sia codificata, non sia una norma giuridica, voi potreste scegliere se seguire o meno il mio invito; ma io non avrei nei vostri confronti un potere coattivo, perché qualcuno di voi potrebbe rispondermi "mi metto vicino alla finestra così non do fastidio", perché tutto sommato non è vietato dalla legge fumare in aula; quindi si trova un accordo affinché io possa fumare e tu non possa respirare il mio fumo passivo, il contenuto è però della mia preposizione prescrittiva è vietato fumare durante la mia ora. Se ci fosse invece il cartello sarebbe vietato fumare, in cui è prevista la trasgressione per coloro che decidono comunque di fumare in aula, è il contenuto stella regola è perfetto, il contenuto è lo stesso, dove sta la differenza? Perché in un caso siete obbligati e nell'altro caso potete scegliere? Perché nel secondo caso la preposizione prescrittiva ha la forma tipica di una norma giuridica, ovvero esiste all'interno del nostro ordinamento giuridico; nell'altro caso invece è una semplice richiesta, certo ho maggiore autorità di voi in questa aula ma la mia voce non ha forza di legge, può guidarvi a comportarvi in una certa maniera a meno che i vostri comportamenti non trasgrediscano norme valide dell'ordinamento giuridico italiano.
Questa concezione che altro ci dice? Se le norme possono essere o valide o non sono l'essere della sua validità, noi sappiamo che la norma è valida solo e soltanto se ha appartiene all'ordinamento giuridico; questo vuol dire che per un verso non esistono norme al di fuori dell'ordinamento giuridico e facciamo anche la deduzione successiva: che ogni norma esiste, solo e soltanto in un ordinamento giuridico specifico.
Dunque, i giusnaturalisti affermano l'esistenza di precisi valori universali, il positivista dice che tutto il discorso giuridico è contenuto nello spazio dell'ordinamento giuridico, di un singolo ordinamento giuridico. D'altronde le norme giuridiche che sono valide in Italia non per questo sono valide in Francia, l'ordinamento giuridico francese contiene le sue norme relative allo spazio, alla popolazione e allo stato francese. Ogni norma esiste all'interno del suo contesto, della sua fiaba per tornare a Cappuccetto Rosso, e non esiste al di là del suo racconto, la storia di ogni norma è contenuta nell'ordinamento che accoglie e racconta la vita di quella norma; nasce e muore, pensate all'abrogazione delle norme, all'interno dello spazio-tempo determinate dall'ordinamento giuridico e dunque *l'ordinamento giuridico che cos'è?* **Un sistema di norme**.
Validità uguale esistenza specifica della norma. Facciamo un'ulteriore considerazione: questa validità proprietà esistenziale ontologica, che tipo di predicato è dal punto di vista logico, è un predicato formale o sostanziale? Solo formale, esclusivamente formale, ancora una volta a noi non interessa quello che dice, non ci frega nulla del contenuto della norma. Noi siamo tenuti a seguire la norma, cioè siamo obbligati, nel momento in cui verifichiamo che quella regola appartiene a un ordinamento giuridico. Non è una semplice regola ma è una norma giuridica, non ci interessa nulla del suo contenuto. Dunque, non ci interessa nulla se la norma sia più o meno giusta, per noi il fondamento è oggettivo, perché logico formale. Qual è il fondamento oggettivo? Perché devo seguire le regole? Qui non c'è nulla lasciato alla soggettività dell'individuo, per me è giusta perché conforme alla mia fede religiosa, per me non è giusta perché la mia etica non è la tua etica; quindi, io decido che la norma sulle tasse potrei pagarla, non pagarla, contestarla; perché la mia natura dell'uomo è diversa dalla tua. Qui invece il fondamento è oggettivo, non mi interessa il contenuto, esiste nell'ordinamento devo seguirla, non esiste nell'ordinamento non sono tenuta a seguirla. D'altronde il positivista giuridico ti fa subito un'altra considerazione: devo seguirla quando ha la forma tipica della norma in quanto se non la seguo mi verrà applicata la sanzione e dunque nei miei confronti si verificherà la forza obbligatoria del diritto. Il fondamento è oggettivo perché è privo di contenuto, ma quando si ha la forma tipica di una norma? Quando è valida. Che significa che è valida? Che appartiene all'ordinamento giuridico in questione, comunque che esiste in e per determinato ordinamento giuridico, altro non mi interessa. Al giuspositivista non interessa altro che verificare l'appartenenza di quel comando, dell'imperativo, di quella prescrizione al sistema che lui definisce come ordinamento giuridico, è così che si costruisce la scienza di un giuspositivista. Tutto sommato è qui l'espressione tutta logica formale di un'operazione logica, andare a verificare se quella norma appartiene o meno al sistema.
La domanda successiva. Operazione logico-formale: perché devo seguire le regole? Devo seguire solo quelle regole per il giusnaturalista sono regole giuste, mentre per il giuspositivista

solo quelle regole che appartengono al sistema di norme che io definisco ordinamento giuridico, operazione logico-formale. Quindi? Andiamo avanti nella risposta, che cosa devo verificare allora? La validità dell'esistenza specifica della regola all'interno dell'ordinamento giuridico, quindi quella regola si trasforma in una norma giuridica, che devo fare io per rispondere più o meno affermativamente alla mia domanda? Devo andare a verificare se quella norma appartiene ad un ordinamento e dunque domanda: come faccio a verificare se quella norma appartiene al sistema tramite un'operazione esclusivamente logico-formale? Quando è posta conformemente, giudizio di conformità, ai criteri previsti dalla norma immediatamente superiore, ordinamento superiore. Che significa questa definizione? Significa che l'**ordinamento è un sistema logico formale che si costruisce a gradi**. **Ogni norma prende validità, cioè viene legittimata dalla norma immediatamente superiore e legittima la norma immediatamente inferiore.** Quindi per vedere se una norma appartiene a un ordinamento giuridico; quindi, per verificare se è stata posta conformemente a quanto previsto dall'autorità competente, non mi resta che andare a vedere se la norma rispetta il processo di delega di validità attraverso i livelli del sistema, il sistema dell'ordinamento giuridico si costruisce a gradi. Hans Kelsen *(da ricordare per l'esame!)* definisce questa divisione a gradi "stufenbaus" in tedesco. L'ordinamento giuridico è un sistema che si costruisce a gradi, dove ogni norma prende validità dalla norma immediatamente superiore. Come fa a prendere validità da quella superiore ad essere validata? Quando quella norma è prodotta conformemente a quanto previsto dalla norma immediatamente superiore.
Come si verifica la validità? Come si fa a vedere se appartiene al sistema? Il sistema è costruito a gradi, ogni norma appartiene a un livello del sistema; ogni norma deve essere conforme alla norma immediatamente superiore, anche qua si opera un giudizio di conformità; ma non è che stiamo cadendo un'ancora una volta nel modo di ragionare giusnaturalistico? No, perché **il giudizio di conformità riguarda soltanto il criterio formale procedurale posti ai gradi immediatamente superiori**. La validità è sempre una questione logico formale.
Per esempio, maggioranze parlamentari o per emanazioni decreti leggi, legislativi, si va a vedere la norma valida e rispettate le formalità di tutte le procedure. Non mi interessa quello che si è deliberato, mi interessa come è stato deliberato, se è stato deliberato con il rispetto delle procedure previste dalla norma di livello immediatamente superiore. Questa è una prospettiva radicalmente giuspositivista che costruisce il diritto come un oggetto logico formale, come se fosse un teorema. L'ordinamento che cos'è? Un sistema di norme prescrittive che è regolato da questa legge di validità, collante è la validità. Come fa ad essere incollato questo sistema? Da un giudizio di conformità e la validità per cui ogni norma deve essere prodotta conformemente ai criteri logico formali e procedurali previsti dalla norma immediatamente superiore, è una visione totalmente astratta del diritto logico formale. Ha tanti vantaggi? Si è stata una conquista enorme degli inizi del 900. Aveva tanti punti deboli? Sì tanti, uno enorme: l'idea di escludere completamente il contenuto di diritto, la nostra stessa Costituzione prevede, enorme che sono poste in conflitto con i principi costituzionali non sono ammissibili, Salvaguardia assoluta di ciò che può emanare la maggioranza al governo, perché poi il problema è fondamentalmente questo: stabilire i limiti a ciò che noi possiamo definire diritto, da ciò che diritto non è. Anche se c'è una maggioranza folle che legittimamente decide di porre determinate norme, fate attenzione io da giurista vi dico che quella norma non è oggettivamente diritto. Quindi ci sono svantaggi e vantaggi. Intanto continuiamo a ragionare sul nostro sistema di norme logico formali. Se ogni norma prende validità e dà validità alla norma superiore e alla norma inferiore, questo è un sistema che ha una connotazione evidentemente gerarchica. L'ordinamento è un sistema a gradi e questa costruzione è una struttura logico formale ma gerarchica che si costruisce come una piramide; a mano a mano che si sale ai livelli del sistema si stringono sempre di più, ha una base di infiniti atti giuridici, li definiamo tali se sono a posti conformemente a norme più astratte, più generali, man mano che saliamo nel sistema abbiamo norme sempre più generale, in norme sono espressione in articoli di legge dal punto di vista giuridico e non solo filosofico, fino ad arrivare a decreti legislativi delle leggi, fino ad arrivare ai principi della costituzione. La costituzione segna l'inizio del sistema, detta i criteri che organizza il sistema, le regole fondamentali con cui si gioca la partita del diritto all'interno del nostro ordinamento giuridico. Dunque, il sistema sui costruisce come un sistema gerarchico piramidale. Come si passa da un livello all'altro del

sistema? Attraverso quella che si chiama delega di competenza, non è altro che la verifica del rispetto dei criteri formali procedurali la norma inferiore rispetto alla forma gerarchicamente immediatamente superiore. La nostra verifica della validità della norma è un'operazione logico formale in cui noi verifichiamo semplicemente se la proposizione prescrittiva appartiene al sistema giuridico; quindi, se è valida rispetto all'ordinamento; quindi, se è stata prodotta conformemente ai criteri logico formali previste dalla norma immediatamente superiore.
Se ogni norma è conformemente posta a quella superiore, su cosa si fonda la Costituzione, quindi il gradino superiore?

FILOSOFIA DEL DIRITTO
Prof. Siniscalchi
LEZIONE 5 DEL 09/10/2024

Chi valida la Costituzione? Qual è il fondamento del sistema?
Il sistema è indecidibile, non siamo in grado di decidere circa il fondamento di validità dell'ordinamento giuridico a meno di non ricorrere a qualche espediente di carattere logico. Esempio di indecidibilità, io sto mentendo, è un paradosso perché se la proposizione è vera, è falsa perché io sto mentendo se è falsa però è vera perché io sto mentendo. Di conseguenza è indecidibile il fondamento di validità del sistema perché ogni volta che pongo una norma al di sopra non ho chi valida questa norma, chi decide. Per risolvere il paradosso della validità del sistema, la soluzione da trovare deve essere una soluzione logico-formale. Esempio: in un villaggio c'è solo un barbiere, può fare la barba a tutti gli abitanti tranne che a sé stesso, chi fa la barba al barbiere?
Come si esce dai paradossi della ricorsività? **Bertrand Arthur William Russell** parla della teoria dei tipi logici. Questa teoria afferma che nel momento in cui abbiamo un sistema di x, all'interno di quel sistema nessun oggetto che appartiene alla classe x di quel sistema può fondare la validità di quel determinato sistema, **è necessario postulare l'esistenza di un altro oggetto che abbia una natura diversa, che non appartenga alla classe x del sistema**, in grado di legittimare il sistema.
Ma come fa Hans Kelsen a venir fuori dal paradosso?
Lo fa applicando la teoria dei tipi logici di Russell al suo caso concreto: abbiamo un sistema (ordinamento) che comprende una classe di oggetti tutti uguali tra loro, gli oggetti x (oggetti x = norme), l'ordinamento è formato da un sistema di oggetti identici tra di loro, norme giuridiche legittimate dalla norma immediatamente superiore e pongono le condizioni di legittimità per la norma immediatamente successiva. In seguito, Russel dice, fin tanto che resti all'interno di questo sistema non ne uscirai mai, devi postulare l'esistenza di un altro oggetto che comprenda tutta la classe degli oggetti di quel sistema e che sia esterno al sistema.
Come ne usciamo?
La teoria dei tipi logici di Russell è l'unico modo per fondare il sistema e presupporre l'esistenza di un oggetto diverso dagli oggetti che compongono la classe degli oggetti del sistema che sia in grado di comprendere tutti quelli oggetti e dunque di fondarne la validità. Se facciamo questa operazione però rischiamo di cadere in un sistema di ragionamento a carattere giusnaturalistico, perché i giusnaturalisti hanno fatto proprio questo, affermano che il diritto è un insieme d regole e per capire se quelle regole sono giuste o meno vediamo se sono conformi ad un sistema giuridico di valori. Quindi postulo l'esistenza di questo sistema, faccio il confronto e vedo se le norme sono legittime o meno. Alla fine, quindi tutto il giuspositivismo giuridico sul fondamento di validità del sistema va a cadere in una visione del diritto di carattere giusnaturalista.
Come ne esce Kelsen?
L'esistenza di che tipo di oggetto dobbiamo postulare per individuare il fondamento logico del sistema inteso come ordinamento? Una norma fondamentale, "**grundnorm**", oggetto astratto, una norma che non ha bisogno di essere validata dalle altre norme (altrimenti torneremmo al tema del regresso all'infinito) e che non deve scivolare verso il giusnaturalismo. Kelsen dice

che questa norma è una norma di cui noi dobbiamo postulare l'esistenza, ma questa norma non esiste effettivamente all'interno dell'ordinamento giuridico. È un oggetto di cui noi presupponiamo l'esistenza al fine di chiudere logicamente il sistema ma la norma non esiste in quanto norma all'interno del sistema, dunque dice Kelsen la norma fondamentale è un atto di pensiero e non è un atto di linguaggio, se le altre norme sono tutte norme che abbiamo definito come proposizioni prescrittive valide perché appartengono al sistema, la norma fondamentale è un oggetto che noi immaginiamo che esista fuori dall'ordinamento per validare il primo livello del sistema, la Costituzione. È una norma che ha contenuto dautologico (ripete all'inizio del sistema quello che già facciamo, seguire la costituzione), dice semplicemente che bisogna obbedire e seguire la Costituzione valida ed efficace, serve esclusivamente a validare la costituzione, è un escamotage, una norma immaginaria che noi presupponiamo che esista al fine di chiudere e validare il sistema, è semplicemente un oggetto logico-formale. Come dice Kelsen non è un oggetto trascendente ma una condizione trascendentale di possibilità e pensabilità dell'ordinamento giuridico in quanto sistema logico formale. È un oggetto che non esiste perché se esistesse non dovremmo giustificarlo nella sua validità.
È una norma che non fa parte della Costituzione, esterna all'ordinamento giuridico.
Che cos'è la norma fondamentale?
La norma fondamentale è un presupposto logico-trascendentale dell'ordinamento giuridico in quanto sistema logico-formale. È un atto di pensiero e non un atto di linguaggio, non innato in quanto relativo sempre all'ordinamento giuridico, una condizione di possibilità e di pensabilità dell'ordinamento giuridico inteso come sistema di norme ed esiste solo nella nostra mente
Come si manifesta?
La norma fondamentale si manifesta come una proposizione dautologica di cui noi immaginiamo l'esistenza. Dobbiamo immaginarla come il vertice della piramide, ma questo vertice ha una modalità ontologica, esistenziale di esistere e di imporsi diversa da tutti gli altri elementi che compongono la priamide. Non appartiene alla classe x delle norme che appartiene al sistema giuridico, ma è un oggetto y che comprende e fonda tutta la classe di oggetti x ponendosi all'esterno (esterno inteso come stesso sistema).
Come funziona questo sistema?
Esempio: i 10 comandamenti sono costituiti da proposizioni prescrittive esattamente come l'ordinamento giuridico, sistema di proposizioni prescrittive. Perché funzionano in modo diverso?
Consideriamo uno dei 10 comandamenti: "non devi uccidere", da questa proposizione generale prescrittiva possiamo dedurre una serie di norme particolari:

- Non devi fare del male
- Non bisogna avere nemmeno l'intenzione di uccidere
- Non bisogna condannare chi lo uccide
- No al suicidio
- No all'aborto
- Divieto di suicidio assistito
- Divieto di eutanasia

Per quanto riguarda il sistema giuridico invece: "non devi uccidere", da questa norma noi non deduciamo che l'aborto sia vietato e così via. Questo perché i sistemi sono differenti. Il sistema giuridico, secondo Kelsen, è un sistema dinamico mentre gli altri sistemi sono statici (sistema statico: sistema in cui data una proposizione generale è possibile dedurre logicamente tutte le proposizioni particolari. Nel sistema giuridico non è possibile dedurre perché noi possiamo dire come giuridicamente vincolante la proposizione solo se quella proposizione è valida. Il divieto di uccidere c'è solo nelle norme che lo prescrivono e che sono validate da altre norme. Quindi il sistema giuridico è un sistema dinamico, la validità delle proposizioni che compongono il sistema dell'ordinamento giuridico non dipende più da criteri extragiuridici quindi etici, morali e religiosi. C'è une netta scissione tra la norma giuridica e quella religiosa che nasce dall'irrilevanza del contenuto nella costruzione del discorso giuridico

Che cos'è una norma giuridica?

Proposizione prescrittiva sanzionatoria valida quando esiste in e per un ordinamento.

Esempio: “è vietato fumare”, è vietato porre una determinata condotta, un’implicazione, se fumi ci saranno delle conseguenze.

Norma giuridica: se compio l’azione x mi verrà applicata la sanzione y. X in questo caso è il comportamento vietato, quindi è il fatto qualificato dalla norma come illecito e y è la sanzione. Allora lo schema tipico di una norma sarà: “se a b o se a deve essere b” dove a è il fatto qualificato come illecito e b è la sanzione prevista. Kelsen descriverà la norma come uno schema di qualificazione trascendentale. Dal punto di vista filosofico questa definizione dice una cosa molto importante, tu puoi fare quello che vuoi in natura fin tanto che il tuo comportamento non è qualificato come illecito da una norma, che qualificandolo come illecito lo sanziona. Quindi non è tanto il comportamento in natura ad essere rilevante ma la qualifica che gli dà la norma. Quindi la norma è condizione di pensabilità e di possibilità di ogni atto che voglia dirsi giuridico.

Esempio: se reco un danno fisico ad una persona, questo comportamento può avere conseguenze giuridiche diverse a seconda di come viene qualificato dalla norma come atto giuridico. Se immotivato ho compiuto dal punto di vista giuridico una azione gravissima, un atto illecito. Se mi accorgo che qualcuno è munito di pistola e io aggredisco questa persona mettendola in condizione di non nuocere nessuno l’atto è differente. Dal punto di vista fisico il comportamento è lo stesso, dal punto di vista giuridico il comportamento è diverso in quanto legittima difesa e non atto illegittimo.

Ecco perché Kelsen dice che la norma è uno schema di qualificazione giuridica trascendentale perché è la norma che rende condizione di possibilità e di pensabilità di quell’atto in quanto atto giuridico di un comportamento che diventa giuridico ed entra nel mondo del dover essere dal mondo dell’essere solo quando c’è la norma giuridica che lo trasferisce con un atto di qualificazione, dove viene qualificato come atto giuridicamente rilevante.

FILOSOFIA DEL DIRITTO
Prof. Siniscalchi

LEZIONE 6 DEL 14/10/2024

Facciamo un passo indietro, rivediamo un attimo tutto il tema della validità ordinamentale, perché oggi diremo una serie di cose in più rispetto a quelle che ci siamo detti mercoledì scorso. Avete imparato che facciamo due passi indietro, un avanti e uno indietro, e poi riprendiamo. Allora avevamo detto che anche la lezione di oggi è fondamentale. Vedrete come oggi arricchiremo il nostro discorso da una serie di elementi di semiotica del linguaggio normativo; quindi, oltre la prospettiva logica proveremo a rielaborare alcuni dei nostri argomenti che abbiamo già visto, che già conoscete, in una prospettiva in modo semiotica del linguaggio normativo.
Abbiamo detto la volta scorsa il concetto fondamentale per sapere se un oggetto è un oggetto giuridico o non è un oggetto giuridico è la validità. La validità è evidentemente la proprietà ontologica di ogni proposizione di logistica che voglia dirsi una norma giuridica.
Abbiamo detto che la validità è l'esistenza specifica di una norma, che ogni norma esiste in e per un ordinamento, cioè che esiste all'interno, in funzione del determinato ordinamento. Ci siamo posti il problema di andare a vedere come faccio a verificare se una norma appartiene o meno a un determinato ordinamento? Quali sono i criteri logici per cercare di capire l'appartenenza o meno? È abbiamo visto come i criteri logici sono la conformità della proposizione logica, che noi abbiamo qualificato come norma, i criteri formali procedurale imposti dalla norma a livello immediatamente superiore. Da qui abbiamo dedotto che cosa? Che l'ordinamento giuridico è un sistema di norme costruito a gradi (la stufenbaus Kelseniana) dove in realtà ogni norma prende validità dalla norma immediatamente superiore; dunque, un sistema a carattere gerarchico che ha la forma di una piramide, dicevamo la volta scorsa. Questo tipo di sistema l'abbiamo definito poi come un sistema dinamico contrapposto ai sistemi statici. Un sistema dinamico perché da un livello all'altro non si passa mai deducendo il contenuto della norma particolare e della norma generale, ma semplicemente ragionando sui criteri formali procedurali posti dalla norma immediatamente superiore. Là il segreto per ricordarsi di tutta questa architettura teorica, dicevo dall'inizio del nostro corso, è fare sempre riferimento al tema della fallacia naturalistica. Quando ragiono sul dover essere non posso mai ragionare sull'essere; quindi, quando considero il discorso giuridico sto parlando sempre soltanto di forma, di forma tipica; i contenuti, la sostanza, i significati delle proposizioni prescrittive che io considero norme, sono sempre irrilevanti. Dunque, un sistema di norme a carattere piramidale costruito a gradi gerarchico, dinamico. Dunque, quando vi chiederò, o vi chiederanno, all'esame che cos'è un ordinamento giuridico nella prospettiva kelseniana? Sapete ormai tutte le caratteristiche che ha l'ordinamento giuridico nella prospettiva della dottrina del diritto di kelsen.
Dicevamo anche che il tema della validità pone un problema nel momento in cui intendiamo l'ordinamento giuridico come un sistema di norme. Ovvero il problema di chi valida il primo grado, il primo livello del sistema, ovvero la costituzione. E qui abbiamo ravvisato un paradosso, perché in realtà, la prima proposizione giuridicamente rilevante, quella che detta in forma i criteri formali procedurali che riguardano l'intero sistema, dal punto di vista della validità è indecidibile, perché non possiamo sapere se sia valida o non valida. A patto di fare che cosa? Da un lato di cordere nel regresso all'infinito. Se la consideriamo una norma al pari di tutte le altre norme che appartengono al sistema avremo necessità sempre di porre una norma superiore che ci dia la validità della norma immediatamente inferiore e così via all'infinito, grado dopo grado. Ma questo implica che quel sistema non avendo un suo fondamento di validità, non si identifica e non si chiude mai come sistema; dunque, non è né possibile né pensabile.

L'altra scorciatoia che dobbiamo evitare è quella di far riferimento ad un fondamento invece extra giuridico che possa fondare il sistema, perché qui cadremo invece in una deriva giusnaturalista, ipotizzando in questo caso un giudizio di conformità. Proprio il vertice del sistema dovrebbe essere conforme a un principio extra giuridico e dunque ci sarebbe un giudizio di conformità che ravviserebbe un tipo di operazione logico formale tipica del giusnaturalismo, non certo del positivismo giuridico.
Come evitare queste due derive e riuscire allo stesso a chiudere il sistema? Teoria dei tipi logici di Bertrand Russell: idea di poter immaginare un oggetto di pensiero, dunque un atto di pensiero e non un atto di linguaggio, un oggetto logico, formale, un presupposto logico, formale dell'ordinamento giuridico, che Kelsen definisce come norma fondamentale, che niente altro è che è una proposizione che appartiene al mondo del dover essere da ontologica, che dice che si deve seguire la costituzione effettivamente vigente, ma non aggiunge nulla dal punto di vista contenutistico a quello che già si fa, che serve semplicemente a chiudere dal punto di vista logico il sistema, rendendo possibile pensare. Dunque, la norma fondamentale è che cosa? È una norma presupposta e composta, è un atto di pensiero e non un atto di linguaggio, è un oggetto logico e non un oggetto linguistico, è un presupposto logico trascendentale dell'ordinamento giuridico. Presupposto logico è una proposizione tautologica che appartiene al mondo del dovere essere, ma non aggiunge nulla dal punto di vista contenutistico. È solo un presupposto formal-procedurale, anche la norma fondamentale. Trascendentale è una condizione, alla Kant, di pensabilità e possibilità dell'ordinamento giuridico inteso come sistema di norme. Dunque, essendo un oggetto logico, essendo una condizione trascendentale, si tratta evidentemente di una condizione a priori di invalidità dell'intero ordinamento giuridico inteso come sistema. D'altronde, la teoria dei tipi logici di Russell ci diceva proprio questo. Fintanto che rimanete all'interno del sistema e gli oggetti che compongono quel sistema hanno tutti le medesime caratteristiche esistenziali, nessun oggetto può fondare il sistema. Vi serve un oggetto che sia esterno al sistema, che contenga tutti gli elementi del sistema, ma esista a delle condizioni di esistenza diverse rispetto agli oggetti che compongono il sistema. La diversa condizione di esistenza potete anche dire che si caratterizza dal fatto di essere una condizione di esistenza a priori. Se le altre norme in quanto poste, sono tutte norme a posteriori, la norma fondamentale in quanto presupposta è una condizione di validità a priori dell'intero ordinamento giuridico. È una condizione di validità che opera solo e soltanto dal punto di vista logico formale.
Cioè a noi serve soltanto a chiudere questo benedetto sistema nel momento in cui questo sistema lo intendiamo soltanto dal punto di vista logico formale. Cioè come se fosse un meraviglioso teorema matematico. Ecco perché abbiamo bisogno del presupposto logico trascendentale. Altrimenti il sistema non ha il suo fondamento di validità, non ha il fondamento che ci permette di identificare le condizioni di esistenza, le condizioni di possibilità o di pensabilità dell'intero ordinamento giuridico inteso come sistema.
Domanda della lezione di oggi: ci sono altre condizioni a priori di validità dell'ordinamento inteso come il sistema? Prima di rispondere a questa domanda riprendiamo quello che ci siamo detto finora e diciamolo un altro modo. Se l'ordinamento è un sistema di norme e se noi sappiamo che le norme esistono solo e soltanto all'interno di un determinato ordinamento, vuol dire che ogni norma è valida solo e soltanto quando esiste in funzione dell'esistenza di altre norme e tutte insieme queste norme, organizzate nel sistema, compongono l'ordinamento giuridico. Possiamo anche definire questo tipo di validità come validità sintattica.
Che significa validità sintattica? Significa una validità che dipende da come è strutturato il sistema, dalla sintassi del sistema. D'altronde se la validità della norma, ora siamo parlando della regola del singolo, e la sua conformità ai criteri formali procedurali, posti della norma immediatamente superiore, e così via fino a giungere alla costituzione. È chiaro che in questo caso la validità che cos'è? La validità è quella proprietà che dicendoci quando una norma esiste o meno all'interno del sistema, organizza, costruisce la sintassi dell'intero sistema.
È un modo diverso per definire la validità come esistenza specifica. Dire che la validità è l'esistenza specifica di una norma in e per un ordinamento significa semplicemente... Allora, tutte le cose che vi sto dicendo adesso, io ve le dico perché a un certo punto, in dei testi, c'è un approccio più semiotico al concetto di validità.
Il significato è sempre lo stesso, alla fine ritradurremo tutto in altri termini e vi farò vedere come l'utilizzo di alcuni termini specifici può essere per voi utile nel momento in cui rinvia immediatamente al concetto. Se non è utile, sia come metodologia di studio sia come tipologia di esame, mi interessa il concetto, non mi interessa in questo caso il nome o la definizione.

Siamo adesso traducendo quello che ci siamo detti in una scorsa lezione in un altro tipo di lessico per vedere se questo lessico è più funzionale per mettere a fuoco alcuni concetti che voi già conoscete. Adesso lo vedrete, è abbastanza semplice in realtà. La validità della norma all'interno dell'ordinamento giuridico, quindi la validità ordinamentale, se l'ordinamento è giuridico, è il sistema all'interno del quale sono stanziate le norme, potremmo dire dal punto di vista linguistico che l'ordinamento altro non è se no la sintassi del linguaggio giuridico. Cosa è la sintassi ragazzi? Chi mi sa dare la definizione della sintassi?
RISPOSTA: È il modo in cui è composto una frase.
Bravo. Allora, è il modo in cui è composto una frase. Se le norme sono i singoli elementi che compongono il discorso giuridico e l'ordinamento è il discorso giuridico, la validità che mi dice come le norme appartengono e formano il discorso del diritto sarà la validità sintattica.
Altro non è se non l'esistenza della norma all'interno di quel determinato sistema. All'interno di questa validità, noi abbiamo distinto due diverse condizioni di validità. Ci siamo? Andiamo piano. Abbiamo distinto che cosa? Nella costruzione dell'ordinamento giuridico, nella validità ordinamentale, abbiamo distinto due diverse condizioni di validità: la validità di ogni singola norma e la validità dell'intero ordinamento giuridico. La validità di ogni singola norma è la validità che la norma ripete quando è posta conformemente ai criteri procedurali formali, posti dalla norma immediatamente superiore.
La varietà invece del sistema, dell'intero sistema, è che cosa? È un presupposto logico trascendentale che noi immaginiamo vi sia, per fondare validamente l'intero sistema di norme. Abbiamo entrambe le condizioni di validità a posteriori e delle condizioni di validità a priori all'interno dell'ordinamento giuridico che suppone il sistema. Quali sono le condizioni di validità a posteriore? La validità è intesa come esistenza specifica. Quale è la condizione di validità a priori? La norma fondamentale. Una è a posteriore perché è posta, quella condizione di validità è posta dalla norma immediatamente superiore. Nel lessico kantiano è una validità a posteriore.
La norma fondamentale è una norma posta? È una norma presupposta, ma se è presupposta, se noi immaginiamo che esista in quanto oggetto puramente logico che non appartiene all'esperienza giuridica, cioè non sta dentro l'ordinamento giuridico. Noi abbiamo imparato che tutto il mondo del diritto è il mondo che abita le stanze dell'ordinamento giuridico. Al di fuori dell'ordinamento giuridico non ci sono fatti o fenomeni del diritto. Tutto il diritto è racchiuso nello spazio dell'ordinamento giuridico. Questo spazio, a sua volta, ha necessità di trovare il fondamento di validità. Questo fondamento di validità l'abbiamo presupposto e non posto. È un fondamento a priori, condizione di validità a priori dell'ordinamento giuridico.
Quando all'esame vi verrà chiesto, per esempio, validità sintattica, potreste dire, potrete rispondere, dicendo che la validità all'interno dell'ordinamento giuridico si suddistingue in condizioni di validità a priori o condizioni di validità a posteriore. Le condizioni di validità a posteriori sono quelle condizioni di validità poste da norme nei confronti di altre norme all'interno della struttura gerarchico-piramidale dell'ordinamento giuridico. Poi c'è almeno una condizione di validità a priori dello stesso ordinamento. Questa condizione di validità a priori di tutta la sintassi, non all'interno della sintassi, ma della sintassi intera del discorso del diritto, è la norma fondamentale. Nell'ambito di semiotica del linguaggio informativo, queste due diverse condizioni di validità hanno due nuovi diversi. La validità, perciò ve lo sto dicendo, perché può darsi, che i nomi vi aiutino a ricordare il concetto. I semiotici definiscono le condizioni di validità di norme su norme; dunque, la validità intesa come esistenza specifica di una norma, come validità o condizioni di validità SINTASSEONOMICHE, dove la condizione di validità è data dal *nomus*; è il *nomus* che pone le condizioni di validità.
Ci torneremo, lo ridiremo, il nome potete non impararlo. Vi sto dicendo adesso, lo vedrete che però se entrate nel meccanismo è più semplice ricordare.
Vi sono poi, condizione di validità a priori. I semiotici definiscono queste condizioni di validità sintattica condizioni di validità, se le altre sono sintasseonomiche, di solito contrapposto a *nomus* c'è il *locos*, e quindi quelle saranno condizioni SINTASSEOLOGICHE. Ragazzi potete scegliere: condizioni di varietà sintattica, condizioni di varietà in e dell'ordinamento, inteso come struttura di norme. Distinguete condizioni di validità all'interno dell'ordinamento a posteriore sintasseonomiche, sono quelle condizioni di validità di norme su norme. Dove la condizione di validità non è nient'altro che la conformità della norma inferiore ai criteri formale procedurali della norma immediatamente superiore. Sintasseonomica: la condizione è posta da un *nomos* nei confronti di un'altra norma. Abbiamo, all'interno delle condizioni di validità sintattica, condizioni di validità a priori o condizioni di validità semplicemente logiche dell'ordinamento giuridico (norma fondamentale ad esempio) quindi che non dipendono più da una norma, ma dipendono dal pensiero,

da un atto di pensiero, sono condizioni a priori, i semiotici parlano in questo caso di condizioni sintasseologiche. Se *logos* e *nomos* vi aiutano a distinguere a priori e a posteriori ben venga. Se vi confondono nel ricordare il tema della validità sintattica alla Kelsen, i nomi li potete lasciare perdere. E il mio compito è spiegarveli perché li troverete comunque nel libro di testo. A me non interessano le definizioni del corso, interessano i concetti, non mi interessano i nomi e le definizioni, quello che mi interessa è a priori e a posteriore. Adesso su posteriore abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, ora passeremo alla norma che avevamo già iniziato. Su priori dobbiamo dire ancora qualcosa.
A priori è il mondo dei pensieri, tutto ciò che non è infinito, tutto ciò che non riguarda in questo caso l'esperienza, in Kant ciò che permette, che rende pensabile l'esperienza. Tutto ciò che noi presupponiamo esista per poter poi aprire le categorie, in questo caso, dell'esperienza sensibile, dell'esperienza normativa, in questo caso, e tutto ciò che noi presupponiamo logicamente debba esistere affinché noi possiamo conoscere tutti gli oggetti di un determinato tipo di campo. Lo spazio e il tempo sono categorie a priori la cui esistenza noi intuiamo per conoscere, per costruire la nostra esistenza sensibile. La norma fondamentale è lo spazio e il tempo dell'esperienza sensibile. È un presupposto che noi, la cui esistenza, non possiamo non presupporre perché altrimenti non costruiremmo lo spazio dell'esperienza giuridica, che sono le norme, le norme materiali (è vietato fumare). E noi immaginiamo questo oggetto logico che non esiste ma che è un presupposto logico. Quindi una condizione di pensabilità e di possibilità. Non potresti fare esperienza del mondo se non all'interno delle categorie spazio-temporale, se non presupponi l'esistenza dello spazio e del tempo, direbbe Kant, la tua esperienza non potrebbe porsi in essere. La norma fondamentale è esattamente la stessa cosa. È un principio logico-formale che rende pensabile e possibile il discorso giuridico, se sei un semiotico, filosofia del linguaggio o semiotica. L'esperienza se sei un fenomenologo del diritto giunto ai fatti, i fenomeni giuridici. Le norme se sei un teorico generale del diritto.
Tutto ciò che è diritto che frequenta il campo giuridico, presuppone, secondo Kelsen, che abbia una categoria logico-formale che ti permette di pensare tutto questo. Questa categoria è la norma fondamentale, dunque a priori, prima dell'imporre presupporre l'esistenza di questo tipo di oggetto, poi puoi evidentemente ragionare con l'esperienza sensibile all'interno del tuo sistema. Quello ti serve come condizione di esistenza del sistema, del campo che stai andando ad esplorare o a conoscere. Quindi, validità sintattica, che è la validità ordinamentale all'interno dell'ordinamento. Esistenza specifica di una norma, giudizio di conformità, validità sintasseonomica, perché quella validità è il prodotto di condizioni formal-procedurali poste da un *nomus*, da una norma rispetto ad un'altra norma all'interno del sistema, che io posso verificare evidentemente a posteriori attraverso la mia esperienza sensibile, esperienza giuridica.
Condizioni di validità a priori, cioè sono il presupposto che io devo immaginare per poter poi operare e pensare all'interno dello spazio del diritto che è lo spazio ordinamentale. La condizione di pensabilità e possibilità dell'ordinamento giuridico inteso come sistema di norme, il fondamento di validità dell'intero sistema. Quindi l'oggetto non dipende da un *nomus*, ma dipende da un *logos*, dalla ragione. Definiamolo il *logos*, anche se il *logos* è uno dei concetti più complessi e più inflazionati di tutta la filosofia, basterebbe riferirci Eraclito per avere tre concetti diversi di *logos*. Se vai a vedere Heidegger la confusione sarebbe ancora maggiore, perché i concetti sarebbero cinque, per esempio. Però il *logos*, noi teniamolo, come pensiero, come ragione. Qui avresti dei principi razionali, logici che sono dei presupposti affinché tu possa costruire correttamente il tuo sistema. Sono dei presupposti di pensiero che tu devi necessariamente utilizzare, postulare per costruire correttamente il tuo pensiero, il tuo sistema, altrimenti quel sistema non è possibile, né pensabile. In questo caso queste condizioni a priori sono condizioni di che tipo?
Sintasseologiche. Potremmo anche dirlo in un'altra maniera. È dall'idea stessa di ordinamento che deriva la norma fondamentale. Cioè se tu pensi all'ordinamento come un sistema chiuso di validità, per renderlo pensabile da quella idea stessa, tu devi derivare necessariamente l'esistenza di un presupposto di validità che rende pensabile l'intero sistema. Così vi ho confuso forse, era il ragionamento a contrario che volevo fare, ma non confondiamo, poi magari ci arriviamo anche al tema, e qui entra in gioco un'altra definizione.
È un presupposto in questo caso a priori, validità sintasseologica. Quindi quel concetto che abbiamo visto ieri, che abbiamo ripetuto oggi, lo potete anche suddividere semplicemente in condizioni a posteriori o condizioni a priori di validità. Le condizioni a priori sono costituite dalla norma fondamentale, le condizioni a posteriori dai criteri formal-procedurali che sono posti dalle norme immediatamente superiori all'interno dell'ordinamento giuridico stesso. Entrambi i criteri concorrono a formare quella che abbiamo definito validità sintattica, cioè il mondo in cui le norme stanno insieme, esistono all'interno e sono organizzate

all'interno di un sistema. Questo sistema è l'ordinamento giuridico, che voi sapete anche avere determinate caratteristiche: è una piramide gerarchica, si costruisce a gradi ed è un sistema dinamico.
Ribadisco se i termini sono fastidiosi o non vi aiutano basta ricordarvi che la norma fondamentale è una condizione di validità a priori, mentre la conformità ai criteri formal-procedurali è una condizione di validità a posteriori, che riguarda in questo caso la costruzione del discorso giuridico all'interno del sistema. Quello invece è un presupposto logico che permette allo stesso sistema di esistere in quanto tale.
Fermiamoci un attimo. Una volta che abbiamo definito le condizioni di validità sintattica e abbiamo distinto condizioni di validità a priori e condizioni di validità posteriori, la volta scorsa avevamo posto un'altra successiva domanda. Quello che abbiamo detto adesso non ha aggiunto nulla a quello che abbiamo detto la volta scorsa. L'ho solo detto in modo diverso. La volta scorsa non avevo fatto cenno alla priori o alla posteriori, ora ho semplicemente detto che è una condizione di validità trascendentale, in senso kantiano, proprio perché trascendentale è una condizione di validità a priori, ma non ho aggiunto nulla dal punto di vista concettuale a quello che ci eravamo detti la volta scorsa.
Qualcosa in più lo potremmo anche dire, rispetto alle condizioni di validità a priori. Oltre la norma fondamentale possiamo identificare un altro principio logico formale a priori dell'ordinamento giuridico in quanto sistema. Che altro ci siamo detti rispetto alla definizione, un principio logico che derivi dalle definizioni stesse dell'ordinamento. Quale è la condizione da cui siamo partiti? Una delle prime cose che abbiamo detto rispetto all'ordinamento e all'esistenza delle norme. Esistono norme, possono esistere norme al di fuori dell'ordinamento giuridico? Cioè le norme esistono in quanto tali solo se fanno parte della sintassi dell'ordinamento giuridico, per usare adesso questa terminologia più semiotica, o fanno parte della struttura dell'ordinamento giuridico. Dunque, le norme che sono fuori dell'ordinamento non sono, dicevamo, non esistono norme invalide o non valide. Le proposizioni prescrittive che non appartengono al sistema non sono norme giuridiche. Quando vengono evidentemente introdotte all'interno dell'ordinamento, quella proposizione prescrittiva assume lo status di norma giuridica, dunque diviene valida. Al contrario cosa potremmo dire?
Proviamo a fare una definizione, a ricavare i principi di quello che ci siamo detti adesso. Che le norme giuridiche esistono solo e soltanto all'interno dell'ordinamento giuridico. Dunque, l'ordinamento giuridico è condizione di pensabilità e possibilità di ogni proposizione prescrittiva che voglia dirsi proposizione prescrittivo giuridica, cioè una norma giuridica. Dunque, sono norme giuridiche solo e soltanto tutte le proposizioni che esistono in quanto valide all'interno dell'ordinamento giuridico. Questo principio si chiama norma di chiusura degli ordinamenti. È un principio logico, è una semplice derivazione logica del fatto che non esistono norme al di fuori dell'ordinamento. Sono norme solo e soltanto quelle proposizioni che appartengono all'ordinamento giuridico. Tutte le norme giuridiche sono solo e soltanto le norme valide all'interno dell'ordinamento giuridico. Dunque, quelle norme che sono state prodotte conformemente ai criteri formal-procedurali dell'ordinamento giuridico. Questo dice che l'ordinamento giuridico è un sistema chiuso e che appartengono al sistema, che dunque sono norme giuridiche, solo tutti quegli oggetti, quegli elementi X che presentano quelle determinate caratteristiche, solo quegli oggetti. È una banalità, abbiamo semplicemente come dire formalizzato quello che noi avremmo visto già attraverso l'esperienza, sappiamo se le norme sono solo quelle proposizioni valide all'interno dell'ordinamento giuridico è evidente che nessun oggetto che sia al di fuori dell'ordinamento giuridico può essere considerato come valido; dunque, l'ordinamento giuridico è un sistema valido chiuso dove si entra o si esce soltanto in base al rispetto al giudizio di conformità dei criteri formali procedurali posti all'interno di quei determinati ordinamenti, quei determinati sistemi.
Passaggio successivo, abbiamo detto tutto quello che potevamo dire sul tema della validità. All'esame questo tema vi verrà chiesto, non l'abbiamo completamente discusso, vi do questa brutta notizia, ma almeno la validità intesa come esistenza all'interno dell'ordinamento abbiamo detto tutto quello che potevamo dire. Questo significa che per esempio all'esame questa domanda può essere posta in tantissimi modi, perché ci sono moltissimi approcci al tema della validità, o si può entrare dalla sintassi, si può entrare dalla norma fondamentale. La cosa essenziale è che voi abbiate chiari tutti i passaggi che abbiamo visto la volta di scorsa, che abbiamo ripetuto oggi, e che andremo adesso a sviluppare ulteriormente rispetto al concetto di validità. Perché il tema della validità è un po' come in logica, l'esame di logica nella facoltà di filosofia. Diceva un mio collega: se non si sapeva cosa fosse la validità o se rispondeva male si andava a casa perché diceva, se uno non sa che cos'è la validità in ambito giuridico è proprio impensabile che abbia capito tutto il resto. Io invece penso che il tema della validità almeno nella versione kelseniana sia un pensabile possibile

in maniera corretta se si ha ben chiaro il tema della fallacia naturalistica. Se ci pensate bene, tutti i passaggi teorici che abbiamo visto fino a ora, sono tutti passaggi derivati dal tema della fallacia naturalistica. Se all'esame non vi dovesse ricordare la differenza tra un sistema statico e un sistema dinamico, fallace naturalistica, siamo nel positivismo giuridico, non centra il contenuto, pensate sempre al tema della forma, validità.
Se vi dovesse essere chiesto la validità sintattica, anche qua il presupposto per cui dovete ragionare è che va esclusa sempre la dimensione contenutistica o significativa. La fallacia naturalistica è il presupposto a tutti gli argomenti che abbiamo sviluppato finora e che andremo a sviluppare adesso. Perché noi finora stiamo ragionando sulla struttura dell'ordinamento giuridico, su come è costruito il sistema. Non ci siamo però posti il problema, anzi avevamo iniziato a porcelo, su che cosa sono i singoli elementi che compongono il sistema. Sì, noi abbiamo definito le norme giuridiche come proposizioni linguistiche prescrittive. Ora, sappiamo che si tratta di proposizioni linguistiche prescrittive valide all'interno di questo sistema.
Ma che cos'è una norma giuridica? Alta domanda chiave all'esame.
Come possiamo definire una norma giuridica? Che cos'è la norma giuridica? Dicemmo la volta scorsa che la norma giuridica è quella proposizione prescrittiva che contiene generalmente una sanzione e che quindi, quando parliamo di forma tipica, la tipicità è data sia dalla validità, ma dal punto di vista formale, dalla presenza della sanzione.
Le norme giuridiche sono proposizioni linguistiche prescrittive, munite di sanzione. Possiamo dire sono proposizioni prescrittive sanzionatorie. E cos'è una norma giudica? Prima definizione: è una proposizione prescrittiva sanzionatoria valida. La forma tipica è quella di una proposizione prescrittiva o sanzionatoria, non c'è solo la prescrizione, l'obbligo, il comando individuo, c'è anche la sanzione prevista nel caso in cui la norma non venga seguita. E dunque come sarà costruita la definizione di una norma giuridica? Dicevamo la volta scorsa, sarà costruita come una proposizione prescrittiva dove c'è la descrizione di un fatto o di un comportamento e poi c'è, dicono i semiotici, la modalità deontica corrispondente, obbligatorio, permesso o vietato; quindi, il fatto viene qualificato in un certo modo.
"È vietato fumare". Quindi il fatto è il fumare. L'atto è il fumare. La qualificazione deontica, cioè il dover essere, è vietato. Il comportamento viene qualificato in un certo modo giuridicamente rilevante. Poi c'è la sanzione che la norma prevede se commenti il fatto qualificato come vietato ti verrà applicata la seguente sanzione e questa è la costruzione evidentemente di una proposizione prescrittiva o sanzionatoria che possiamo definire norma giudica.
DOMANDA: Non c'è un rimando alla norma immediatamente superiore?
No, non c'è un rimando alla norma immediatamente superiore. In alcuni casi c'è all'interno, ora stiamo ragionando sulla proposizione, sulla parte prescrittiva o sanzionatoria. Allora, questa domanda la mettiamo nel cassetto come al solito. Sposta il discorso un po' più di là, non siamo ancora in grado di rispondere a questa domanda, ci confondiamo troppo le idee. La tua domanda è però protonica a tutta un a critica che svolgeremo all'approccio kelseniano, perché non crediate che la storia che vi sto raccontando non lasci anche me perplesso. Io ribadisco sempre ragazzi, ormai sono passati per me tantissimi anni, che è sempre particolare secondo me spiegare a dei ragazzi, a degli studenti, un approccio alla teoria generale del diritto, quindi un approccio alla terapia del diritto, che non consideri il problema se il diritto sia giusto o meno. Cioè, resta assolutamente contro intuitivo. Quindi è vero che è assolutamente geniale ed è indispensabile costruire il diritto come scienza del diritto, cioè il merito qui, la costruzione del discorso giuridico come una scienza giuridica. È anche vero però, che parlare del diritto e dire che il diritto è giustizia, sono due categorie concettuali che non c'entrano nulla. Cioè, per il mio modo di vedere è una questione questa davvero paradossale, molto più paradossale della norma fondamentale, perché significherebbe dire che anche in fase di giudizio, quindi, non solo in fase di costruzione del discorso giuridico, ma in fase di esecuzione del discorso giuridico, quindi dinanzi a un giudice. I giudici che sono? Sono dei neri, contabili, notabili, che guardano come incastrare il discorso giuridico valido o si devono porre anche delle questioni di giustizia sostanziale? È inutile che stiamo a girarci intorno, la prospettiva è affascinante ma è storicamente datata, anche per questo modo di guardare e di costruire il diritto come un oggetto meraviglioso, oggetto logico. È affascinante sicuramente, ma ha dei limiti evidenti. Adesso li andremo a vedere quando chiuderemo questa parte, e cercheremo altre risposte, perché noi siamo partiti dalla nostra domanda: perché dobbiamo seguire le regole? Perché tutto sommato è obbligatorio ciò che dice una norma valida e non ci dobbiamo interessare di tutto ciò che c'è dietro la norma valida. Questa la trovo oggi una risposta davvero riduttiva, soprattutto oggi che ci sono questioni di giustizia sociale, di giustizia sostanziale enorme: problemi del riconoscimento,

nuovi diritti, le metamorfosi continue del discorso giuridico. Dire che il lavoro del giurista è il lavoro del logico, insomma. Il giurista deve acquisire gli strumenti della logica, ma non può limitarsi poi a considerare il diritto come soltanto un oggetto logico.
Detto questo torniamo però a fare i logici perché noi stiamo ragionando in questo momento e stiamo rispondendo alla nostra domanda proprio in questa prospettiva, proprio attraverso questo tipo di metodo. Allora se la norma giuridica è la proposizione prescrittiva sanzionatoria che qualifica un fatto da un punto di vista deontico, cioè dice che quel fatto è permesso obbligatorio o vietato e prescrive l'applicazione di una determinata sanzione, se volessimo ricavare una definizione logico formale di cosa è una norma giuridica, potremmo tranquillamente dire che la norma giuridica è una proposizione che qualifica un determinato fatto e prevede nel caso in cui quel compimento di quel fatto accada, l'applicazione di una determinata sanzione, ovvero se io commetto il fatto qualificato come illecito, mi potrebbe essere applicata una sanzione. Se volessimo astrarre ulteriormente, quindi costruire davvero una formula logico formale, potremmo dire se A deve essere B, dove A che è il fatto qualificato come illecito (il livello di illiceità lo stabilisce volta per volta, se è un fatto vietato, un fatto solo permesso in qualche caso, se è un fatto permesso sempre quindi non è un fatto illecito), B è la sanzione legata alla condizione di quel determinato fatto. Dunque, la norma che fa? La norma è uno schema di qualificazione giuridica. La norma qualifica come giuridicamente rilevante un fatto che appartiene al mondo sociale e naturale e lo fa entrare all'interno dell'ordinamento, qualificandolo dal punto di vista deontico e prevedendo l'applicazione a quel fatto di una determinata sanzione.
Ricordate la volta scorsa l'esempio del cazzotto? Il fatto, nella sua socialità, nella sua naturalità, non cambia, può cambiare la qualificazione giuridica del fatto a seconda delle circostanze che sono rilevanti per le norme giuridiche. Dunque, il fatto di per sé non ha alcuna rilevanza dal punto di vista giuridico, diventano rilevanti i nostri comportamenti solo e soltanto quando c'è una norma che li qualifica come giuridicamente rilevanti. Fintanto che non c'è la norma, noi possiamo fare quello che vogliamo. Cioè tutti i nostri comportamenti sono indifferenti rispetto al mondo dell'ordinamento giuridico. Diventano sensibili per l'ordinamento giuridico quando c'è una norma che li qualifica come giuridicamente rilevante. Cioè dice "stai attento, da ora in poi se ti comporti così quel tuo comportamento sarà un comportamento vietato, sarà un comportamento permesso, sarà un comportamento obbligatorio". Fintanto che non c'è evidentemente la norma, fintanto che non c'è la norma che lo qualifica in questo modo, il fatto è irrilevante rispetto all'ordinamento giuridico. Può accadere qualsiasi cosa, ma il diritto se ne infischia. Perché il fatto risulta essere irrilevante per l'ambito giuridico? Fallacia naturalista. Perché tutti quei fatti continuano ad appartenere al mondo dell'essere, a quella parte del mondo che è ciò che esiste, in maniera sociale, in maniera naturale, in maniera biologica. fin tanto che non c'è una norma che lo trasferisce nel mondo del dover essere, cioè lo qualifica come un giuridicamente irrilevante, invitandoli una sanzione, qualificandolo un giuridicamente, quel fatto è irrilevante dal punto di vista giuridico. Che voi siate o meno composti a tavola è un fatto che all'ordinamento non interessa. Se invece durante il vostro pranzo prendete il coltello e lo piantate nella pancia di un vostro parente, un esempio particolarmente macabro, in quel caso il vostro comportamento caspita se è giuridicamente rilevante, perché quel comportamento è qualificato da una norma e dunque trasferito dal mondo dell'essere, l'atto che avete sferrato il colpo che è un atto fisico che appartiene al mondo dell'essere, al mondo del dover essere. Quel fatto è qualificato deonticamente come tentato omicidio, come omicidio volontario, come un atto per il quale è prevista una sanzione. Potremmo dire meglio dal punto di vista filosofico, che ogni norma "se A deve essere B" è condizione di pensabilità e di possibilità di ogni atto giuridicamente rilevante. Questa è la definizione precisa di pensabilità. Significa che l'atto è giuridicamente rilevante, cioè è pensabile ed è possibile come atto giuridico se c'è una norma che lo qualifica come tale. Altrimenti è irrilevante dal punto di vista giuridico, appartiene al mondo dell'essere e non al mondo del dover essere. E voi sapete che tra essere e dover essere non ci sono contatti.
La norma giuridica è uno schema trascendentale di pensabilità e possibilità di ogni atto giuridico. Ogni atto, ogni comportamento è pensabile e possibile giuridicamente, solo se c'è una norma, uno schema che lo qualifica come atto giuridico, altrimenti quell'altro resta nel mondo dell'essere, non passerà nel mondo del dovere essere. Questa idea sembra una banalità, ma in realtà è un'idea che ha delle implicazioni notevoli dal punto di vista della rilevanza del mondo dei fatti rispetto al mondo dei valori. Pensate a tutti quei comportamenti che sono socialmente rilevanti, per esempio tutto il problema che si è creato negli ultimi anni per le famiglie di fatto, era una situazione che si creava per esempio di fatto, ma non ha in molti casi un'adeguata tutela giuridica. Perché accade questo? Perché non c'è una legge che qualifica quei fatti socialmente rilevanti, caspita influiscono sulle vite di tantissime persone, come fatti giuridicamente rilevanti.

Quindi quei fatti rimanevano nel mondo sociale; ma il mondo sociale è il mondo dell'essere, è il mondo di ciò che esiste, di ciò che si produce, ma non venivano qualificati come fatti giuridicamente rivelanti perché non c'era la norma che regolava quei fatti. Perché oggi tutte queste polemiche che sono uscite anche in televisione, quando molti dicono "vorremmo una legge, una norma per regolamentare questa situazione", perché moltissime situazioni, pensate a tutti i temi che ci sono sulla finanza virtuale, le blockchain, tutti fenomeni che ormai sono fenomeni socialmente rilevanti, economicamente rilevanti, che fintanto che non vengono regolamentati da una norma apposita, ovvero non vengono trasferiti dal mondo dell'essere al mondo del dover essere, quei fatti non sono giuridicamente rilevati. E dunque chi pone in essere quegli atti e quei comportamenti non ha tutele giuridiche, non ha diritti e non ha doveri neanche rispetto ai terzi.
Vedete, è piena di conseguenze l'idea che insegnano, perché questa idea per cui appunto l'ordinamento, il diritto e tutto ciò che sta all'interno dell'ordinamento, dice anche che fatti che possono essere socialmente ormai rilevanti che chiedono continuamente tutele giuridiche, fintanto che non sono trasferiti dal mondo dell'essere al mondo del dovere essere, quei fatti non sono giuridicamente rilevati. Vedremo, sinteticamente, come spetta in questo caso a chi aggiunge attraverso l'attività di interpretazione trovare norme che più o meno disciplino, fatti simili, per poter applicarle in maniera analogica, cioè per analogia, ma questa è una cosa che vedremo tra qualche lezione.
Ancora una volta questa idea su cui stiamo ragionando, il tema della norma come schema di qualificazione giuridica, la norma come schema trascendentale, è ancora una volta una derivazione del rapporto tra essere e dover essere. In nessun caso l'essere è giuridicamente rilevante se non c'è il dover essere che lo prende e lo trasporta all'interno del discorso giuridico. Questo dover essere è la norma giuridica che qualifica quel comportamento come una fattispecie giuridicamente rilevante. Nella visione kelseniana qualifica quel comportamento, quel fatto come illecito e prescrivere l'applicazione di una determinata sanzione. Dunque, se A deve essere B.
Che cosa ci resta da chiarire rispetto alla nostra definizione? Se A deve essere B, se pongo in essere il fatto qualificato come illecito, mi deve essere applicata la sanzione. Necessariamente mi deve essere applicata la sanzione. C'è un nesso di necessità.
DOMANDA: Se tu fumi nell'aula necessariamente e sicuramente ti verrà applicata la sanzione? Oggi hai un margine di possibilità ampio che ti possa anche non essere applicata?
RISPOSTA: Qualora tu sia colto in fragrante.
Dunque, il dover essere che lega il fatto qualificato come illecito alla sanzione che tipo di dover essere è? Un dover essere necessario o un dover essere solo possibile? Un dover essere solo possibile. Aspettate perché non è così semplice. La lingua tedesca, in realtà, il verbo dovere lo traduce con quattro verbi diversi che hanno tutti quanti una intensità, in realtà, di doverosità diversa. Brauchen, dürfen sollen e müssen, sono quattro verbi tedeschi che significano tutti quanti dovere.
Qualcuno sa la differenza chi ha studiato il tedesco al liceo?
Müssen è obbligatorio. È strettamente necessario, è il non poter far diversamente.
Sollen è obbligatorio in senso morale.
Il dürfen e il brauchen sono quel dovere e potere. Potrei fare una cosa? Potresti per me, quindi è legato al concetto del potere. Il dovere potere non è legato al tema della nostra obbligazione, perché qui in realtà si sta parlando di un tu devi, non di un tu vuoi, non è una richiesta io potrei. Restano in ballo sollen e müssen: müssen indica il dovere che si riferisce ai fatti e ai fenomeni naturali.
Esempio: Se lascio cadere questo mazzo di chiavi, questo mazzo di chiavi deve necessariamente toccare terra, perché c'è la forza di gravità, una legge della miniatura che mi dice che c'è un nesso di necessità fra una causa e una azione.
Se lascio cadere l'oggetto, esso deve necessariamente cadere per terra. È in esso causa-effetto tipico delle leggi naturali. Potrebbe mai essere questo il dovere, il dover essere di una norma giuridica che lega il fatto qualificato come illecito alla sanzione prevista dalla norma.
Dovete sapere che una parte del nostro corso a breve, una lezione straordinaria, dove vedremo le immagini, sarà sul panopticon. La seconda parte del nostro corso è Michel Foucault. Faremo una parte del pensiero di Foucault attraverso il panopticon.
Non so se qualcuno di voi ha visto un film di fantascienza di parecchi anni fa che si chiamava "Minority Report" con Tom Cruise tratto da un libro di Philip Dick. Era un classico romanzo, film dispotico, dove si immagina un mondo in cui in realtà la giustizia è amministrata da alcune creature che sono delle creature veggenti, che riescono a leggere, a prevedere il futuro, ciò che chiunque può compiere. Poi c'è una polizia

speciale che segue i suggerimenti, di queste creature veggenti. Non sono neanche dei profeti perché la profezia è un'altra cosa; quindi, d'altra parte c'è la capacità di vedere ciò che accade e quindi di poter vedere in anticipo il compimento di atti qualificati come illeciti. Questo significa che in realtà se tu sei scoperto ancora prima di compimento di atti qualificati come illeciti. Questo significa che in realtà se tu sei scoperto ancor prima di compiere l'atto illecito, non hai possibilità di non essere arrestato, di non essere preso. Quindi qui cosa avviene in realtà? Ragazzi ora stiamo ragionando filosoficamente alti. Nel momento in cui noi veniamo sanzionati per atti illeciti che non abbiamo ancora compiuto e dunque non possiamo sfuggire al nostro ipotetico destino di criminali (che pio era il senso non tanto del film quanto del romanzo di Philip Dick), qual è il tema che viene meno? Cioè se A deve essere B, quell'essere sia un müssen, analogo al dover essere delle leggi naturali, che data una determinata causa deve necessariamente eseguire un determinato effetto, se fosse costruita così l'idea di norma giuridica cosa rischieremmo di perdere? Panopticon, cosa verrebbe meno? Il nostro libero arbitrio. Noi verremmo in realtà puniti ancora prima, quindi come dire, noi sapremmo in anticipo che se volessimo scegliere di trasgredire qualsiasi sanzione, di porre in essere, come dicono i sociologi, un comportamento deviante, non necessariamente un comportamento trasgressivo (che sono due cose diverse: un comportamento deviante non è una trasgressione, ma è una trasgressione molto minore, non c'è la violazione della regola, ma c'è un comportamento che ha limite con la violazione della regola), vedremmo immediatamente il nostro comportamento represso e dunque sapremmo in anticipo di non poter fare diversamente rispetto a quanto ci viene prescritto da un ipotetico legislatore.
Non esisterebbe il diritto. Cioè quel sollen è proprio un elemento identificativo fondamentale di che cosa sia il diritto, perché lì dentro si annida tutto il mondo del dover essere, il mondo deontico del diritto si rivela proprio in quella scelta, non del müssen, ma del sollen, quel dover essere solo possibile, solo le determinate condizioni, solo in certe condizioni.
Cosa distingue allora il rapporto tra il fatto illecito e sanzione rispetto al rapporto causa-effetto di una legge naturale? Dunque, qual è il tratto caratteristico della norma giuridica, quel tratto che lega attraverso il dover essere il fatto qualificato come illecito al compimento della sanzione? Kelsen lo chiama nesso di imputazione e lo distingue dal nesso di causalità. Il nesso di causalità è quel nesso per cui data una causa deve necessariamente verificarsi quel determinato effetto.
Leggi della natura, nesso di imputazione: dato un fatto qualificato come illecito deve essere possibilmente applicata alla sanzione. Discorso giuridico, legge giuridica. Causalità, imputazione. Ancora una volta, differenza fra essere e dovere essere. Il mondo dell'essere, il mondo della causalità, dell'essere inteso come natura in questo caso. Il mondo del dovere essere non ha nulla a che fare con i principi che regolano il mondo della natura.
Domanda tipica all'esame: causalità e imputazione. Se non vi ricordate che cosa rispondere, ancora essere e dover essere, fatti e norme. Legge naturale e leggi giuridiche. Differenze. Sono due mondi che non si toccano tra loro. Sono regolamentati da leggi e da principi diversi.
DOMANDA: In una concezione giusnaturalistica potremmo prevedere anche come conseguenza obbligatoria la divina provvidenza?
Assolutamente sì, è proprio questo il nesso e il rischio. Kant, per esempio, nella sua costruzione da un enorme importanza al tema della provvidenza, anche tanto a un certo punto, sempre però riferito alla ragione, alla razionalità. Non è la divina provvidenza di Manzoni, si tratta di una provvidenza diversa quella kantiana. Però la norma funziona come uno schema di qualificazione trascendentale. Questo schema è costruito se A deve essere B. A è il fatto qualificato dalla norma come illecito. B è la sanzione. Cosa lega A a B? Un nesso di imputazione. Nella formulazione tedesca alla Kelsen della norma, se il dover essere è espresso dal verbo sollen, il nesso di imputazione si oppone al nesso di causalità dei fatti naturali, ad ogni causa deve necessariamente, müssen, derivare un effetto. Il diritto non funziona attraverso il rapporto causa-effetto, ma attraverso il rapporto di imputazione, per cui la norma giuridica imputa al fatto qualificato come illecito l'applicazione di una determinata sanzione. Ma l'applicazione non è automatica, non conosce un nesso di necessità o di consequenzialità logica. È sempre un nesso di imputazione.
Allora, adesso abbiamo anche una definizione, abbiamo anche una definizione logico-formale di che cosa sia una norma giuridica. La norma giuridica è uno schema trascendentale, cioè logico- formale, s A deve essere B, A è fatto in valutato come illecito, B è la sanzione, ciò che è lega A a B è un nesso di imputazione. Dunque, l'elemento caratterizzante dal punto di vista della forma giuridica, di una norma giuridica, nella visione kelseniana qual è? La presenza della sanzione. È la sanzione, quella che ci permette di qualificare, ci dà la forza, fermo restando che la norma sia valida, ciò che ne testimonia la sua forza è la presenza della

sanzione. La forza della norma è data dalla sua prescrittività. La prescrittività della norma riposa nella sua sanzione.
Esistono però anche delle norme che non hanno le sanzioni, che non prevedono sanzioni.
Esempio: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.
Le norme costituzionali, ora saliamo nella nostra piramide, arriviamo al livello più alto della nostra piramide. La norma al vertice della piramide è una norma composta dai nostri principi costituzionali. Se ve li andate a leggere lì di sanzioni non ce ne sono, perché sono le norme che dettano i criteri formal-procedurali che costruiscono il sistema dell'ordinamento giuridico italiano. Dove stanno le sanzioni? Non ci sono le sanzioni. DOMANDA: Non è giuridicamente descrittiva più che prescrittiva?
No. Allora, nel cassetto, questa obiezione; perché tu dici l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, proposizione descrittiva. Vedremo perché non è una preposizione descrittiva.
Facciamo qualche passo indietro. Constatiamo però che a prescindere dal verbo queste proposizioni che noi chiamiamo norme, caspita se non sono norme le norme della Costituzione che altre proposizioni possiamo qualificare come norme. Queste proposizioni però non contengono sanzioni. Non contengono prescrizioni e allora come la mettiamo? Se noi sappiamo che la norma è solo quella, se A deve essere B, dove A è una cosa e B è la sanzione (questa è la forma tipica della norma giuridica) le altre che fanno non sono norme? Però stanno nel sistema.
DOMANDA: Avendo noi uno schema a priori che ci dice che dobbiamo rispettare la costituzione è come se non ci fosse bisogno di avere una sanzione perché è già in noi il fatto di rispettare la costituzione.
Va ben, ma dal punto di vista di come si presentano, di come sono costruite, come è possibile che queste proposizioni non siano proposizioni prescrittive? Lei l'ha detto, sembrano preposizioni descrittive. Sicuramente qua non sono preposizioni prescrittive, la prescrizione dove sta? L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro voi vedete la prescrizione. Voi vedete la prescrizione? Kelsen dice un'altra delle sue cose geniali ma controintuitive. Cioè Kelsen dice che le norme sono soltanto le preposizioni prescrittive sanzionatorie, cioè le preposizioni descrittive munite di sanzione, perché la forza del diritto riposa tutta nella possibilità di condizionare i nostri comportamenti sotto la minaccia dell'applicazione di un a determinata sanzione. Dunque, dice Kelsen, che il sistema dell'ordinamento giuridico è costituito da norme primarie e norme secondarie. Quali sono le norme primarie? La Costituzione, giusto? È esattamente il contrario. In maniera controintuitiva, Kelsen dice che le norme primarie sono tutte quelle proposizioni che hanno lo schema, se A deve essere B. Cioè munite di sanzione, perché dice Kelsen, la forma tipica del discorso giuridico è la forma prescrittiva sanzionatoria. Poi ci sono tutta una serie di norme, perché Kelsen definisce norme secondarie, che sono quelle norme che servono semplicemente a organizzare il sistema, che sono prodromiche all'emanazione di norme primarie, che sono le norme secondarie. Le norme costituzionali nella visione kelseniana sono norme in conflitto, che attendono di avere la loro forza, di trovare la loro forza operativa, in norme munite di sanzioni. Kelsen le definirà principi generali, ma non norme. Addirittura, l'ultimo Kelsen parlerà di principi generali, il primo Kelsen le definirà norme secondarie o frammenti di norme.
Cioè dice Kelsen, quelli sono frammenti di nome che attendono poi di essere completati perché il discorso giuridico trova la sua essenza, la sua forza nella sanzione. Dice Kelsen, se ci fosse solo la Costituzione sarebbe un insieme di bei principi che probabilmente non seguirebbe nessuno se non ci fossero le norme operative, che sono le vere norme giuridiche, che sono quelle che, minacciando l'applicazione della sanzione, fanno sì che l'intero sistema abbia forza obbligatoria, quindi si costruisca l'ordine sociale, e dunque si seguono le regole, domanda da cui siamo partiti.
L'essenza del diritto è la sua forza prescrittiva sanzionatoria. Ciò che caratterizza il discorso giuridico è la presenza della sanzione. Dunque, per Kelsen, la funzione del diritto per il positivismo giuridico è la sua forza obbligatoria. Per Kelsen, questa forza obbligatoria riposa interamente nella sanzione, nella presenza della sanzione. Non è un caso che la politica di Kelsen si chiami anche normativismo giuridico. L'essenza del diritto è la norma, e la norma è se A deve essere B. È la proposizione prescrittiva sanzionatoria, perché le altre proposizioni giuridiche che appartengono all'ordinamento o sono norme secondare o sono frammenti di norme che attengono di essere completati all'interno dalla presenza della sanzione che restituisce forza all'intero ordinamento e all'intero sistema. Dunque, l'ordinamento giuridico (ulteriore elemento quando vi avrà chiesto ordinamento giuridico all'esame) è composto nella visione kelseniana da norme primarie e norme secondarie. Contro intuitivamente le norme primarie sono le norme munite di sanzione, le norme

secondarie sono invece le norme che appartengono per esempio alla costituzione o costruiscono il sistema. O norme secondarie o frammenti di norme.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 7 DEL 16/10/2024

Dopo aver compreso la sintassi delle norme e compreso il collante di questa sintassi, che è il concetto di validità, facciamoci delle domande ulteriori.

Partiamo dalla domanda iniziale: "perché devo seguire delle regole?"; il positivismo giuridico Kelseniano risponde in un certo modo: si seguono le regole fin tanto che queste regole hanno la forma tipica di una norma, ovvero sono recepite all'interno di un ordinamento giuridico e dunque sono espressione e prodotto di una norma valida.

Questo tipo di risposte ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi. I vantaggi li abbiamo fin ora considerati un po' tutti: la dottrina pura del diritto, abbiamo costruito un fondamento dell'obbligatorietà che risulta essere fondato oggettivamente infatti non si interpretano i contenuti e questo ha permesso di costruire un concetto di diritto valido che sia il più oggettivo possibile; questo implica anche la possibilità, per la prima volta nella storia del pensiero giuridico, di costruire il diritto come una scienza. La scienza giuridica nasce con il positivismo giuridico: l'idea che il diritto sia un insieme di proposizioni tutte verificabili mediante il concetto di validità, proposizioni logico-formali che non vengono a contatto con altri elementi e dunque si auto fondano e attraverso il concetto di validità e il concetto di norma fondamentale trovano il loro fondamento solo nella loro forma tipica. Dunque il diritto si costruisce come una scienza logico-formale.

Sembrano delle conseguenze abbastanza scontate per noi, ma per i loro tempi sono dei risultati rivoluzionari, perché si forma per la prima volta una teoria generale del diritto.

I punti deboli.

Abbiamo visto come molte soluzioni proposte da Kelsen, ad esempio, sono soluzioni interessanti, anzi particolarmente elaborate dal punto di vista logico-formale, che pero risultavano essere un po' contro produttive a partire da un macroscopico problema che ha questo tipo di visione: quando qualcuno ci chiede "perché seguire le regole giuridiche?", è difficile che qualcuno risponda che le seguiamo "fin tanto che sono valide"; generalmente la risposta è "le seguiamo se le riteniamo giuste" , tanto che le aule dei tribunali si chiamano aule di giustizia, quando si ricorre in giudizio non è per verificare se una norma sia valida o non sia valida, ma perché vogliamo essere reintegrati da una situazione che noi consideriamo come un torto che ci è stato fatto e quindi chiediamo giustizia.

È la stessa definizione di ius, il concetto romano di diritto deriva dalla parola di iustizia. Come fa il diritto a prescindere completamente dal considerare all'interno del proprio discorso e della propria costruzione, il problema della giustizia? Alla fine si rischia di finire in un altro paradosso: quello di costruire una teoria del diritto slegata completamente da un'idea di giustizia.

È ammissibile un diritto senza giustizia?

Prima questione che ci pone l'approccio kelseniano.

Vedremo anche come se ne esce kelsen da questa obiezione che non comprende come sia possibile la costruzione di una dottrina del diritto che ha come presupposto il fatto che la giustizia non rientra all'interno del discorso giuridico.
Prima questione che rischia di farci precipitare in un paradosso, il diritto è un affare che non riguarda questioni di giustizia che ovviamente non è ammissibile.
Ci sono altri punti deboli nel ragionare con l'approccio kelseniano?
Dividendo le norme primarie dalle norme secondarie, anche qui la risposta di Kelsen era contro intuitiva: sono primarie quelle munite di sanzione e sono secondarie tutte le altre norme da lui considerate frammenti di norme. Eppure le norme riposano nelle loro norme costituzionali.
E dire "quelle quasi non sono norme" o "attendono il braccio armato del diritto", cioè le norme munite di sanzione per poter essere considerate come diritto, vi dice due cose: da un lato che il diritto è come dice kelsen, una tecnica di manipolazione sociale, un insieme di prescrizioni sanzionatorie che regolamenta un contesto sociale attraverso la paura della sanzione. Quindi se il comando contenuto in una regola valida viene trasgredito molto probabilmente verrà imputata una sanzione, dunque l'ordine sociale si costruisce a partire dal timore dell'imputazione della sanzione se si trasgredisce la norma.
Su questo tema intorno agli anni 30, Kelsen inizia un carteggio per una discussione accesa con Freud, padre della psicoanalisi, perché il tema è quello della reazione del soggetto ad un comando di diritto per paura, di qui si apre un mondo in cui il perché seguire una regola ha a che fare con la predisposizione a recepire e interiorizzare il comando munito di sanzione. Freud critica una serie di impostazioni kelseniane seppure ci indurrà ad altre risposte giuspositiviste. Non è un caso che dietro al tema dell'ordine sociale, il diritto è uno strumento dotato di una particolare forza coercitiva, unico strumento in grado di garantirlo, ed è evidente nella particolare distinzione che kelsen fa tra norme primarie e secondarie, perché norma primaria è quella munita di sanzione in quanto fine del diritto è mantenere ordine sociale attraverso la sanzione stessa. Quindi se il diritto lo intendiamo come tecnica di regolazione sociale il suo fine è prescrittivo-sanzionatorio. Ma se intendiamo il diritto solo come una tecnica di regolazione sociale riduciamo il vero valore del diritto, poiché il diritto è molto di più. Resta un punto dubbioso e spinoso della teoria kelseniana, probabilmente questa risposta andava bene nella prima meta degli anni 30 del secolo scorso, ma sicuramente non va bene nel mondo attuale. Ecco il secondo punto debole della teoria kelseniana: il fine del diritto.
"L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro", è una proposizione prescrittiva seppur sembri descrittiva. Il linguaggio del diritto, sicuramente non è descrittivo però fatichiamo a pensare che l'articolo sopra citato sia una proposizione prescrittiva. Kelsen afferma che è una norma perché attende di essere completata da una norma prescrittiva, ma dal punto di vista dell'analisi del linguaggio a Kelsen sfugge un ulteriore riduzione linguistica che attraversa il discorso giuridico. Dobbiamo escludere il linguaggio descrittivo, perché linguaggio giuridico parla con lingua prescrittiva ma che accanto a quest'ultima ci sia un linguaggio non ancora scoperto.
C'è una terza questione, che questa architettura logico-formale nel momento in cui costruiamo il discordo giuridico, non è ancora prevalsa: la costruzione di un'adeguata teoria del soggetto giuridico. Il diritto nasce con noi, ed è il prodotto di una comunità, di un insieme di soggetti, di un'intersoggettività.
La teoria kelseniana come considera il soggetto di diritto, come lo definisce?
Kelsen dice che siamo considerati dal diritto solo nel momento in cui compiamo un fatto, assumiamo un comportamento qualificato giuridicamente dalla norma, altrimenti siamo indifferenti al mondo del diritto, perché apparteniamo al mondo dell'essere, diventiamo rilevanti solo quando poniamo in

essere una condotta che è qualificata dal punto di vista giuridico da una rispettiva norma. Dice Kelsen che il soggetto del diritto si definisce destinatario della norma, cosi come tutte le dottrine del positivismo giuridico. Il destinatario per Kelsen è un mero centro di imputazione di interesse, ciò significa che tu sei giuridicamente visibile quando ti imputa, interessi perché hai posto in essere una condotta giuridicamente rilevante. Il presupposto, infatti è sempre lo stesso :"essere e dover essere". Fin tanto che resti nel mondo dell'essere puoi anche uccidere un tuo simile ma se la tua condotta non è qualificata dalla norma, al diritto non interessa perché in natura non esistono condotte illecite o vietate, lo diventano tali se c'è la norma che le qualifica come tali e ciò prevede l'applicazione della sanzione. Se volessimo fare una considerazione ideologico-politica, la visione del diritto kelseniana è una visione liberale, perché l'ordinamento giuridico ti rende libero di fare qualsiasi cosa purché tu non arrechi danno a qualcuno e la tua condotta sia lecita. Lontani da visione prettamente dirigista.
L'uomo assume un ruolo marginale a differenza di molti teologi del diritto che costruiscono la visione giuridica partendo proprio dal basso, occupandosi proprio del soggetto giuridico, il perché deve seguire le regole e quali sono le condizioni entro cui deve seguirle.
Quindi i tre punti deboli della teoria kelseniana sono appunto: giustizia, funzione del diritto e il suo linguaggio, e concezione del soggetto di diritto.
Kelsen scrive un volume che si chiama *"Il problema della giustizia"*, quindi: è pensabile una visione del diritto che non tenga minimamente conto di un elemento di giustizia seppur minimo? È possibile escludere dal discorso giuridico la valutazione su ciò che è giusto o non è giusto? Non è una questione teorica, perché il problema dinanzi a cui ci troviamo è un problema giurisprudenziale, cioè riguarda scelte dinanzi a cui si sono trovate le corti, ovvero i giudici nell'immediato dopoguerra nella neonata Germania federale. Intorno agli anni 30 del secolo scorso Kelsen fa scuola di diritto e quasi tutti i giuristi austriaci e tedeschi aderiscono alla sua visione del diritto, il positivismo giuridico che conosce la massima sua espansione. Ma sorge un problema storico e politico, perché in quegli anni e in Germania sulle ceneri della Repubblica di Weimar si insedia uno stato che rispetta tutti i presupposti di legalità, legittimità e validità dal punto divista del positivismo giuridico e non nasce da un colpo di stato o da una rivoluzione, bensì in maniera assolutamente legittima. Ma ben presto questo ordinamento giuridico pone in essere norme valide con un contenuto aberrante: le leggi raziali, come tante altre. Durante la vita di questo ordinamento giuridico, il Terzo Reich, tutti seguivano le leggi che erano in vigore; ma con la caduta del Reich e la fine della Seconda Guerra Mondiale, nasce un problema giuridico che sarà il fondamento di tutti i processi aperti nel secondo dopoguerra in Germania nei confronti di chi si era macchiato di crimini contro l'umanità seguendo le orme tedesche. Nel processo di Norimberga alla domanda: "perché hai seguito le regole?" agli imputati, la risposta che ne seguiva era "ho eseguito ordini prescritti da norme valide". Una risposta kelseniana. Il tema che riguarda il conflitto tra validità e giustizia. Le norme sono ingiuste ma valide e i soggetti le hanno poste in essere. Ma ci sono tantissimi processi che si aprono dinanzi alle corti della Germania federale nell'epoca post bellica, perché durate il nazismo sulla base di leggi valide si sono effettuate una serie di atti spregevoli, come confische dei beni e violazioni dei diritti successori, e quando il Reich cade i sopravvissuti chiedono giustizia e quindi la restituzione di tutti i beni, la reintegrazione di tutti i diritti di successione… e come si fa a ristabilire giustizia?
Il primo caso interessante proposto è quello dinanzi alla corte di Nordhausen di un cittadino tedesco che era stato condannato a morte sulla base di un atto di delazione probabilmente fatta dalla moglie dell'uomo anche amante del un gerarca nazista (comportamento lecito e incentivato nella Germania nazista), i discendenti chiedono giustizia per quanto accaduto al parente. Anche qui è pensabile che l'atto di delazione sia un comportamento giuridico ammissibile?

Ma il problema è quello di una serie di atti che ora si pongono come crimini contro l'umanità, ma nel momento in cui erano compiuti erano addirittura promossi da norme giuridiche.
Quindi il giudice come fa a decidere da Norimberga in giù, fino al più piccolo tribunale della Sassonia della Germania federale, cosa sia giusto?
Le strade sono due o accettare la tesi positivista, quindi la linea di difesa dei gerarchi nazisti, che un comando è un comando indipendentemente dalla sua atrocità proprio perché il giurista non lascia spazio alle valutazioni personali, tanto più anche a livello di pubblica opinione si era creata un'opinione comune che giustificava l'orrore posto da quelle norme; oppure non considerare il positivismo giuridico e tornare ad interrogarci sulla giustizia e risolvere l'antica visione del diritto giusnaturalista. Non si può ammettere la validità di una norma se va contro l'umanità.
È impensabile rispondere soltanto in senso giuspositivista alle istanze di giustizia che venivano presentate. Non solo, circa la difesa sulla validità, molto spesso negli ordinamenti giuridici contemporanei vige un ulteriore principio che rafforza la posizione dei criminali nazisti: il principio di retroattività, un principio a garanzia che pone in essere condotte qualificate come illecite, cioè la condotta non è qualificata come illecita se è stata posta in essere quando non era stata qualificata come tale da una norma giuridica. Nel caso dei gerarchi nazisti il loro comportamento non era giudicato criminale, per di più era prescritto come obbligatorio dalle norme vigenti. Quindi dal punto di vista giuridico le argomentazioni sono stringenti, eppure l'esigenza di fare giustizia risulta essere innegabile.
Come si recupera giustizia all'interno di una visione positivista?
Per tornare a parlare di giustizia dobbiamo superare il momento della fallace naturalistica (la legge di Hume su cui si forma il pensiero kenseniano) e quindi definire aberrante il contenuto della legge raziale, quindi tornare a parlare di contenuti senza scivolare nel giusnaturalismo neoclassico.
Bisogna partire dalla fallace naturalistica, che dice che il diritto è solo una forma e non bisogna tener conto dei contenuti. Siccome la fallace naturalistica è il risultato di un semplice sillogismo aristotelico e dal punto di vista logico non c'è verso di passare dall'essere al dover essere, dal fatto concreto non deriverai mai una norma, il valore che essa assume e il fine che persegue, insomma il suo dover essere. Possiamo però provare a forzare il ragionamento usando un'altra metodologia non logica ma fenomenologica, cioè ragionando tramite il pensiero di Husserl e usando un esempio inserito nelle sue "Ricerche logiche", utilizzando solo la sua argomentazione filosofica: come considerare il tema giustizia. La legge di Hume e la fallacia ci dicono che dal fatto non si deriva la regola di questo, quindi dal suo essere non si può derivare il suo dover essere, ma se ragionassimo diversamente sul concetto di essere?
Ma se ci ponessimo un'altra idea di cosa significhi quell'essere all'interno del nostro sillogismo? Fino ad ora l'essere lo abbiamo considerato come la mera essenza di un fatto biologico, naturale o sociale; ma l'essere è anche l'essenza di qualcosa, essenza intesa in senso fenomenologico considerando la seguente proposizione usata da Husserl: un guerriero deve essere valoroso. Il significato di questa proposizione è che il concetto di guerriero implica il dover essere valoroso. Ma esistono guerrieri non valorosi? Sul piano dell'esistenza esistono guerrieri più o meno valorosi, tant'è che le battaglie o si vincono o si perdono. Sul piano esistenziale possiamo ammettere l'esistenza di guerrieri meno valorosi ma sul piano concettuale non è pensabile una definizione di guerriero che non faccia riferimento ad un minimo di valorosità, non lo definiremmo più tale. La natura di guerriero è quella di dover essere valoroso per andare a combattere, dunque il dover essere del guerriero non è inteso come un dover essere di comando, ma che ricaviamo dall'essenza stessa di guerriero, o dalla natura di guerriero se la intendiamo come costrutto logico.

Dal concetto di guerriero deriviamo il dover essere guerriero.
Abbiamo quindi derivato un dover essere da un essere che pero si delinea come un concetto, idea, pura essenza e non come un concetto materiale. La grammatica del concetto di guerriero, come direbbe Wittgenstein, implica il suo dover essere un minimo valoroso. Abbiamo quindi abbandonato la fallacia naturalistica se consideriamo il fatto sul piano ideale e possiamo derivare il dover essere logico e formale che necessariamente costituisce il concetto del fatto stesso. Un ponte tra essere e dover essere a patto di considerare l'essere come una mera idea, concetto di qualcosa.
Analogamente l'ordinamento giuridico che non debba essere un minimo giusto non possiamo considerarlo giuridico. Questo smonta tutte le tesi difensive dei gerarchi nazisti, perché se ordinamento giuridico nazista è un ordinamento che non ha garantito quel minimo di giustizia per poterlo considerare un ordinamento giuridico, significa che non era tale e che era un ordinamento apparentemente giuridico e violava il dover essere di un ordinamento giuridico nell' essere almeno un minimo giusto, non può essere considerato giuridico e non vale l'argomento difensivo del seguire delle norme valide, perché qui la validità non trova spazio in uno spazio criminoso.
Ecco l'argomento analizzato dal filosofo del diritto Gustav Radbruch, fino a quel momento un positivista radicale, all'interno del saggio "Ingiustizia legale e diritto sovra legale", non c'è riferimento al diritto naturale o alla giustizia. Egli elabora proprio un criterio per risolvere il conflitto tra validità e giustizia. Criterio che ci permette di salvare l'architettura del positivismo giuridico senza rinunciare a considerare la giustizia.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 8 DEL 16/10/2024

Allora il tema di cui stavamo discutendo é proprio il conflitto tra la validità e la giustizia.

COME NE VENIAMO FUORI?

Se abbiamo trasferito in realtà il ragionamento che avevamo fatto del guerriero, cioè il tema che il guerriero deve essere valoroso, avevamo sostituito nel nostro ragionamento il concetto di guerriero con il concetto di ordinamento.

Un sistema di norme di un ordinamento che voglia dirsi giuridico, deve essere minimamente giusto.

Questo tipo di ragionamento fu elaborato da Gustav Radbruch nell'immediato dopo guerra, ed è stato un'altra delle elaborazioni teoriche che permette, in realtà, di non aderire pienamente ad una tesi rigorosamente positivista che non ci avrebbe permesso di rispondere pienamente alle richieste di giustizia di tutti gli individui danneggiati dall'ordinamento giuridico fascista.

Ma dall'altra parte ci permette di non precipitare con la mente all'interno di una visione del diritto a caratteri pienamente giusnaturalistico.

DOMANDA: Perché, come possiamo declinare meglio questo tipo di ragionamento nel momento in cui ci muoviamo dall'ambito fenomenologico all'ambito giuridico?

Che vuol dire che l'ordinamento giuridico per essere tale deve necessariamente conservare un minimo di giustizia?

Cosa vuole dire Radbruch in questo senso?

Radbruch conia quello che nell' ambito filosofico e giuridico sono chiamate formule di

Radbruch, che sono due criteri per risolvere un caso in cui si crei un conflitto tra validità e giustizia, come nel caso visto all'inizio della lezione.

DOMANDA: Che accade nel momento in cui si verifica un conflitto tra validità e giustizia e perché non ci troviamo dinanzi ad una soluzione che pesca all'interno dell'arsenale teorico del giusnaturalismo?

Semplicemente perché Radbruch Pensa che nel momento in cui si verifica un conflitto tra validità e giustizia, Prevale sempre la validità.

Fintanto che c'è una norma valida e questa norma presenta dei livelli di giustizia non intollerabili, la norma può essere intesa più o meno giusta e può investire una dimensione valutativa diversa, (che cosa sia giusto di quale sia il concetto di giustizia) in tutti questi casi la giustizia non è un criterio per poter derogare alla validità, poiché prevale sempre la tesi positivista che ammette che la giustizia non è rilevante nella mia risposta del perché seguire le regole.

Perché seguire le regole?

perché sono tradotte in norme, dunque perché c'è la validità.

Fintanto che ci sono norme più o meno giuste, ma valide, nel caso in cui si verifichi dinanzi il giudice un conflitto tra validità e giustizia, non esiste la possibilità di valutare quelle norme da un punto di vista del contenuto, poiché se un ordinamento giuridico è valido e le norme sono state prodotte in maniera conforme al criterio di produzione e validità, le norme devono essere seguite.

Caso particolare si presenta nella seconda formula di Radbruch, Nel caso di conflitto tra validità e giustizia prevale sempre la validità tranne nel caso in cui l'ordinamento giuridico sia talmente ingiusto, cioè non conservi quel minimo di giustizia tale da poter considerare quel sistema di norme come un sistema di diritto e non un sistema criminale.

Dunque c'è un livello, dice Radbruch, di intollerabilità che stabilisce di far rientrare dalla finestra la giustizia che avevamo cacciato da fuori, ma è l'unico caso in cui noi possiamo ricorrere al tema della giustizia, quando proprio il contenuto di quelle norme dell'ordinamento é intollerabile e palesemente il contenuto è antigiuridico o come nel caso dell'ordinamento giuridico nazista, contro-giuridico.

In quel caso il positivismo giuridico deve cedere il passo alla visione in cui la giustizia travolge la validità.

L'idea di Radbruch, sarà un'idea seguita da moltissimi positivisti giuridici della seconda parte del novecento, Il positivismo giuridico a partire dalla seconda guerra mondiale si dividerà in due correnti

-Positivismo giuridico inclusivo, colui che tollera e include un concetto minimo di giustizia.

-positivismo giuridico esclusivo, visione del positivismo giuridico che resta sui suoi passi.

Negli anni 60, Kelsen si pone nuovamente il problema della giustizia e scrive un bellissimo libro che si chiama "il problema della giustizia".

Ma la giustizia davvero non riguarda il diritto?

Kelsen risponde con due argomentazioni:

1. Kelsen inizia da Aristotele e finisce ai moderni contemporanei, e fa una disamina dal concetto di giustizia, concludendo che il concetto di giustizia è un concetto relativo e soggettivo. Per tale motivo è inidoneo a formare una teoria oggettiva del diritto.

2. Non solo non esiste un concetto univoco di giustizia, ma è auspicabile che resti tale e quindi faccia parte della politica del diritto e non della scienza giuridica. Se L 'uomo potesse ritenere di possedere un concetto di giustizia universale e oggettivo, non farebbe altro che imporlo anche agli altri attraverso l'uso della forza.

Per tale motivo Kelsen ritiene Che la giustizia debba rimanere un concetto relativo perché nel momento in cui dovesse diventare un concetto universale, sarebbe un concetto foriero di prepotenza da parte degli Stati che siano in grado di imporla agli altri Stati.

Ancora oggi Kelsen è ritornato al centro del dibattito universale rispetto al tema della giustizia universale dei diritti dell'uomo, molti giuristi consistono al tema dell'universalità e si rifanno alle tesi sulla giustizia universale di Kelsen.

Le formule di Radbuch parlano di un positivismo inclusivo, dove è ammesso all'interno di un discorso giuridico un minimo ricorso all'idea di giustizia e dunque ad elementi di diritto naturale.

Esiste un'immagine che fa comprendere come funzionino le formule di Radbuch:

Potremmo paragonare, se rovesciassimo una piramide, ad un enorme calice di cristallo.

Tale bicchiere é trasparente, ovvero il positivista si occupa soltanto di come è stato costruito il bicchiere, cioè se tutti i pezzi che formano l'involucro siano stati assembrati nel modo migliore seguendo quindi il criterio di validità.

In questo oggetto per il giurista Kelseniano è possibile versare qualsiasi cosa, poiché se il calice è ben costruito avrà la capacità di contenere qualsiasi cosa.

Tranne in un caso, poiché se dentro il calice si versa dell'acido muriatico, probabilmente l'involucro si sceglierà; questo è il senso della formula di Radbuch.

DENTRO L'OGGETTO POTRÀ ANDARE QUALSIASI COSA PERCHÉ INTERESSA SOLO IL MODO IN CUI VIENE COSTRUITO, A PATTO PERÒ CHE AL SUO INTERNO NON CI SI METTA QUALCOSA DI COSÌ CORROSIVO DA SCIOGLIERE L'INTERA STRUTTURA E E DA TRAVOLGERE IL SENSO STESSO DELLA GIURIDICITÀ DI QUEL SISTEMA DI NORME.

Le leggi razziali sono così intollerabili da travolgere la giuridicità di tutto quel sistema ovvero di tutto il calice che costituisce e forma l'ordinamento giuridico nazista.

Questa è la metafora visiva che fa comprendere come è possibile integrare il senso giusnaturalista.

Radbuch non è un giusnaturalista ma un positivista, Che però spiega un caso solo dove Non è possibile salvare attraverso la validità, ma deve entrare in gioco il tema della giustizia, poiché il contenuto è così intollerabile che quello non è più diritto e per tale motivo non è più possibile parlare di forma giuridica poiché si è dissolta.

Il problema delle formule di Radbuch é che con questa soglia minima del diritto naturale, pone il problema di una soglia rispetto a crimini contro l'umanità.

L'argomento delle formule di Radbuch è stata analizzata per esempio nei processi che hanno condannato tutti gli ex militari e capi processati per le persecuzioni a Sarajevo, tali formule anche se non citate direttamente sono tornate ad essere un tema a caldo e sentito dalla giurisprudenza internazionale.

Resta l'idea di provare ad individuare un concetto, un limite, una soglia di giustizia minima che possa essere spendibile anche nella nostra architettura senza incorrere in qualsiasi tipo di deriva soggettiva o relativista.

DOMANDA: La giustizia la possiamo radicare in un senso oggettivo e non solo soggettivo?

Per fare questo abbiamo bisogno di alcuni strumenti che abbiamo studiato, che ci possono venire in aiuto insieme ad alcuni ragionamenti svolti oggi a partire dal guerriero che deve essere valoroso.

Per Far guadagnare a questa soglia di giustizia un'oggettività che sia più possibile oggettiva, è possibile tentare di ricostruire un criterio formale procedurale che ci dica quando la norma non ha un minimo di giustizia e quando l'ordinamento non è un minimo giusto.

Abbiamo bisogno di un processo che ci aiuti ad identificare una soglia minima di giustizia senza toccare il contenuto.

In questo senso Kant potrà aiutarci, poiché abbiamo un criterio a priori per individuare come definire e individuare quella soglia minima di giustizia sia per quella che riguarda la norma, sia per quello che riguarda l'ordinamento.

Kelsen applica Kant al discorso giuridico, motivo per cui Ross lo disprezzerà poiché riterrà tutto metafisico.

Quando Abbiamo parlato di validità sintassica e l'abbiamo distinta in validità sintasseologica e validità sintasseonomica,abbiamo distinto due diverse condizioni di validità, una a posteriori e una a priori.

La validità sintasseonomica é una definizione che utilizziamo in vista semiotica, il nome sta per il concetto anche se il nome in realtà nella tradizione filosofica dice ben altro, però la validità sintasseonomica è una validità a posteriori cioè una validità posta da una norma rispetto ad un'altra norma.

Abbiamo detto che le condizioni di validità a posteriori sono condizioni di validità alla Kelsen.

La validità sintasseologica é intesa come a priori, ovvero come condizione di possibilità e impensabilitá, in questo caso significa riferire quel termine "logos" a Kant.

Il logos per noi è a priori,ovvero Ciò che non esiste sul piano dei fatti, ma esiste sul piano dei pensieri,ciò che presupponiamo norma fondamentale esista perché senza quel presupposto (categorie di spazio e tempo) Non saremo in grado di pensare all'esperienza giuridica.

Conosciamo una validità che riguardi le singole norme intese come atti linguistici?

La semiotica si divide in tre Opere:

1. Semantica
2. Pragmatica
3. Sintattica

La semantica studia il significato dei segni, la pragmatica il modo in cui noi usiamo i segni e in particolar modo studia le condizioni di validità dei nostri atti di linguaggio, la sintattica studia invece il modo in cui i segni e gli atti stanno insieme.

La sintattica del diritto é l'ordinamento, la struttura, che tiene insieme tutte le norme giuridiche.

La pragmatica sono invece le condizioni di validità che riguarda il singolo atto di linguaggio con cui noi produciamo le norme.

Le norme sono delle proposizioni linguistiche.

CI SONO DELLE CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE NORME INTESE COME ATTI DI LINGUAGGIO?

(Es.) comprendiamo se ci sono delle condizioni di validità a priori dell'atto di linguaggio della promessa.

"Io vi prometto di essere stato qui la settimana scorsa", ha senso o non ha senso?

Non ha senso, poiché è una cosa già accaduta.

"Io vi prometto che settimana prossima faremo lezione", che differenza c'è tra questi due atti linguistici e le due modalità in cui è stato promesso qualcosa?

Una promessa deve essere necessariamente di cosa futura, ogni atto che voglia dirsi promessa deve essere necessariamente di cosa futura.

Il dovere essere necessariamente di cosa futura, è un dovere che deriva dall'idea stessa di promessa.

Al lato della promessa deve quindi essere necessariamente rivolto verso il futuro e il dovere essere della promessa deriva dall'essenza promessa esattamente come il dovere essere un minimo valoroso (guerriero) deriva dall'idea del guerriero.

C'È UNA DIFFERENZA TRA QUESTI DUE TIPI DI PROMESSE?

Nel caso del guerriero, il dovere essere si lega al valore del guerriero, nel caso della promessa non c'è nessuna valutazione se la promessa possa essere giusta o non giusta, per tale motivo il dovere deriva dalla struttura della parola.

Possiamo definire questo tipo di dovere come una condizione di validità dell'atto di linguaggio della promessa come a priori, perché é il concetto stesso di promessa che implica il suo dover essere fatta per un tempo futuro.

Il dovere però si riferisce alla struttura grammaticale dell'atto linguistico della parola e non riguarda il valore della promessa, é quindi una condizione di validità praxeologica.

La promessa è vera se viene mantenuta, il valore della promessa è quindi essere mantenuta dal promittente nei confronti del promissario.

L'argomento lo spiega Kant nella "formazione della metafisica dei costumi", anche in questo caso il ragionamento é essenza e esistenza, la prospettiva è fenomenologica.

POSSONO ESISTERE PROMESSE CHE NON VERRANNO MANTENUTE?

La maggior parte delle promesse, probabilmente non vengono mantenute, é pensabile dice Kant, che se tutti facessimo promesse senza la minima intenzione di mantenerle, a venir meno sarebbe l'idea stessa di promessa.

Per produrre validamente la promessa ci deve essere almeno l'intenzione di mantenerla, altrimenti si tratterebbe di un atto a mentire.

É quindi possibile individuare anche per la promessa due tipi di condizioni di validitá

1. Condizione di validità praxeologica rispetto alla struttura
2. Condizione di validità praxeologica rispetto alla funzione o al valore che la promessa vuole perseguire

Sono entrambi condizioni di validità a priori.

Se la promessa viene recepita da una norma giuridica avremo delle condizioni di validità praxeonomiche.

Ogni atto linguistico già possiede delle condizioni di validità che sono condizioni a priori, queste condizioni si dividono in condizioni strutturali che riguardano la struttura stessa dell'atto di linguaggio e in condizioni valoriali, che riguardano il fine e la funzione che deve adempiere quel determinato atto linguistico.

Queste vengono chiamate condizioni praxeologiche e riguardano la pensabilità e la possibilità dell'atto giuridico.

La condizione di validità sintasseologica (norma fondamentale) è una condizione di validità a priori che riguarda Solo la struttura.

La norma fondamentale non ci dice niente del sistema, non può quindi informarci su quale sia la funzione del sistema.

Abbiamo quindi la necessità di individuare la condizione di validità a priori che riguardi la funzione del sistema, che ci dica quando quell'ordinamento è giusto e che ci aiuti ad individuare in maniera trascendentale quella soglia di giustizia che ci permette di identificare quell'ordinamento, come un ordinamento giuridico.

Per trovare un criterio di questo tipo si può attingere al filosofo Kant, nell'opera "per la pace perpetua", dove individua un criterio di pubblicizzabilitá delle masse.

Kant ritiene che tutte le masse (nel nostro lessico norme) che sono pubblicizzabili, risultano solo per questo minimamente giuste. Per Kant la garanzia che le norme prodotte dall'ordinamento giuridico siano minimo giuste é il fatto che possono essere anche pubblicizzate ai destinatari senza che questi provino scandalo.

Se sono comunicabili al soggetto che le deve ricevere, vuol dire dire che il contenuto a prescindere da quello che possa essere non è così scandaloso perché chi le riceve non è sconvolto. In tal caso la pubblicità é ciò che garantisce che quella massima rispetti un minimo criterio etico, l'eticità è data dalla comunicabilità.

Accanto alla norma fondamentale abbiamo quindi un principio a priori che riguarda la funzione dell'ordinamento, che é il principio di pubblicizzabilitá.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 9 DEL 21/10/2024

Il concetto dei diritti umani è un concetto tutto sommato variabile. Se leggete un libro famoso di Norberto Bovio chiamato "l'età dei diritti", Bovio dimostra come i diritti cambiano e abbiano una loro evoluzione, anche i diritti fondamentali si sono evoluti nel contenuto, nel significato e nella definizione.

Come facciamo ad elaborare una teoria del minimo di giustizia che sia depurata da ogni scoria di soggettività e abbia un fondamento oggettivo? Perché sia fondata questa teoria dev'essere necessariamente rintracciare in un criterio a priori. Come facciamo ad identificare questo criterio a priori? Ci siamo affidati alla semiotica del linguaggio normativo, ovvero alla scienza che studia i segni attraverso cui parlano le norme. Questa semiotica si chiama deontica filosofica. Se qualcuno si imbatterà mai in un testo di deontica filosofica saprà che stiamo parlando di semiotica del linguaggio normativo. Questa semiotica si divide in 3 aree: la semantica, la pragmatica e la sintattica.

La semantica riguarda il significato delle norme; la pragmatica l'uso che facciamo dei segni e la sintattica il modo in cui i segni costruiscono un discorso, ovvero la logica che li tiene insieme e permette ai segni di significare. Abbiamo rintracciato partendo dalla pragmatica una serie di validità a priori, ovvero la condizione di validità praxeologica in cui abbiamo studiato l'atto della promessa poiché ogni promessa dev'essere di cosa futura. Qui è un dover essere necessario e significa che ogni promessa affinchè sia tale deve necessariamente essere di cosa futura e deve contemplare il verbo al futuro.

È una condizione a priori che riguarda la struttura del linguaggio e non ci dice nulla sullo scopo della promessa. Condizione di validità che riguarda anche il fine per cui noi promettiamo qualcosa, ma in realtà l'interesse che ha qualcuno nel farsi promettere qualcosa da noi è nella nostra prevedibile affidabilità nel mantenere una promessa. Abbiamo detto che esistono, però, promesse non mantenute, il problema è distinguere tra il "senza" e l'esistenza". Possono esistere una marea di promesse che non vengono mantenute, non è pensabile una promessa che sia fatta senza la minima intenzione di essere mantenuta perché quella non sarebbe una promessa, bensì un atto linguistico di altra natura. Anche qui abbiamo ricavato una condizione di validità che deriva dall'idea stessa dell'atto, cioè la promessa che però non riguarda più semplicemente la struttura di quell'atto, ma riguarda la funzione che quell'atto vuole realizzare. In entrambi i casi noi ricaviamo una condizione a priori, quindi una condizione slegata da un'esperienza contingente e sensibile, però queste due condizioni di validità parlano di due fenomeni diversi. La prima si limita ad affermare come deve

necessariamente essere dal punto di vista linguistico un atto che voglia dirsi una promessa. La seconda si interroga sul valore che noi vogliamo realizzare con la promessa. Cosa vuoi fare promettendo qualcosa? Vuoi adempiere un obbligo verso una persona spostando il tempo futuro. Se però prometti senza la minima intenzione di realizzare la promessa è l'idea stessa di promessa. Dunque questi dover essere sono dei dover essere a priori presupposti perché derivano dall'idea stessa di promessa. La pragmatica considera, oltre a queste condizioni, quelle praxeonomiche, cioè quelle condizioni che sono poste da altre norme e da altri tipi di linguaggio nei confronti dell'atto linguistico della promessa.

Nell'ambito giuridico la promessa effettuata dal minore non viene considerata giuridicamente rilevante perché c'è una norma imposta da altra norma. Lo stesso tipo di ragionamento lo abbiamo applicato nella validità sintattica con una condizione di validità a priori che abbiamo chiamato condizioni di validità sintasseologiche e anche qui abbiamo il sunto tra condizioni di validità rispetto alla struttura dell'ordinamento e condizioni di validità sintasseologiche rispetto alla funzione dell'ordinamento. Rispetto alla struttura la condizione di validità sintasseologica è sicuramente la norma fondamentale, condizione a priori e presupposta e che non dice nulla sul fine dell'ordinamento, è solo il presupposto meramente logico-trascendentale che ci permette di chiudere il sistema e di renderlo possibile e pensabile. La norma fondamentale è una condizione di validità che deriva dall'idea stessa di ordinamento, se non fosse altro che senza la norma fondamentale l'idea di ordinamento viene meno, cioè non è né possibile né pensabile. Questa condizione di validità non ci dice nulla rispetto alla struttura dell'ordinamento.

Il ragionamento per identificare la condizione a priori trova luogo nel secondo tipo di condizioni di validità a priori sintattica perché accanto ad una condizione di validità a priori che ci dice oltre che alla struttura dell'ordinamento è possibile identificare anche una condizione di validità sintasseologica a priori dell'ordinamento rispetto alla funzione dell'ordinamento, quindi è da questa funzione che possiamo capire se è un ordinamento giuridico o no, cioè se conserva una condizione minima di giustizia, anche qui però abbiamo necessità di individuare un criterio a priori, un criterio formal-procedurale e lo andiamo a prendere da Kant. Nell' "Opera per la pace perpetua" Kant menziona il criterio trascendentale del diritto pubblico, un criterio di pubblicizzabilità delle massime (le norme), ovvero una norma che ha un contenuto non è pubblicizzabile se non è nemmeno pubblicizzabile all'esterno e quindi il contenuto di quella norma non garantirà il rispetto di un minimo di giustizia. Un criterio diverso da quello di Radbruch che si affida al contenuto dei diritti umani o fondamentali vigenti in una determinata epoca storica. Kant non fa riferimento al contenuto, ma verifica a priori se quella norma conservi un minimo di giuridicità, dunque in questo caso la condizione di validità a priori non si riferisce alla struttura dell'ordinamento, ma alla sua funzione, questo criterio viene detto ius publicum.

DOMANDA: Che problemi restano nella costruzione della teoria della giustizia?

Nonostante l'individuazione di un criterio a priori che però è un criterio sempre formal-procedurale, quindi è un criterio che a sua volta dice poco sul contenuto delle singole norme e, invece, si mantiene il problema dell'interpretazione.

Pensate al processo di Norimberga, se Kant ci dà un criterio a priori, ma all'interno del criterio noi abbiamo il livello minimo di giustizia, ma il tema della giustizia differenzia dal tema della validità, che è una proprietà logico-formale. Il tema della giustizia, anche nel momento in cui lo andassimo ad ancorare il più possibile in una visione a priori lascia sempre margini all'interpretazione di chi applica le norme, è sempre il prodotto di un'interpretazione, almeno nel senso moderno della giustizia. Quando oggi si parla (e Kant è il primo a farlo) di giustizia procedurale, che è un modello

che si basa sui criteri, sulle forme e sull'interpretazione e su una visione moderna della giustizia ed è il frutto di un'evoluzione rispetto ad un concetto sostanziale della giustizia (ciò che è giusto e ciò che non è giusto). Anche la giustizia ha una prospettiva gius-naturalista; c'è una parte significativa del positivismo giuridico contemporaneo che è il positivismo inclusivo, ovvero che ammette al suo interno il recupero di un minimo di giustizia. Quasi tutti i giuristi contemporanei di area anglosassone sono legati a questo tipo di visione e sono legatissimi alla decisione giurisprudenziale, che è sempre frutto di un'interpretazione e contempla sempre il riferimento ad un livello minimo di giustizia. Per scavare all'interno di questa visione contemporanea di giustizia formal-procedurale ci avventuriamo nella ricostruzione del concetto antico di giustizia attraverso la contrapposizione tra due figure che non appartengono né al dibattito filosofico né a quello giuridico, ma appartengono agli ambiti letterali e teatrali. Queste due figure sono Antigone e Porzia. Mi soffermerò sul concetto di giustizia che emerge dall'Antigone di Sofocle. Tutti i temi di cui abbiamo discusso sono contenuti nella Tragedia di Sofocle e in particolare nell'Antigone. La figura di Antigone e Porzia nasce da un giurista italiano del secolo scorso di nome Tullio Ascarelli, che scrive un saggio dedicato ad Antigone e Porzia rileggendo la Tragedia di Sofocle e la Commedia di Shakespeare utilizzando queste due figure per indicare due diversi modi di intendere la giustizia. Nella Tragedia di Antigone il conflitto insanabile finisce in tragedia e culmina con la morte di Antigone e dal punto di vista giuridico Ascarelli identifica nel conflitto fra la volontà di Antigone di seppellire il fratello e l'editto di Creonte il conflitto tra l'ordine naturale e il diritto positivo di Creonte. La giustizia secondo la propria coscienza non trova alcuna mediazione con la giustizia che viene imposta dal legislatore (Creonte). Dunque un conflitto insanabile tra due ordini in cui in entrambi i casi ci si scontra tra il contenuto prescritto dalla coscienza di Antigone e il contenuto dell'Editto di Creonte; è uno scontro irrisolvibile poiché avviene tra due norme che hanno un contenuto opposto. Questa è la visione classica e antica del diritto. La teoria giusnaturalista dice che la norma non va seguita se non rispecchia il valore extragiuridico e in questo caso il giudizio di valore di Antigone rispecchia perfettamente il ragionamento di un giusnaturalista. Il ragionamento è tanto inconciliabile che sfocia nella morte della protagonista. Anche Creonte si appella all'ordine naturale, quindi non si può parlare totalmente di diritto positivo, tuttavia avviene il passaggio attraverso la formalizzazione della prescrizione, che manca in Antigone. Antigone davvero decide di non seguire la regola solo perché pensa che essa violi il proprio diritto naturale e cosa si intende per diritto naturale? Hegel ha scritto una serie di pagine sull'Antigone in cui ragiona sul cosa giustifica il non voler seguire la regola, ovvero in che cosa si sostanzia l'appello alla vita di Antigone ed Hegel dà un inclinazione particolare affermando che Antigone agisce sulla base di un diritto non scritto e che scaturisce dai legami famigliari, ovvero quello che oggi chiameremmo diritto consuetudinale, ovvero fatto di azioni che si ripetono nel tempo e che sono dei comportamenti che si instaurano all'interno di un gruppo famigliare. Hegel afferma, quindi, che il divieto di Creonte è vissuto da Antigone come un affronto rispetto a quel diritto orale che è frutto di una costante ripetizione di atti e comportamenti di un gruppo famigliare che impone alle sorelle di dare sepoltura agli altri membri della famiglia. Hegel parla anche con disprezzo di un diritto parentale al femminile dicendo che questo diritto tanto non è diritto che non è codificato, poiché Antigone non fa riferimento ad una norma scritta, bensì ad una consuetudine e quando si oppone a Creonte lo fa appellandosi a questa consuetudine affermando che questi doveri fondati sui vincoli di parentela derivano direttamente dalla legge degli dei. Hegel poi dice che la trasgressione di Antigone è ancora più grave della colpa di Edipo perché mentre Edipo non è cosciente di violare il tabù dell'incesto Antigone rivendica davanti a Creonte le sue ragioni non fondate su un diritto pubblico, ma su norme che nascono da consuetudini famigliari e che oggi non sono più opponibili rispetto al diritto statale. Per Antigone non c'è altra via che la morte perché è colei che non solo trasgredisce, ma rivendica la sua trasgressione rispetto alla legge statale. Negli anni 70 Jacques Lacan critica la versione di Hegel, ma giunge alle stesse conclusioni.

Lacan è attratto dalle motivazioni per cui Antigone decide di non seguire la regola e secondo lui Antigone è una figura mossa da un desiderio che si traduce sin dall'inizio in una pulsione di morte, ovvero che Antigone è morta dall'inizio della Tragedia, poiché segna il suo destino nel momento in cui oppone il suo desiderio di dare sepoltura al fratello richiamandosi alle leggi dei morti e non alle leggi dei vivi e questo essere immane di Antigone nasce dal muoversi ai confini dell'ordine simbolico della comunità.

Secondo Lacan la costruzione dell'ordine sociale nasce nel momento in cui all'interno degli uomini si istituisce un simbolo che per lui è il padre, che garantisce con la sua voce la legge e l'ordine sociale e permette che questo ordine si tramandi di generazione in generazione. L'ordine simbolico nasce col divieto dell'incesto e dalla legge del padre. Antigone rifiuta l'ordine simbolico, rifiuta la legge del padre di Edipo (che le scaglia la sua maledizione) e lo fa perché appellandosi alla legge degli dei rifiuta le leggi dei vivi e l'idea è ancora più interessante rispetto a quella di Hegel poiché il diritto naturale non è più un precetto extragiuridico, ma è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione ed è un ordine basato sul diritto consuetudinale che va a contrasto col diritto positivo di Creonte. Antigone per affermare la propria individualità si appella a questo ordine divino rifiutando le convenzioni attraverso cui si è costituita la polis con l'Editto di Creonte. Quindi Lacan afferma che dal momento in cui Antigone si autoesclude fin dall'inizio dalle convenzioni sociali e linguistiche su cui si basa l'ordine sociale scegliendo in quel momento di morire poiché il suo destino vira alla legge dei morti e ci dà un significato di diritto naturale diverso rispetto a come noi intendiamo la natura delle cose. Il tema, quindi, è quello dei simboli che si tramandano di generazione in generazione e che garantiscono l'ordine sociale che Antigone rifiuta per affermare il proprio diritto, ovvero la propria volontà misericordiosa verso il fratello. Secondo Lacan Antigone deve necessariamente morire. Queste interpretazioni sono servite poiché per esempio Judith Butler vede in Antigone la figura che riesce all'interno dei vincoli parentali a confondere i ruoli. C'è chi intravede, invece, l'amore incestuoso nei confronti del fratello. Queste teorie leggono tutte diversamente il perché Antigone trasgredisce le regole e quando si fa riferimento ad un ordine naturale a tutto si fa riferimento fuorchè ad un ordine immutabile dove, infatti, vediamo sia la legge dei morti che quella parentale e si va ad interpretare il perché Antigone decide di non seguire la regola. Antigone ci dà una risposta drastica al perché seguire la regola, ma la nascita del discorso normativo nasce con questo dilemma e il pensiero giusnaturalista riduce la risposta a questa domanda.

Con Shakespeare nel Mercante di Venezia la situazione è più goliardica e meno drammatica anche perché il concetto di giustizia di Shakespeare subisce una torsione diversa rispetto al concetto tragico di Antigone. Il tema è la storia di un prestito usuraio andato male. Ci sono due giovani fidanzati, Porzia e Bassanio che vogliono convolare a nozze e non hanno il denaro sufficiente per pagare le nozze e Bassanio chiede ad Antonio, un suo amico commerciante di Venezia di finanziare il matrimonio e lui chiede a sua volta un prestito a Shylock, un ebreo di Venezia. Shylock acconsente a fornire il prestito alla condizione che se la somma non gli fosse stata restituita entro un determinato periodo di tempo avrebbe avuto il diritto di tagliare la libbra di carne di Antonio più vicina al cuore. Tutto va per il verso sbagliato e Shylock si presenta per ottenere la sua ricompensa secondo il contratto pattuito. Si va dinanzi ad un giudice e qui entra in scena un avvocato che interviene tirando fuori un'argomentazione stravagante: rileggendo il contratto il giurista dice che nel contratto letteralmente si prevedeva l'asportazione della libbra di carne nel caso di non restituzione del denaro, ma non si parla di una goccia di sangue, quindi se Shylock riesce ad estrarre la libbra di carne senza versare neanche una goccia di sangue ben venga, ma se dovesse versare anche solo una goccia di sangue dovrebbe essere applicato l'editto degli stranieri che prevedrebbe guai per chi, straniero, dovesse versare anche solo una goccia del sangue di un veneziano. Dopo tutta una serie di argomentazioni si giunge all'assoluzione anche perché tutti odiavano il mercante ebreo di Venezia in quanto usuraio. Il giurista alla fine dell'arringa si toglie il mantello e si scopre essere Porzia, che per salvare

il migliore amico del marito si è costituita in giudizio ed è intervenuta con quest'argomentazione che si basa su una norma scritta, che a differenza della rivendicazione di Antigone, non si basa, quindi, su un giudizio di valori. Si crea quindi una giustizia procedurale poiché nella sostanza il mercante ha ragione, tuttavia proceduralmente siccome manca l'espresso riferimento al sangue non può procedere. Porzia effettua una lettura formal-procedurale basata sull'interpretazione della legge positiva e giunge ad una conclusione capace di restaurare un ordine di giustizia. Non c'è, quindi, una contrapposizione tra due ordini di pensiero, qui tutto avviene all'interno dell'ordine positivo. Quando facciamo riferimento ad un criterio minimo di giustizia stiamo ponendo un criterio procedurale attraverso cui leggere le norme e la funzione di un ordinamento giuridico. Non è l'operazione che fa Antigone, mentre Porzia lo fa ed inaugura un concetto di giustizia moderno, legato al come poter ottenere giustizia ponendo dei criteri formal-procedurali attraverso l'interpretazione ed una visione positivista del concetto di giustizia. Non c'è nessun riferimento all'ordine naturale delle cose, tutto avviene all'interno del discorso giuridico e all'interpretazione che porta ad un'analisi formal-procedurale. Entrambe sono opere teatrali e ci fanno capire quanto sostanzialmente il diritto sia una messa in scena. Il diritto nasce "nelle piazze" banalmente quando ci sono due persone ed un terzo soggetto e le due persone ricostruiscono ciò che è accaduto nel modo più fedele possibile secondo il proprio fine per ottenere ragione dal terzo soggetto. Interessante è il fatto che sia Antigone che Porzia sono figure, femminili, che però confondono il genere, seppur in maniera diversa.

La teoria di Kelsen presenta 3 problemi: il tema della giustizia, di cui siamo riusciti a capirci qualcosa in più; la funzione delle norme (il diritto è solo una tecnica di regolazione sociale?); il tema della soggettività del diritto (il soggetto nella costruzione del diritto è davvero soltanto un mero centro di imputazione di interessi?).

DOMANDA: Il diritto, davvero, è solo e soltanto prescrivere?

A mio modo di vedere se questa risposta poteva essere esaustiva fino agli anni 70 quando Kelsen pubblica i suoi ultimi lavori; nel mondo attuale dire che il diritto serve solo a prescrivere è una risposta controintuitiva rispetto a ciò che abbiamo attorno a noi. Il diritto è quel linguaggio che costruisce la nostra realtà, tutta quella in cui viviamo. Noi viviamo in un mondo costruito da regole. Dobbiamo partire da una constatazione linguistica.

DOMANDA: "l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" è una proposizione descrittiva?

È una norma che ci permette di identificare il nostro Stato, in questa proposizione, però, c'è l'essere e non il dover essere, possiamo affermare che sia una proposizione sempre vera, ma che viene disposta per norma di legge e Kelsen definisce questa come un "frammento di norma" e, anche se c'è il verbo essere essa ci dice come lo Stato deve essere. Su questa proposizione possiamo anche e soprattutto dire che sia una norma che costituisce l'ordinamento italiano come una Repubblica democratica fondata sul lavoro, cioè ci dice che quello è un ordinamento giuridico che deve essere una Repubblica democratica fondata sul lavoro e che è costituito come una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 10 DEL 23/10/2024

Qual è la differenza su cui ci siamo soffermati a proposito di Porzia e Antigone? Perché la visione della giustizia di Porzia è una visione che alla fine trova un principio di mediazione che non trova Antigone, che dal punto di vista teatrale e drammaturgico permette di svoltare tutto sommato la commedia shakespeariana giudiziale in una commedia mentre Antigone finisce in tragedia?

Dicevamo che i due concetti di giustizia sono diversi: uno è un concetto di carattere SOSTANZIALE, l'altro è un concetto a carattere FORMALE-PROCEDURALE.

Mentre Antigone rivendica la giustizia sulla base di una sua pretesa, che si fonda su una richiesta che risulta essere completamente antitetica rispetto a quella di Creonte, in Porzia invece non c'è lo scontro fra due ordini di ragione: Porzia utilizza il "DIRITTO POSITIVO" , ossia il patto che legge e rilegge e che interpreta poi diversamente.

Quindi la giustizia moderna, che inaugura almeno metaforicamente Porzia, è una giustizia che si basa su un criterio formale-procedurale e che è il risultato di un PROCESSO DI INTERPRETAZIONE. Ecco perchè si giunge alla fine ad una composizione degli interessi, perchè si interpreta il patto fintanto che non si trova il modo per ottenere o per fare giustizia.

Rapidamente soffermiamoci sul tema dell'interpretazione: che cosa significa interpretare una norma giuridica? Perchè poi abbiamo detto che Porzia interpreta e che quindi interpretando quella norma riesce a mettere in scacco la pretesa di Shylock. Se ci fossimo basati sul significato letterale del fatto, Porzia avrebbe dovuto obbedire per ovvie ragioni a Shylock. Porzia invece, attraverso una sua rilettura del significato di quella disposizione, di quel patto, riesce evidentemente a individuare un significato ulteriore.

Quindi che cosa significa interpretare una norma? Quando si devono interpretare le norme?

Interpretare una norma significa applicare fondamentalmente la fattispecie generale ed astratta che è contenuta all'interno della norma giuridica al caso concreto.

Torniamo quindi alla nostra "madre di tutte le norme" che utilizziamo nei nostri ragionamenti: "E' vietato fumare".

Tale norma prevede tutti i possibili casi in cui qualcuno possa fumare, quindi è vietato fumare le sigarette, come il sigaro, come la pipa, a maggior ragione sostanze stupefacenti = quindi la fattispecie è generale e astratta perché tenta di coprire il maggior numero di casi possibili. Il legislatore è così che parla. Costruisce norme che sono rivolte a una maggioranza, in questo

caso di casi concreti, e questa maggioranza deve essere specificata di volta in volta da parte del giudice.

Abbiamo detto però che l'ordinamento giuridico è un sistema dinamico, ciò significa che mentre in un sistema statico c'è una prima serie di previsioni che si incastrano l'una con l'altra secondo il principio di deduzione logica, dunque si tratta di un sistema fisso, immodibile ed immutabile che vale per tutti i casi che possono essere ricondotti alle fattispecie considerate all'interno di quel determinato sistema, nel diritto, inteso come sistema dinamico non funziona così: il diritto deve avere la norma che espressamente prevede e qualifica quel fatto come giuridicamente rilevante. La norma seleziona quindi una

serie di fatti sociali o naturali e assegna loro una qualificazione deontica o una qualificazione giuridica.

Che cosa accade nel momento in cui si producono fatti socialmente rilevanti che però non sono espressamente previsti dalla norma?

Questo può accadere ad esempio perché manca completamente la norma e in questo caso si parla di LACUNA DEL DIRITTO, cioè in questo caso l'ordinamento è lacunoso poiché non contempla all'interno delle fattispecie previste dalle sue norme la possibilità di regolare quel determinato caso.

Questo succede spessissimo, soprattutto è un tema di ampia attualità perché, specialmente nel corso di questi ultimi decenni, con lo sviluppo tecnologico o con lo sviluppo sociale che ha reso possibile tutta una serie di azioni, operazioni di processi, mentre la società accelerava in un senso, il diritto restava cristallizzato in un altro poiché il legislatore faticava ad adeguarsi ai mutamenti e alle metamorfosi della società accelerata per esempio dal progresso tecnologico. Pensate a tutti i problemi che si stanno creando oggi sul tema dell'intelligenza artificiale e sul tema del diritto informatico, inerente alle regolamentazioni degli spazi virtuali sulla rete e anche lì improvvisamente i legislatori nazionali e sovranazionali si sono trovati dinanzi a realtà che difficilmente rientravano nelle fattispecie che avevano finora costruito ma dove si scontrano interessi e molti dei soggetti coinvolti, che vedevano pregiudicati i propri interessi, ricorrevano dinanzi a un giudice ed il giudice come poteva decidere in questi casi? Perché all'interno del nostro ordinamento giuridico, per esempio, il legislatore costruisce le fattispecie; al giudice spetta di applicare, interpretando quelle fattispecie, le norme al caso concreto. Applicando la norma al caso concreto si arriva alla decisione giurisprudenziale, al diritto giurisprudenziale che è il diritto evidentemente costituito e formato non dalle norme intese in senso astratto e generale, ma da decisioni, sentenze che sono gli strumenti con cui i giudici applicano le norme astratte al caso concreto. In molti di questi casi si verificava l'impossibilità da parte del giudice di effettuare questo tipo di operazione semplicemente perché il legislatore non aveva inserito all'interno dell'ordinamento giuridico la norma valida che qualificava quei fatti dal punto di vista deontico o giuridico.

E dunque il giudice come poteva decidere in questi casi? Attraverso l'interpretazione.

E' infatti una sciocchezza dire "i giudici devono limitarsi ad applicare la legge" poiché "limitarsi ad applicare la legge" significa sempre interpretarla. Non c'è l'automaticità dell'applicazione di una legge. Per altro le norme di cui si deve tener conto nelle decisioni sono a loro volta norme nazionali che dipendono gerarchicamente da ordinamenti sovraordinati (pensate all'ordinamento dell'Unione Europea) quindi immaginate il lavorio di interpretazione

che c'è sia nell'ambito della struttura gerarchica di validità sia nell'ambito della circoscrizione del caso concreto da applicare alla norma generale e astratta.

Ad esempio, l'articolo 12 delle disposizioni preliminari del nostro codice civile stabilisce tutta una serie di criteri che possono essere utilizzati dai giudici quando il caso concreto è dubbio su quale norma, quale fattispecie andare ad applicare. Questo articolo suggerisce di privilegiare sempre l' INTERPRETAZIONE LETTERALE della norma. Prima di tutto quindi andiamo a leggere la norma e vediamo se il caso concreto può rientrare nella lettera della norma, cioè nel significato che immediatamente risulta essere evidente seguendo la costruzione letterale del linguaggio del legislatore. Quasi mai l'interpretazione letterale risulta essere soddisfacente o idonea a riuscire ad incastrare il caso concreto all'interno della

fattispecie generale e astratta, soprattutto quando non c'è una norma che espressamente regola proprio quel caso concreto.

C'è un filosofo del diritto della seconda metà dell'Ottocento, Rudolf Von Jhering, che fa un esempio particolarmente interessante sul tema dell'interpretazione delle norme. Von Jhering racconta questo episodio: in un paese del Danubio c'è una piccola stazione ferroviaria. All'interno di questa stazione c'è una sala d'aspetto, davanti alla quale c'è una scritta in cui c'è scritto che è vietato l'accesso ai cani all'interno della sala d'aspetto. Si presenta una persona con al guinzaglio un enorme pastore maremmano. Qualcuno protesta e chiede l'applicazione della norma. In questo caso c'è la norma espressamente prevista e dunque è evidente che ci sia la piena sussunzione del caso concreto all'interno della norma generale ed astratta. (primo caso)

Tuttavia (proprio come per la norma "E' vietato fumare") le fattispecie sono generali ed astratte, i casi però che si possono verificare possono essere infiniti.

Mettiamo il caso che in sala d'aspetto si presenti un signore con al guinzaglio un cucciolo di orso. La fattispecie non prevede il divieto di accesso per gli orsi eppure qualcuno nella sala d'attesa protesta. Qui la fattispecie generale ed astratta non c'è. Si presenta quindi un caso che secondo l'articolo 12 presenta analogie rispetto al divieto posto espressamente dal legislatore. (secondo caso)

Quindi mentre nel primo caso l'interpretazione letterale ci salva, nel secondo caso la norma generale ed astratta non fa riferimento al caso dell'orso quindi se ci muoviamo nell'ambito di un'interpretazione letterale tutto sommato dovremmo dire che il soggetto può tranquillamente attendere il suo treno con al guinzaglio l'orso.

Dicono però i giuristi che quando si presentano casi simili, bisogna molto spesso andare a vedere qual è la ratio della norma, quindi effettuare probabilmente un' INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA, cioè andare a vedere qual è la finalità che il legislatore voleva raggiungere ponendo quella fattispecie generale ed astratta. Forse il caso concreto dinanzi al cui mi trovo corrisponde alla stessa ratio.

Perchè si vieta l'accesso ai cani? Evidentemente perchè c'è chi può avere paura.

Ma se qualcuno ha paura del cane, che non è un animale aggressivo di natura, a maggior ragione potremmo dire che potrebbe aver paura dell'orso che ha un livello di pericolosità sociale decisamente più alto rispetto al cane. Se la ratio è questa allora si può utilizzare

un'interpretazione analogica: la norma non c'è, ma io posso far rientrare quel caso all'interno di una fattispecie generale e astratta che regola casi simili, perché la ratio che c'è alla base di questa norma è la stessa. Anzi qui è rafforzata la ragione per cui io non devo far accedere l'orso, se la ragione che sta alla base della norma "è vietato l'accesso ai cani" è la sicurezza degli altri passeggeri, probabilmente il legislatore non poteva neanche immaginare che qualcuno si presentasse con al guinzaglio un orso. Ma a maggior ragione io applico la medesima norma al caso concreto perchè quel caso non fa che esasperare le ragioni di sicurezza che sono alla base della norma che vieta l'ingresso ai cani.

In questo caso vedete la fattispecie non c'è. Cioè il legislatore non ha normato esattamente quel caso, ma ricostruendo la ratio alla base di quella norma posso estendere l'applicazione della norma interpretandola sulla base del fine per cui quella norma è stata posta.

Ci possono essere anche casi che sono però simili per differenza.

Poniamo un caso diverso, ma simile. Immaginiamo che si presenti in sala d'attesa una signora non vedente con al guinzaglio un cane guida. Che si fa in questo caso?

Come interpretiamo la norma? Anche qui l'interpretazione teleologica ci suggerisce di guardare la ratio. Se la ragione per cui il legislatore ha posto quella norma è di tutelare gli altri passeggeri dalla ipotetica pericolosità del cane è evidente che qui non siamo dinanzi a un cane pericoloso, ma a un cane che anzi svolge una funzione di soccorso e di carattere sociale. Quindi qui l'interpretazione non è per analogia, ma per differenza. E' vero che il caso è lo stesso, ma il caso concreto presenta significative differenze rispetto a quello generale e astratto contemplato dalla norma. E dunque io posso interpretare diversamente la norma. L'idea è sempre quella di evitare, scavalcare l'interpretazione letterale e affidarsi all'analisi della ratio, della ragione che è alla base della norma.

C'è un terzo modo di interpretare le norme.

Mettiamo il caso che due persone stipulano un patto macabro (come quello tra Antonio e Shylock nel caso di Porzia). Pongono in essere dunque un contratto fra di loro che ha un oggetto scandaloso. Come mi regolo dinanzi a quel contratto? E' ammissibile o no?

La terza possibilità di interpretazione è quella che si chiama INTERPRETAZIONE DOGMATICA o SISTEMATICA, cioè guardo non tanto i casi rispetto alle norme, ma le norme rispetto ad altre norme che possono essere i principi generali dell'ordinamento, le norme Costituzionali. Oppure, dato che il contratto è un tipo di negozio giuridico, mi vado a vedere la disciplina del negozio giuridico, se la disciplina del contratto non mi dice espressamente come devo regolarmi dinanzi a quel caso concreto. Svolgo una ricognizione all'interno del sistema e nelle norme di sistema e di come sono incastrate all'interno del sistema e mi rendo conto se posso evidentemente ricavare dei principi utili per capire come regolarmi nel caso concreto e che tipo di disciplina applicare al caso.

Alla fine le norme giuridiche, che noi finora abbiamo sempre definito come proposizioni prescrittive e sanzionatorie che esprimono schemi di qualificazione trascendentale, in realtà poi sono sì uno schema di qualificazione ma c'è sempre poi il prodotto dell'interpretazione da parte di chi applica la norma al caso concreto. Cioè quello schema poi è sempre, nel momento in cui

si passa all'applicazione della norma, interpretato e reinterpretato da parte di chi deve poi decidere sull'applicazione della norma.

Riprendiamo l'esempio da cui siamo partiti: "È vietato fumare".

La norma è generale. Come ci regoliamo nel caso in cui qualcuno utilizzi una sigaretta elettronica che non è nociva per l'altro? O nel caso in cui qualcuno debba utilizzare delle sostanze stupefacenti a basso grado per motivi terapeutici? Anche qui quella norma "E' vietato fumare" può essere forzata, interpretata rispetto ai casi concreti in maniera diversa.

Torniamo al tema precedente del divieto di accesso ai cani.

Un conto è il pastore maremmano di cui tutti hanno paura e immaginate invece uno di quei cani piccolissimi che si mettono in borsa o si tengono in braccio. Quel cane rientra o non rientra nel divieto? Perché quel cane non sarebbe pericoloso all'interno della sala. Quindi anche nella letterarietà, nel rispetto della letterarietà dell'interpretazione della norma si aprono scelte di come applicare la fattispecie generale e astratta al caso concreto, che sono volta per volta sindacabili da parte di chi è chiamato a decidere, cioè del giudice.

Porzia nel "Mercante di Venezia" di Shakespeare è il primo esempio teatrale e letterario di come la giustizia nella modernità, quindi la giustizia in ambito positivista, sia una giustizia formale-procedurale ed è sempre il prodotto di un atto di interpretazione.

Così abbiamo chiuso la parentesi sulla giustizia.

Abbiamo esaurito la prima parte che riguarda le critiche che avevamo mosso a Kelsen.

La prima critica che risultava essere evidente ai nostri occhi è sempre stata "Ma è ammissibile il diritto senza giustizia?", cioè possiamo costituire una teoria generale del diritto che non contempli minimamente il tema della giustizia? La risposta in questo caso è no.

Un minimo di giustizia deve essere presente altrimenti si perde l'essenza del discorso giuridico. C'è il rischio di pensare di continuare a parlare di diritto ma in realtà parliamo di un altro sistema normativo, che può essere addirittura contro giuridico, un pensiero che può essere criminale (se pensiamo a quello nazista).

Qual era la seconda critica che abbiamo mosso a Kelsen? Il tema delle norme primarie e norme secondarie. Ci eravamo posti la questione "L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro". Che linguaggio parla questa norma? Il dover essere c'è in questa norma? No, non c'è. Parla il linguaggio dell'essere questa norma? Apparentemente si.

Kelsen risolve queste domande in maniera furba, più che intelligente. Lui dice queste norme non sono vere e proprie norme, ma sono norme secondarie poiché tutto sommato l'essenza del discorso giuridico è la sua forza obbligatoria, per cui le norme primarie sono tutte quelle munite di sanzione. Le altre sono frammenti di norme. Tuttavia secondo la teoria generale del diritto, le norme della Costituzione sono quelle primarie. E' Kelsen che ribalta il concetto fra norma primaria e norma secondaria., poiché per Kelsen la funzione del diritto è quella di essere una mera tecnica di regolazione sociale, cioè il diritto è semplicemente un linguaggio prescrittivo-sanzionatorio che ci serve a costruire il nostro ordine sociale.

Come costruisce il nostro ordine sociale il diritto? Attraverso il timore dell'applicazione della sanzione se trasgrediamo le regole codificate come norme.

Il pensiero di Kelsen ha anche delle implicazioni che riguardano la funzione del diritto a livello teorico. Cioè davvero pensiamo che il diritto sia così poca cosa? Che sia solo un linguaggio che

ci può far paura? Siamo rimasti a Hobbes. Al concetto del Leviatano di Hobbes. In realtà come vedremo la funzione del diritto non è soltanto quella prescrittivo sanzionatoria, non ci sono dubbi che il diritto sia il linguaggio più cogente all'interno delle forme di linguaggio. Ma è anche vero che il diritto è molto di più di un linguaggio prescrittivo sanzionatorio. Il diritto è il linguaggio attraverso cui costruiamo la nostra realtà sociale (e lo vedremo con un filosofo contemporaneo John Searle). Quindi in realtà il diritto svolge una funzione molto ma molto più ampia rispetto a come la identifica Hans Kelsen.

Riprendiamo il nostro esempio "L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro". Questa non è una norma alla Kelsen, perchè non c'è uno schema di qualificazione, non c'è un fatto qualificato come illecito, non c'è una sanzione, non c'è imputazione.

Che differenza passa tra la proposizione "L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro" e la proposizione "Oggi è una bella giornata"?

Entrambe le proposizioni parlano il linguaggio dell'essere.

La prima è sempre vera, la seconda invece può essere vera o falsa.

Perché però la prima è sempre vera? Facciamo un salto nella filosofia del linguaggio, per andare a recuperare una teoria degli atti linguistici di un filosofo inglese del linguaggio che ha insegnato a Oxford nella seconda metà del 900, che si chiama John Austin (da non confondere con il padre del positivismo giuridico americano, l'omonimo John Austin, vissuto all'inizio del 900). Austin dunque scrive un libro intitolato "Come far cose con parole": lui dice che ci sono tutta una serie di cose che noi facciamo che sono fatte di parole, fatte attraverso il linguaggio. Ci sono tante azioni che noi possiamo compiere solo attraverso il linguaggio.

Facciamo degli esempi:

- "Io vi prometto che la seconda parte della lezione di oggi sarà divertente". Come faccio a promettere qualcosa a qualcuno se non glielo dico?
- "Io vi ringrazio di essere venuti oggi a lezione".

Come faccio a ringraziare qualcuno se non glielo dico?

- "Io vi giuro che non sarò clemente agli esami". Come faccio a giurare se non lo dico?
- "Io affermo che oggi è una bella giornata".

Come faccio ad affermare qualche cosa se non lo dico?

- "Io dispongo che da domani le lezioni si svolgano con le finestre aperte".

Il "disporre" è un altro verbo che indica un'azione che possiamo compiere solo attraverso il linguaggio.

Il chiedere, il promettere, il giurare, il pregare, il ringraziare, il giudicare ecc sono tutte azioni che noi possiamo compiere solo attraverso il linguaggio. Se non le dico, non posso porre in essere l'azione. Austin si rende conto, poiché lui inaugura questa branca della "filosofia del linguaggio ordinario", che finora la logica e la filosofia avevano considerato due funzioni del linguaggio che tutto sommato quotidianamente hanno una funzione marginale, ossia la funzione

descrittiva e la funzione prescrittiva, ma che tra le mille cose che ci diciamo quotidianamente, raramente descriviamo o prescriviamo qualcosa.

Tra queste due alternative si apre un mondo di atti linguistici che esprimono poi la nostra relazionalità sociale. Cioè tutti quegli atti con cui noi ci relazioniamo con gli altri sono atti che esprimono azioni che noi possiamo compiere solo attraverso il linguaggio. Allora Austin individua una terza funzione del linguaggio: FUNZIONE PERFORMATIVA (dall'inglese "to perform"), ovvero l'idea per cui per effettuare alcune azioni (performance) è necessario produrre determinate parole. Queste azioni io le posso compiere solo se le dico. Non solo, poiché si tratta di azioni che io vengo a compiere, Austin parla piuttosto che di proposizioni performative, poiché io mi approprio della proposizione e la traduco in un atto linguistico nel compimento di un'azione, di "ENUNCIAZIONE". L'enunciazione è l'appropriazione da parte di un soggetto di una proposizione, usandola. Quindi Austin parla di ENUNCIAZIONI PERFORMATIVE.

Che cosa sono le enunciazioni performative?

Sono quelle enunciazioni che compiono l'azione che dicono di compiere (ES: io ti ringrazio solo se dico di ringraziarti). In questo caso il linguaggio non esprime né un comando, né una descrizione ma costruisce qualcosa che prima non c'era (la promessa, il ringraziamento, la condanna, la preghiera, il giuramento), tutt'una serie di oggetti che si possono evidentemente costruire solo attraverso le relative parole, perciò Austin intitola il suo libro "Come far cose con parole" perché effettivamente lui si accorge che la maggioranza dei nostri scambi sociali avviene attraverso azioni che noi possiamo compiere solo se le diciamo. Dunque le enunciazioni performative hanno una funzione costitutiva rispetto agli atti che producono.

Torniamo all'esempio che abbiamo già visto:

"Io vi prometto che domani ci sarà lezione".

Nel momento in cui io proferisco la parola "io vi prometto che domani ci sarà lezione" in quel momento si è costituito un obbligo e sappiamo che attraverso il linguaggio si è costituito un

oggetto che prima non c'era e che esiste solo e soltanto attraverso la pronunzia delle relative parole che lo pongono in essere.

"Io vi prometto" è una proposizione che possiamo definire vera o falsa? Perché non è né vera né falsa? Perché è nel futuro.

Ma nel momento stesso in cui io ho detto "io vi prometto", lasciamo perdere se poi mantengo o meno la promessa, ma la promessa si è costituita?

Si, e allora quella proposizione è sempre vera rispetto alla promessa.

Se l'enunciazione performativa si costituisce validamente, l'oggetto che costituisce è sempre vero.

Tanto è vero che c'è uno studio, tra i tanti studi antropologici, di due antropologi ungheresi che si recarono sull'isola di Tonga a studiare i costumi, i comportamenti e le regole di vita di alcuni gruppi di indigeni locali. Costoro non sapevano nulla e iniziarono a osservare, così arrivarono ad una conclusione. Loro riuscirono a capire che nei gruppi di indigeni nessuno prometteva qualcosa a qualcun altro perché mancando la parola "promessa", il verbo "promettere", mancava l'idea stessa di obbligarsi con qualcun altro a porre in essere un'azione futura. Cioè il

compimento dell'azione era così legato all'idea del linguaggio che mancando la parola questo significava che in quei gruppi sociali non conoscevano l'idea di obbligarsi tra loro per il futuro, proprio perché tu puoi promettere a qualcuno se conosci la parola che ha quel significato e pronunci quella parola. Dove manca la parola, manca anche il concetto perché la cosa è fatta di parole.

Quindi che significa che possiamo "far cose con parole"?

Significa che ci sono atti sociali che noi possiamo declinare solo e soltanto come atti linguistici.

Dunque dicevamo che il contenuto di un'enunciazione performativa è sempre vero solo e soltanto nel momento in cui si produce l'enunciazione.

Qui non c'è dunque vero o falso perché non c'è corrispondenza tra il linguaggio e lo stato di fatto (per citare la teoria di Tommaso D'Aquino) in quanto lo stato di fatto è prodotto dal linguaggio.

Mentre possiamo comparare il bel tempo, che non dipende da noi, a quello che io sto dicendo, che dipende da me, "io vi prometto" l'atto del promettere si produce nel momento stesso in cui io affermo che sto promettendo. Quindi l'oggetto dell'enunciazione non è esterno all'enunciazione ma è sempre vero perché è il prodotto dell'enunciazione. L'oggetto della proposizione si costituisce nel momento stesso in cui io produco l'enunciazione perché è fatto di parole.

Produco l'atto linguistico quindi produco l'azione sociale, perciò è sempre vero. D'altronde la definizione di "performative" ci dice che l'enunciazione è performativa quando compie l'azione che dice di compiere e dunque se compie l'azione che dice di compiere, quando lo dice si verifica l'azione e dunque l'azione è sempre vera perché si è prodotta nel momento stesso in cui io l'ho detta.

Adesso facciamo un esempio diverso.

"Io vi prometto che domani ci sarà lezione".

Domani però non c'è lezione: io vi sto promettendo una cosa che domani non manterrò quindi l'oggetto della promessa si è costituito, la finalità della promessa è vanificata dal fatto che noi sappiamo che domani la promessa non ci sarà. Dunque noi iniziamo a pensare che un conto è l'oggetto della promessa, un conto è il fine che io voglio raggiungere con la promessa.

Un conto è l'atto che si produce, un conto è lo scopo che io voglio raggiungere con quell'atto.

Mi spiego diversamente: se io dovessi convocare davanti a me due di voi (uomo-donna; donna-donna; uomo-uomo) e dovessi in questo preciso istante pronunciare le seguenti parole "Io in qualità di pubblico ufficiale vi dichiaro marito e moglie; moglie e moglie; marito e marito" voi sareste legati da vincolo coniugale? La mia dichiarazione si produce? E' vera? Si, io ve lo sto dichiarando.

Ma gli effetti della mia enunciazione performativa qui si producono o non si producono? Non si producono evidentemente.

E perché non si producono?

Risponderemo alla domanda nella seconda parte della lezione.

UNIVERSO
STUDENTI

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 11 DEL 23/10/2024

Perché la mia enunciazione performativa, pur essendo vera (perché la dichiarazione si produce nel momento stesso in cui io produco l'atto di linguaggio e quindi compio la relativa azione) non ha effetti? Perché gli effetti della dichiarazione non si producono? Cosa manca? Perché non sono legittimato a produrre gli effetti perché non c'è una norma valida che mi autorizza.

Quindi, che differenza c'è tra "io vi ringrazio di essere venuti oggi" e "io vi dichiaro marito e moglie"?

La seconda ha un'implicazione giuridica. E invece qual è la differenza tra ringraziare e promettere? Il ringraziamento finisce lì, il ringraziamento rinvia ad un'obbligazione futura. Questo ci fa capire che le enunciazioni performative, mentre tutte le altre enunciazioni sono sempre vere, possono essere più o meno valide rispetto agli effetti che producono. Austin divide le enunciazioni performative in due categorie diverse. Potete scegliere la definizione di Austin o quella data dai semiotici del linguaggio. In questo caso, la definizione di Austin mi piace di più.

Austin definisce, in questo caso, enunciazioni che producono effetti a livello di word- parola- e enunciazioni performative che producono effetti a livello di world- mondo. Dunque, enunciazioni che finiscono lì- produci l'atto attraverso la parola (ringraziare)- e enunciazioni attraverso cui noi possiamo modificare il mondo. Il linguaggio incide sul mondo come il tema della dichiarazione del matrimonio, se fatta secondo la norma valida che riguarda il matrimonio. Anche la promessa, in realtà, mi obbliga a comportarmi in un certo modo. Che io possa scegliere di comportarmi in un determinato modo è un conto, ma l'obbligazione o vincolo morale c'è sempre. Dunque, non è un mero dire come il ringraziare, l'affermare, il pregare: atti che si esauriscono a livello di linguaggio.

Diverso invece è il giudicare, il disporre, il condannare, il dichiarare quando si verificano condizioni ulteriori che rendono gli effetti di quelle enunciazioni performativa come degli effetti validi. Tutte sono sempre vere. Quando si produce l'atto linguistico, si produce anche evidentemente l'oggetto dell'enunciazione performativa.

Il fine dell'enunciazione performativa chiede un qualcosa in più. Dunque, Austin distingue enunciazioni performative che operano solo al livello di linguaggio e incidono solo sulle parole o si esauriscono solo attraverso le parole e dice che quelle sono enunciazioni performative che operano a livello di word da quelle che, invece, modificano il mondo e sono enunciazioni performative che operano a livello di world.

I semiotici parlano di enunciazioni performative retiche ed enunciazioni performative tetiche. Sono retiche quelle che si risolvono come un mero dire, sono tetiche quelle che, invece, pongono a qualcosa di nuovo e che incidono a livello di realtà.

Inutile dire che per quanto riguardale enunciazioni performative retiche, utilizzando lessico kantiano, il linguaggio è condizione necessaria e sufficiente affinché l'enunciazione performativa sia vera e valida. Rispetto a quelle tetiche, il linguaggio è condizione necessaria ma non sufficiente affinché l'enunciazione performativa produca validamente i suoi effetti. È necessario che ci sia la legittimazione ad agire da parte del soggetto che produce l'enunciazione performativa.
La categoria delle tetiche sarà più interessante per noi.
Il problema di oggi è basato su una domanda: che linguaggio parlano le norme secondarie o i frammenti di norme? Per fare ciò abbiamo scoperto una nuova dimensione di linguaggio: la maggior parte degli atti linguistici che noi produciamo sono atti linguistici performativi attraverso cui produciamo atti sociali che possiamo produrre solo e soltanto attraverso il linguaggio. Abbiamo distinto, all'interno delle enunciazioni performative, le enunciazioni performative che operano attraverso word- retiche- per cui il linguaggio è condizione necessaria e sufficiente da enunciazioni performative che operano attraverso world-tetiche- dove il linguaggio è condizione necessaria, ma non anche sufficiente. È necessario una ulteriore condizione di legittimazione da parte del soggetto che produce quella determinata enunciazione.
Poiché il linguaggio del diritto è un linguaggio che incide sempre sul reale in quanto è normativo e plasma continuamente la realtà. Le enunciazioni tetiche sono importanti e ci interessano per risolvere il nostro problema giuridico. Chi si è accorto che le norme di rilevanza per il linguaggio giuridico è Gaetano Carcaterra, filosofo del diritto italiano. Egli, negli anni '70 scrive 2 libri: "La forza costitutiva delle norme" e "Le norme costitutive".
Carcaterra dice che ci sono una serie di norme che non parlano il linguaggio descrittivo ma, parlando il linguaggio performativo, sono quelle norme che costituiscono e istituiscono gli oggetti giuridici che compongono la struttura dell'ordinamento giuridico.

Prima ancora di stabilire quando un contratto risulta essere viziato e quindi nullo o annullabile, ci vuole una norma che definisca cosa è il contratto e che lo introduca all'interno del sistema. Quindi, Carcaterra dice che quello non è una norma secondaria poiché è una norma che cambia la realtà del diritto.
"L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro" è una norma sempre vera perché quella norma della costituzione è sempre vera perché definisce, costituisce, istituisce il nostro ordinamento giuridico come una repubblica democratica fondata sul lavoro. Queste sono norme che costruiscono il sistema, non prescrittive.
L'intuizione del filosofo deriva dagli studi condotti da suo padre- Antonio Carcat- famoso romanista della seconda metà del '900. È dal diritto romano che per la prima volta si verifica il tema della rilevanza della teoria dei performativi del linguaggio giuridico. Il diritto romano conosce tutta una serie di atti giuridici che si produce quando si pronunziano determinate parole. Questo tema era già tutto all'interno del diritto romano e certo non c'era una teoria o filosofia del linguaggio. In realtà, l'idea della costitutività del linguaggio giuridico e della sua prescrittività è antica, la teorizzazione è moderna: i romani lo facevano già senza sapere cosa stessero facendo.

Carcaterra applica la performatività al linguaggio giuridico. Egli dice che ci sono norme che costituiscono oggetti giuridici che prima non c'erano. Molti teorici del diritto, invece di norme costitutive, parlano di norme definitorie del sistema, norme che definiscono gli oggetti del sistema. Prima di stabilire il fatto come illecito, ci deve essere una norma che mi introduce il concetto di

illecito, presupposta gerarchicamente alla norma che costituisce la sanzione. Questa norma non è un frammento di norma, ma una norma che costituisce un fatto giuridico illecito che prima di quella norma non esisteva all'interno della "favola" dell'ordinamento giuridico. Sono quelle norme che introducono gli oggetti del sistema. Sono norme che introducono gli oggetti del sistema. Sono norme che, attraverso il linguaggio performativo, costituiscono la realtà dell'ordinamento. È chiaro che queste norme hanno necessità del carattere prescrittivo sanzionatorio. Ma non possiamo dire che queste sono conseguenze di quelle, al massimo il contrario. Io prima costituisco, qualifico l'oggetto giuridico e poi stabilisco la norma con forza prescrittivo sanzionatoria.

Costitutività e prescrittività sono domande molto frequenti all'esame (90-95%). Il tema della costitutività torna nella seconda parte del nostro corso. Anche diritto e linguaggio.
Carcaterra ci dà una nuova definizione di norma giuridica da affiancare al concetto prescrittivo sanzionatorio dello schema di qualificazione trascendentale disegnato da Kelsen.
Come definirà la norma costitutiva Carcaterra? Avrà uno schema logico della norma. La norma si presenta secondo lo schema: si dispone che la determinazione D appartenga al sistema S.
Le enunciazioni performative si producono in quanto c'è sempre un soggetto che le produce. Chi è il soggetto che le dispone? Il soggetto che dispone è il legislatore. La norma appartiene al sistema S dell'ordinamento giuridico. Una norma costitutiva è la disposizione del legislatore che introduce all'interno del sistema una nuova norma che costituisce, modifica, struttura il nostro sistema ordinamento giuridico.
Si dispone è il verbo performativo. Il linguaggio è il linguaggio del legislatore quindi performativo. La norma è costitutiva perché costituisce nel sistema giuridico un oggetto che prima non esisteva. Questa norma non prescrive nulla, serve soltanto a costruire il sistema. Le norme prescrittive saranno sempre le norme di cui parla Kelsen: se A, allora B. Ma quello schema dice Carcaterra non è sufficiente a mostrarci la molteplicità delle norme che costituiscono il sistema dell'ordinamento giuridico. Se la prescrittiva sanzionatoria ci dice cosa dobbiamo e non dobbiamo fare, la costitutiva si preoccupa di costruire il sistema.
Dunque, logicamente, le norme costitutive sono sempre gerarchicamente sovra-ordinate a quelle prescrittivo sanzionatorie.
Le norme alla Kelsen si rivolgono a noi come destinatari, sono norme che pongono obblighi, divieti e permessi dunque modalità deontiche nei confronti dei destinatari che siamo noi.
A chi si rivolgono queste norme costitutive?
Il destinatario delle norme costitutive è solo e soltanto il sistema, servono a costituire e costruire il sistema dell'ordinamento giuridico.
Ma se si rivolgono al sistema e non a noi, che differenza c'è nei nostri confronti rispetto alle norme costituti ve? La differenza è la sanzione. Se non vogliamo incappare nella sanzione, dobbiamo produrre atti di adempimento alla norma prescrittivo sanzionatoria. In entrambi i casi, la validità della norma è legata al nostro riconoscimento. Noi possiamo trasgredire un divieto in quanto sappiamo che quell'azione è vietata. Sia l'atto di adempimento che di inadempimento sono entrambi atti di riconoscimento della validità della norma che pone l'obbligo.
Le norme costitutive, invece, sono norme immediatamente valide, nel momento stesso in cui sono introdotte nel sistema a prescindere perché non richiedono alcun atto di adempimento da parte dei destinatari. Semplicemente perché i destinatari non sono i soggetti a cui si rivolge la norma che è immediatamente operativa nel momento stesso in cui viene introdotta nel sistema. Il sistema viene modificato dalla norma.

Un esempio classico di norma costitutiva che rispecchia lo schema "si dispone che la determinazione D appartenga al sistema S", che è immediatamente operativa all'interno del sistema senza la necessità di altri atti di adempimento è la norma abrogativa (norma che abrogano e tolgono la validità di una norma precedentemente valida).
Nel momento in cui il legislatore dispone che la norma che ha abrogato- divieto di fumare nelle aule universitarie- è valida all'interno del sistema, da quel giorno la norma che poneva il divieto non è più valida e non esiste più all'interno dell'ordinamento giuridico.
La norma è immediatamente valida ed efficace per il sol fatto di essere stata abrogata dal legislatore perché il destinatario è il sistema, non noi.

Carcaterra, nel secondo 900, arrivò a teorizzare che tutte le norma hanno effetti costitutivi e che il linguaggio del diritto è solo costitutivo e che il prescrittivo sia solo una conseguenza del costitutivo cioè l'esatto contrario della teoria di Kelsen. Carcatella arrivò a definire il diritto solo come costitutivo.

Piuttosto che sposare o l'una o l'altra delle due teorie, mi permetto di fare un'osservazione finale su questa nostra scoperta della dimensione costitutiva del linguaggio giuridico.
Le norme costitutive - es. "L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro" - le definiamo comunque norme, non proposizioni.
Perché continuiamo a definirle norme e affianchiamo il linguaggio costitutivo al linguaggio prescrittivo. Se sono norme, anche se sono costitutive, producono effetti prescrittivi.
Come condurre alla sfera del costutività alla prescrittività? Mentre Carcaterra dice che parliamo tutti un linguaggio costitutivo e quindi la prescrittività deriva dalla costutitvità.
Quando ci muoviamo all'interno del linguaggio del diritto, quest'ultimo non è mai neutro.

Non è vero che le norme costitutive non sono norme. Ma davvero il performativo, nel momento in cui abita il linguaggio giuridico, non produce effetti prescrittivi nei nostri confronti o è vera la tesi contraria?
Nel momento in cui stabilisco (attraverso le norme costitutive) le regole del gioco. Esse ci definiscono tutto. Ci dicono a quale gioco stiamo giocando, poi noi stabiliamo le sanzioni. Il nostro codice civile continua a definire il matrimonio come un'unione civile tra due persone di sesso diverso. Non pensate che questa sia già di per sé una limitazione nella costruzione dell'idea di famiglia?
Questa norma costitutiva ha effetti normativi, anche se a noi non sembra. Perché quella norma non dice che una famiglia è costituita da due persone che condividono una serie di cose x e y? Se fosse così x e y, abrogheremmo il problema della sessualità e avremmo una fattispecie più astratta e generale. Dire, invece, che due persone debbano essere necessariamente di sesso diverso sta già limitando la scelta. Chi vuole costruire una famiglia, deve necessariamente essere di sesso diverso. La limitazione del nostro spazio d'azione ci viene detto a contrario della nostra norma costitutiva.
Il problema è di mostrare come le norme costitutive non sono neutre e che quell'essere, in realtà, è un dover essere. Se lo interpretate e lo leggete al contrario, le norme costitutive producono effetti anche nell'ambito del concetto di contratto di negozio giuridico ci sono degli studi di diritto privato: "Il terribile diritto". L'autore, Rodotà, decostruisce le norme costitutive cioè quelle che istituiscono gli oggetti giuridici che riguardano il nostro diritto privato, mostrando come quelle sono scelte che

derivano da una determinata "ideologia" - visione politica di come costruire i nostri rapporti sociali all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.
Dire che "il contratto ha la forza di legge tra le parti entro i limiti dell'ordinamento giuridico" significa dire che, attraverso il contratto, non possiamo fare tutto ciò che vogliamo ma dobbiamo muoverci nella sfera delimitata dal legislatore. Non sarebbe valido un contratto con cui noi scambiamo le libre di carne- come il mercante di Venezia perché il legislatore, con quella norma costitutiva, ha già limitato la nostra sfera d'azione. L'ordinamento dice che possiamo fare quello che vogliamo entro i limiti dell'ordinamento giuridico.

Quindi, le norme costitutive, nel momento in cui definiscono e stabiliscono "le regole del gioco", vi dicono come dovete giocare al gioco del diritto. Non ci dicono come siamo liberi di giocare, ma come dobbiamo giocare. Non è vero che le norme costitutive non producono effetti prescrittivi, li producono in modo indiretto. Quando si dice cos'è la famiglia, cos'è il contratto, si dice cosa DEVE ESSERE per essere giuridicamente rilevante una famiglia o un contratto nell'ordinamento giuridico italiano.
La vera prescrittività è proprio insita nelle norme costitutive perché sono quelle che organizzano gli istituti giuridici e quindi traducono le nostre decisioni, abitudini, tradizioni, visioni politiche in oggetti giuridicamente vincolanti. Le norme prescrittivo sanzionatorio alla Kelsen sono poca roba.
Il diritto non è soltanto porre un linguaggio descrittivo sanzionatorio, c'è molto di più. Con il diritto stabiliamo cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare, cosa è vita e cosa non lo è.
La legge 194 sull'aborto istituendo la possibilità di abortire entro il 3 mese, vi dice cosa l'ordinamento giuridico considera vivo o non vivo. Quella norma costitutiva ha un'importanza devastante. Poi c'è la sanzione, a monte della sanzione c'è una norma che vi costituisce e limita una sfera vitale così importante come lo stato giuridico del nascituro che non è ancora venuto al mondo.
Quindi, convergono una serie di istanze che sono politiche, scientifiche, biologiche, religiose. Tutto ciò converge e si fa sintesi nella norma costitutiva, non nella norma sanzionatoria. Questa questione traduce la visione politica del legislatore o del diritto. Sono ancora in vigore norme, nell'ambito del diritto penale, che risalgono al fascismo e hanno una visione del fatto considerato illecito radicalmente diverso.
È un tema di politica del diritto. Le norme costitutive che Kelsen chiamava secondarie sono norme che ci dicono in che mondo viviamo, in che tipo di ordinamento abitiamo o ci spostiamo. È chiaro che queste sono norme che hanno degli effetti prescrittivi devastanti, seppur indiretti e non immediatamente evidenti. È diversa la norma del fumare da quella della famiglia. Sono due norme che hanno una valenza completamente diverso. Le norme costitutive c'è un altro modo in cui indirettamente possono costituire diritti prescrittivi.

Parliamo della costruzione gerarchica dell'ordinamento. L'esempio è quello precedente. Se c'è la norma costitutiva come norma abrogativa, è una norma che restituisce vita ad un vecchio divieto. Quello che era permesso, da oggi non c'è più la norma che è stata abrogata, ma torna in auge la norma che lo proibiva.
O si crea un vuoto legislativo o quando si abroga una norma automaticamente torna in vigore quella precedente. Se la norma abrogata è una norma che conteneva un permesso e dava la facoltà di fare qualcosa, immediatamente torna in auge la norma che conteneva il divieto o l'obbligo.
Quindi, anche quando le norme costitutive vanno a costruire il sistema, non sono norme neutre. Il sistema che stiamo analizzando, limita la condizione della nostra sfera della libertà personale. Non è

vero, come diceva Carcaterra, che tutte le norme producono effetti costitutivi. Lui vuole arrivare alla dimensione di politicità. Carcaterra gioca sul tema, ma la verità è che è impensabile non riconoscere una dimensione prescrittiva alla dimensione costitutiva.

Ci sono regole che servono per trasgredire le regole, ma ci sono regole fondamentali che organizzano e strutturano il gioco. Vedremo la differenza fra i diversi tipi di regole. Detto tutto ciò, abbiamo accanto alla descrizione prescrittiva delle norme, una descrizione costitutiva. Questa dimensione costitutiva nasce dagli anni '60 del secolo scorso da parte di un filosofo del linguaggio: John Austin.

Cos'è il linguaggio performativo? È un linguaggio attraverso cui compio l'azione che dico di compiere- posso fare cose con parole. All'interno delle enunciazioni performative, io posso distinguere due diversi tipi di enunciazione: tetiche o word e retiche o world. Nel primo caso sono enunciazioni performative con cui io posso modificare solo il linguaggio, dunque il linguaggio è condizione sufficiente affinché l'enunciazione performativa sia vera e valida. Nel secondo caso io modifico il mondo attraverso il linguaggio. Il linguaggio è condizione necessaria ma non sufficiente affinché l'enunciazione sia sicuramente vera ma non anche valida. È necessaria una legittimazione particolare del soggetto che produce l'enunciazione. Nell'ambito giuridico, sono queste ultime ad essere valide e rilevanti in ambito giuridico.

Come sono valide e perché sono rilevanti in ambito giuridico?

Carcaterra, attraverso il linguaggio performativo del legislatore, ha rintracciato una diversa tipologia di norme con lo schema: "si dispone che la determinazione B appartenga al sistema S". Si dispone indica il linguaggio performativo del legislatore, la determinazione B è la norma e il sistema S si riferisce all'ordinamento giuridico. Ciò significa che il destinatario delle norme costitutive è il sistema stesso. Inoltre, costruiscono, modificano e trasformano il sistema stesso definito come ordinamento giuridico. Dunque, queste norme hanno sempre come destinatario il sistema e mai come destinatario i singoli cittadini. È proprio per questo che le norme sono immediatamente valide nel momento stesso in cui sono disposte dal legislatore senza bisogno di nessun atto di adempimento del destinatario, a differenza delle norme prescrittivo-sanzionatorie.

Quali sono gli effetti di queste norme? Accanto agli effetti costitutivi, queste norme producono anche effetti costitutivi di riflesso, non meno importanti e rilevanti perché:

1)Stabiliscono le regole del gioco cioè stabiliscono quali sono gli oggetti giuridici che noi possiamo utilizzare all'interno del nostro sistema

2)Modificando, abrogando, trasformando l'ordinamento giuridico possono incidere indirettamente su norme con contenuto prescrittivo sanzionatorio (obblighi, divieti e permessi).

Tutto questo come si riflette a sua volta sul tema della funzione del diritto? È chiaro che individuare una dimensione costitutiva accanto ad una dimensione prescrittiva ci dice che il diritto non è semplicemente una tecnica di regolazione sociale. Il diritto è lo strumento ufficiale attraverso cui noi costruiamo la nostra relazionalità sociale. Tutti gli strumenti che noi utilizziamo per comporre i nostri interessi all'interno del contesto in cui viviamo sono costruiti e regolati dal linguaggio giuridico.

Dunque, il linguaggio giuridico è un linguaggio secondo cui costruiamo l'intera realtà sociale. Abbiamo intravisto nella teoria degli ordinamenti una funzione diversa del diritto, individuata partendo dalla scoperta del linguaggio performativo.

Andiamo avanti passiamo, alla 3^ critica che avevamo mosso a Kelsen: il soggetto. Per Kelsen, noi siamo rilevanti all'interno del diritto solo se il diritto qualifica il nostro comportamento come giuridicamente rilevante. Che visione politica traduce questa idea di Kelsen? Il soggetto (noi) è rilevante solo se è centro di imputazione di interesse cioè se c'è una norma che implica conseguenze giuridicamente rilevanti. Per il resto, noi siamo indifferenti al mondo del diritto. Noi siamo liberi di fare quel che vogliamo fintanto che non c'è una norma che qualifica un nostro atto o comportamento, non un nostro status.

La visione kelseniana del diritto è liberale nel senso più classico del termine. Tutto torna, il diritto serve a permettere a chiunque di fare quello che vuole garantendo un ampio spazio di libertà purché quella libertà non violi la libertà altrui. Kelsen è kantiano non solo nel lessico, ma anche nella ratio che c'è nel suo progetto giuridico. Per il resto, l'ordinamento giuridico non fa altro che promuovere spazi di libertà per noi purché questi non vengano a configgere con gli interessi tutelati nella visione dell'ordinamento.
In un mondo come il nostro un filosofo tedesco contemporaneo -Jürgen Habermas- afferma che il livello di giuridificazione della lebenswelt (mondo della vita) è così elevato che quasi non ci sono più spazi normati da regole. Ormai sono crollati i presupposti il mondo è giuridificato e "colonizzato" dal diritto.
Torniamo al tema kelseniano che ha dei limiti perché risulta avere una visione limitata rispetto alla metamorfosi. Rileggere il diritto attraverso le ottiche kelseniane significa non comprendere pienamente il fenomeno giuridico. L'immagine della piramide oggi è completamente rovesciata. Queste sono tutte certezze che ci stiamo costruendo del secolo scorso.

Torniamo al tema della soggettività, Kelsen è liberale e garantista rispetto alla soggettività. Il problema è che il soggetto di diritto è completamente escluso dal discorso della costruzione teorica. Non c'è un'ottica partecipativa da parte del soggetto. Il linguaggio del legislatore è valido, trasparente, costruito secondo una teoria gerarchica, logica, che ha un fondamento a priori ma dove qualsiasi dimensione partecipativa da parte dei destinatari è esclusa nella costruzione del soggetto giuridico. Questo è un limite enorme, moltissimi allievi fedeli al dogma del positivismo giuridico rimprovereranno a Kelsen questa visione del diritto. Quella di Kelsen è un'ottica tutta logica, dogmatica e teorica. Invece, a partire dagli anni 60, la prospettiva di costruzione del diritto muta radicalmente e lo sguardo si sposta all'interno o all'esterno del gioco del diritto. Diventa uno sguardo che implica la partecipazione e non semplicemente la costruzione di un oggetto logico teorico, quasi artificiale.
Le teorie del diritto sono fondamentalmente degli strumenti che i teorici hanno costruito per conoscere il fenomeno giuridico, spiegarci le ragioni, le giustificazioni, indagare i meccanismi di funzionamento, di costruzione e di decostruzione (post-modernità). Kelsen lo costruisce come oggetto logico e metafisico.
Nella teoria della completezza dei sistemi, i grandi logici sanno bene di essere dei grandissimi metafisici. La logica è una delle forme più astratte e pure della metafisica. La teoria logica non è una conoscenza "dal basso", che possiamo avere noi che guardiamo il diritto.
Le teorie successive del positivismo giuridico partono da una "mancanza". Tentano di costruire un'altra prospettiva attraverso cui conoscere l'oggetto giuridico.
Qual è lo strumento attraverso cui avvicinarsi al mondo delle norme? Torniamo alla prima lezione. VNoi vogliamo costruire una teoria epistemologica del diritto, dei fatti giuridici. Dobbiamo partire

dall’osservazione di ciò che accade intorno a noi. La figura principale o teorica su cui si fondano le teorie del positivismo giuridico nel primo 900 è la figura dell’osservatore. Si parte dall’osservazione. Ogni prospettiva suggerisce la costruzione di una teoria diversa del diritto e una risposta diversa alla domanda della filosofia del diritto: “Perché io devo seguire le regole?”.
Ma fondamentalmente la risposta di Kelsen resta di seguire il diritto quando è valido, ha la forma tipica di una norma. La risposta anche qui è riduttiva. Se volessimo rispondere in maniera più esaustiava, dobbiamo partire dalla prospettiva dei giuristi che possono fornirci giustificazioni sul perché c’è l’ordine piuttosto che il caos. A differenza di Kelsen, le nuove teoria partono da una prospettiva attraverso cui osservare e guardare, conoscere il fenomeno giuridico.
La domanda successiva che ci dobbiamo porre è: Come osservare?

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE DEL 28/10/2024

La volta scorsa stavamo dicendo che per elaborare una teoria più potente, in grado di rispondere alla nostra domanda "perchè devo seguire le regole?", poiché siamo noi che dobbiamo seguirle, forse siamo noi la parte cruciale che mancava in tutta l'elaborazione del positivismo giuridico kelseniano; abbiamo detto che devo seguire quelle regole perchè hanno la forma tipica della norma: era, seppur una risposta logico-formale oggettiva e consolatoria, totalmente insufficiente e inadeguata perchè alla fine non teneva conto proprio di chi materialmente deve seguire le regole. Perciò siamo tornati indietro ripartendo proprio dal momento in cui siamo noi che ci siamo chiesti come sia possibile conoscere il fenomeno giuridico. Abbiamo detto la volta scorsa dunque che per elaborare una teoria della soggettività giuridica il primo passo che dobbiamo fare è quello di capire con che tipo di soggetto dobbiamo avere a che fare. *Come identificare questo soggetto?* Banalmente, come conosciamo il fenomeno giuridico ma in generale tutti i fenomeni attorno a noi? Attraverso la percezione visiva. Ci eravamo anche soffermati sul fatto che il termine "vedere" è un termine che si dice in tanti modi (es. "avete dato un'occhiata ai libri di testo?/ avete studiato i libri di testo? -->in entrambi i casi si sottintende che voi abbiate guardato i libri di testo, ma l'azione del guardare presuppone due modalità diverse del guardare). Ludwig Wittgenstein, un filosofo che è tornato diverse volte nelle nostre conversazioni, diceva nelle "ricerche filosofiche", che il concetto di vedere è un concetto confuso perchè il vedere è sempre legato a un vedere *come?* , ovvero come stai guardando, che tipo di prospettiva stai utilizzando, che tipo di sistema visivo stai utilizzando e dunque che tipo di soggetto sei? Poichè ci sono tanti modi di vedere, ogni oggetto chiede un atto di visione diverso. Per riuscire a comprendere quali sono le modalità del vedere che ci toccano direttamente facciamo un esercizio, andiamo a prendere i nostri concetti da un altro ambito del sapere e poi importiamoli all'interno del linguaggio giuridico e della teoria generale del diritto. Qual è il nostro scopo? Quello di costruire una teoria generale del diritto, un'epistemologia, ovvero un sistema che ci permetta di conoscere il fenomeno giuridico che sia più efficace del modello kelseniano soprattutto rispetto all'ipotetica risposta alla domanda "perchè devo seguire le regole?". Per far questo dobbiamo ripartire dal tema della soggettività, quella legata all'esercizio dello sguardo, eppure come diceva Wittgenstein non tutti guardano allo stesso modo, non tutti gli atti del vedere sono uguali o simili tra di loro. Dobbiamo quindi rintracciare quei significati dell'atto di vedere che siano rilevanti nella costruzione del linguaggio giuridico. Come fare per isolare questi significati? Iniziamo la nostra analisi non dal linguaggio giuridico, ma dal linguaggio pittorico: analizziamo il quadro "Las meninas" di Velazquez. Questo quadro è diventato rilevante dal punto di vista filosofico perchè ne ha parlato il filosofo Michel Foucault ne "Le parole e le cose" (incipit). E' un quadro del barocco seicentesco che rappresenta la vita dei reali della corte di Spagna, al centro abbiamo l'infanta Margherita, intorno ci sono le damigelle d'onore e i vari accompagnatori. C'è inoltre la figura di un pittore, che è lo stesso Velazquez, che sta dipingendo; noi non vediamo cosa sta dipingendo, o almeno non dovremmo: dietro c'è infatti uno specchio che riflette il soggetto di questa rappresentazione (il re e la regina di Spagna). Ci sono due elementi interessanti che ci permettono di far emergere due forme di soggettività dello sguardo che dipendono proprio da come il quadro è stato costruito: il primo è il pittore che si autoritrae all'interno

del suo quadro. Autoritraendosi il pittore ci sta comunicando che quando dipinge guarda in maniera soggettiva, nel quadro sta compiendo un'azione guardando un ipotetico modello che è fuori dal quadro, che noi vediamo solo attraverso lo specchio, il suo sguardo è rivolto verso chi c'è all'esterno della tela, il suo sguardo non è fermo ma è finalizzato al compimento di un'azione, cioè fare nel miglior modo possibile il ritratto dei due reali. Quindi è uno sguardo che ha una dimensione partecipativa ed è uno sguardo finalizzato ad un'azione. Il pittore si mette in scena come qualcuno di interno, partecipe alla sua rappresentazione. Ma non finisce qui, Velazquez innesca un gioco ulteriore di sguardi: riusciamo a scorgere il soggetto del ritratto attraverso lo specchio--> per essere riflessi nello specchio il re e la regina si trovano al posto dell'osservatore, noi ci identifichiamo quindi col modello ritratto nel quadro, noi osserviamo il quadro e il quadro osserva noi e se il quadro ci sta osservando significa che all'interno della costruzione del quadro delle prospettive si affaccia un altro soggetto: questo soggetto siamo noi che dall'esterno stiamo guardando il quadro. Ma noi quindi in che modo stiamo guardando il quadro? Noi siamo esterni alla rappresentazione, siamo "fuori campo", il nostro modo di guardare è radicalmente diverso dal modo in cui guarda il pittore. Noi che stiamo fuori non possiamo incidere sulla rappresentazione, mentre il pittore si—>il nostro è uno sguardo totalmente passivo, noi guardiamo una rappresentazione, invece il pittore mentre dipinge guarda la realtà. Possiamo allora distinguere due tipologie di soggetto che guarda: uno (il pittore) esercita uno sguardo attivo, mentre l'altro (noi che guardiamo la rappresentazione) uno passivo. Il primo soggetto è definibile come osservatore, mentre nel secondo caso parleremo di spettatore. Questo dunque si traduce in una forma di soggettività diversa: da un lato abbiamo l'osservatore, dall'altro uno spettatore. Un soggetto si definisce osservatore quando guarda un fenomeno reale in modo attivo, invece definiremo lo spettatore come colui che guarda una rappresentazione o una finzione esercitando uno sguardo totalmente passivo. Possiamo dire che la natura, la consistenza dell'oggetto osservato ci suggerisce la diversa tipologia del soggetto che sta guardando. La seconda parte del corso si basa su questa dicotomia tra osservatore e spettatore. Per ora prendiamo la figura dello spettatore e mettiamola momentaneamente da parte, concentriamoci invece sull'osservatore. L'osservatore è un concetto che nasce all'interno della teoria del positivismo—>Kant è uno di quelli che distingue i vari modi del guardare. (Es. stasera col telescopio andiamo a osservare la luna: per osservare scientificamente osservo le regolarità del fenomeno, così da iniziare a comprendere quali sono le leggi che regolano il funzionamento di quel determinato fenomeno. I dati che raccolgo devono essere organizzati in uno schema, che è un tipo di metodo. Quindi l'osservazione parte dalla costruzione di una metodologia che io elaboro per conoscere le leggi che strutturano un fenomeno reale, dunque il funzionamento, da cosa il fenomeno è causato e cosa produce, il logos di esso. Per fare tutto questo attraverso l'osservazione è necessario sviluppare un apparato metodologico: quindi l'osservazione è sempre un processo teleologicamente orientato attraverso la costruzione di un metodo volto a comprendere le leggi che determinano un fenomeno (=fatto reale). L'oggetto osservato però non si ha mai in sé per sé, ma è sempre trasfigurato dal metodo che scegliamo per osservarlo, è modificato dal metodo che stiamo utilizzando—>l'osservatore ha uno sguardo attivo sul fenomeno che sta guardando: significa che può conoscere un fenomeno solo e soltanto se costruisce un suo modello di legittimità di esso—>quel modello piuttosto che un altro permette di conoscere il fenomeno in un modo piuttosto che in un altro. Anche in questo momento in quest'aula c'è chi sta seguendo dal libro, chi dal tablet, chi dal PC: ognuno di voi sta utilizzando uno strumento epistemologico diverso, dunque ha una resa soggettiva diversa rispetto al fenomeno della realtà che sta osservando. L'osservatore proprio perché costruisce dei modelli epistemici è sempre in grado di intervenire attivamente sulla realtà, di plasmare il fenomeno, mentre lo spettatore elabora altri sistemi in modo passivo. Dal punto di vista semantico, l'osservare dice già di una prassi visiva che ha a che fare già col seguire le regole: si osservano le leggi—>prassi visiva orientata alla costruzione di un modello di regole, se sei osservatore sei anche osservante. L'osservare non è neutro, ma implica sempre il seguire—>l'osservatore è sempre osservante, e l'osservante è sempre osservatore. Ma che significa che io devo costruire il mio metodo nel modo migliore possibile per conoscere un fenomeno, come faccio? Attraverso la costruzione di un punto di vista, una prospettiva.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 13 **DEL 30/10/2024**

La volta scorsa parlavamo di **osservatore** e **punto di vista**.

Facciamo una prima parte della lezione: vi garantisco che è semplice anche se sono concetti che vi chiederò in seduta d'esame.

La volta scorsa avevamo individuato due figure di soggetti che attraverso lo sguardo costruiscono il discorso giuridico; quindi, la diversa modalità per guardare aiutava la costruzione del discorso giuridico.

- *Quali sono queste che figure che avevamo introdotto?*
  L'**osservatore e lo spettatore**. Avevamo detto che l'**osservatore è colui il quale osserva fenomeni reali con uno sguardo attivo**; lo **spettatore invece è colui il quale osserva una rappresentazione o una finzione con sguardo totalmente passiv**o. Dunque, l'oggetto osservato ci diceva anche la modalità dello sguardo da considerare: la rappresentazione implica uno sguardo passivo (introduce una dimensione spettatoriale del guardare), viceversa invece i fenomeni reali (oggi vedremo come questo fenomeno si può declinare sia in un fatto naturale che in un fatto sociale) implicano da parte dell'osservatore uno sguardo attivo.
- *Quale e la domanda immediata che suscita lo sguardo dell'osservatore? Che significa che l'osservatore guarda l'oggetto con uno sguardo attivo?* Significa che lo guarda costruendo, con l'elaborazione di una metodologia che permette all'osservatore di conoscere in profondità un tratto o l'oggetto guardato, dunque di carpirne le leggi sul suo funzionamento. Questa metodologia non è altro che l'elaborazione di una prospettiva ovvero di un punto di vista. L'osservatore guarda sempre a partire da un punto di vista ben preciso (concetto anche questo con molti significati). Il concetto di punto di vista che a noi interessa è quello di elaborazione, costruzione di una prospettiva che permetta di inquadrare nel modo migliore possibile l'oggetto che sto tentando di conoscere
- *Che cosa e un punto di vista? Quali sono i punti di vista levanti per l'osservatore?*

"Las meninas" di Velazquez. Cosa avevamo osservato in quel quadro? Perché quel quadro è così particolare? Qual è la prima particolarità del quadro di Velazquez? Che c'è un pittore (lo stesso Velazquez) che nell'atto di dipingere mette in scena sé stesso Dunque, lo stesso soggetto che noi abbiamo definito come osservatore; ovvero il pittore, si presenta in due modalità diverse: come colui che ha dipinto il quadro che noi stiamo osservando, e colui in quale è dentro il quadro, una figura che noi possiamo soltanto intravedere nel riflesso dello specchio che è dietro la rappresentazione principale. Che differenza c'è tra questi due concetti di osservatore? La volta scorsa avevamo già dato una risposta esaustiva. Uno è **estero alla scena** e l'altro invece è **interno alla rappresentazione**. Dunque, entrambi sono osservatori ma si distinguono per la loro posizione "geografica" rispetto all'oggetto della rappresentazione. Che differenza c'è tra questi due punti di vista?

- *Raccolgono le stesse informazioni gli osservatori da un punto di vista interno e gli osservatori da un punto di vista esterno?*

Ragioniamo diversamente, facciamo un esempio cinematografico: non so se qualcuno di voi ha visto " La finestra sul cortile" di Hitchcock che racconta la storia di un fotografo che si è rotto una gamba e trascorre il suo tempo guardando il cortile fuori della sua finestra, osservando tutto quello che accade inizia a raccogliere informazioni sulle attività dei vicini. Questo è un esempio perfetto per quello che vogliamo andare a dimostrare oggi.

Facciamo un esempio più semplice.

Facciamo finta che nel palazzo difronte a noi ci sia un signore che non ha nulla da fare, questo signore acquista un telescopio o binocolo e passa il suo tempo guardando ciò che accade nelle stanze difronte; si imbatte nella nostra lezione e osserva ciò che accade qui dentro. Che tipo di osservazione è questa, esterna o interna? Esterna rispetto a noi che siamo in aula. Come si svolge questa osservazione? Che tipo di informazioni può raccogliere il signore? Informazioni strettamente visive cioè potrà dire che una persona sta avendo un dialogo con altre persone che lo ascoltano; com'è fatta l'aula; il numero di persone presenti; la durata del dialogo; le caratteristiche delle persone. Se però volesse sapere il numero dei frequentanti o in che altro giorno si ripete la lezione, che tipo di osservazione deve svolgere? Un'osservazione costante e continuativa del suo oggetto, che siamo noi. Secondo voi, *il signore difronte che tipo di indagine può svolgere nei nostri confronti?*

Può elaborare delle ipotesi e verificare se sono vere o meno.

Questa che tipo di indagine è? Come la chiamereste?

Risposta 1: la chiamerei scientifica, perché nella scienza di fa così, si utilizza un metodo empirico. Dal punto di vista delle scienze naturali, l'osservatore esterno è lo scienziato che osserva e giunge a delle conclusioni. Quello che facciamo qui dentro noi, è tuttavia un gioco sociale.

Che tipo di sapere sociale si può costruire partendo da un punto di vista esterno? Si può capire che **c'è regolarità nei nostri comportamenti**, è questo che un tipo di sapere definito sociologico. La sociologia nasce infatti come scienza sociale positivista attenta a registrare i

comportamenti dei soggetti che abitano in un determinato gruppo sociale. L'atteggiamento dell'osservatore nei nostri confronti che tipo di atteggiamento sarà? **Esterno e oggettivo**, perché lui non è compromesso da dei sentimenti nei nostri confronti. Per ottenere il massimo dell'oggettività si deve avere il minimo coinvolgimento dell'osservatore rispetto all'oggetto osservato. *Allora quali saranno le caratteristiche del punto di vista esterno?* **Imparzialità** e possiamo dire che è un punto di vista **avalutativo** (espressione che deriva da Max Weber, considerato il padre delle scienze sociali), inoltre è **asettico** (non si lascia coinvolgere da ciò che avviene), tutto questo per giungere a un livello massimo di oggettività. Quindi possiamo definire il punto di vista esterno come un punto di vista oggettivo, perché tutte le caratteristiche prima citate mirano a raggiunge la massima oggettività rispetto alle conoscenze che io posso avere dell'oggetto che sto guardando. Il metodo scientifico nasce proprio con questa idea: quella di garantire il sapere più oggettivo possibile prima della natura, poi dell'uomo e poi della società. Questi saperi sono la sociologia, ancora il sapere statistico che si costruisce con un punto oggettivo, l'antropologia dove almeno una parte si costituisce con un punto di vista esterno. L'osservatore e sempre un agente relativo e contestualizzato.

-La psicologia è un punto di vista esterno o interno? È molto complesso il tema della psicoanalisi, ma è un esterno che diventa interno. Lo status della psicoanalisi è ibrido, tant'è che c'è ancora l'idea che sia una scienza.

-Che altra scienza si può costruire a partire da un punto di vista rigorosamente esterno, quindi oggettivo? L'economia, almeno una parte delle indagini economiche sono costruite nella maniera più oggettivo possibile.

-Nell'ambito giuridico, che tipo di saperi si costruiscono a partire da un punto di vista oggettivo? La prima è la sociologia del diritto, che è quella branca della sociologia che in senso oggettivo studia i comportamenti dei destinatari delle norme all'interno di un contesto sociale, non si interroga sul perché c'è ordine piuttosto che il caos.

L'altra scienza è quella dogmatica giuridica, che raccoglie tutte quelle scienze che costruiscono il diritto dal punto di vista logico formale. Una di queste scienze è la dottrina pura del diritto di Kelsen, l'idea di una scienza del diritto costruita a partire da un punto di vista oggettivo che non si parla di osservatore ma di logica formale di un sistema a priori per ambire al massimo dell'oggettività. Accanto a Kelsen, si può ricordare tutto il positivismo che si costruisce tra le due guerre mondiali. Abbiamo visto i grandi vantaggi della prospettiva oggettiva, imparziale, asettica e avalutativa, quindi la possibilità di restituire una immagine il più oggettiva possibile del fatto sociale o naturale che si tenta di conoscere.

-Quali sono i limiti di questo modo di osservare? Torniamo all'esempio di prima (l'osservatore nel palazzo di fronte che osserva la nostra lezione): quali sono le cose che non può comprendere, guardandoci con il binocolo? Ci sono una serie di informazioni che l'osservatore si scorda di poter conoscere guardando dal binocolo. Quali sono queste informazioni? L'osservatore non potrà mai sapere determinate informazioni. Per avere queste informazioni che deve fare l'osservatore? Deve venire a lezione e sedersi tra gli studenti, al fine di raccogliere informazioni diverse rispetto a quelle viste. Quando si siede tra gli studenti, l'osservatore ha un quadro più completo? L'osservatore deve interagire e chiedere informazioni alle persone

presenti in aula. Anche chiedendo queste informazioni, il suo status non è uguale rispetto a quello degli studenti, perché il livello di coinvolgimento emotivo e razionale è sicuramente diverso dall'osservatore allo studente. L'agente epistemico riesce comunque a raccogliere una serie di informazioni diverse aggiuntive rispetto a quando non si trova in aula.

-*Qual è la differenza maggiore rispetto alle informazioni che riesce a raccogliere dall'esterno?* **L'osservatore interno riesce a comprendere le ragioni e le emozioni che provano i membri di quel gruppo sociale.** Riesce ad interrogarsi sul perché quei componenti stanno partecipando a una determinata pratica sociale. Però per fare tutto questo **l'osservatore** non deve solo spostarsi geograficamente, ma **deve divenire partecipante**, perché deve partecipare anch'egli al gioco sociale che sta osservando. Quando cambia il punto di vista, l'osservatore diviene partecipante. Se l'osservatore diventa partecipante, deve immedesimarsi e quindi condividere le emozioni di chi partecipa al gruppo sociale che sta osservando.

-*Quando l'osservatore diventa partecipante?* Quando condivide le ragioni e le emozioni del gruppo a cui sta partecipando. Da un punto di vista filosofico se l'osservazione esterna nasce col positivismo giuridico e nell'ambito delle scienze naturali, l'osservazione da un punto di vista interno nasce proprio all'interno delle scienze sociali. Nasce negli anni ‘60 con Ludwig Wittgenstein dell'Università di Cambridge, Peter Winch. Peter Winch elabora il concetto di "idea sociale", un concetto che ha rilevanza solo all'interno di un ambito di relazioni umane. Secondo Winch per conoscere in profondità come funzionano le leggi che animano una idea sociale, non si possono guardare queste solo esternamente perché la società è costruita da relazioni interne che si costruiscono attraverso i membri di quel gruppo sociale. Mentre il punto di vista oggettivo è eccellente per lo studio della natura, ma è assolutamente fallace per lo studio della società e delle scienze sociali. Secondo Wittgenstein lo sguardo esterno non restituirà mai la complessità dell'agire sociale, perché bisogna immedesimarsi nel gruppo sociale e nella cosiddetta "forma della vita". Winch fa tesoro di queste annotazioni e costruisce una teoria filosofica: **la teoria dei punti di vista**.

-*Come si caratterizza il punto di vista interno?* Esattamente in contrapposizione al punto di vista esterno. Se il punto di vista oggettivo è avalutativo, in questo caso si chiede di condividere i valori di un gruppo sociale e di comprenderne le ragioni. Questa è una prospettiva né avalutativa né asettica. Non è una prospettiva imparziale.

-*Che tipo di conoscenza si costruirà a partire da questo punto di vista?* Una conoscenza soggettiva perché l'osservatore quando si rivolge agli studenti nel caso dell'esempio precedente, chiede le impressioni e le emozioni puramente soggettive degli studenti. Il punto di vista della prospettiva interna si costruisce soggettivamente e quindi propone un sapere che si costruisce da un punto di vista soggettivo. Si può distinguere all'interno della metodologia dell'osservatore due diversi punti di vista: **un punto di vista oggettivo e un punto di vista soggettivo.**

Il punto di vista oggettivo che si basa sul principio di imparzialità, asetticità e avalutatività ed è sempre esterno all'oggetto che sta studiando e quindi produce il massimo di oggettività possibile.

Il punto di vista soggettivo è un punto di vista interno rispetto all'oggetto osservato, non imparziale e non avalutativo che produce un sapere fondato soggettivamente.

-Che tipo di saperi si possono costruire partendo da un punto di vista soggettivo nelle scienze umane? La psicoanalisi è una scienza che si fonda su un punto di vista soggettivo, in quanto l'inconscio è fondato sulla soggettività.

Dietro la domanda "Perché devo seguire le regole"? C'è un ragionamento psico-analitico. All'inizio del "Trattato teologico-politico", l'autore Spinoza si pone una domanda che è simile a quella di partenza (Perché dobbiamo seguire le regole?). Egli è in polemica con Hobbes che dice all'interno del Leviatano che il diritto si fonda su una emozione. L'ultima parte del Leviatano è intitolata "Il regno delle tenebre" cioè il regno senza diritto, dove le tenebre rappresentano la paura di un mondo senza regole. "L'Homo homini lupus" ci dà l'idea di un diritto fondato sulla emozione e non sulla ragione.

-Che altri saperi all'interno delle scienze umane si costruiscono a partire da un punto di vista interno? Molti dei saperi che abbiamo visionato prima subiscono una torsione quando si scopre il punto di vista interno, e quindi all'interno delle scienze sociali si apre una dimensione nuova. La stessa sociologia si muove in maniera diversa.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 13 DEL 30/10/2024

C'è un film bellissimo che vi da perfettamente l'idea del passaggio dal punto di vista oggettivo al punto di vista soggettivo. La storia è basata su un romanzo autobiografico da parte del direttore del carcere che fece questo esperimento psicologico: il direttore voleva conoscere effettivamente quali fossero le condizioni dei suoi detenuti, si fece arrestare e si finse detenuto.

Quindi cercando di immedesimarsi completamente nel punto di vista del gruppo sociale dei detenuti, si accorse di tutta una serie di ingiustizie e abusi che non era possibile scorgere col punto di vista oggettivo.

Questo film mostra come cambiando prospettiva cambi completamente la qualità e quantità di informazioni che io posso raccogliere su uno stesso oggetto.

Il direttore riesce a raccogliere informazioni solamente dal punto di vista soggettivo, questo ci dice che anche nell'ambito della teoria del diritto il punto di vista soggettivo può schiudere prospettive completamente nuove se non che nel momento in cui ragioniamo dal punto di vista soggettivo nell'ambito di un ambito giuridico è necessario fare delle considerazioni.

Perché il gioco del diritto è un gioco sociale molto particolare perché ci sono delle regole e queste regole prescrivono l'obbligazione di una serie di sanzioni.

Nell'ambito giuridico quanti punti di vista possiamo avere?

Facciamo un esempio non giuridico e consideriamo il calcio o il tennis nel momento in cui non adottiamo più un punto di vista oggettivo ma soggettivo quanti punti di vista soggettivi abbiamo? Quanti modi di partecipare abbiamo?

-Allenatore, arbitro, giocatori.

Sono tutti partecipanti?

Si. I giocatori e l'allenatore e gli arbitri ma partecipano tutti allo stesso modo?

No perché hanno funzioni diverse: i giocatori giocano per vincere, gli arbitri sono i garanti del regolare svolgimento del gioco, quindi all'interno della prospettiva del punto vista soggettivo individuiamo già due forme di soggettività che sono diverse per chi partecipa e per chi garantisce l'ordinato svolgimento della partecipazione.

Passando alla teoria generale del diritto, chi gioca il gioco del diritto? Tutti noi.

Si dice che l'osservatore nell'ambito giuridico diventa partecipante quando usa le norme, usa il diritto.

Tutte le forme del 900 delle teorie generali del diritto ricorrono alle forme logico astratte che derivano dal discorso teologico.

Se un vostro amici vi chiedesse "Sei cattolico?" "Si ma non praticante"

Anche detti cattolici non osservanti: c'è la fede ma non seguo i precetti della chiesa cattolica.

Gli osservanti sono coloro che osservano un precetto, dove l'osservare implica il seguire. L'osservatore conosce l'oggetto che è chiamato a seguire, ad adempiere

Il tema dell'osservatore inteso come soggetto che guarda in modo attivo è evidente.

L'osservante è colui che guarda in funzione di un ordine da seguire:

prima categoria dei soggetti del diritto, dal punto di vista soggettivo che partecipano al gioco del diritto sono gli osservanti, altra categoria di soggetti del diritto sono i custodi dell'osservanza.

Se gli osservanti sono tutti coloro che usano le norme, chi saranno i custodi dell'osservanza?

Le corti.

Il punto di vista soggettivo si ramifica nuovamente: teorie del diritto che si costruiscono dal punto di vista dei custodi dell'osservanza e teorie del diritto che si costruiscono dal punto di vista degli osservanti.

Quindi consideriamo la domanda "Perché devo seguire le regole" mediante la prospettiva dei custodi dell'osservanza.

Ritornando all'esempio del calcio: nel concetto di seguire una regola il sapere che c'è un arbitro cosa implica sul comportamento dei giocatori?

Crea sicuramente un maggiore timore, un maggiore condizionamento, pensiamo all'idea che ci fossero delle videocamere, il vostro comportamento sarebbe completamente diverso sapreste di essere registrati, questo produce effetti sul destinatario diversi, in questo caso c'è un livello di certezza maggiore di essere visto.

Le immagini in realtà vanno interpretate, non c'è nulla di più ingannevole che pensare che le immagini ti mostrano esattamente ciò che è accaduto.

Ci sono interi processi basati sull'interpretazione delle immagini, ricordiamo un pestaggio di un cittadino nero, la polizia lo pestò a sangue e non si accorse che nella palazzina difronte qualcuno registrò tutta l'operazione.

Durante il processo di primo grado di appello i poliziotti furono tutti assolti; si ricorre in appello e furono tutti condannati con le stesse immagini.

Facciamo un esempio diverso: siete usciti di casa per venire in università e seguire le lezioni di diritto. Siete in ritardo e i semafori sono tutti rossi, non ci sono auto che stanno passando al primo incrocio perciò decidete di attraversare ugualmente, state per passare nuovamente al secondo incrocio ma vi fermate perché in questo caso vedete una videocamera, sicuramente perché c'è il timore che la nostra azione possa essere sanzionata possiamo dire quindi che il "perché devo seguire la regola" si rafforza attraverso un controllo preventivo.

Quindi quando parliamo di custodi dell'osservanza parliamo di colori che possono custodire, sorvegliare in maniera diversa rispetto al regolare svolgimento del gioco, può sorvegliare in maniera classica, in maniera tecnologicamente avanzata con i nuovi dispositivi che influenzano la nostra condotta e dunque il nostro decidere o meno se seguire le regole rispetto alle custodi dell'osservanza a forma umana.

Perché scegliamo di seguire le regole dal punto di vista del custode dell'osservanza?

Perché rappresenta un deterrente che esercita su di noi una pressione, suscita delle emozioni sui destinatari che ci portano a seguire le regole in maniera preventiva, parliamo quindi della logica della tensione.

Mentre per Kelsen non esisteva il rapporto di imputazione, era un dover essere meramente ipotetico qui invece il tema è la pressione che io sento nei miei confronti da parte del custode dell'osservanza la cui sola presenza condiziona i miei comportamenti.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 15 DEL 04/11/24

Vi ricordo che cerchiamo sempre una risposta più soddisfacente sempre alla medesima domanda, ossia. "perchè rispettiamo le leggi?" e in particolare ne cerchiamo una che sia più soddisfacente di quella kelseniana che ci dice che bisogna rispettarle in quanto aventi forma tipica di una norma. In particolare abbiamo individuato la possibilità di rispondere a questa domanda attraverso lo slittamento di prospettiva, di punto di vista, da oggettivo a soggettivo.

Per fare questo, giochiamo a scacchi.

Immaginiamo tutti di non sapere nulla del gioco degli scacchi, neanche che esista, siamo degli spettatori completamente ignoranti del gioco, e osservate due persone giocare a scacchi.

Dunque cosa ricavate da ciò che vedete, senza sapere nulla del gioco degli scacchi?

Iniziamo a classificare il punto di vista: di che punto di vista si tratta? Uno esterno, assolutamente oggettivo. Più o meno con lo stesso sguardo con cui gli antropologi osservavano gli indigeni sull'isola, in modo esterno alle dinamiche sociali, attraverso un'osservazione continua e costante.

Osservando che cosa ci salta all'occhio di primo acchito? A cosa stiamo assistendo?

In primo luogo ad un'interazione tra due persone, che interagiscono in uno scontro, notiamo quante pedine ci sono di un colore o dell'altro.

E invece riusciamo a ricavare che tipo di gioco i due stanno giocando?

È un gioco in cui due persone si scontrano, in cui ci sono pari pedine, di due colori diversi e anche forse che si tratti di un gioco di strategia.

Tuttavia, non sapendo assolutamente nulla, potremmo ricavare le regole del gioco degli scacchi? potremmo scorgere un determinato tipo di regolarità (di un'azione) che poi porti ad una regola?

Negli scacchi è quasi impossibile, poiché una determinata regolarità non porta per forza di cose ad una regola e pertanto dunque come conosciamo le regole del gioco?

Le chiediamo a chi sta giocando. questa è effettivamente l'unica maniera, ma nel momento in cui noi chiediamo stiamo spostando il punto di vista, da esterno ad interno.

Tale spostamento è dunque assolutamente necessario per il nostro fine ossia comprendere le regole del gioco, poiché ci si immedesima nel giocatore, arrivando ad una comprensione maggiore del

gioco, poichè la praxis che stiamo affrontando non è una praxis naturale ma sociale e dunque bisogna immedesimarsi in chi è coinvolto in quel tipo di dinamica sociale.

Tuttavia bisogna chiedersi: tale cambiamento di prospettiva è condizione necessaria e sufficiente per la conoscenza globale del gioco degli scacchi ammesso che le regole siano state comprese? Si può dunque **conoscere** il gioco degli scacchi?

No, perchè conoscere le regole non vuol dire per forza di cose, sapersi costruire per esempio una strategia ottimale per giocare ad un gioco che si costruisce tutto sulla strategia.

Questo è infatti un livello di conoscenza successivo, nel percorso conoscitivo del gioco, di fatto ve ne sono 3:

- 1° livello - l'osservazione che ci permette di identificare quella determinata praxis come un gioco;

- 2° livello - punto di vista soggettivo, ci immedesimiamo in chi gioca e comprendiamo le regole del gioco;

- 3° livello - strategie di gioco, che ci permettono di comprendere a fondo il gioco degli scacchi comprendendo le mosse del mio avversario e dunque aiutandomi a vincere.

Dunque le strategie non sono altro che schemi di previsione di ciò che il giocatore contro di me farà, agevolandomi nel vincere.

Gli scacchi dunque sono uno dei giochi utilizzati di più come metafora del diritto, a partire addirittura da Leibniz per giungere poi a un giurista italiano, Franco Cordero, che dice espressamente che "il gioco del diritto è un gioco degli scacchi un po' più serio".

Dunque trasferiamo questa teoria nell'ambito della teoria del diritto. Cosa ne ricaviamo?

L'osservazione di tipo soggettivo ci permette di comprendere di che tipo di leggi o di norme stiamo osservando attraverso la conoscenza di qualcun altro, e quel qualcuno potrebbe rispondere che stiamo seguendo le leggi e le norme che hanno forma tipica di legge. Tuttavia nella vita di ogni giorno noi non ragioniamo così:

Sempre prendendo l'esempio del codice stradale un passante potrebbe dirci: "sono in macchina, posso attraversare col rosso?"

Noi sicuramente gli risponderemmo di no per via della presenza di norme stradali, per via della sua ed altrui sicurezza e poi soprattutto perchè rischierebbe di incappare in una sanzione pecuniaria abbastanza salata.

Abbastanza diversa è la situazione nel caso in cui ci dica "Sono a piedi, devo attraversare per forza sulle strisce pedonali?" Teoricamente bisognerebbe rispondergli di si', ma spesso e volentieri si indicano le strisce come un semplice strumento di maggiore sicurezza e non come un qualcosa da rispettare obbligatoriamente e dunque si invita a non attraversare sulle strisce, questo perchè qualsiasi cosa succeda la pressione sul pedone, nell'ordinamento giuridico è molto inferiore rispetto a quella che viene applicata sul automobilista o in genere sulla circolazione stradale.

Questo è esattamente ciò che Alf Ross dice nel '900. infatti lui dice che le regole che vanno seguite sono quelle che vengono effettivamente applicate.

E come si fa a sapere quali regole vengono effettivamente applicate all'interno del proprio ordinamento giuridico? le strategie di chi bisogna analizzare?

Quelle dei custodi dell'osservanza: le corti, i giudici, i tribunali.

La risposta di Ross è totalmente diversa rispetto a quella di Kelsen in quanto quest'ultimo ritiene che qualsiasi legge con forma tipica di legge debba essere rispettata e seguita, per Ross invece vanno seguite quelle regole che sono efficaci, ossia quelle regole che effettivamente vengono applicate dalle corti, la previsione delle strategie delle quali funge da schema di previsione sulle sentenze simili future.

Dunque così come nel gioco degli scacchi la semplice conoscenza delle regole è necessaria ma non sufficiente perché è necessario conoscere le strategie delle corti stesse.

Un esempio di questa cosa sta nella nascita della nostra storia repubblicana quando alcune norme specie quelle del codice rocco, non vennero eliminate benchè discriminatorie verso alcuni gruppi come le donne, ma seppur fossero valide nessuno le rispettava perché nessun giudice le applicava più.

Che altro possiamo dedurre da questo cambio di prospettiva?

Che la centralità si sposta dalla costruzione dell'ordinamento giuridico alle corti stesse che diventano il fuoco vero e proprio della teoria di Ross.

Rispetto dunque alle norme che io ho ragionevole certezza che verranno applicate, so già che applicheranno su di me una determinata pressione **psico-sociale.**

Dunque per Ross le norme **sono fatti psicosociali**, poiché sono frutto di una osservazione empirica di come si comportano i destinatari, al fine di generare una certa uniformità di comportamenti, attraverso una osservazione di tipo empirico.

Ross inoltre dice che sono inserite in schemi di previsione, ovviamente di come si comportano e si comporteranno le corti.

Ross dunque prende Kelsen e lo ribalta completamente, perchè dove c'è il trascendentale kantiano Ross implementa la più totale empiria, non c'è più nulla di metafisico.

Nella prospettiva di Ross possiamo individuare anche che cos'è l'ordinamento e per definire cosa esso sia bisogna anche qui cambiare la prospettiva, in quanto per lui l'ordinamento giuridico è paragonabile ad una macchina che funziona costantemente e coerentemente, l'ordine sociale produce per Ross un certo ronzio del motore ad indicare la sua giusta funzionalità, e conosce momenti di funzionamento fisiologici (in cui l'ordine sociale viene mantenuto) e momenti patologici in cui il ronzio viene sovrastato dal disordine di atti trasgressivi e in tal caso intervengono i meccanici dell'ordine sociale ossia le corti, i giudici che riparano il motore attraverso le decisioni giurisprudenziali, attraverso l'applicazione effettiva della norma.

FILOSOFIA DEL DIRITTO
Prof. Siniscalchi

LEZIONE 16 DEL 06/11/2024

-Dove siamo arrivati?
Ross?Concetto di norma giuridica e di ordinamento in Ross?
Abbiamo guadagnato, nella prospettiva dei custodi dell'osservanza, una seconda definizione di norma giuridica.
Abbiamo detto che la norma giuridica si può declinare come un fatto psicosociale.
"Fatto psicosociale" altro non è se non il prodotto di uno schema di previsione rispetto a ciò che, molto probabilmente, con ragionevole certezza, faranno evidentemente le corti, ovvero le regole che effettivamente le corti vanno ad applicare all'interno di un determinato ordinamento giuridico.

La cosa che dovete avere presente, dovete aver metabolizzato ed essere capaci poi di esporre in seduta d'esame, sono tutti i passaggi, la consequenzialità dei passaggi: la metamorfosi della nozione della definizione di norma giuridica e di ordinamento; norma giuridica come schema di previsione, norma giuridica come fatto psicosociale e l'idea che l'ordinamento altro non sia se non un insieme di fatti psicosociali che esercita una pressione su tutta una comunità di destinatari, finisca per assomigliare, per essere paragonato ad un ronzio di una macchina quando funziona regolarmente *(quindi fase fisiologica e fase patologica)*..La cosa importante *(che poi sarà una delle modalità che chiederò all'esame)* è dimostrare tutta la consequenzialità logica, cioè queste definizioni noi le andiamo a ricavare proprio nel momento in cui cambiamo prospettiva. Sono diretta conseguenza del fatto che noi abbiamo cambiato punto di vista e quindi dal punto di vista oggettivo logico-formale alla Kelsen ci siamo postati verso un'altra prospettiva: il punto di vista soggettivo dei custodi dell'osservanza, o almeno di un certo tipo di custodi dell'osservanza (*oggi analizzeremo un altro tipo di custodi dell'osservanza).* Il problema, dunque, è far vedere come in quella prospettiva la validità diventa obbligatorietà o efficacia, quindi le norme giuridiche che devo seguire sono le norme efficaci, quindi quelle che vengono effettivamente applicate dalle corti.

Questo come retro-agisce sulla definizione di norma giuridica?
Non c'è più una definizione logico-formale, la norma non è più uno schema di qualificazione trascendentale ma se le norme che devo seguire *(vedete, la domanda è sempre la stessa...partite dalla domanda "Perché devo seguire le regole?" ed a seconda di come rispondete, la diversa risposta vi permette di costruire tutta una serie di definizioni diverse rispetto ai concetti cardine della teoria generale del diritto, dell'epistemologia giuridica che stiamo andando a costruire)* sono quelle effettivamente applicate nelle corti, queste norme sono quelle che esercitano nei miei confronti una pressione psicosociale perché io prevedo (schema di previsione) che quelle siano le norme che sicuramente verranno utilizzate, applicate da chi usa il diritto.
Chi usa il diritto?
Le corti.
L'ordinamento giuridico, allora, in questa prospettiva, come si configura? Come un insieme. Non più di norme che altro non sono se non schemi logico-formali, ma di norme che si presentano come il. Prodotto di una pressione psicosociale che condiziona i miei comportamenti in funzione della

previsione che io faccio rispetto alle regole che le corti verranno quasi sicuramente ad applicare e dunque a rendere efficaci.

Tutto nasce dalla nostra domanda, se noi modifichiamo la risposta alla nostra domanda riusciamo a costruire tutta una serie di concetti, consequenzialmente, che sono diversi rispetto ad esempio all'architettura logico-formale trascendentale costruita da Hans Kelsen.
Certo, siamo sempre su un piano positivista, stiamo sempre ragionando attorno al positivismo giuridico, ma ci sono differenze fondamentali nel rispondere "devo seguire la regola perché ha la forma tipica della norma" e "devo seguire solo quelle regole efficaci, cioè solo quelle regole che effettivamente hanno forza obbligatoria all'interno dell'ordinamento giuridico".
Sono due risposte che escludono una deriva giusnaturalistica, ma tra di loro sono due risposte profondamente diverse.
Oggi andremo a vedere come ed in che termini. Hanno anche riferimenti filosofico-culturali radicalmente diversi, pur essendo Alf Ross un allievo diretto di Hans Kelsen .

Cosa manca all'interno della nostra costruzione di una teoria generale del diritto?
-Fate il paragone con la dottrina pura del diritto e con l'architettura kelseniana.
Abbiamo dato una definizione di norma giuridica nuova, abbiamo dato una definizione della proprietà fondamentale che ci permette di identificare una regola come norma giuridica, non più la validità ma l'efficacia, anzi la validità declinata come efficacia o come forza obbligatoria. Abbiamo definito che cos'è l'ordinamento giuridico, la macchina del diritto, fase fisiologica e fase patologica.
Cosa manca al quadro che abbiamo elaborato partendo dal punto di vista soggettivo dei custodi dell'osservanza? Rispetto a Kelsen cosa ci manca? Il tema che ci ha stordito maggiormente nell'esposizione di Kelsen qual è?
-Perché dobbiamo rispettare le norme
-E quindi la risposta è che rispettiamo le norme perché queste esercitano nei nostri confronti pressione psicosociale...Che cosa manca nel momento in cui abbiamo definito norma ed ordinamento? Cosa manca rispetto alla definizione di ordinamento?
-Forse il sostituto della norma fondamentale?
-Bravissimo! Chi accende il motore? Chi mette in moto la macchina? Qual è il fondamento dell'efficacia dell'intero ordinamento se qui la validità si dice efficacia.

Qual è qui il problema? Secondo voi, in una concezione di positivismo giuridico alla Ross potremmo immaginare il presupposto logico-trascendentale per giustificare il fondamento dell'ordinamento? Radicalmente no.
Perché? Perché la teoria di Ross si caratterizza per un elemento fondamentale: per Ross le teorie o sono empiriche, radicalmente empiriche o non sono teorie.
La norma fondamentale è tutt'altro che un oggetto giuridico, anzi, è un oggetto metafisico, nel senso più classico del termine... e dunque? Dove possiamo ritrovare il fondamento dell'ordinamento giuridico?
Se tutto si risolve, nella prospettiva di Ross, all'interno del discorso del diritto, è chiaro che, iniziando da una collocazione geografica "dentro e fuori", fuori dall'ordinamento non c'è spazio per alcun tipo di fondamento.
Ross rimprovera a Kelsen il fatto che la sua teoria puzza di metafisica, gli dice: "Tu sei stato bravissimo a scardinare il giuspositivismo e a costruire una scienza del diritto che si è liberata da ogni influenza da parte di altri saperi, la dottrina pura del diritto...C'è, però, un problema: tutta la costruzione della teoria del diritto di Kelsen, dunque la missione ordinamentale di Kelsen, si fonda su un presupposto metafisico. Alla fine, se è vero che tu svuoti la norma fondamentale di ogni contenuto...

Vi ricordate? La norma fondamentale è un atto di pensiero e non un atto di linguaggio, è un principio logico-formale trascendentale, una condizione di pensabilità e di possibilità, è una

proposizione dautologica, quindi non ha un significato, ripete ciò che già sappiamo attraverso la Costituzione.

Se tutto questo è vero, c'è però un problema: il modo in cui tu fondi la validità dell'ordinamento giuridico è esattamente identico al modo in cui fondano la validità dei sistemi giuridici i giusnaturalisti, perché ipotizzi un fondamento extra giuridico (perché la norma fondamentale non appartiene al linguaggio giuridico.... è vero che è un oggetto logico-formale ma è pur sempre un oggetto e se non è trascendente, nel senso dei giusnaturalisti, è trascendentale nel senso kantiano...ma comunque hai fondato un sistema logico-formale su un presupposto metafisico. Non solo, ma il modo …(*vi ricordate le prime lezioni? Come ragiona un giusnaturalista? ***DOMANDA TIPICA ALL'ESAME*** Non "che cosa dice…", ma "come ragiona…". Qual è lo schema di ragionamento di un giusnaturalista?*
Lo schema è quello di ipotizzare due ordini di valori: le norme ed i fatti che sono esterni al mondo delle norme . Le norme devono essere seguite, anzi, sono giuste se il contenuto è conform4e al sistema di valori extra giuridico.
Qui si, abbiamo svuotato il contenuto, perché è tutto logico-formale, ma il modo di ragionare è sempre lo stesso. Fondi tutto il discorso giuridico su un presupposto che giuridico non è, ma che è metafisico. Hai sostituito alla visione di Tommaso d'Aquino e di Sant'Agostino la metafisica kantiana.
Sappiamo la differenza fondamentale che passa tra un sistema e l'altro)
Però il modo in cui tu fai l'operazione più importante, cioè individui il fondamento logico di tutto il tuo discorso, è il modo che tu hai mutuato dagli schemi di ragionamento giusnaturalisti.

Vi ricordate la critica che faceva Schmitt, la "Politische Theologie", la "Teologia politica"? Alla fine chi è che fonda l'ordinamento giuridico? Chi ha il potere della decisione, chi è più forte, chi ha il potere di instaurare e mantenere l'ordine giuridico.
Tutto sommato la norma fondamentale assomiglia ad un Dio secolarizzato, ad una divinità secolarizzata, svuotata di ogni contenuto, che rappresenta il fondamento dell'ordine sociale. Ma il meccanismi è sempre un sistema di ragionamento a base giusnaturalista o addirittura, in alcuni casi, suggerito dalla teologia.

Vi avevo detto come quasi tutta la teoria del diritto e la scienza giuridica del Novecento, anche negli autori più positivisti, pensiamo a Kelsen, padre del positivismo giuridico, ci sia una fortissima influenza ed il mutuare continuo di forme e schemi di ragionamento che vengono dal discorso teologico.
Ahimè, aveva ragione Schmitt quando parlava di "Teologia politica" nel Novecento.
Moltissime delle costruzioni dogmatiche (*anche il termine...la scienza giuridica o scienza del diritto nel Novecento, il positivismo si identifica con la dogmatica giuridica, ma la dogmatica è la scienza di chiara derivazione ed ascendenza teologica.*
Quindi, se dovete utilizzare un discorso di riferimento per cercare di interpretare le forme e gli schemi della teoria generale del diritto del Novecento, il discorso teologico è sempre un ottimo presupposto per interpretare e comprendere come hanno ragionato i teorici del diritto ed i giuristi, almeno fino agli anni Ottanta del secolo scorso.
Vedremo, e sarà la sfida del nostro corso, che il discorso teologico tramonta ed il diritto, invece di guadagnare ancora terreno, perde ulteriormente terreno perché inizierà a mutuare gli schemi e le forme dal discorso economico. Ci sarà una sostituzione del teologico con l'economico. Vedremo poi questo a cosa porterà...)

La stessa idea della struttura piramidale... (ci sono dei bellissimi studi di un egittologo, Jan Hassman, uno studioso dell'egittologia e della teologia politica che si accorge, proprio studiando la dinamica delle piramidi, che è Kelsen, poi, fondamentalmente...)
Fino al Novecento tutti i grandi modelli sono sistemi piramidali, ma quella piramide che

rappresenta il triangolo, un sistema gerarchico, è un'immagine tutta profondamente teologica. Il diritto mutua anche il modo di guardare e rappresentare l'ordinamento.
Da questo punto di vista, e non solo, Alf Ross, in tutti i suoi libri, rappresenta una novità enorme nel panorama della teoria generale del diritto del Novecento perché Ross tenta veramente di sbarazzarsi di tutta questa architettura teologica; cioè per Ross il diritto è sollo e soltanto quello che possiamo osservare e percepire empiricamente. Ed allora, in questa visione radicalmente empirica del discorso giuridico, il fondamento dell'ordinamento non può che essere interno al diritto stesso.
Di qui l'idea di Ross di edificare il fondamento dell'ordinamento, ovvero la scintilla che mette in moto il motore, la macchina del diritto, all'interno della stessa Costituzione, all'interno delle stesse leggi costituzionali.
Dove e perché ravvisa lì la possibilità di fondare l'ordinamento giuridico?
Ross dice che ogni Costituzione contiene al suo interno delle norme che prevedono i criteri di revisione costituzionale, anche la nostra Costituzione.
In televisione sentite costantemente i dibattiti sulla necessità di cambiare la Costituzione.
Dov'è il problema? Il problema è che le Costituzioni come la nostra, che sono Costituzioni rigide, non cambiano. Non è possibile da parte del legislatore, qual si voglia sia il legislatore di turno, mettere mano alla carta costituzionale perché quella è la prima legge, che identifica il nostro sistema *("L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro").*

Ogni volta si pone il problema di avere in mano dei criteri, che si chiamano criteri rafforzati, ovvero, ad esempio, particolari maggioranze parlamentari, che possono revisionare gli articoli della costituzione.
Questo che significa?
Questo significa, secondo Ross, che se queste norme alla Kelsen contengono i criteri formal-procedurali per modificare la prima legge dell'ordinamento, forse il fondamento di tutto l'ordinamento lo possiamo ravvisare in queste norme, cioè nelle norme costituzionali che contengono i criteri di revisione della Costituzione stessa.

Domanda che mi dovreste fare: "Chi valida le norme di revisione costituzionali?".
Qui l'idea, lo stratagemma di Ross: se appartengono alla Costituzione vuol dire che quelle norme sono a loro volta validate dalla Costituzione stessa, cioè sono per un verso i criteri di validità della Costituzione perché indicano le modalità attraverso cui io posso trasformare o modificare le norme costituzionali, per altro verso il regressus in infinitum non si crea perché quelle norme, essendo delle norme costituzionali, sono a lor volta validate dalla Costituzione a cui appartengono; quindi, dice Ross, non c'è bisogno di andare ad ipostatizzare un fondamento logico-trascendentale esterno all'ordinamento. La Costituzione può essere sia prima norma del sistema, sia norma che si autolegittima in base alla presenza al su interno di norme che contengono criteri di revisione della Costituzione stessa.

Bene, dal punto di vista di Ross, che ,ribadisco, ha spostato l'ottica attraverso cui noi stiamo guardando il diritto. L'ottica di Ross non è più solo logico-formale. Questa soluzione è pienamente accettabile.

Domanda: "Da un punto di vista kelseniano, logico-formale, è accettabile questa soluzione? Oppure Kelsen ha ragione a continuare a difendere fino all'ultimo l'idea della norma fondamentale come presupposto esterno all'ordinamento giuridico? E se si,perché? O se no, perché? Dove, dal punto di vista logico-formale si può creare una crepa nella soluzione proposta da Ross? C'è qualcosa di strano, di curioso in queste norme che contengono i meccanismi per trasformare la Costituzione stessa ma che appartengono alla stessa Costituzione?

- Se non c'è qualcosa che è sopra, si può, in qualche modo, incorrere, effettivamente, nel problema...quindi Kelsen,prima di tutto, potrebbe aver ragione nel continuare con la norma fondamentale, ma perché c'è bisogno che alla base di un ordinamento ci sia qualcosa che

costruisca l'ordinamento. Se quel qualcosa è dentro l'ordinamento c'è una falla.

- Il motivo è questo fondamentalmente. Adesso vediamo che tipo di falla si viene a creare...Voi sapete che io non son uno che appena sente il nome di Kelsen si strappa i capelli dalla gioia, però, in questo caso, Kelsen non è uno sprovveduto. Dal punto di vista logico-formale tutte le sue deduzioni e controdeduzioni, considerando che il punto più bello dal punto di vista filosofico della sua teoria è la norma fondamentale, che è il ragionamento più profondo che c'è all'interno della filosofia di Kelsen, ma è anche, proprio perché filosoficamente più profondo, il punto debole, il tallone d'Achille di tutta la sua architettura, è chiaro che lui su questo tema non si è mai fatto trovare impreparato.. Se lo spostiamo, se la critica di Ross, con l'idea di quest'ultimo, la spostiamo in un ambito logico-formale, vediamo che c'è almeno un caso in cui la soluzione di Ross non è accettabile dal punto di vista logico-formale.

Qual è il caso?
Il caso è che le norme di revisione costituzionale decidano di revisionare o di modificare sé stesse. Non solo, e se modificando sé stesse decidessero di porre in essere delle nuove norme di revisione costituzionale che contengano dei criteri di revisione costituzionale opposti e contrari rispetto a quelli originariamente previsti, ci troveremmo dinanzi ad una contraddizione irrisolvibile, ovvero torneremmo in una situazione di indecidibilità. Il sistema inizierebbe a girar intorno a sé stesso perché se le norme di revisione originali sono valide, non sono valide quelle che abbiamo derivato logicamente dalle stesse. Se, invece, sono valide le seconde, non sono più valide le prime, ma l'invalidità delle prime travolge anche le seconde.
Siamo esattamente all'interno del paradosso della ricorsività “io sto mentendo”, che era il paradosso della norma fondamentale.
Se è vero che sto mentendo, è falso ciò che sto dicendo. Se è falso quello che sto mentendo, è vero che è falsa la proposizione.
Ci troviamo esattamente nello stesso caso, identico. Non siamo in grado di decidere in merito alla validità di norme di revisione costituzionale perché, se sono valide le prime, non sono valide le seconde, al contrario, se sono valide le seconde, allora non son valide le prime, ma quindi non dovrebbero esistere, a rigor di logica, nemmeno le seconde.
Qui c'è almeno un caso che è il caso della ricorsività dove, ancora una volta, il sistema si avvita su sé stesso. Siamo di nuovo dentro un dipinto di Escher, non abbiamo una via d'uscita, non sappiamo dove inizia: se è valida una, non è valida l'altra, se è valida la seconda non è valida la prima, ma se è valida la prima non è valida la seconda.
Se dal punto di vista empirico, dei fatti, dell'esperienza del diritto, diciamo che questa è un'ipotesi abbastanza remota, quindi, tutto sommato nella visione di Ross, quella può essere una visione accettabile, ma nella visione di Kelsen no perché quella ci porta esattamente nel paradosso che noi abbiamo evitato attraverso la norma fondamentale.

D'altronde, l'idea della norma fondamentale che noi abbiamo analizzato e ricostruito attraverso la teoria dei tipi logici di Bertrand Russell...non è che Russell e Kurt Gödel, Gödel è il più grande logico del Novecento, amico anche di Kelsen, siamo sempre nello stesso periodo, periodo della Grande Vienna, tra gli anni Dieci e gli anni Trenta del secolo scorso. Gödel è colui il quale crea il famoso “Teorema dell'incompletezza dei sistemi logico-formali”.
Dice Gödel, ancora una volta, che i sistemi logico-formali non-riescono ad auto-completarsi se non ipotizziamo un fondamento esterno al sistema, che contenga tutti gli elementi del sistema, e che sia fondamento del sistema stesso.
La “teoria dei tipi logici” di Russell spiegava, però, all'interno di un insieme di applicazioni...per altro, poi, Gödel, attraverso questi teoremi, giungerà a dimostrare l'esistenza di Dio, o l'esistenza di un Dio.

Kelsen non è uno sprovveduto, quindi, dal punto di vista logico-formale continua ad avere ragione lui. Dal paradosso del fondamento di validità dell'ordinamento noi non ne usciamo.
Certo, se cambiamo prospettiva, allora cambia il gioco.
Direbbe Wittgenstein:" Stiamo giocando ad un altro gioco, ma se giochiamo ad un altro gioco, allora non valgono più le regole del gioco precedente, anche se i due giochi si assomigliano".
Però abbiamo cambiato gioco, abbiamo quindi cambiato punto di vista, semplicemente.
Ovvero, voi sapete che dietro il termine, l'espressione "punto di vista" noi intendiamo l'approccio metodologico, il modo di studiare, di costruire un metodo per conoscere l'oggetto di diritto, l'oggetto giuridico.
Ora vedrete proprio come si opera cambiando la prospettiva.
A seconda della prospettiva, a seconda dell'epistemologia che noi utilizziamo, abbiamo un oggetto, costruiamo un sapere sul diritto che risulta essere diverso.
La famosa Einleitung, introduzione, alla "Fenomenologia dello spirito" di Hegel dice proprio questo,che costruiamo l'oggetto a partire dal metodo di conoscenza che scegliamo per approfondire quel determinato oggetto, che cambia a seconda della prospettiva.
Qui il gioco è proprio questo, è proprio questo che stiamo facendo.

Quindi, se giochiamo al gioco di Ross, allora, tutto sommato, il suo gioco è coerente col suo approccio metodologico. Dove Ross sbaglia? Egli sbaglia nel dire che poi il suo approccio potrebbe essere anche un modo per criticare la metodologia kelseniana. Quello no! In quanto si tratta di due giochi diversi. Uno gioca sul piano logico-formale (Kelsen), trascendentale, l'altro gioca su un piano squisitamente empirico (Ross).

A conclusione di tutto questo quadro che stiamo analizzando rispetto alla prospettiva dei custodi dell'osservanza, quali sono, quali potrebbero essere, le correnti, i movimenti di pensiero che nutrono l'approccio metodologico di Ross?

A questa cosa tengo particolarmente in quanto uno degli obiettivi del mio corso, di tutto il mio percorso di studi del diritto, ed in questo caso è davvero una lotta contro Kelsen, è l'idea per cui il positivismo, il formalismo giuridico, la dottrina pura del diritto, in realtà, anche quella sia frutto di uno Zeitgeist (uno spirito del tempo). Cioè il diritto, alla fine di questo corso, una delle idee che vorrei farvi passare, tutto è tranne che una tecnica di regolazione sociale, ma è una "forma dello spirito" (per dirla alla Hegel), quindi per comprendere il diritto non servono soltanto delle tecniche di interpretazione delle norme, ma quelle tecniche vanno sempre inseriti in contesti culturali molto più ampi: la stria, la geografia, la letteratura, addirittura il cinema, le arti visive, si contamina continuamente. Non ci capirete nulla del diritto contemporaneo con uno sguardo rigidamente logico-formale. Avrete bisogno, senza dubbio, degli schemi di ragionamento perché,ormai, gli schemi di ragionamento non ve li insegna più nessuno sulla metodologia giuridica, ma quegli schemi di ragionamento dovete sempre essere in grado di acquietarli considerando il diritto come una forma di cultura e non come una tecnica di regolazione sociale.
E lo vedete, le teorie del diritto non nascono come funghi nelle menti de giuristi che vivono appartati, o meglio, quelle che nascono così si dimenticano dopo qualche anno. Quelle interessanti sono quelle che mescolano il diritto con altre branche del sapere. Lo stesso Kelsen che tutto sommato trasferisce sul diritto da un lato Kant, ma in quegli anni la logica-formale è soprattutto del Neokantismo. Quindi tutta la logica trascendentale è di filosofi come Ernst Cassirer, Hermann Cohen, ed anche altri filosofi tedeschi di quell'epoca. Ed anche lo stesso Kelsen ha scritto dei libri meravigliosi su Dante e sulla Divina Commedia. Kelsen, ad un certo punto, si misura con alcune nozioni che derivano dalla letteratura, un po' per mettere meglio a fuoco i concetti della sua teoria generale del diritto.

Ross, invece...
Quali possono essere le filosofi che nutrono l'approccio metodologico di Ross? In che quadro concettuale e culturale possiamo inserire Ross? *Vi do qualche indizio*: che cosa è la norma per Ross?
- L'Empirismo.
- Non solo l'Empirismo, ma anche una particolare forma di Empirismo, che è il Neoempirismo logico che è la versione della logica-formale che aveva influenzato Kelsen molto più radicale, dove, in realtà, l'empirista logico basa, costruisce tutta la sua teoria della conoscenza sul principio di verificazione.

Che cos'è il principio di verificazione?
Quel principio secondo cui sono vere, e dunque scientifiche, solo quelle proposizioni che io posso verificare attraverso l'esperienza.

Prendete questo schema di ragionamento e trasferitelo all'idea di Ross.
Perchè, cosa dice Ross?
Sono norme solo quelle norme la cui applicazione, in quanto norme, posso verificare empiricamente.
Qual è il metodo di verificazione di una norma?
L'applicazione della norma da parte delle corti ed il fatto che noi effettivamente seguiamo quella norma.

Se per Kelsen il principio di verificazione è tutto logico-formale
es. Perchè non devo fumare?
Se la regola ha la forma tipica di una norma, io non devo fumare.
La verifica è tutta astratta, è tutta logico - formale.

In Ross, invece, il principio di verificazione si svolge empiricamente.
Quali sono le regole che devo seguire?
Quelle di cui posso verificare l'effettivo uso all'interno dell'ordinamento giuridico.
Come verifico l'effettivo uso all'interno dell'ordinamento giuridico?
Sono semplicemente quelle norme che usano le corti e che dunque producono pressione psicosociale nei confronti dei destinatari.
La verifica è tutta empirica, è un trasferimento, si traslano i principi cardine del Neoempirismo logico alla teoria generale del diritto.

Principio di verificazione in ambito scientifico e filosofico, principio di efficacia, di effettività nell'ambito giuridico.
Quali sono, potremmo dire, *ma non lo ripetete perché potrebbe dare adito a confusioni*, "Quali sono l vere norme?", *anche se sappiamo che la verità non si predica della norma*, quindi quelle norme che io devo veramente seguire.

Le norme che sono efficaci, che effettivamente si usano all'interno dell'ordinamento giuridico.
Quali sono queste norme?
Quelle che producono pressione psicosociale, che son seguite dai destinatari perché questi prevedono la loro applicazione da parte delle corti.
Non c'è nulla di trascendentale, non c'è nulla di trascendente. La verifica circa la norma o meno è una verifica che si muove, che si sposta solo e soltanto su via empirica.
Neoempirismo logico.
Dunque, l'approccio logico-formale trascendentale di Kelsen cede il passo al Neoempirismo logico.

C'è almeno un'altra suggestione filosofica che entra all'interno della teoria di Ross e la rende

assolutamente moderna e contemporanea rispetto a Kelsen.
Cosa fa la norma?
Le norme sono un fatto psicosociale e dunque all'interno della teoria del diritto irrompe la dimensione psicologica perché le norme intanto le seguiamo perché svolgono una costante pressione psicosociale nei nostri confronti, quindi noi interiorizziamo attraverso la pressione psicosociale la forza obbligatoria della norma per la prima volta.
Se ragionate, anche qui, è evidente il passaggio.
Se da un punto di vista rigorosamente oggettivo dove il soggetto...
Che cos'è il soggetto in Kelsen? *Riduciamo all'osso i residui di soggettività...*Kelsen vuole individuare un fondamento dell'obbligatorietà che sia il più oggettivo possibile. Allora, per essere massimamente oggettivi, riduciamo ogni possibilità di soggettività all'interno del discorso giuridico. Il soggetto del diritto, il destinatario di Kelsen è un mero centro di imputazione di interessi. Tutto sommato si definisce in funzione della norma come schema di qualificazione. È una funzione della norma come schema di qualificazione.
Se cambiamo il punto di vista, se cambiamo la prospettiva, è chiaro che nel momento in cui il punto di vista diviene soggettivo e non più oggettivo, la soggettività irrompe all'interno del discorso giuridico.
E nel momento in cui irrompe la soggettività e quindi noi diventiamo protagonisti anche della costruzione del discorso del diritto, è evidente che la dimensione psicologica si affacci all'interno della teoria generale del diritto. L'efficacia non è più una proprietà logico-formale, l'efficacia è quella forza che preme nei nostri confronti e che fa si che noi seguiamo le regole ed è una forza che a livello sociale crea uniformità dei comportamenti.
A livello psicologico condiziona costantemente, continuamente il nostro modo di comportarci alla prescrizione individuata dalla norma e dalla regola.

È interessante dal punto di vista storico- filosofico. Vi avevo detto che Kelsen intrattiene, ad un certo punto della sua carriera di studioso rapporti, si incrocia con Sigmund Freud.
L'incrocio dura poco, si scontrano poi sul concetto di massa. Pensate un po', il tema della rilevanza delle masse per il discorso giuridico.
L'ultimo Freud è quello che dalla dimensione psicanalitica dell'individuo, tenta di analizzare la psicanalisi delle masse e quindi del modo in cui si muovono i popoli, “Totem e tabù”, gli ultimi lavori di Freud sono tutti rivolti al tema della massa.
Kelsen è molto perplesso, ma Kelsen è perplesso in genere, è curioso ma è frenato dall'irrompere della soggettività psicanalitica all'interno della teoria generale del diritto, tanto che, ad un certo punto, i due sentieri si separano.

Ross, invece, è attratto dal tema della psicanalisi di Freud e non solo dalla psicanalisi di Freud, ma in particolar modo dalla psicanalisi di Jung. Quindi, essendo così attratto dalla psicanalisi di Junge, partendo da questi studi inizia a pensare che tutto sommato come il tema del seguire le regole, del perchè seguiamo le regole, non possa ignorare la dimensione psicologica o psicanalitica della nostra predisposizione, interiorizzazione alle regole, ad un mondo costruito di regole.
L'intuizione di Ross è geniale perchè gran parte delle teorie post-moderne del diritto partiranno dal riconoscere una dimensione psicanalitica preponderante al tema del perchè devo seguire le regole e probabilmente c'è chi ci dirà “seguiamo le regole perchè siamo addestrati a seguire qualcosa, siamo disciplinati continuamente nell'essere sensibili ad un mondo fatto dalle regole”, ma è chiaro che questa supposizione, questa abitudine, quest disciplina si radica in una dimensione che è tutta psicologica e psicanalitica.
Quindi l'intuizione di Ross è veramente un'intuizione feconda e profonda, considerando che siamo in ogni caso nella seconda metà del secolo scorso, siamo negli anni Sessanta.

Ultima considerazione sul perché reputo questo quadro teorico interessante: la teoria di Ross è una delle poche teorie del Novecento che ha ancora da dire qualcosa al mondo contemporaneo.

In Ross l'asse della teoria generale del diritto da chi è rappresentato? Il fuoco di tutta questa costruzione, di tutta questa architettura teorica, da chi è rappresento?

- Dalle corti

Sono le corti.
Per Kelsen è il linguaggio del legislatore che costruisce il sistema, incardina i livelli, e quindi la teoria generale del diritto kelseniana è tutta focalizzata nell'identificare il discorso giuridico come un ordinamento che altro non è che forma giuridica di quello che noi chiamiamo Stato.
L'ordinamento giuridico è la struttura giuridica dello Stato.
In Kelsen si identificano i due concetti, ordinamento e Stato. L'asse è tutto concentrato sulla costruzione logica del linguaggio del legislatore.

In Ross il baricentro della teoria cambia radicalmente perchè qui invece sono gli atti di linguaggio prodotti dalle corti, sono le decisioni delle corti che ci dicono cosa è il diritto e cosa non lo è, perché, vi dicevo l'altra volta, e non siamo in un'ipotesi di scuola, che ci possono essere norme valide in un ordinamento, ma se le corti decidono di non applicarle più, quelle non sono più norme, non le segue più nessuno perché tutti sanno che quelle norme non producono più forza obbligatoria.

Es. passaggio dall'ordinamento fascista all'ordinamento costituzionale-democratico, la storia repubblicana dell'Italia: non si riuscì ad abrogare tutte le norme del Codice Rocco, le corti iniziarono a non applicarle più perché non erano conformi ai nuovi valori costituzionali.

Vedete come la teoria di Ross è molto più interessante perché riesce a spiegare meglio come funziona effettivamente il discorso giuridico, ma l'idea di spostare dal centro, dal linguaggio del legislatore al linguaggio del giudice, al linguaggio delle corti, ha un'altra funzione (*qui Ross è stato profetico rispetto a Kelsen, considerate che l'ultimo Kelsen scrive l' "Allgemeine Theorie der Normen", "teoria generale delle norme" negli anni Settanta, quindi Kelsen ha scritto fino quasi alla fine degli anni Settanta. È un tema che non intendo portare in quanto l'ultimo Klesen rinnegherà molto del lavoro che aveva fatto precedentemente. Alla fine della sua carriera Kelsen decide e definisce che le norme non sono più degli astratti schemi di qualificazioni giuridiche ma sono degli atti di decisione, passando però dal normativismo al decisionismo. Sembra mutuare e formalizzare una posizione che era stata la posizione che si era posta a lui per tutto il Novecento, che era quella di Carl Schmitt, ma questa non è oggetto delle nostre lezioni).*

Questo per dirvi che l'intuizione di Ross è profetica rispetto a quello ch vedremo nelle lezioni successive. Perché? Perché oggi a cosa assistiamo, da un po' di decenni a questa parte, sicuramente con l'ingresso nel nuovo secolo?
Ad una profonda crisi dello Stato-nazione e dell'ordinamento giuridico in quanto fonte principale del linguaggio giuridico.
Perché?
Perché si sono creati, poi, (lasciamo perdere la contro-crisi che vive la globalizzazione, tutto quello che sta accadendo negli ultimi anni), rispetto agli anni del Novecento, degli ordinamenti sovraordinati all'ordinamento giuridico che sono ordinamenti che dettano le loro direttive, i lor principi ed a cui l'ordinamento giuridico si deve adeguare.
Uno su tutti è l'Unione Europea, ad esempio, in ambito del diritto comunitario ed internazionale rispetto all'ordinamento giuridico italiano o, ancora, le enormi controversie che ci sono oggi tra multinazionali ed ordinamenti giuridici nazionali. Tutto questo ha segnato una crisi dello Stato-nazione, del linguaggio del legislatore.
A livello internazionale tutte queste controversie, tutti questi scontri, tutti questi conflitti giuridici sono risolti oggi da giudici internazionali, dai famosi tribunali internazionali che non sono altro che corti, le cui decisioni hanno forza di legge tra gli Stati, o tra gli Stati e le multinazionali. Quindi, viviamo in un mondo dove, tutto sommato, il linguaggio del giudice, soprattutto nei nuovi scenari, chiamiamoli, "globali", internazionali, ha acquisito una nuova rilevanza, che era inimmaginabile

nell'epoca di Ross, ma che eRoss aveva intuito con notevole lucidità, spostando l'asse,il baricentro della sua costruzione teorica, non solo il linguaggio del legislatore.
Fate attenzione perchè poi la legge la fa, tutto sommato perchè si parla di ius? Lo ius dicere è quello che dice il giudice. Ross ha ragione dal punto di vista della nascita del corso giuridco.
Il diritto nasce per risolvere il conflitto d'interessi, la controversia.
Dunque, qual è il soggetto che risolve la controversia?
Il soggetto terzo.
Le parti si rivolgono ad un terzo, che è la figura del giudice.
È lì che c'è l'essenza più profonda del diritto. Questa rinascita del diritto, si chiama, quello del giudice, diritto giurisprudenziale, cioè un diritto che non è fondato, radicato nel linguaggio del legislatore, ma nella giurisprudenza, cioè nelle decisioni dei giudici.

Ross è il primo, probabilmente, nel corso del Novecento ad avere quest'intuizione sul diritto giurisprudenziale. Un'intuizione che oggi si riflette in tutta la sua attualità.

●CUSTODI DELL'OSSERVANZA

Siamo partiti dalla figura dei custodi dell'osservanza ed avevamo individuato due diverse tipologie di custodi dell'osservanza...*Quali sono queste due tipologie? Vi ricordate lo svolgimento delle partite di calcio? C'erano due diverse possibilità di costruire e garantire l'ordine sociale, cioè di custodire l'osservanza delle regole durante la partita, durante il gioco del calcio…Chi se lo ricorda?*
-L'arbitro ed il VAR

Che differenza c'è? Ora potete qualificare, potete ragionare diversamente in realtà, su arbitro e VAR, perché avete più strumenti teorici a vostra disposizione per capire come funzionano.
In base a che cosa?
Vi ricordate, l'altra volta dicevamo come cambiano i comportamenti dei giocatori durante la partita se c'è l'arbitro o se c'è il/la VAR.

Qual è la differenza fondamentale? Ora avete una categoria di pensiero ulteriore per poter identificare la differenza fondamentale tra arbitro e VAR rispetto alle modalità di comportamento di chi gioca la partita.
Perché? Qual è la differenza tra arbitro e VAR?

- L'arbitro potrebbe non essere imparziale mentre la tecnologia non fa altro che registrare i comportamenti dei giocatori
- Quindi maggiore imparzialità?
- Sì
- Perfetto, quindi questo per quanto riguarda una giustizia dei comportamenti

Ci sono altre differenze che possiamo identificare?
Se stiamo giocando una partita di calcio e siamo nella nostra area di rigore, ci pensiamo due volte, noi giocatori, a fare fallo perché sappiamo che c'è un occhio imparziale che guarda ed è sicuro che il nostro comportamento venga registrato e rivisto, quindi poi ci sia l'applicazione della sanzione, quindi calcio di rigore, che viene comminato dall'arbitro nei confronti della mia squadra.
Questo cosa significa?
maggiore pressione psicosociale
il VAR come funziona rispetto a chi partecipa, gioca una partita di calcio?
Esercita una maggiore pressione psicosociale

In che senso?
Facciamo un esempio diverso, torniamo al nostro esempio di diseducazione civica sull'attraversamento della strada.

STRISCE PEDONALI e SEMAFORO ROSSO:
siamo dubbiosi sul se attraversare lo stesso anche se non ci sono le strisce pedonali.
Mettiamo il caso che ci sia una lezione universitaria alla quale non vogliamo affatto rinunciare, ma noi siamo fortemente in ritardo e ci accorgiamo che (siamo dei pedoni in questo caso) non passa nessuna auto in quel momento, ma noi siamo lontani dalle strisce pedonali. Arrivare alle strisce pedonali significherebbe fare 700 metri indietro rispetto alla mia destinazione e quindi perdere ulteriormente tempo.
Come ragioniamo?
Attraversiamo lo stesso.
Perché?
Perché sappiamo non solo che non vi è un rischio effettivo, ma sappiamo anche che anche se ci fosse qualcuno ponto a sanzionarci, tutto sommato, la regola per cui i pedoni devono attraversare solo in corrispondenza delle strisce pedonali, è una regola che ha una forza obbligatoria minima nei nostri confronti, dunque la pressione psicosociale che esercita nei nostri confronti non è tale da farci prevedere un'applicazione della norma per la trasgressione della regola.

Stesso caso, ma siamo usciti di casa in auto. Arriviamo all'incrocio che è perennemente con il semaforo rosso, i minuti passano, abbiamo fretta di arrivare in università, ci sporgiamo, avanziamo lentamente con l'auto e ci rendiamo conto che non ci sono auto né a destra né a sinistra, dunque non vi è pericolo per noi e per gli altri. Il semaforo però è rosso. Cosa facciamo? Passiamo o non passiamo?
Restiamo fermi o non restiamo fermi?
- Se non c'è un posto di blocco nei paraggi passiamo
- Se non c'è la fotocellula passiamo...

Siamo indecisi se passare o meno, ci ragioniamo sul passare o meno. Non dovremmo. Qui la pressione psicosociale è notevolmente superiore nei nostri confronti.
Facciamo un ragionamento diverso da quello del primo caso.

Terza ipotesi: siamo nelle stesse condizioni dell'ipotesi precedente, ci rendiamo conto che non ci sono rischi di alcun tipo nel passare col semaforo rosso. Vediamo però che il semaforo è munito di fotocellula o di una videocamera che inquadra chi passa o non passa. Che facciamo in questo caso? Ragioniamo sul passare o non passare? O no? O escludiamo completamente l'ipotesi del passare? Prima ci avremmo pensato...Ora lo escludiamo? Perché?
Perché con la fotocamera siamo ragionevolmente certi che la nostra trasgressione venga poi sanzionata, cioè che la regola sia effettivamente applicata.
Dunque, il mezzo della fotocamera garantisce una maggiore efficacia, maggiore effettività alla norma che dice che con il semaforo rosso mi devo fermare.
Perché? Perché esercita nei nostri confronti, alla Ross, una pressione psicosociale notevolmente superiore.

Vi fermate. E se la fotocellula fosse spenta? Nel dubbio vi fermereste lo stesso?
esempio di Siniscalchi che passa con la ZTL attiva nel centro di Roma convinto che fosse disattiva e che non gli sarebbe arrivata la multa, ma non è andata proprio così

Proprio perché dinanzi a questi meccanismi, dispositivi di rilevazione della possibile trasgressione di un comportamento, è ragionevolmente certo che la norma sia efficace, si effettiva, cioè che la sanzione venga applicata.
Poco importa se la fotocellula sia operativa o no perché noi nel dubbio avvertiamo la pressione psicosociale. Potremmo anche ignorare se la fotocamera sia accesa o spenta, la pressione

psicosociale è data dalla presenza del dispositivo, dalla presenza dell'oggetto. La stessa cosa, se torniamo all'esempio della partita di calcio, lo vedete nelle partite di calcio. Ci sono dei saggi interessantissimi da parte dei sociologi del comportamento su come sono cambiati i comportamenti dei giocatori e le dinamiche nelle partite di calcio da quando hanno inserito il VAR. non sono studi di calcio o di sport, sono studi di sociologia dei comportamenti perché il livello di condizionamento psicologico, sapendo di poter essere visti con certezza in qualsiasi momento, altera le dinamiche, la relazionalità del gruppo sociale, in questo caso dei giocatori che giocano a calcio.
E perché c'è questa alterazione?
Semplicemente perché cambia la pressione psicosociale che viene esercitata da questi dispositivi e questa pressione psicosociale dove mostra la sua forza e la sua differenza rispetto a quella teorizzata da Ross?
Qual è il punto divergente tra un tipo di custode di osservanza e l'altro? La pressione psicosociale come viene esercitata nei nostri confronti da parte di questo custode dell'osservanza?

In maniera costante.

Attraverso che cosa?
Attraverso lo sguardo, l'osservazione costante e continua. L'idea che la pressione psicosociale nelle società contemporanee, quindi successive a quella di Ross, non sia data tanto dal classico custode dell'osservanza che è il tribunale, la corte, ma sia una pressione ormai diffusa, costante, continua, esercitata da un'altra forma di custode dell'osservanza, cioè dai dispositivi, è venuta in mente da un filosofo che non era un filosofo né un teorico generale del diritto, nel lontano 1976, quando Michel Foucault pubblica un volume famosissimo che si chiama “Sorvegliare e punire: nascita della prigione”. Il libro di Foucault è interessante perché egli scrive un libro su come cambia il regime di detenzione con l'avvento dell'illuminismo e dell'utilitarismo. In realtà a Foucault il tema della prigione interessa poco e niente, il libro è una meravigliosa metafora di come si costruiscono le nostre contemporanee ed attuali società disciplinari che sono società molto diverse da quelle che aveva ipotizzato Ross ed ancora più diverse da quelle che aveva ipotizzato Hans Kelsen all'inizio del secolo scorso. Con Foucault entriamo nella contemporaneità del discorso giuridico dove la pressione psicosociale non è soltanto quella esercitata dalle regole e dalle norme, ma è quella esercitata in maniera costante ed uniforme da dispositivi di sorveglianza che evidentemente sono di ausilio alle norme giuridiche ma in realtà la costruzione dell'ordine sociale, dunque la risposta alla nostra domanda “perché seguo le regole?” nelle società contemporanee non può più prescindere dal considerare questa forma dei custodi dell'osservanza, che , come vedremo, è una forma giuridica ma è anche una forma extra ed in alcuni casi contro-giuridica, ma le regole le seguiamo non soltanto per il timore,per l'emozione, per la previsione circa l'applicabilità da parte del tribunale, ma anche perché siamo costantemente sottoposti a quello che Foucault chiamava “regime dello sguardo” che condiziona continuamente e costantemente nostri comportamenti, uniformandoli. Questa intuizione trova la propria genesi in uno studio che Foucault fa partendo da un progetto carcerario elaborato da un filosofo che è Jeremy Bentham, del 1700, padre dell'utilitarismo, intitolato “Panopticon”, che è una grande metafora delle attuali società del controllo e dell'osservanza, dove il livello di pressione psicosociale è elevatissimo e che non si giustifica soltanto nell'ottica di Ross.

Vedete Ross com'è interessante. Tutto sommato, negli anni Sessanta/Settanta del secolo scorso, Ross, nella sua prospettiva di teorico generale del diritto, aveva intuito perfettamente moltissimi dei problemi a venire.
Per altro, se il movimento di Kelsen, positivismo giuridico kelseniano, si chiama Normativismo, perchè il nucleo centrale della teoria di Kelsen è la norma giuridica, la teoria di Ross e tutti i discepoli che si muovono attorno a quest'ultimo (la scuola norvegese, scandinava) si chiama Realismo giuridico, proprio perchè il diritto va conosciuto nella realtà dei fatti che produce.
Il diritto è un fatto, non è più una norma.
È un fatto psicosociale. Il realismo giuridico è anche ciò che nutre la teoria e la prospettiva,

decisamente più moderna, di Michel Foucault.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 17 **DEL 06/11/2024**

Allora stavamo dicendo che negli anni settanta del secolo scorso, un filosofo francese dal nome Michel Foucault inizia ad interrogarsi sulla pressione psico-sociale dunque, in questo caso, la domanda alla fine fu posta in maniera diversa da come ce la siamo posta noi, ma la domanda alla fine è sempre quella cioè perché siamo soggetti che scelgono di seguire le regole? In realtà come vedremo la risposta di Foucault è proprio in quello "scelgono" li tema, cioè secondo Foucault noi non siamo più soggetti che scelgono di seguire le regole ma siamo soggetti che non possiamo far altro di seguire le regole.
In realtà li tema che si aggancia al custode dell'osservanza che abbiamo visto in Alf Ross è proprio quello della pressione psico-sociale e dell'effettività di regole rispetto al compimento dei nostri comportamenti. L'idea di Foucault è quella per cui nei nostri confronti operi una pressione costante, continua, una pressione psico-sociale che lascia pochissimi spazi nei confronti del soggetto e che tende costantemente a rimodellare la nostra attitudine, la nostra sensibilità a comportarci seguendo regole e modelli prestabiliti. L'idea Foucault la rintraccia in un antico progetto architettonico di un altro filosofo padre dell'utilitarismo inglese cioè Jeremy Bentham. È il progetto filosofico di un istituto di pena,un istituto carcerario che si intitola Panopticon. Che cosa è il panopticon? In realtà li panottico è una trovata di idea tanto geniale quanto inquietante di Bentham. Bentham immagina, che cosa? Entrate nell'ottica di un filosofo utilitarista; siamo agli albori della nascita della società industriale in inghilterra, i centri

urbani in particolar modo Londra, iniziano a popolarsi di una serie di soggetti, che finora invece erano destinati alle campagne o alle periferie e sono gli operai.Si creano fabbriche,si creano delle nuove classi sociali,ahimè sapete bene come questa situazione indichi uno sfruttamento non indifferente della forza lavoro che proviene principalmente dalle campagne. Dunque si iniziano a costruire quelle che noi chiameremmo oggi le periferie o delle realtà suburbane ,rispetto in questo caso al centro cittadino, che tendono ad espandersi sempre di più.Perchè vi dico questo?Perchè la vita che inizia a formarsi all'interno di questi sobborghi è tutt'altro che tranquilla;Gli operai lavorano a volte 12-14 h al giorno dopo di che durante la notte generalmente si ubriacano,scoppiano inevitabilmente risse e si pongono in essere una serie di comportamenti che alterano l'ordine pubblico.Qual è la risposta in quegli anni? Iniziamo ad imprigionare, questa pratica su cui Foucalt si interroga durante tutta la vita,da dove nasce questa idea di rinchiudere qualcuno all'interno di una stanza nel momento

in cui costui pone in essere dei comportamenti anti-sociali.L'idea a Foucalt in realtà era venuta qualche anno prima studiando non tanto i comportamenti degli anti e di possibili criminali ma capendo come in realtà dietro la definizione di criminali, molto spesso si celavano una serie di forme di soggettività che semplicemente turbavano l'ordine pubblico in quanto definite come anormali o non normali,è li tema ,in questo caso,della storia della follia nell'età classica che è li suo primo grande volume dove una volta

Foucalt,inizia ad interrogarsi sull'idea che le società moderne hanno di segregare, di allontare,di rinchiudere qualsiasi forma che non sia omogenea alla forma dominante dunque quello di sbarazzarsi di tutte le forme di diversità come criminali,folli,banditi dunque iniziare queste pratiche di segregazione che iniziano con quelli che vengono definiti folli ma che poi troveranno pieno compimento con la nascita del carcere moderno,della prigione moderna che inizia verso la seconda metà dell'ottocento. *Su questo tema del carcere come luogo di segregazione e sulla rappresentazione in questo caso del carcere, faremo un seminario alla fine del corso o una lezione seminariale alla fine del corso perché in realtà li carcere è uno dei luoghi più inquietanti e più interessanti di una ricerca che abbiamo svolto un po' di anni fa e stiamo continuando a svolgere noi dell'università di Bari con l'università di Torino con una serie di altre associazioni. Perché questa ricerca sul carcere è interessante? Perchè è l'unico luogo istituzionale di cui non si ha una percezione esperienziale diretta a meno che o non ci lavori cioè non sei un addetto alla giustizia o non sei un detenuto. Quindi uno dei fatti istituzionari chiusi allo sguardo dei destinatari e qual è, come si costruisce l'epistemologia carceraria? Se io vi dovessi chiedere che immagine avete del carcere?
Come ve la siete costruita, come lo immaginate il carcere, voi che non ci siete mai entrati? La risposta sarebbe attraverso che cosa?
Intervento: La prima cosa che mi viene in mente sono le sbarre

Ma l'immaginario del carcere,il nostro immaginario sul carcere da dove proviene? Intervento I: Dai Film che abbiamo visto e dai film che avete visto ragazzi fondamentalmente, le serie televisive, da tutta una cultura di massa che ha costruito un'immagine di questo fatto istituzionale e quindi da ìl abbiamo svolto tutta questa ricerca su cui stiamo ancora ragionando sull'epistemologia giuridica che è un’epistemologia in cui la conoscenza del fatto giuridico non è una conoscenza immediata ma è una conoscenza mediata attraverso le immagini. Il carcere è li luogo per antonomasia dove ni realtà l'uomo comune conosce li fatto giuridico, tra l'altro il fatto giuridico più inquietante delle nostre società occidentali, attraverso un immaginario che è quasi esclusivamente televisivo o cinematografico. Tutte queste intuizioni si trovano già all'interno di Foucalt, quindi è proprio prendendo le mosse da Foucalt che abbiamo iniziato, non solo noi, questa in realtà è ricerca originale che abbiamo svolto solo noi ma ci sono moltissime ricerche in questo senso. Nell'ultima parte del corso spero faremo una serie di indagini iconografiche all'interno delle forme di rappresentazione del diritto, anche perché voi siete abituati ad identificare li diritto con li linguaggio scritto, in realtà li diritto ha tutta una sua architettura visiva che solo di recente è stata riscoperta, considerate che le antiche fonti sia del diritto medievale erano tutte fonti visive o iconografiche per spiegare e raccontare il diritto c'era poco di testuale e c'era molto di figurale come dicono i semiotici. Noi faremo un esercizio nella riscoperta di questo tipo di

dimensione visiva del diritto perché vi mostra come cambiano le immagini del diritto dal novecento alla contemporaneità. Detto questo anche oggi faremo un'esperienza di questo tipo. Che cosa è li Panopticon? Il panopticon è un progetto carcerario in cui Bentham immagina di fare che cosa? In realtà l'idea di Bentham è un'idea perfettamente coerente con la sua filosofia, cioè quella di dire dato che dobbiamo rinchiudere queste persone che sono persone che turbano l'ordine sociale, cerchiamo di massimizzare, di rendere più possibile utile alla comunità li fatto di tener rinchiuse queste persone massimizzando le attività che costoro possono svolgere durante il carcere e riducendo al minimo i costi. Come fare per arrivare a questo scopo, a questo fine? Bentham immagina un carcere che ha una struttura circolare (pensate al Colosseo), una struttura circolare dove le celle sono disposte sulle mura circolari del carcere a diversi piani e a diversi livelli. Le celle hanno una particolarità, adesso vedremo visivamente, le particolarità di queste celle è quella di avere la parete rivolta verso l'interno della struttura trasparente, al centro della struttura c'è la torre in questa torre è collocato un osservatore, un custode dell'osservanza.
Qual è li gioco che immagina Bentham? La torre a differenza della trasparenza delle celle ha i vetri oscurati
Intervento: Cioè li prigioniero non vede mai la guardia se passa, la guardia però vede i prigionieri.
Esatto, allora questo che significa, il gioco è proprio un gioco degli sguardi, si gioca tutto proprio fra l'essere visto e li non poter vedere. Chi è recluso è costantemente sottoposto allo sguardo del custode dell'osservanza non solo, siccome non può vedere all'interno della torre effettivamente nella torre potrebbe anche non esserci nessuno ma comunque li detenuto è condizionato nei suoi comportamenti perché pensa, teme di poter essere scrutato in qualsiasi momento e in qualsiasi istante. E esattamente la pressione psicologica della foto cellula all'incrocio, se voi sapete o non sapete se è accesa o non è accesa, anche qui voi non sapete, il detenuto non sa se nella torre c'è qualcuno che lo sta guardando effettivamente o no ma è l'architettura, il modo in cui è congeniato li dispositivo visivo che mette sempre in scacco chi è osservato, che produce sempre pressione psico-sociale costantemente, totale, nei confronti del soggetto osservato da parte dell'osservatore.
Intervento: *Questa cosa fa pensare a quello che avviene nelle sale interrogatorie*
Si certo, con li vetro trasparente, è anche esatto ma adesso vedremo come in realtà Foucalt riscopre li tema del Panopticon ma non tanto per raccontarci come lavorava con Benthan ma in quel progetto rintraccia una grande metafora di come funzioneranno le società che lui definirà società disciplinari nella post-modernità. Perché che cosa accade attraverso li meccanismo di dispositivo visivo del panopticon,dove porta questo condizionamento costante e continuo che avviene attraverso li processo di osservazione
*Vedete perché è interessante per noi che stiamo ragionando sull'osservatoio qui la pressione psico-sociale è il prodotto di un processo di osservazione,di un processo costante di osservazione. C'è un altro filosofo francese più o meno contemporaneo morto qualche anno fa, mentre Foucalt è scomparso negli anni 80 del secolo scorso, che si chiama Jacques Derrida che ha scritto su questo tema un volume che si chiama "Spettri di Marx", ha definito in realtà questo tipo di condizionamento, questo tipo di processo dell'osservazione: effetto visiera dice Derrida che l'effetto visiera è proprio li

dispositivo, li congegno che caratterizza le nostre società contemporanee come le società del controllo cioè l'idea di qualcuno che ti guarda e non può essere visto perché è mascherato da una visiera che gli copre lo sguardo, gli copre li viso.Il condizionamento costante che si crea fra chi osserva senza essere osservato e chi è osservato senza poter guardare chi lo osserva.! gioco è quello del Panopticon, la metafora però del Panopticon è in realtà una metafora che si può applicare in tantissimi contesti, anche qui l'idea di Foucalt è assolutamente profetica, geniale poiché i dispositivi che oggi chiamiamo i dispositivi di controllo, dispositivi di sorveglianza funzionano esattamente nello stesso modo, la logica del processo di osservazione e gli effetti di pressione psico-sociale che producono è esattamente la stessa. Prima di ragionare sugli effetti, guardiamoci un panopticon, dirlo è una cosa guardarlo è un'altra. Questo è li progetto originale, quello di Bentham, vedete com'è costruito. Questa è la planimetria, qui lo vedete dall'alto e poi qui vedete sezione e lateralmente, è costruito in maniera circolare e qui potete già capire com'è la dinamica qui ci sono tutte le celle e al centro c'è la torretta. Questo invece è un disegno sempre dell'epoca, vedete qui c'è la torre che si vede in secondo piano, qui c'è la parte interna della cella che è completamente visibile da parte di chi è all'interno della torre, qui c'è li detenuto che non può che essere ritratto mentre svolge la sua penitenza inginocchiato, tipico disegno dell'epoca. Qui avete invece delle rivisitazioni moderne, dovete sapere che Bentham non è riuscito a costruire li suo modello di prigione ispirato al Panopticon nella sua epoca. Ma ne sono stati costruiti, il carcere di Bari ha una vecchia parte che si può ammirare quando entrate, non la parte moderna che vedete costeggiando lungo la strada, c'è una parte molto più antica che è costruita seguendo un progetto panopticon. Quello di Bari e li carcere di Milano inizialmente nascono come carceri a struttura Panoptica, poi l'idea è stata evidentemente abbandonata. Quello che vedete qui invece ad esempio è li progetto di un carcere che si trovava ,poi lo vedrete in stato di abbandono, negli Stati Uniti che invece è stato realizzato proprio seguendo l'idea di Bentham.

Che effetti produce l'idea del Panopticon? La pressione psico-sociale che effetti in questo caso produce? l processo di osservazione panoptico produce degli effetti nei confronti di chi deve seguire le regole decisamente diversi rispetto al mero fatto psico-sociale prodotto dalle norme così come le aveva teorizzate Alf Ross, l'abbiamo detto si tratta di un processo costante, continuo, capitale. Che effetto produce nel condizionamento dei nostri comportamenti? Dice Foucalt che questa pressione costante e continua nei nostri confronti, produce un effetto che non è solo un effetto di timore rispetto alla trasgressione della norma e alla certezza dell'applicazione della pena ma essere sottoposti costantemente a questo processo di osservazione finisce per disciplinare completamente inostri comportamenti questo significa che la nostra sensibilità rispetto alla norma non è più data dal timore che ci venga applicata la sanzione ma è condizionata in maniera così costante, così continua, che noi ci autodisciplniamo seguendo la volontà di chi ci osserva. Gli effetti normativi, l' effetto di normazione nei nostri confronti è profondamente diverso, un conto è la libertà che ci era lasciata dalla predittività, dagli schemi di previsione di predittività di Ross ,li si parlava solo di efficacia o effettività delle regole giuridiche, ni questo sistema di osservazione invece attraverso questo tipo di pressione psico-sociale finiscono per disciplinare le nostre condotte, cioè noi assumiamo degli standard di comportamento che non ci permettono più sul lungo periodo di pensare di attraversare la strada con li semaforo rosso

anche se non c'è nessuno perché come dice Foucalt la pressione costante non è soltanto un disciplinamento degli atti ma è un disciplinamento dell'anima ovvero veniamo condizionati nel modo stesso di pensare, nella sensibilità stessa che noi abbiamo rispetto alla regola, lo standard fissato dalla regola è abitudine che interiorizziamo che non ci permette più di immaginare, di ipotizzare la trasgressione rispetto alla regola perché li condizionamento è cosi pervasivo, così potente che finisce per addomesticare i nostri corpi. Dunque qui vedete come il tema del perché dobbiamo seguire le regole assume tutta un'altra dimensione, finora ci siamo posti li tema perchè dobbiamo seguire le regole ingenuamente tutto sommato, abbiamo dato sempre delle risposte che ci lasciavano margini di libertà. In Kelsen siamo obbligati a seguire quelle regole che hanno la forma tipica, in Ross le regole sono norme efficaci cioè effettivamente applicati dalle corti, qui invece li tema del perché devo seguire le regole diventa un tema completamente diverso, qui devo seguire le regole perché non posso fare altrimenti, se sono inserito inserito in queste logiche sistemiche, in questi sistemi di dispositivi il condizionamento a lungo andare non mi lascia libertà di scelta, produce una sensibilizzazione al seguire le regole che è costante e continua. Foucalt usa un termine francese che si usa per l'addestramento dei cavalli li dressage, queste norme, questa esposizione a questi sistemi riescono a condizionare, a disciplinare così tanto da renderci perfettamente conformi allo standard prodotto dal sistema e dall'idea di Bentham cioè Bentham diceva che l'osservazione costante dei detenuti gli avrebbe resi per un verso inoffensivi per un altro verso produttivi rispetto agli standard dei fini, pensate alle attività svolte nel carcere, massimizziamo la produzione piuttosto che tenere tutte queste persone a non far nulla nelle celle se gli imponiamo alcuni standard da realizzare, li possiamo mettere a regime dal punto di vista della produttività economica con li minimo dispendio di energie perché qui tutto sommato la pressione psicosociale non è data più dalla presenza diffusa di guardie o dall'esercizio della forza fisica ma soltanto da un gioco psicologico che si forma tra osservatore e osservato,l'idea è geniale ed è tutta la logica del controllo che abbiamo visto, opera in maniera diffusa nelle nostre società contemporanee. Da questo punto di vista come si riflette questa logica del controllo, anche sugli strumenti che noi abbiamo analizzato finora e questo fa una riflessione interessantissima sulla metamorfosi del concetto di norma giuridica, non tanto la norma giuridica quanto il concetto di norma intesa come standard di normalità da realizzare cioè qui non c'è più l'idea di un comportamento deviante, di una trasgressione, di un fatto qualificato come illecito e della sanzione imputata che compie quel comportamento; qui c'è l'idea di creare comportamenti, di normalizzare i comportamenti rispetto a standard prefissati. L' idea, la logica è completamente diversa cioè questi custodi dell'osservanza producono effetti nei confronti dei destinatari che sono effetti profondamente diversi rispetto all'altra figura dei custodi dell'osservanza e Foucalt è stato li primo ad intravedere rischi e benefici potremmo anche ragionare sui benefici di un controllo costante e continuo rispetto alla costruzione dell'ordine poi ci dovremo chiedere che tipo di ordine abbiamo costruito in questo modo però. Non è un caso che questi dispositivi si siano diffusi a macchia d'olio dappertutto cioè che il panopticon sia diventata la metafora per raccontare, descrivere nel modo migliore la costruzione dell'ordine sociale e l'idea che troveremo, Foucalt anticipa tantissimi dei temi che noi vedremo alla fine del corso, quando vedendo il passaggio fra ordine ideologico e ordine economico all'interno del discorso giuridico, vedendo li passaggio da ordinamento a governace, ci inizieremo a rendere conto di come li diritto per come lo

stiamo studiando nel corso del 900 rispetto alla costruzione dell'ordine sociale abbia ormai una funzione residuale cioè l'ordine sociale
si costruisce non solo attraverso li diritto ma attraverso tutta una serie di logiche di dispositivi, di strumenti di controllo, di pressione psico-sociale che a volte non solo sono di accompagnamento, di reiterazione della forza obbligatoria delle norme ma in alcuni casi sono addirittura di contro giuridici. C'è stata qualche anno fa una sentenza della
corte europea che ha condannato l'utilizzo delle videocamere all'interno degli ingressi dei bagni, non ricordo se era la Fiat o un'altra grande multinazionale, dove venivano cronometrati li tempo in cui i lavoratori dipendenti sostavano all'interno dei bagni, se un tot di volte si eccedeva li tempo cronometrato dalla videocamera si prendeva una
sanzione, vedete qui la pressione psico-sociale,li controllo è addirittura esercitato in maniera contro anti-giuridica cioè è dovuto intervenire li diritto per tutelarci nei confronti di questi strumenti.Quindi se li custode dell'osservanza nel senso di Ross è un
custode che resta fermo nell'ambito giuridico queste forme non solo esortano li discorso giuridico ma molto spesso è necessario far appello al diritto per ritrovare, per essere tutelati dinanzi a questi strumenti di controllo e di sorveglianza. È tutto lì tema della privacy che ormai impazza ovunque, qui li diritto sembra che in alcuni casi addirittura è impotente a poter regolamentare situazioni che si basano su questi tipi di dispositivi che inevitabilmente condizionando costruiscono ordine o ordini sociali che ribadisco molto spesso non trovano la loro fonte primaria nelle leggi e nelle regole giuridiche; Dov'è li problema? Molto spesso questi dispositivi costruiscono un ordine sociale che ha una sua fonte di legittimazione che non essendo una fonte di legittimazione giuridica è una fonte di legittimazione di carattere economico cioè tendono a massimizzare i profitti sulla base di ordini artificiali che vengono creati e spesso sono ordini pregiudizievoli rispetto ai nostri spazi di libertà e tutela personale. È una delle più grandi questioni attuali del diritto: Quanto li diritto riesce a bloccare, fermare, a tutelarci dinanzi a questi sistemi di controllo e sorveglianza? Che forme deve reinventare li diritto? Derivano i grandi temi su cui oggi si dibatte perché molto spesso all'interno dei sistemi di governance che analizzeremo fra qualche lezione, uno dei grandi temi del giurista d'impresa poiché si occupa prevelantemente dei sistemi di governance. All'interno dei sistemi di governance coesistono fonti normative che hanno radici e legittimazioni diverse tra loro: ci sono le norme giuridiche, ic sono i dispositivi di sorveglianza, ci sono i dispositivi di controllo e l'ordine sociale che si crea è un ordine complesso dove spesso le istanze normative entrano in conflitto tra di loro e li giurista è proprio la figura che bilancia ed è chiamato a decodificare queste fonti, a creare o a costruire tutele. Da qui, due conseguenze dal punto di vista teorico che derivano dalla teoria di Foucalt: il tema della norma, la norma in questo caso è sinonimo di un processo di normalizzazione, i dispositivi producono processi di normalizzazione sociale questo significa che rendono conformi comportamenti verso standard sociali prefissati, non sono mirati a sanzionare la trasgressione ma sono mirati a massimizzare, normalizzare gli atti e i comportamenti dei soggetti che sono osservati che sarebbero in questo caso i destinatari. Qui c'è un ulteriore salto teorico, se in Ross abbiamo parlato di efficacia delle norme, qui parliamo di efficienza. Il panottico e tutte le strutture panottiche, tutti questi dispositivi, tutti questi custodi dell'osservanza tendono a
rendere massimamente efficienti i nostri comportamenti. Vedete quindi dall'efficacia che è una caratteristica tipica delle norme giuridiche si passa all'efficienza che è una serie

di strumenti normativi che tendono a condizionare, conformare, uniformare i nostri comportamenti verso il perseguimento di scopi prefissati, generalmente scopi economici; Anche qui l'origine non lo dimentichiamo, li panopticon chi lo ha ideato? Bentham, padre dell'utilitarismo cioè quella filosofia che prima ha mischiato la filosofia con l'economia e ha tentato di elaborare schemi di comportamento che potessero massimizzare l'utilità sociale fondamentalmente dal punto di vista economico e questo lo ritroviamo nella visione del panoptico: se la norma diventa un processo costante e continuo non di qualificazione di un fatto illecito per applicare una sanzione ma di processo di normalizzazione finalizzato a ottenere la massima efficienza possibile nei comportamenti dei destinatari, a questo serve li processo di osservazione da parte di questi custodi dell'osservanza.
Intervento: Esattamente è un po' come funziona l'algoritmo sui nostri cellulari, noi siamo costantemente visti e anche con uno scopo economico.
Esatto, vedremo proprio una serie di applicazioni moderne del tema del panoptico Intervento I: Qual è la differenza tra efficacia e efficienza?
L'efficacia è la proprietà che riguarda la pressione psicosociale che esercitano le regole giuridiche, l'efficienza invece è la pressione psicosociale che esercitano i dispositivi di controllo e di sorveglianza; in un caso si tratta del timore dell'applicazione della sanzione da parte del giudice nell'altro caso invece si tratta di un processo costante e continuo di normalizzazione sociale dei comportamenti ovvero di comportamenti che sono orientanti verso li raggiungimento di un determinato standard prefissato chiamati soglie di normalità. Qui li discorso giuridico è solo una componente della risposta al perché devo seguire le regole, tutto quello che noi ci stiamo dicendo adesso tornerà quando analizzeremo e affronteremo li passaggio dalla sovranità che è la caratteristica degli ordinamenti alla governance dove in realtà le strutture di governance vedremo che operano in maniera opposta e contraria rispetto a come operano le strutture ordinamentali che stiamo studiando adesso.

Solo che nelle reti che si costruiscono oggi tra economia, diritto, società, l'idea della governance è quella, quel concetto che ci permette di spiegare e dunque di conoscere il fenomeno giuridico come parte di una rete, di una serie di fenomeni che si intrecciano tra loro da cui scaturisce il nostro ordine sociale e dunque vedremo che la risposta alla nostra domanda del perché devo seguire le regole, subisce, diventa sempre più complessa.*Torneremo indietro la settimana prossima ragionando sugli osservanti, anche sugli osservanti analizzeremo una teoria classica del diritto e una teoria che riguarda la post modernità per poi attraverso Foucalt arrivare al tema della governance e introdurre l'ultima figura cioè dello spettatore giuridico, questo è il percorso che ci attende nelle prossime lezioni*

Vediamo i sistemi panoptici, prima considerazione: il panoptico ha una chiara vocazione teologica, quando eravate bambini e vi comportavate male, cosa dicevano i genitori? "Non dare gli schiaffi a tuo fratello perché anche se mamma non c'è Gesù vi guarda", ragazzi questo è un modo di ragionare panoptico cioè è il panoptico, comportatevi bene perché Dio vi guarda. Quello che Spinoza chiamava sguardo "Sub specie aeternitatis", l'occhio a chi non sfugge nulla è quello di Dio cioè la forma principale di panoptico è l'occhio divino. Vediamo

l'immagine dove al posto della torre c'è l'occhio che si apre sul tema del controllo e della sorveglianza, ancora una volta il tema del custode dell'osservanza, tutta la costruzione del discorso giuridico si radica in un immaginario che è teologico, nella concezione Cristiano-cattolica poiché per i buddisti l'occhio del Buddha non ha mai funzione di controllo. Il tema teologico è ancora una volta il tema principale, questa è un'immagina del carcere panoptico abbandonato in America, questa è l'immagine di un film di Luis Bunuel uno dei padri del surrealismo del 900 chiamato Un Cane Andaluso e il tema del film è l'immagine di quest'occhio che viene aperto e viene completamente lacerato da una lametta da barba. Proprio in quegli anni Bunuel è uno dei primi che con questo film afferma il potere dell'occhio. Quest'altra immagine di George Orwell 1984,un'altra delle grandi figure del panoptico novecentesco. Altra immagine il cui autore è Philip Dick ,un altro autore di fantascienza che ha scritto il libro "un oscuro scrutare" che è un altro libro su quest'occhio che si manifesta sui processi di osservazione e di condizionamento. Queste sono immagini di istituti panoptici in dismissione. Altra immagina sul tema del controllo oggi, di un film: il quinto potere.

C'è un problema all'interno del panoptico di cui Foucalt neanche si è reso conto ma alcuni autori successivi se ne sono resi conto. C'è uno scrittore svizzero Friedrich Dürrenmatt, autore di gialli metafisici che tendono a decostruire delle categorie giuridiche come la giustizia, la figura del giudice sono dei paradossi raccontati in forma di romanzo sui temi del diritto. C'è un suo romanzo che ragiona sul tema di chi osserva gli osservatori, in realtà Platone già si poneva il tema della repubblica cioè chi controlla il controllore? Se qualcuno ha presente il tema delle gerarchie della repubblica. Chi osserva l'osservatore? È uno dei temi filosofici contemporanei, i giuristi si interrogano oggi sull'uso che si fa dei dati raccolti attraverso gli algoritmi cioè chi ci controlla attraverso gli algoritmi?Chi ci tutela dal controllore? Oggi questo è il tema nei dispositivi panoptici di osservazione: Chi controlla i controllori?

*C'è una graphic novel di un fumettista Alan Moore, si chiama Watchmen dove si racconta di un mondo distopico dove i supereroi in realtà sono diventati dei controllori della nostra società persi tra nevrosi, psicofarmaci, stati di ubriachezza. Il tema è proprio chi guarda i watchmen cioè i soggetti che controllano l'ordine sociale, siamo sicuri che il problema non è tanto chi trasgredisce l'ordine sociale ma sono ormai chi garantisce l'ordine sociale? Domanda di Alan Moore, ormai filosoficamente attuale. Lui immagina questo mondo sospeso fra la guerra fredda dove in realtà la figura classica del supereroe è messa in discussione come chi in realtà ha bisogno a sua volta di un controllore che controlli il suo operato.

Il tema che dicevo prima, qual è il problema di queste forme di controllo che non si radicano nel discorso giuridico? Il discorso giuridico è un discorso in cui noi siamo tutelati a 360 gradi, che negli ordinamenti come il nostro repubblicani e democratici nasce all'interno della costruzione di un pensiero che passa attraverso l'iter parlamentare che è un iter democratico. Questi sistemi di costruzione dell'ordine sociale sono sistemi che noi non controlliamo, che non hanno alla base tutele legali fondati su un potere democratico-liberale condiviso da noi

destinatari, è qui la differenza fondamentale. Il problema resta anche per noi, oggi uno dei grandi problemi è proprio questo e vedremo come nel momento in cui passiamo all'interno della vecchia figura dell'ordinamento giuridico e ci affacciamo sulle nuove forme della governance economica globale, perché si è vero che oggi abbiamo visto il ritorno delle guerre fatte per pezzi di territorio ma c'è un altro livello che è il livello della grande finanza globale, della grande economia che sposta le guerre ma si muove in maniera completamente collaterale e sovraordinata alle guerre di stato e gli ordinamenti e incide non poco a livello legislativo e a livello normativo, quello è un sistema di governance. Foucalt è uno dei grandi pensatori che nel corso del secolo scorso ha intuito praticamente tutto quello che sarebbe accaduto di lì a venti ;Ha intuito la fine della crisi stato-nazione, il tema della metamorfosi del diritto da sistema prescrittivo-sanzionatorio in sistema di controllo costante e continuo, la prevaricazione di nuovi dispositivi, di nuove forme di custodia dell'osservanza che avrebbero in questo caso costituito non solo uno strumento ausiliare agli strumenti giuridici ma in alcuni casi strumenti contro giuridici che necessitano di una nuova tutela a livello giuridico. Il tema del processo di osservazione dei custodi dell'osservanza è un tema in realtà attualissimo che va continuamente bilanciato e contro bilanciato fra discorso giuridico e discorsi di altra natura che si intrecciano al discorso giuridico. Riepilogando seconda figura dei custodi dell'osservanza, qui il custode dell'osservanza si dà come dispositivo, le norme giuridiche sono molto spesso una parte di questo meccanismo più complesso che è formato da un dispositivo sociale, normativo. Le norme si inseriscono all'interno di strutture più complesse che tendono a normalizzare, quindi ad esercitare nei nostri confronti una pressione costante, continua e psicosociale per normalizzare il nostro modo di ragionare per alterare la nostra sensibilità alle regole condizionando le nostre condotte sempre verso la realizzazione di determinati standard di normalità. Dunque i dispositivi pongono in essere dei processi di normalizzazione sociale. Il caso paradigmatico Foucalt lo rintraccia all'interno della filosofia utilitarista di Bentham cioè il caso del Panoptico istituto di reclusione in cui un meccanismo visivo interamente impermeato sul guardare, osservare senza essere visti costituisce un fortissimo meccanismo di pressione psico-sociale.Il panoptico diviene una metafora per cercare di comprendere la costruzione dell'ordine sociale all'interno delle nostre società contemporanee dove non operano soltanto le norme giuridiche ma le norme giuridiche si trovano all'interno di meccanismi molto più complessi che sono i dispositivi. Nel caso che abbiamo considerato noi ci siamo fermati ad analizzare un dispositivo dove il processo di normalizzazione si radica integralmente su un processo di osservazione ma come osservava lui prima anche gli algoritmi ci osservano, qui è chiaro che il processo di osservazione bisogna intenderlo in senso figurato, metaforico e non è solo l'osservazione fisica ma è il controllo che viene fatto attraverso una serie di attività che potremmo definire come processo di osservazione.

È evidente anche che queste dicotomie che ci servono per ragionare, non sono definitive cioè finora abbiamo ragionato della prospettiva dei custodi dell'osservanza ma quando parliamo di condizionamento sociale, pressione psicosociale, psicanalisi all'interno delle teorie del diritto stiamo comunque ragionando anche degli osservanti. Quindi la prospettiva con cui abbiamo costruito la teoria è quella dei custodi dell'osservanza ma anche in questo caso Ross e Foucalt si occupano anche degli osservanti, noi abbiamo deciso di suddividere, classificare in questo

modo le teorie ma gli incroci, gli scambi fra custodi dell'osservanza e osservanti sono continui all'interno delle teorie.

All'esame dovete imparare ad inventarvi dei vostri percorsi all'interno delle teorie e delle risposte che stiamo dando

Domanda Esame: Gli osservanti

Non è detto che dobbiate necessariamente parlare subito degli osservanti così come li vedremo a partire da lunedì perché il ruolo degli osservanti lo trovate in Ross, in Foucalt ma anche in Kelsen. Aldilà delle suddivisioni l'esercizio da fare è quello di tracciare dei propri percorsi, individuate tutte le possibili connessioni che avete logico-concettuali tra nozioni, concetti, ragionamenti fatti a lezione per costruire dei propri discorsi.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 18 DEL 11/11/2024

A mettere a fuoco le serie di passaggi concettuali che forse non abbiamo ancora focalizzato nel modo migliore. La cosa secondo me più interessante riguarda le differenze fra la figura del custode dell'osservanza in Alf Ross quella che abbiamo esaminato in Alf Ross e invece la figura che abbiamo disegnato attraverso l'epistemologia di Michel Foucault cioè la teoria della conoscenza di fenomeni in questo caso sociali non solo giuridici. Quali sono queste ipotetiche differenze, alcune le abbiamo dette, altre invece le scopriamo proprio oggi, ragionando un po' insieme. Innanzitutto vi ricordate dove siamo partiti con la teoria di Alf Ross? con la teoria dei giochi in particolare con l'osservazione della parità a scacchi. Che cosa volevamo conoscere attraverso quei livelli di osservazione? C'è l'epistemologia di Ross a cosa punta? Alla conoscenza di che cosa? Perché distinguiamo quei tre livelli di osservazione? Per arrivare al concetto di efficacia, il tema è sempre partire dalla domanda "perché devo seguire le regole?" Quella teoria epistemologica mi permette di conoscere le regole che effettivamente devo seguire perché sono le regole efficaci all'interno di un determinato contesto. Perché quelle regole sono efficaci? Perché sono quelle regole che io prevedo che vengono applicate dai custodi dell'osservanza. Così ragiona un teorico che si ispira ad Alf Ross. Dunque l'epistemologia di Alf Ross è costruita e mirata a conoscere le regole efficaci all'interno di un determinato contesto sociale, il contesto sociale che guarda il gioco degli scacchi, è proprio il contesto della partita a cui stiamo assistendo.
L'epistemologia il sapere invece si costruisce attraverso la figura del custode dell'osservanza elaborata da Michel Foucault. Che tipo di sapere configura? Quella è un'epistemologia che porta a che cosa invece? Quando all'Interno del panopticon attraverso la torretta al centro dell'edificio osserviamo costantemente, continuativamente, capillarmente i comportamenti degli osservanti, che cosa sappiamo di loro? Conosciamo solo le regole che effettivamente efficaci, quelle che effettivamente dovrebbero seguire o il nostro sapere ci permette di assumere tutta una serie di altre informazioni e se sì quali? Cioè è un sapere finalizzato a vincere la partita? No, è un sapere finalizzato a che cosa? A controllare, a conoscere la pressione, è un sapere più strutturato al sapere della conoscenza dell'osservanza, la regola e la regolarità, le strategie. Bentham perchè pensa al panopticon, utilitarismo, vuole rendere più efficienti i comportamenti dei detenuti minimizzando i costi di detenzione, quindi di gestione della prigionia da parte di questi soggetti e dunque questo è un sapere che più che conoscere, tendere a conoscere le regole efficaci, cioè le regole effettivamente seguite dai destinatari è rivolto e teso a che cosa? Mira alla conoscenza delle paure di tutti gli aspetti vitali di questi soggetti che vengono osservati, è un sapere che si costruisce per fare che cosa? Per gestire al meglio, nel modo più efficace possibile l'esperienza detentiva di questi soggetti. Quindi è un

sapere orientato, a che cosa? Ad una costruzione,alla gestione di un determinato ordine sociale. È un sapere che esercita un potere. Quindi siamo dinanzi a degli schemi epistemologici che funzionano in maniera diversa perché sono evidentemente finalizzati a scopi diversi. Prima differenza, questa differenza ne comporta, né implica immediatamente un'altra come conseguenza logica, è un sapere che implica sempre l'esercizio di un potere, si acquisiscono più dati possibili

per meglio gestire l'ordine costituito all'interno dell'istituto penitenziario. Per ora stiamo ragionando sempre attraverso la metafora del panopticon, poi la abbandoneremo per ragionare ovviamente in termini di discorso che non è più discorso giuridico ma è un discorso normativo in senso generale. È un tipo di sapere che assomiglia al predizioni, alle "profezie" dell'osservanza di Ross, ma è un sapere molto più generalizzato, molto più ampio, una raccolta di dati e informazioni che si acquisiscono attraverso l'osservazione, attraverso il processo di osservazione, molto più capillare rispetto a quello invece "profetizzato" proprio da Alfross. E perché questo sapere è finalizzato all'esercizio di un potere, alla gestione dei corpi dei condannati, dei detenuti all'Interno dello spazio carcerario. Dunque qui la differenza fondamentale che poi è per noi di importanza fondamentale. Che tipo di potere è questo? È diverso dal potere nella norma in Kelsen o è lo stesso tipo di potere? (Domanda d'esame). Che tipo di potere è questo? In kelsen manca sicuramente la dimensione psicologica, non è la risposta ma è un presupposto per la risposta.
Quindi se è un potere dissuasivo, che tipo di potere è questo? Però non lo metterei in termini di solo dissuasivo perché per la norma di Kelsen ha un potere deterrente, la sanzione è un potere deterrente. Un potere coercitivo, o meglio prescrittivo sanzionatorio, che significa? Come funziona la norma in Kelsen? La norma in Kelsen funziona che se io pongo in essere un comportamento qualificato come illecito, mi deve essere imputata una determinata sanzione. Dunque questo è un potere di che tipo? Sanzionatorio, cioè un potere che qualifica negativamente un comportamento e gli imputa l'applicazione di una sanzione. In Ross come funziona il potere della norma? È simile a Kelsen oppure al caso in cui ci siamo imbattuti adesso, cioè all'idea del potere normativo in Foucault? Vi ricordate l'immagine che abbiamo dato dell'ordinamento giuridico in Alf Ross? Come l'abbiamo definito? Come la macchina del diritto. Che significa che l'ordinamento funziona come una macchina? Fase fisiologica è fase patologica. Qual è la fase patologica? Quella fase in cui il ronzio
del motore si interrompe perché c'è il comportamento deviante da parte di qualcuno che spezza l'uniformità del fatto psicosociale prodotto dal timore dell'applicazione nelle norme efficaci. Anche qui stiamo ragionando in termini di timore, la norma ha un effetto deterrente perché c'è una fase fisiologica e una fase patologica. La norma sanziona che cosa? Sanziona il comportamento deviante che turba l'ordine sociale. Tutto sommato se pur in una prospettiva diversa non siamo lontani da Kelsen, il potere giuridico funziona in questo senso, come usando un potere che tende a prescrivere una sanzione nel momento stesso in cui viene compiuto un comportamento deviante. Funzionano diversamente questi due tipi di poteri, uno funziona a monte l'altro funziona a valle. Uno reprime solo gli atti che qualifica come illeciti, l'altro è un potere che addomestica e per essere un potere che addomestica Foucault lo definisce come un potere disciplinare e lo contrappone al potere prescrittivo sanzionatorio. Perché funzionano in maniera così diversa, il potere prescrittivo sanzionatorio e il potere disciplinare? Perché Foucault è il primo nella storia del pensiero filosofico a pensare che il potere non sia ciò che ci dice cosa dobbiamo o non dobbiamo fare, ma il potere è sia ciò che crea costantemente il nostro spazio d'azione, cioè il potere non ha soltanto una funzione prescrittivo e

sanzionatorio. Tu eserciti il potere su di me perché mi dici cosa devo fare, se mi oppongo tu hai il potere di sanzionare. Ma il potere è anche ciò che mi costituisce in quanto soggetto, ovvero condiziona i pensieri, orienta i comportamenti, gestisce il carico intero della mia vita. Dice Foucault il potere nelle società disciplinari di cui il Panottico è una meravigliosa ricorrente metafora e ciò che prende in carico la nostra vita per intero e la gestisce. Dunque non è più un'istanza negativa, ma è un'istanza positiva "tu puoi negli spazi che ti dico io". Funziona in maniera radicalmente diversa, perché il primo che fa? Vi ricordate quando vi dissi che la teoria generale di Kelsen è una teoria a base libera dal punto di vista ideologico se la volessimo valutare politicamente, diremmo che la teoria di Kelsen è una filosofia liberale, perché? Il potere, in questo caso giuridico, non si prende a carico l'interezza delle tue azioni, fin quando non arrechi danno ad un soggetto terzo. Perché? Perché fin quando non compi un atto considerato illecito, sei libero di gestire la tua vita. Il potere disciplinare dice l'opposto, prende in carico l'intera gestione della tua vita, è quella la grande novità rivoluzionaria di aver considerato il Panottico come metafora per descrivere le nostre società contemporanee e qualificate non più come società del diritto, ma come società della disciplina. Accanto al potere prescrittivo sanzionatorio della regola giuridica di Foucault, si afferma nella nostra società contemporanea un potere normalizzante che il potere che costruisce continuamente e costantemente i nostri
spazi di libertà, che non gestiamo più noi autonomamente ma che sono presi in carico da chi gestisce questo potere. Dunque il potere non è l'amplificazione della realtà, ma è affermare la realtà. Non è più ciò che distrugge, ma è ciò che crea. Non è più ciò che interdice, ma è ciò che agevola, che crea, che costituisce, che costruisce. Cambia completamente la funzione del potere con il modello del panopticon. È questa la grande idea di Foucault, cambiamo l'istanza che costruisce il nostro ordine sociale. Non è più un'istanza negativa, ma è un'istanza positiva, affermativa. Lo vedremo proprio perché dicevo la volta scorsa, Foucault è una di quelle figure di transizione cioè ci permette di capire i passaggi fondamentali, l'evoluzione dalla costruzione di un ordine sociale fondato sulla sovranità e sull'ordinamento alla costruzione di un ordine sociale fondato sul concetto Governance. Foucault inizia a intravedere la crisi nel modello giuridico prescrittivo sanzionatorio del 900 e la formazione di un nuovo modello di costruzione dell'ordine sociale che Foucault non definisce come modello di Governance, ma in realtà poi
studiosi del pensiero di Foucault hanno identificato con i sistemi di Governance e vedremo che da Governance funziona seguendo direzioni opposte e contrarie rispetto alle direzioni inaugurate dall'ordinamento giuridico inteso come sistema di norma. Dunque potere che afferma e non nega, un potere che crea e non distrugge, il modello panopticon (dispositivo normativo), l'idea di dispositivi è quella di una funzione radicale un mutamento di metamorfosi nel concetto di potere, questo potere allora non sarà soltanto un potere giuridico, terza differenza nel custode dell'osservanza inaugurata da Foucault. Ma lo definiremo un potere normativo in senso lato, l'effetto normativo non è prodotto soltanto dalle norme giuridiche ma è prodotto da un insieme di dispositivi che oggi sono fondamentali per comprendere come si costruisca l'ordine sociale. Questo tema del potere che gestisce la nostra

vita in tutti i suoi aspetti si definisce potere biopolitico, ovvero la politica intesa come gestione caratterizza, costituisce e costruisce tutti gli aspetti della nostra vita, va dal biologico al sociale. Il potere biopolitico è ciò che ci costituisce come in quanto soggetti, è ciò che crea e costituisce la nostra soggettività. Foucault individua quelle che lui chiama tecniche del sé oppure pratiche di soggettivazione che Foucault recupera la possibilità di costituirsi un fuori, la recupera dal pensiero gerco antico, cioè da una serie di tecniche che tendono a costruire una soggettività che sfugga al potere e quindi per esempio c'è una riflessione di Foucault sul discorso di dire la verità sul potere, in cui alcuni filosofi greci ritestavano una serie di pratiche discorsive che erano in grado di costituire un margine al potere del loro tempo.
Quindi Foucault nell'ultima parte della sua vita, quella in cui pratica l'estetica dell'esistenza, dice che ognuno di noi ha la possibilità di rendere la propria vita un'estetica di resistenza all'omologazione che ci impone il potere. Foucault dedica l'ultima parte della sua vita alla storia della sessualità, la sessualità era un qualcosa di cui non si riusciva a parlare serenamente, Foucault svolge l'operazione inversa poiché proprio il parlare di sessualità ha creato in realtà un potere che ha costruito e costituito la nostra soggettività moderna e contemporanea, ribalta nuovamente l'indagine epistemologica da un potere che censura ad un potere che dimostra, che dialoga, che instaura pratiche discorsive. È da qui che vengono riscoperte una serie di pratiche del sé. Foucault è stato più volte accusato di non essere all'altezza di un pensatore individualista e alla fine un pensatore che ha parlato male del neoliberismo ma poi fondamentalmente la fuga per Foucault è sempre una fuga individuale non è mai una fuga che mette in condizione di fuggire tutti insieme, le pratiche di soggettivazione e discorsive che lui individua sono tutte sicure del fuori che permettono al singolo sé di costruirsi una gabbia per resistere alla pressione psicosociale del potere biopolitico. Potere che afferma, potere che nega, potere giuridico, potere normativo è un potere che ci costruisce, che ci costituisce la nostra individualità e soggettività, prendendosi carico di tutta la nostra vita, di tutti gli aspetti e dunque potere di gestione che per altro parte dall'essenza biologica, Foucault fa
degli studi sul concetto di razza. Foucault afferma che la natura non esiste ed è il prodotto dell'esercizio di un potere, e quindi non c'è via di fuga, tutto è prodotto della disciplina, esito della pressione psicosociale delle nostre regole. Da quando nasciamo, dice Foucault noi siamo addomesticati secondo un sistema di valori, un sistema di regole che esercitano nei nostri confronti pressione psicosociale. Il potere addomesticata anche il folle e quindi lo ingabbia.
Il potere giuridico si costruisce sempre come un potere che nega, che ci dice che cosa fondamentalmente non dobbiamo fare, che ritroviamo sia in Kelsen che in Ross. L'idea di Foucault è quella di affiancare a questo potere giuridico negativo un potere affermativo che Foucault definisce potere disciplinare che non tende a sanzionare quindi a proibire, bensì a costruire, a promuovere determinati comportamenti, determinati atti, determinati modi di essere, modi di pensare, che sono l'esito dell'esercizio del potere dello stesso potere. Per Foucault questo tipo di potere è un potere che caratterizza le società disciplinari e quelle che vengono definite società di controllo. Che altre differenze ci sono tra queste due figure? Che

altre differenze possiamo identificare? Questo tipo di potere crea una problematicità maggiore rispetto al potere prescrittivo sanzionatorio? Qual è il tema di watchmen,
chi controlla il controllore? Chi sorveglia il sorvegliante? E allora qual'è il problema di esercizio di questo potere normativo, biopolitico, disciplinare? Ci sono problemi di legalità e problemi di legittimità, la legalità è la giustificazione dei limiti entro cui quel potere si esercita, la legittimità riguarda la giustificazione del potere. Se il potere giuridico è sempre da un punto di vista politico legittimato, almeno nelle nostre democrazie liberali, su base politica e democratica, questi poteri disciplinari non hanno una fonte, non sono poteri legittimi. Molto spesso si tratta di poteri che sono anzi, come dice Foucault, poteri contro giuridici. Quarta ed ultima differenza che dobbiamo considerare, che tipo di custode dell'osservanza configura questo potere? Il custode dell'osservanza che c'è in Alf Ross chi è? Noi facciamo degli schemi di previsione rispetto alle regole che saranno applicate dalle corti. Il custode dell'osservanza ha un nome e ha un contro, sono i tribunali sono le corti. Il custode dell'osservanza che si affaccia attraverso l'architettura del panopticon, è senza nome, è una delle prime grandi idee soggettività, che garantiscono, gestiscono l'ordine sociale perfettamente anonimo. I poteri che si nascondono dietro gli algoritmi sono poteri anonimi, se il potere giuridico ha sempre un nome i poteri normativi sono poteri che costituiscono ordini sociali partendo da una posizione di totale anonimato. Altra considerazione, vedremo ancora come questo tipo di potere anonimo che tende ad includere, a catturare più soggetti possibili, è il tema dell'algoritmo. Il diritto cerca strumenti nuovi per normare questi poteri di carattere disciplinare, che in realtà sono poteri politici che esortano e praticano i loro poteri.
Troveremo di nuovo queste nozioni quando parleremo di Governance, uno dei pensatori che muove tutta la costruzione, applicando un potere inclusivo, un potere anonimo, tutte caratteristiche che Foucault inizia ad evidenziare in sorvegliare-punire (75) parlando e utilizzando la metafora del panopticon. La prima figura di osservatore dal punto di vista soggettivo ha una sua ormai configurazione stabile. Abbiamo 2 tipi di custodi dell'osservanza, le corti discorso giuridico prescrittivo e abbiamo una seconda figura di custode dell'osservanza il dispositivo discorso in senso ampio, potere che crea in funzione del tutto anonima e che si configura come un potere disciplinare. Dai custodi dell'osservanza ci tocca spostarci verso l'altra soggettività che guarda dal punto di vista soggettivo. Nei custodi dell'osservanza abbiamo considerato una figura di custode dell'osservanza, che riguarda la teoria classica e una figura di custode dell'osservanza che invece ci introduce alla teoria del diritto contemporanea. Faremo la stessa operazione per quel che riguarda gli osservanti, inizieremo analizzando una figura di osservante che appartiene alla teoria del diritto classica, anzi analizzeremo la teoria del diritto di un filosofo contemporaneo di Ross, che ha lavorato tantissimo con Ross e per vedremo una seconda figura di osservante di un filosofo americano che è stato allievo diretto di Michel Foucault, anche se lui rispetto a Foucault ha visto la parte illuminata del possibile potere costitutivo, cioè la possibilità che attraverso le regole si possa costruire il nostro mondo di relazionalità sociale e questo mondo tutto sommato non è poi che possiamo valutare solo gli
effetti negativi nei confronti della costruzione della nostra soggettività. Ultima

considerazione, così come le teorie dei custodi dell'osservanza non sono teorie esclusivamente degli osservatori, ma sono punti di vista verso cui abbiamo inquadrato il diritto, affiorano anche riflessioni che riguardano gli osservanti. In Ross quando si parla di fatto di tipo sociale come prodotto di uno schema di previsione. In Foucault c'è una grande attenzione per i destinatari. In entrambe le teorie c'è una fortissima commistione fra tutte queste soggettività dello sguardo, quindi anche all'interno del punto di vista soggettivo.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 19 DEL 13/11/2024

3 principali differenze tra le varie figure dei custodi dell'osservanza.

Il concetto di sapere. Quindi che tipo di conoscenza implicano le due teorie rispetto al destinatario delle norme, dunque al partecipante. Di conseguenza la profonda connessione tra sapere e potere.

In tutte le teorie il potere assume sempre il ruolo di ciò che interdice, di ciò che prescrive e sanziona dunque ciò che proibisce. Un dover essere, che evidentemente sanziona dei comportamenti, una volta che questi comportamenti compiono dei fatti previsti da una norma.

La grande innovazione che c'è all'interno di Michael Foucault è quella invece di considerare il potere come un'istanza positiva, dunque non soltanto come interdizione ma anche come promozione di determinati comportamenti. La funzione del potere cambia: passa dalla funzione prescrittivo-sanzionatoria, coercitiva, a una funzione disciplinare. Il potere quindi è ciò che disciplina costantemente e coerentemente attraverso il condizionamento e attraverso dei processi di normalizzazione sociale.

La fonte dell'esercizio del potere, nella teoria generale del diritto del 900, ha sempre un "nome e un volto" (il legislatore kelseniano, che produce il discorso giuridico che costituisce il sistema come insieme di norme, le corti in Ross). L'idea invece che permea la teoria di Foucault, (nelle pagine di "sorvegliare e punire") è proprio quella per cui il custode dell'osservanza si manifesta come una forza anonima (riferimento a "Il processo" di Kafka).

"Perché devo seguire le regole?": per Ross si seguono quelle regole che sono efficaci, cioè quelle regole di cui posso prevedere l'applicazione da parte delle corti. Per Foucault invece le regole vengono seguite perché non si può fare altrimenti, perché il processo di condizionamento è così forte tanto che non vi si può sfuggire.

INTERVENTO: si può dire che nel sistema teorizzato da Foucault ci sia un momento in cui noi arriviamo a non chiederci più perché dobbiamo seguire le regole?

Il tema fondamentale quindi è l'introiettamento così profondo della regola, tanto da seguire ciecamente la regola, senza quindi chiedersi il perché la si sta seguendo.

Foucault non è il primo ad avere un'intuizione sul panopticon di Jeremy Bentham. Qualche anno prima della pubblicazione di sorvegliare e punire, il panopticon viene rispolverato in un saggio di uno psicanalista chiamato Jacque Alain Miller. Dunque Miller rispolvera il panopticon, perché si pone il tema di un disciplinamento che diventa un condizionamento psicologico e psicanalitico, non tanto del corpo ma come dirà meglio Foucault dell'anima. Foucault parla di disciplinamento o addomesticamento dell'anima del destinatario e li definisce con un termine specifico: "I corpi docili". L'addomesticamento è un totale recepimento a livello psicologico dell'istanza normativa.

Un punto di contatto tra Ross e Foucault è la presenza dell'aspetto psicanalitico. Ovviamente non allo stesso modo, perché Ross non porta a compimento tutte le eventuali implicazioni che ci sono o che ci potrebbero essere tra la dimensione psicoanalitica e quella giuridica. D'altronde la teoria di Ross è una teoria che privilegia la prospettiva del custode dell'osservanza, non l'atto dell'osservante. Nella prospettiva del custode dell'osservanza, la dimensione psicosociale riguarda gli effetti della norma sul destinatario. Ma non ce un'analisi dettagliata del funzionamento di essa. Questo tipo di funzionamento invece è molto più presente nella teoria di Foucault. Anche se Foucault sarà uno dei più grandi critici della psicanalisi, in realtà criticandola riesce a conoscerla a fondo. Quindi è chiaro che il versante psicoanalitico anche se in maniera critica è molto presente nella teoria di Foucault.

Le 3 categorie individuate ci permettono di ricostruire le nostre teorie attraverso l'individuazione di un punto di vista: osservatore, custode dell'osservanza e osservanti. Ovviamente sono 3 concetti che si influiscono reciprocamente. Per esempio nelle teorie dei custodi dell'osservanza vengono considerati anche gli aspetti riguardanti osservanti. Naturalmente ogni teoria prediligerà una delle 3 categorie, ma in ogni caso ci sarà una rilevanza di tutte le forme di soggettività.

POSSIBILE DOMANDA ALL'ESAME: Qual è il ruolo dei destinatari all'interno della teoria di Ross?/ Le figure del destinatario nelle varie teorie.

Concatenazione delle varie figure nelle varie teorie: analogie e differenze tra i destinatari descritti dalle diverse teorie.

In primo luogo analizziamo la figura quindi dell'osservante, proveniente proprio dalla teoria generale del diritto del 900, contemporanea a Ross. Successivamente analizzeremo la figura dell'osservante elaborata da una delle teorie post moderne del diritto, che riguarda la teoria della costruzione della realtà sociale di John Searle, (filosofo americano contemporaneo vivente, che fu allievo di Michael Foucault). Quindi abbiamo il punto di vista oggettivo e quello soggettivo che a loro volta si biforcano in custode dell'osservanza e osservante: il custode dell'osservanza si biforca a sua volta in 2 figure ulteriori, ovvero, quella di Ross e quella di Foucault. Anche l'osservante si divide in due figure che sono rispettivamente correlate alle figure dei custodi dell'osservanza descritti dalle due diverse teorie (schema ad albero, costruito per bipartizioni che sono concettualmente contrapposte).

A livello semantico gli osservanti sono coloro che osservano in funzione di seguire la regola che stanno osservando, quindi il processo di osservazione descrive la funzionalità e l'atto con cui si segue la regola (es. Il cattolico osservante segue le regole imposte dalla chiesa cristiana, ovvero va a

messa). Quindi l'osservatore si limita solo alla conoscenza, invece l'osservante conosce sempre in funzione del compimento di un'azione, che si sostanzia nel seguire una determinata regola.

La differenza tra il punto di vista oggettivo e quello soggettivo consiste nella partecipazione, che ci permette di conoscere le emozioni e le ragioni di chi partecipa. Nella prospettiva aperta dalla teoria di Ross, abbiamo visto che le norme sono schemi di previsione dell'applicazione delle regole da parte delle corti. Questa previsione genera nel destinatario una pressione psicosociale, dunque la norma è un fatto psicosociale empiricamente osservabile e verificabile. Il punto soggettivo nelle teorie in Ross evidenzia il timore del destinatario dell'applicazione della sanzione da parte delle corti. Il timore è una reazione che noi possiamo conoscere solo attraverso un punto di vista soggettivo. Per quanto riguarda le ragioni per cui i soggetti partecipano ad un determinato gioco sociale, si fa riferimento alla teoria di Peter Winch: per conoscere un fatto sociale, devo necessariamente parteciparvi, ovvero conoscere e condividere le ragioni e le emozioni.

Herbert Hart si pone la stessa domanda, partendo dalla prospettiva degli osservanti. E lo fa applicando la teoria, di Peter Winch, al discorso giuridico in senso specifico.

Es. 5 ragazzi vanno a fare colazione al bar. (Il primo ordina un caffè, il secondo prende un caffelatte con cornetto, il terzo uno spritz, il quarto un ginseng, il quinto prende una spremuta d'arancia e due toast. Dopo la consumazione della colazione, ci si reca a pagare il conto e ognuno paga per se).

Ognuno usa un metodo di pagamento diverso, mettendo in atto un contratto di compravendita usando le norme. La prospettiva dell'osservante, è la prospettiva di chi usa costantemente le norme giuridiche. Ovviamente le norme si presentano sempre con una fattispecie generale e astratta, dunque usare una norma significa interpretarla, cioè applicarla dal caso generale al caso concreto. Quindi partecipare ad un fatto giuridico significa usare le norme giuridiche, che comporta quindi l'interpretazione di quest'ultime.

Ma ritornando all' esempio: il quinto ragazzo ha consumato la sua colazione ma al momento del pagamento si ricorda di non avere soldi con sé per poter pagare la colazione. Perciò chiede al quarto, che ha un conto aperto con il bar di mettere a credito anche la sua colazione, e l'amico accetta. Il giorno dopo si ripropone la stessa colazione. Nel momento del pagamento il quinto ragazzo ha dimenticato ancora una volta i soldi. Perciò si fa offrire la colazione dal terzo, e così via fino a che tutti gli amici non gli avranno offerto una colazione. Quale sarà poi la reazione degli amici? Quindi gli osservanti che tipo di atteggiamento assumono rispetto a chi attorno a loro non segue le regole? Se qualcuno ci taglia la strada con il rosso la nostra prima reazione è quella di suonare il clacson, per mostrare il nostro dissenso, rispetto al suo comportamento che non segue le regole: perche gli osservanti si aspettano una reciprocità rispetto all' osservanza delle norme. Quindi il punto di vista soggettivo di chi osserva le regole seguendole, cioè dell'osservante, si traduce in un atteggiamento critico riflessivo, rispetto alle norme dell'ordinamento giuridico.

L'atteggiamento critico riflessivo è un atteggiamento assunto da chiunque partecipi ad un fatto giuridicamente rilevante. La partecipazione ad un fatto giuridico implica una riflessione che porti ad interiorizzare e a riconoscersi nelle ragioni che sono alla base di quelle determinate regole. E dopo aver assimilato queste ragioni che giustificano l'obbligatorietà delle regole giuridiche, il nostro atteggiamento risulterà critico-riflessivo rispetto a chiunque decida di non seguire le regole che abbiamo condiviso e nel quale ci siamo riconosciuti.

L’atteggiamento critico riflessivo nella teoria di Hart ha un nome ben preciso: Hart lo definisce punto di vista interno, che è diverso dal punto di vista soggettivo. Il punto di vista soggettivo racchiude diverse forme di soggettività, a differenza del punto di vista interno, così come lo ha teorizzato Hart, che identifica soltanto la prospettiva degli osservanti. Il punto di vista esterno e interno di Hart sono delle specificazioni del punto di vista oggettivo e soggettivo che abbiamo definito noi.

POSSIBILE DOMANDA ALL’ESAME: Le differenze tra il punto di vista interno e quello soggettivo? Il punto di vista interno è un tipo, una specie del punto di vista soggettivo che costruisce la teoria generale del diritto privilegiando il punto di vista dell’osservante.

OSSERVAZIONE: anche chi trasgredisce la regola è un osservante. È osservante sia colui che osserva le regole per seguirle, che colui che osserva le regole per trasgredirle. Perciò il punto di vista soggettivo si riferisce sia a chi partecipa alla partita che a chi la governa, invece il punto di vista interno si riferisce solo a chi partecipa. Il non osservante è colui che si pone all’esterno del sistema: es. considerando un professore americano, che sta studiando il nostro ordinamento giuridico e la nostra teoria generale del diritto, il professore in questione è completamente esterno perché non partecipa al nostro gioco del diritto.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 20 DEL 13/11/2024

Abbiamo detto che il punto di vista interno e il punto di vista esterno in Hart sono tutto sommato delle declinazioni più specifiche di concetti più generali che abbiamo definito con il punto di vista oggettivo e soggettivo. Quello che ci interessa è il rapporto tra il punto di vista interno e il punto di vista soggettivo; il punto di vista interno e l'osservante che usa le regole attraverso l'interpretazione e interpretando le norme assume un atteggiamento critico-riflessivo, questo differenzia il nostro punto di vista soggettivo che è molto più ampio e varia all'interno della costruzione della teoria generale del diritto.

Se l'idea è quella di costruire i concetti del diritto partendo da questa prospettiva, e sappiamo che questa prospettiva si sostanzia in un atteggiamento critico-riflessivo, ovvero nell'uso cbe si fa nelle norme, torniamo all'esempio della colazione al bar: ognuno sceglie di pagare la colazione in modo diverso, interpretando la norma a suo modo ovviamente entro i limiti della norma stessa. Come potremmo definire la norma giuridica? Per Kelsen la norma giuridica è uno schema di qualificazione trascendentale, condizione di pensabilità e possibilità di ogni atto o azione che sia giuridicamente rilevante; Ross da una definizione radicalmente empirica, la norma è uno schema di previsione dell'efficacia delle norme effettivamente applicata dalle corti, una ipotesi su un fatto che possiamo verificare attraverso l'osservazione, il fatto è il fatto psico-sociale prodotto dalla pressione della norma quando diviene un'ipotesi di previsione su come si comporteranno le corti.

Nel nostro esempio stiamo interpretando la norma sulla compravendita, in questo caso la norma sarà uno schema semanticamente aperto, una fattispecie a struttura semanticamente aperta. La norma in questi casi configura sempre uno schema.

Vuol dire che la norma non ha una struttura rigida, ma è una fattispecie generale astratta che viene volta per volta, attraverso l'uso da parte dell'osservante, calata, specificata, plasmata, determinata, sul caso concreto; quindi, va costruita la norma individuale partendo dalla norma generale attraverso l'interpretazione. Quindi la norma, nella prospettiva di chi la usa, è uno schema ed entro questi spazi chi usa la norma non fa altro che rimodellare il suo significato. Come si fa a rimodellare continuamente il significato della norma? Attraverso l'interpretazione.

Dunque, in questa prospettiva la norma si presenta come uno schema a struttura semanticamente aperta. È la conseguenza del presupposto metodologico che utilizziamo. Hart riprende Wittgenstein perché per Wittgenstein il significato di una norma è l'uso che se ne fa; dunque, è l'uso cioè l'interpretazione che noi facciamo attraverso l'uso costante e quotidiano della norma stessa.

In questa prospettiva la norma non può essere altro che quello schema che ci permette di usarla, dunque di ridefinire entro i limiti dello schema, costantemente e continuamente il suo significato.
Quali saranno le norme valide all'interno del sistema, in questa prospettiva? Qui Hart si uniforma a Ross, le norme effettivamente valide sono quelle che usiamo costantemente secondo l'interpretazione corrente che viviamo; quindi, il significato della norma può cambiare in base all'interpretazione che le diamo.
Ma Hart costruisce questa teoria in un Common Law, nella quale, a differenza del Civil Law, la norma ha valori giurisprudenziali completamente diversi (per questi filosofi il tema della validità è sganciato dalla struttura ordinamentale a causa della flessibilità presente nel Common Law).
Hart ci dice che il significato della norma è sottoposta a una continua metamorfosi data dal modo in cui una norma viene interpretata da chi la usa. Questo significa che una norma, senza essere abrogata o modificata, può assumere entro i limiti dello schema prefissato significati molto diversi.
Le norme a seconda dell'evoluzione del modo in cui noi le usiamo, cambiano anche il loro significato.
Cambia radicalmente la prospettiva, i concetti della teoria del diritto, a seconda della prospettiva da cui li osserviamo.
L'epistemologia che scegliamo costruisce diversamente il nostro oggetto.
Se la norma è uno schema di interpretazione a fattispecie semanticamente aperta e il significato è dato dall'uso e dall'interpretazione, l'ordinamento sarà l'insieme delle interpretazioni. In Hart l'ordinamento è un gioco sociale, un insieme di interazioni tra chi partecipa a quel fatto sociale denominato diritto. La metafora del gioco risulta essere particolarmente illuminante. Cordero è uno dei grandi sostenitori dell'analogia tra gioco e diritto, lui costruisce la teoria del diritto partendo dal gioco e in particolare al gioco degli scacchi, anche se al gioco del diritto non si può scegliere di partecipare; inoltre, si tratta di un gioco più serio perché il baro viene sanzionato attraverso l'applicazione della norma giuridica.
Il diritto funziona come un gioco sociale, tutte regole che articolano e strutturano quel determinato fatto socialmente rilevante. La terza grande figura dell'ordinamento che possiamo considerare (dopo la piramide e la macchina) è l'immagine dell'ordinamento inteso come gioco sociale.
Ma c'è un problema che è davanti a voi da quando abbiamo iniziato a parlare della teoria degli osservanti di Hart.
Che significa partecipare al gioco del diritto?
Il punto di vista soggettivo implica l'immedesimazione nelle ragioni di tutti coloro i quali svolgono quelle determinate attività. Ma se condivido le tue ragioni cosa condivido? Le ragioni sono dei valori alla base delle mie scelte.
Il problema è che si ritorna a ragionare sul contenuto. Cioè, se la norma è uno schema semanticamente aperto il cui significato è dato dall'uso, ma il significato è il contenuto della norma, siamo tornati a ragionare intorno al contenuto.

Abbiamo abbandonato l'oggettività totale della forma kelseniana o del punto di vista esterno. C'è il problema di misurarci all'interno di una teoria giuspositivista che prevedono il riferimento al contenuto.
Atteggiamento critico-riflessivo: accetto la forma ma anche il contenuto, riconosco anche i valori che contiene la norma giuridica.
Come ne usciamo?
Perchè possiamo non considerare Hart un giusnaturalista? La via di fuga è esattamente la via di fuga di Radbruch plasmata e vista dal punto di vista degli osservanti.
Hart dice una cosa semplice, l'atteggiamento critico riflessivo non accetta il contenuto di tutte le norme dell'ordinamento giuridico, quelle le usa e basta perchè sono norme. Quando io accetto e riconosco nelle ragioni del diritto vuol dire che sto riconoscendo e accettando i principi fondamentali che identificano quell'ordinamento come ordinamento giuridico, cioè quei valori fondamentali che sono contenuti all'interno di quelle che Hart chiama "norme di riconoscimento". Le norme di riconoscimento sono quelle norme che contengono i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Cioè, quelle norme che mi permettono di identificare quell'ordimento o caratterizzano la giuridicità di quell'ordinamento. Sono tutte quelle norme che chiunque partecipi all'ordinamento giuridico riconosce perché contengono i caratteri fondamentali di quell'ordinamento giuridico. Lì scatta il meccanismo di identificazione, mi riconosco in quei valori e non in tutto il resto dell'ordinamento.
Tornando all'esempio del Monopoly: tra i 5 amici c'è uno che bara, allora decidete di semplificare il gioco ad esempio togliendo la possibilità di andare in prigione; ma il gioco continua anche senza quella regola, perchè non è una regola fondamentale che definiscono il Monopoly, è una regola che possiamo o non possiamo seguire. Ma se alteriamo il Monopoly in maniera così evidente allora stiamo giocando un altro gioco.
L'immedesimazione riguarda quelle regole, quei valori fondamentali che ci permettono di definire l'ordinamento giuridico, non tutte le regole che ci sono. L'accettazione critico-riflessiva avviene solo per quelle che Hart chiama norme di riconoscimento.
Queste norme di riconoscimento che sono?
Se sono le norme che ci permettono di identificare il sistema, sono le norme che fondano l'obbligatorietà del sistema, sono le norme di riconoscimento che giustificano e costituiscono il fondamento dell'obbligatorietà dell'intero ordinamento inteso come gioco sociale. Se la prospettiva non è più logico formale, non è più radicalmente empirica alla Ross, allora è chiaro che chi usa le norme identifica il fondamento dell'obbligatorietà del gioco nelle regole che applicano i valori fondamentali di quel gioco.
In Ross è un meccanismo solo procedurale, in Hart il fondamento si carica di un contenuto valoriale di principio perché cambia la prospettiva, lo guardiamo nella prospettiva di chi partecipando ne condivide le ragioni. Quali sono le ragioni? I valori fondamentali che ci permettono di identificare quel determinato ordinamento giuridico.
Hart parla di un contenuto minimo di diritto naturale, cioè ogni teoria del diritto deve fare necessariamente un minimo riferimento a un sistema di valori, altrimenti rischia di degenerare e non avere quel vincolo che può evitare che il sistema normativo diventi un sistema criminale (alla fine Hart prende un minimo da Radbruch).
Hart paragona la norma di riconoscimento al metro sbarra-campione che è custodito ed esposto al museo del Louvre, che definisce la lunghezza di 1 metro. Quel metro sbarra-

campione misura sempre 1 metro, ma è vero? No, perchè l'estate i metalli si dilatano e d'inverno si restringono, quindi durante l'anno non misura esattamente 1 metro, effettivamente può misurare qualche centimetro in più o in meno. Ma per noi quello è sempre 1 metro, perché la misurazione ha natura convenzionale. Dunque, le norme di riconoscimento sono il metro sbarra-campione, perché sono valori e principi frutto dell'accordo tra i destinatari e gli osservatori, cioè hanno origine convenzionale. Tutta la teoria di Hart si basa su natura convenzionale (il contrattualismo che ha radici da Locke a Hobbes).
È un vincolo valoriale che nasce dalla convenzione; le norme di riconoscimento sono quelle norme che ci permettono di identificare l'ordinamento giuridico e che sono sempre fondate su un ordine convenzionale, su un accordo.
In Hart poiché la prospettiva è quella degli osservanti è evidente in questo caso che noi possiamo convenzionalmente decidere altrimenti. Significa che al Monopoly possiamo cambiare le regole (tranne quelle che lo identificano) oppure possiamo accordarci di giocare a un altro gioco, i cui principi e valori fondamentali li decidiamo noi.
Anche in Hart il convenzionalismo si muove sempre entro i limiti del giuridico, ma entro quei limiti sono dei principi che ci permettono di identificare l'ordinamento giuridico che provengono dal nostro riconoscimento che è una convenzione che stabiliamo come fondamento dell'intero ordinamento inteso come gioco sociale. Chi disconosce l'ordinamento (i criminali sono cattivi osservanti), chi non vuole giocare il gioco del diritto? Chi vuole giocare un altro gioco, secondo ipotesi di Hart, non commette un crimine ma un atto di insurrezione. Non significa violare la regola ma capovolgere quella regola, qui manca l'accettazione e il riconoscimento dei principi fondamentali.
La teoria di Hart si rivolge a situazioni tipiche di paesi con fortissime liberal-democrazie e che conoscono molto poco i moti di insurrezione politica, è la classica teoria fondata sull'idea che si partecipi al diritto e ci riconosciamo nei principi fondamentali della liberal-democrazia, tutti giochiamo al gioco del diritto e siamo pronti a bacchettare chi non segue le regole del gioco. È interessante perché sposta l'attenzione sugli osservanti.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 21 DEL 18/11/2024

La volta scorsa abbiamo concluso tutto il tema della teoria che vedeva l'osservatore come osservante in Hart. La teoria di Hart, come quella di Kelsen si chiama dottrina pura del diritto, la teoria di Ross è il realismo giuridico, la teoria di Hart è denominata sociologia descrittiva e l'opera di riferimento si chiama "The concept of law", il concetto di diritto, che è stata pubblicata da Hart un paio di anni dopo "diritto e giustizia" di Alf Ross. Tra Ross e Hart ci sono moltissimi punti di contatto, suggestioni comuni e tantissimi dibattiti tra di loro sul tema del punto di vista soggettivo, in Hart è quello interno, in Ross è in questo caso il punto di vista delle corti.

La volta scorsa abbiamo definito l'osservatore partecipante come osservante, abbiamo chiarito in che cosa si sostanzi il concetto del punto di vista interno in Hart, lo abbiamo definito come una specie del punto di vista più ampio che è il punto di vista soggettivo, dando la definizione del punto di vista interno; che non è solo il punto di vista di chi usa le norme, definizione mutuata da Peter Winch, ma usare le norme significa interpretarle attraverso un atteggiamento critico-riflessivo, e da questa prospettiva abbiamo ricostruito i concetti principali della teoria generale del diritto di Hart nella prospettiva del punto di vista dell'osservante: il concetto di norma, schema a struttura semanticamente aperta il cui significato è dato dall'interpretazione che gli osservanti ne danno; ordinamento giuridico come gioco sociale; fondamento dell'ordinamento giuridico; il tema delle norme di riconoscimento ovvero noi che ci riconosciamo in quei valori fondamentali che ci permettono di identificare la giuridicità di quel determinato ordinamento, contengono il contenuto minimo di diritto naturale. Dunque la teoria di Hart pur essendo una teoria possibilista è una teoria positivista inclusiva, perchè permette la possibilità di riferirsi almeno un minimo al tema della sostanza del diritto (ovvero il riconoscimento di questi principi fondamentali). E abbiamo detto come questi principi abbiano una natura convenzionale, in questa ottica la teoria del diritto di Hart si iscrive alle teorie che si fondano sul contrattualismo sociale (noi osservanti troviamo un accordo, per convenzione stabiliamo quali siano i valori fondamentali intorno a cui costruire il nostro ordine sociale, contrattualismo alla Locke e lo stesso Hobbes).

Esattamente come abbiamo diviso i custodi dell'osservanza, per l'osservante abbiamo la figura classica quindi che appartiene al positivismo giuridico moderno che è quella vista con Hart, a questa completiamo la figura dell'osservante con un osservante partecipante che non si limita a partecipare ma costruisce la realtà sociale all'interno della quale partecipa, e una parte significativa di questa realtà è la realtà giuridica, o come meglio la chiama John Searle la realtà istituzionale.

Dunque John Searle (che nasce come filosofo del linguaggio per la filosofia del diritto e per le neuroscienze), sviluppa la sua teoria: primo presupposto, l'osservante non si limita a partecipare ma anzi la forma di partecipazione dell'osservatore di Searle è quella che costruisce la realtà sociale. L'opera fondamentale di John Searle si chiama "The construction

of social reality", la costruzione della realtà sociale, un'opera che Searle ha costantemente rivisto, l'ultima sua opera si chiama "Making a social world" ma il tema è sempre lo stesso: come costruire la realtà sociale partendo dalla figura dell'osservatore.
È evidente che l'osservatore è interno, partecipante, che se in Hart si declinava come uso delle norme, in Searle la partecipazione non è solo interpretazione ma costruzione costante e continua della nostra realtà sociale.
Domanda: come si costruisce la realtà sociale?
Searle inizia osservando una prima distinzione, proprio rispetto a ciò che esiste intorno a noi, distingue due diverse di tipologie di cose, oggetti o entità: i fatti bruti e i fatti istituzionali.
Che differenza c'è? (l'aggettivo bruto significa proprio fatto non alterato)
Che cos'è un fatto bruto e cos'è un fatto istituzionale?
Quali possono essere esempi di fatti bruti?
Ad esempio una valanga che travolge gli sciatori, che è un fatto bruto perchè non dipende da nessuno. Fatti la cui esistenza non dipende da noi, come gli eventi naturali quando non sono conseguenza della nostra opera, quindi il moto della luna intorno alla terra non dipende da noi, come la pioggia, il cuore che batte e pompa il sangue. Possiamo iniziare a definire i fatti bruti come tutti quei fatti che non dipendono dall'osservatore.
Sono bruti tutti quei fatti la cui esistenza non dipende dall'osservatore.
E quindi per contrapposizione i fatti istituzionali sono tutti quei fatti la cui esistenza dipende dall'osservatore.
Quali potrebbero essere degli esempi di fatti istituzionali?
Ad esempio le norme giuridiche.
Siamo noi che costruiamo la realtà sociale, la nostra relazionalità sociale, perchè la società siamo noi.
Per tornare a qualche lezione fa quando ci siamo soffermati sui verbi promettere, ringraziare, salutare, asserire, condannare, giurare, sono tutti atti sociali perchè se non ci fossimo noi tutti questi atti non esisterebbero. Se non ci fossero gli osservatori, o uomini e donne che si impegnano tra loro per mantenere obblighi futuri, non esisterebbero le promesse; si tratta di atti che non esistono in natura ma che noi pronunciamo attraverso il linguaggio perchè sono costitutivi della nostra relazionalità sociale.
L'idea di Searle, che poi ha tantissimi sviluppi, si interroga sull'ontologia sociale, cioè esplora tutte le condizioni di pensabilità e possibilità, ovvero le condizioni di esistenza, di quelli che noi chiamiamo atti o oggetti sociali, quindi tenta di ricostruire una ontologia sociale.
Cioè come esistono quegli oggetti, quegli atti così particolari che sono costitutivi della nostra relazionalità sociale?
È chiaro poi che essendo il diritto, il discorso giuridico, una particolare modalità del discorso sociale, l'ontologia ha una sua enorme applicazione all'interno dell'ambito giuridico, proprio perchè gli atti giuridici sono atti sociali.
Dunque l'idea di ricostruire una ontologia sociale si rivelerà feconda per costruire una ontologia giuridica le cui condizioni di esistenza partono proprio dalla figura dell'osservatore che guarda dal punto di vista soggettivo e guardando dall'interno non si limita più a partecipare usando le norme, ma costruendole come atti sociali.
E come fa l'osservatore a costruire le norme come atti sociali? Da dove può partire? Cosa esiste?
Partiamo da ciò che esiste, da ciò che è, quindi dalla fisica, per costruire l'ontologia sociale quindi metafisica. Durante la prima lezione abbiamo chiarito come sia impossibile uscire con una norma giuridica, perchè non hanno corpo (la prima era una lezione di ontologia sociale).
Dunque si parte dalla fisica, allora per costruire i fatti istituzionali dobbiamo partire dai fatti bruti, l'unica cosa che noi abbiamo sono i fatti bruti.

L'idea di Searle è quella secondo cui l'osservatore costruisce la realtà sociale partendo dai fatti bruti.
Dunque il presupposto per la costruzione di ogni realtà sociale è iniziare a ragionare partendo dalla materia, dalla materialità di ciò che noi possiamo percepire direttamente, in questo caso dal punto di vista filosofico Searle è un realista.
Una volta che abbiamo il fatto bruto come facciamo a costruire un fatto istituzionale? che non ha una sua consistenza materiale.
Dove avete trovato materialità nelle teorie del diritto che abbiamo studiato? Quella di Ross. Perchè? Perchè si chiama realismo giuridico e ci dice che le norme sono fatti empiricamente osservabili, dunque conosce il fatto giuridico partendo dall'effetto che il fenomeno giuridico produce nella società, quindi parte dalla materialità, un discorso completamente opposto a quello di Kelsen. Dopo Ross chi ha portato alle estreme conseguenze è Foucault, che osserva i comportamenti, gli effetti del diritto sono tangibili dal punto di vista fisico. Come costruiamo allora partendo dal fatto bruto una realtà complessa come quella istituzionale? Attraverso la figura dell'osservatore.
Analogamente a quanto fa Kelsen, Searle elabora uno schema attraverso cui l'applicazione è possibile passare dal fatto bruto al fatto istituzionale. La formula è: X conta come Y in C
Che significa? X è il fatto bruto; conta come Y è il passaggio più complesso, che significa? Ha lo stesso valore. Come facciamo ad assegnare a un fatto bruto X un valore Y, in maniera oggettiva? Come faccio a costituire in capo a X che è un fatto bruto il valore Y? Noi sappiamo che la realtà sociale si costruisce attraverso le parole, le stesse norme sono proposizioni linguistiche aventi carattere prescrittivo, siamo partiti da qui. All'interno di questo linguaggio abbiamo scoperto anche un linguaggio che ci permetteva di far cose con parole, il linguaggio performativo. Quindi la prima idea è che il passaggio da X a Y è un passaggio veicolato che utilizza necessariamente l'assegnazione di questo valore che avviene attraverso il linguaggio, e non può essere diversamente perchè stiamo ragionando di atti sociali. Ma questo linguaggio poichè costruisce qualcosa di nuovo sarà performativo, quindi primo elemento è il linguaggio performativo. Il passaggio da X a Y avviene attraverso il passaggio performativo.
Che altro ci può essere? Y altro non è se non la funzione che noi assegniamo a X, partiamo dall'esistenza del fatto bruto e attraverso il linguaggio performativo assegniamo una diversa funzione.
Searle distingue due diversi tipi di funzione che possono essere assegnate: le funzioni agentive e le funzioni non agentive. Sono funzioni non agentive quelle funzioni che non dipendono dall'osservatore, cioè quelle funzioni che caratterizzano i fatti naturali; esempio: il cuore ha la funzione di pompare il sangue, tipica funzione non agentiva.
Le funzioni agentive sono tutte quelle funzioni che dipendono da noi, che sono assegnate da noi.
Considerate un pezzo di legno che trovate per strada, è un fatto bruto, ma voi siete aspiranti scultori e tornati a casa con un coltellino scolpite il pezzo di legno e gli assegnate la funzione di fermacarte, quello adesso è semplicemente un fatto bruto o è stato trasformato attraverso la propria attività e gli ha assegnato una diversa e nuova funzione agentiva. In questo caso per assegnare una nuova funzione agentiva l'osservatore ha modificato la materialità di X, attraverso la propria azione. Qui la funzione agentiva ha una sua oggettività, abbiamo modificato la materia di X e assegnato una funziona diversa ponendolo sulla nostra scrivania con la funzione di fermacarte.
Ma per esempio, il discorso giuridico funziona così? Quando il discorso giuridico modifica le nostre funzioni modifica la nostra X? esempio: quando entrate in un’aula il vostro status giuridico muta, la funzione non è più solo quella di giovani ma di giovani studenti.

Abbiamo iniziato le nostre lezioni dall'esempio è vietato fumare in aula, nel momento in cui entrate in aula le funzioni che svolgete regolarmente conoscono un nuovo svolgimento, conoscono una nuova funzione di professore e studenti. Quando salite in auto dovete sottostare al fatto istituzionale che è regolamentato dalle norme sulla circolazione stradale, quindi da semplici pedoni diventate responsabili per una serie di azioni che venite a compiere.
Se vincete un concorso in polizia diventati agenti di pubblica sicurezza, quindi nell'esercizio delle vostre funzioni potete esercitare tutta una serie di poteri che vi vengono riconosciuti. Tutte queste funzioni che il diritto vi riconosce, modificano la vostra X, la vostra materialità? No, evidentemente no, le funzioni agentive non modificano X.
Searle all'interno della categoria delle funzioni agentive distingue le funzioni agentive di status. Sono tutte quelle funzioni che riconoscono in capo a X l'assegnazione di poteri, doveri, senza che venga in alcun caso modificata la natura di X. X è il fatto bruto, Y è la funzione assegnata al fatto bruto, sempre attraverso il linguaggio performativo. Posso assegnare una funzione non agentiva o una funziona agentiva, che possono essere funzioni agentive di status o funzioni agentive non di status. Le funzioni agentive non di status sono quelle funzioni che vengono assegnate modificando la natura di X (per esempio il legno intagliato trasformato in un fermacarte). Ci sono funzioni agentive invece che dipendono esclusivamente dall'osservatore che non modificano in alcun caso X assegnandoli l'esercizio di poteri o doveri.
Le funzioni agentive non di status sono funzioni agentive la cui assegnazione è oggettivamente riscontrabile a un fondamento oggettivo nel fatto che noi siamo andati a modificare la struttura di X, ma per tutte quelle funzioni agentive che non implicano in nessun caso la modifica di X, come faccio ad assegnare oggettivamente quella funzione considerando che non ho la modifica di X? Come facciamo a far si che X svolga la funziona agentiva di status Y se X non viene mai modificato nella sua natura? In questo caso l'assegnazione della funziona agentiva di status, come per Hart, ha natura convenzionale. Significa che la assegnano gli osservatori, ma in questo caso gli osservatori devono stabilire tra loro una convenzione che li metta tutti d'accordo sull'assegnazione della funziona agentiva di status. Searle definisce questo accordo come intenzionalità collettiva.
Significa che noi tutti collettivamente abbiamo l'intenzione di assegnare a X quella determinata funziona agentiva di status Y. Abbiamo tutti gli elementi per capire come si passa da X a Y. X è il fatto bruto e Y è la funziona agentiva di status e si assegna attraverso un linguaggio performativo che veicola una intenzionalità collettiva.
Dove si verifica l'assegnazione della funziona di status? In un contesto C, l'ultima parte della nostra formula.
Questa formula è semplice, ma apre problemi metafisici, tanto è semplice quanto è problematica.
Se prendiamo una nostra moneta abbiamo che questo pezzo di metallo ha il valore di 1 euro all'interno dell'unione europea. X conta come Y in C. È chiaro che noi tutti siamo d'accordo ad assegnare al pezzo di metallo il valore di 1 euro all'interno dello spazio geopolitico dell'unione europea. Partendo da una base tutta fisica che è l'oggetto di metallo assegno una funzione agentiva di status, ovvero un valore di scambio, in un contesto definito che è l'unione europea. Il verbo assegnare è un chiaro verbo performativo, l'intenzionalità collettiva è data dal nostro accordo collettivo, la funzione è quella agentiva di status per valore di 1 euro.
Tutti siamo d'accordo ad assegnare la funzione di professore a Siniscalchi all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Non cambia la X ma cambia lo status, il professore ha una serie di poteri che non esercita fisicamente, ma che esercita grazie al fatto che noi tutti siamo d'accordo nel riconoscere quelle facoltà e nell'assegnare quei diritti e doveri.

Il funzionamento è semplice, il problema sono tutte le implicazioni che la formula ci darà nel momento in cui la smonteremo pezzo dopo pezzo.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 22 - CINEFORUM DEL 20/11/2024

Anche Searle, vi dicevo ieri, con Foucault, inaugura le teorie post-moderne del diritto: le teorie post-moderne del diritto fondamentalmente chi sa cosa significa post-moderno? Uno dei termini, fino a qualche anno fa tutto ciò che era spregiativo si definiva post-moderno, era un termine in cui si diceva tutto e nulla dal punto di vista filosofico.

(intervento) diciamo dopo la fine della Seconda guerra mondiale si comincia a parlare un po' di post-moderno, cioè dal momento che i paradigmi della modernità non riescono più a spiegare.

Oh, dal momento in cui i paradigmi della modernità non riescono più a spiegare diciamo la realtà che si sta costruendo. Vedi il post-moderno in realtà è più recente, nasce il termine proprio post-moderno da un libro di Jean-Francoise Lyotard, un filosofo francese, che si chiama "Condizione post moderna", fondamentalmente nasce negli anni '80 del secolo scorso diciamo il pensiero post-moderno. Il pensiero post-moderno come dicevi tu giustamente è quel pensiero che mette fine alle categorie della modernità, ovvero che dice che tutte le categorie che noi abbiamo spiegato della nostra realtà non sono più sufficienti a mettere a fuoco e ad inquadrare i mutamenti che stanno accadendo in merito alla nostra società contemporanee. Quindi le società passano da una definizione di moderno ad una definizione di post-moderno, si dice fondamentalmente che la post-modernità metta fine anche alle grandi narrazioni del '900 e della modernità, quindi tutti quei grandi concetti che hanno caratterizzato l'epoca novecentesca a partire per esempio da Hegel, mi riferisco in ambito giuridico al concetto di stato, il concetto di sovranità, il concetto di ordinamento. Sono tutti concetti che entrano in crisi a partire dagli anni '80, e vedremo i motivi per cui entrano in crisi la settimana prossima, mercoledì prossimo in particolar modo, e iniziano a disgregarsi. La realtà che noi eravamo capaci di racchiudere all'interno di grandi categorie di pensiero, di grandi categorie concettuali, e di poterla analizzare analiticamente nella sua purezza, nella sua unicità, Kelsen, l'idea che il diritto possa essere un linguaggio puro che possiamo isolare da tutti gli altri linguaggi e possiamo analizzare come un oggetto cristallino. In realtà proprio questa idea cessa perché il mondo inizia a subire i processi di prova, di iniziazione e quindi la crisi dello stato-nazione, la crisi dell'ordinamento, la crisi della sovranità, la crisi della cittadinanza. Pensate all'inizio degli anni dei flussi migratori inizia a disgregarsi a frammentarsi, il post-moderno privilegia la logica del frammento, dei frammenti che si uniscono e si contaminano continuamente tra di loro. Dal punto di vista epistemologico, quindi dal punto di vista della teoria della conoscenza, la realtà non è più un

monolito che puoi conoscere isolandolo dal resto di tutti i contesti in cui il fenomeno appare, ma i fenomeni sono tutti tra di loro frammentati e contaminati e dunque i saperi che si costruiscono per conoscere questa nuova realtà frammentaria e contaminata sono a loro volta necessariamente dei saperi contaminati. Da qui l'idea allora che anche la teoria generale del diritto, il diritto nasce all'interno della società, è un fenomeno, un fatto sociale, diceva una fotografa e filosofa del secolo scorso: "l'arte è lo specchio suo della nostra società", probabilmente anche in alcuni casi il diritto è uno specchio, non sappiamo se più o meno scuro della società in cui il diritto è prodotto, ma il diritto si rispecchia nella società, quindi se la società si frammenta, se la società si frammenta, se non è più spiegabile, racchiudibile all'interno dei concetti è chiaro che anche quei concetti finiscono per ibridarsi, per contaminarsi e dunque anche i concetti della teoria generale del diritto iniziano ad aprirsi ad altri saperi. Da qua l'idea, in questo caso, di una serie di studiosi prima anglo-americani, poi continentali, partendo paradossalmente dallo studio di alcuni autori francesi, vedremo come lo studio di questi autori permette ad una serie di giuristi anglo-americani ad elaborare quelle che si chiamano "teorie post-moderne del diritto". Che cosa sono le teorie post-moderne del diritto? sono quelle teorie che conoscono e intendono conoscere il diritto integrandolo con altri saperi, non c'è più la dottrina pura del diritto, non c'è più la teoria generale del diritto, ma se vuoi comprendere come funziona il diritto lo devi fare studiandolo attraverso altre griglie culturali, dunque l'idea del diritto e la post-modernità introduce tutta una serie di epistemologie giuridiche dove i concetti del diritto sono conoscibili attraverso la contamina<ione del discorso giuridico con altri discorsi culturali. Diritto ed economia, "Critical legal studies", per esempio, che sono quel movimento di giuristi anglo-americani creato a partire dagli anni '80 che ha pensato di decostruire le grandi categorie concettuali del diritto e della teoria generale del diritto novecentesco sulla base di interessi economici, cioè loro dicono: "guardate che ogni norma nasconde dietro un interesse ed è prodotta perché si nasconde un potere dietro quella norma, generalmente un potere economico", i critical legal studies sono quel movimento di giuristi che ha iniziato a decostruire, per esempio dicono i legal studies: "diamo per acquisito il concetto di proprietà nei nostri ordinamenti giuridici, perché in base a quale tipo di assetto o di interesse si potrebbe costruire un discorso giuridico diverso". Per esempio, tutte le teorie dei gender studies contemporanei, le teorie del femminismo giuridico, fanno operazioni molto simili, diritto e genere, diritto e femminismo, decostruiscono le categorie del discorso giuridico partendo dalla differenziazione sessuale, e anche li c'è tutto un ragionamento per cui il diritto non viene più conosciuto come discorso assestante, ma è sempre in relazione costante con un altro sapere. Una delle teorie più interessanti, a mio parere, è il movimento "law and literature", diritto e letteratura, che nasce verso la fine degli anni '70 sempre in ambito anglo-americano, il giurista di riferimento si chiama James Boyd White, che inizia a considerare il discorso giuridico, il linguaggio giuridico, come una forma di narrazione, cioè J.B. White dice che il diritto è una delle grandi storie che noi raccontiamo all'interno della nostra cultura occidentale, e dunque iniziamo a capire le storie per raccontare il diritto. All'interno del movimento diritto e letteratura verso la fine degli anni '80, si afferma quella teoria post-moderna del diritto che al posto della letteratura considera una particolare forma di letteratura, tra virgolette, ossia la letteratura cinematografica, da qui il movimento "law and film", che è il movimento che studia il diritto conoscendolo attraverso il cinema, attraverso le rappresentazioni delle immagini visive che si vedranno nelle nostre società contemporanee, quindi l'idea che c'è alla base di law and film è proprio questa. Oggi abbiamo fatto tutto sommato esercizio, un po' di pratica, adesso ricostruiamo un dibattito teorico, oggi non si poteva andare in profondità con il law and film, ne avete avuto un

assaggio rispetto alla cosa più semplice che si possa fare cioè la rappresentazione del processo, fondamentalmente quando si pensa a diritto e cinema si pensa al cinema processuale e quindi all'avvocato, al giudice, alla giuria e allo spettatore che tenta di capire più o meno se l'imputato sia o meno colpevole e da qui come abbiamo fatto oggi si riflette sul come vengano rappresentate queste dinamiche processuali, anche se poi abbiamo detto due parole su ogni film perché i filmati che avevamo selezionato erano tanti rispetto al tempo che ci eravamo dati per poterli vedere. In realtà li accenno oggi , poi ci possiamo dedicare più tempo se ritenete opportuno e se ne avremo la possibilità, avevo tra i tantissimi seminari che ho fatto su law and film e sul rapporto tra diritto e cinema, ne avevo scelto uno sta mattina che volevo farvi vedere poi ho pensato che era un seminario che avevo fatto in questa università per i dottori dottorandi di ricerca 2/3 anni fa, poi ho pensato che avrei confuso le cose, oggi vi do le linee generali, poi chi se la sente e ha interesse potremmo pensare di degnare uno spazio molto più approfondito alle metodiche e alle tematiche, all'epistemologia di law and film con un seminario più preciso. Che cosa si intende per diritto e cinema? Non si intende soltanto quello che abbiamo fatto oggi, il campo di applicazione è molto più complesso e molto più interessante, oggi ve ne fornisco alcuni esempi che poi potremmo approfondire, vediamo se nella lezione del seminario del 5 o sennò dovremmo farlo noi chiuso il corso, cioè finito tutto quello che dobbiamo fare, perché dobbiamo ancora fare la teoria dello spettatore. Alla fine, diritto e cinema è una delle teorie dello spettatore giuridico, ecco perché l'avrei lasciata alla fine, ma poi la ricolleghiamo, ed è molto più interessante e molto più profondo che non parlarne solo in netta analisi e circoscrizione. Generalmente il movimento law and film si distingue in tre approcci epistemologici cioè si gemina in tre diverse tipologie con cui si studia il diritto attraverso il cinema, la prima si chiama "law in film", il diritto nel cinema, ora vedremo che significa, la seconda si chiama "law as film", cioè il diritto come cinema, la terza si chiama "film as law", cioè il cinema come diritto. Che significa, che cosa evidenziano, cosa circoscrivono questi tre ambiti epistemologici, queste tre teorie che riguardano il rapporto tra diritto e cinema? Law in film è la metodologia più utilizzata, quello che abbiamo fatto oggi, cioè vedere come il cinema ha rappresentato il diritto nel corso del tempo, qui abbiamo due possibilità, perché è interessante questo approccio, questa epistemologia, per tre ragioni. In primo luogo perché, inutile dirvi che leggere un testo di diritto, un testo giurisprudenziale o guardarsi la rappresentazione di quei concetti, di quei ragionamenti, di quelle metodiche attraverso le forme narrativa di un film ha due effetti diversi sul destinatario, si ha un approccio, dicono gli studiosi, empatico-cognitivo rispetto alla conoscenza del diritto che passa attraverso l'immedesimazione che lo spettatore fa con i personaggi sullo schermo che chiaramente, l'aridità del testo, anche quello più entusiasmante filosofico-giuridico per me o in termini giurisprudenziali il testo legislativo è chiaro che non hanno, quindi è evidente che dal punto di vista della conoscenza del diritto didatticamente, didascalicamente, il cinema è un ottimo strumento per discutere di alcuni temi, per un verso. Per altro verso il cinema è stato usato molto spesso per criticare, decostruire alcuni concetti giuridici, pensate proprio alla tradizione che oggi abbiamo visto il film che parte da Stanley Kubrick passa attraverso Orson Welles ma ne potremmo citare tanti altri di film e di cinema, di esempi che invece di rafforzare le conoscenze del diritto, operano una critica al sistema giuridico, agli apparati concettuali, nel caso che abbiamo visto oggi proprio alle dinamiche concettuali del diritto. Terza questione, qui la cosa diventa ancora più interessante, alcuni studiosi prediligo l'idea per cui il diritto costituisca una vera e propria epistemologia filmica dei fenomeni giuridici, qualche tempo fa vi suggerivo, come fate a sapere che cos'è un istituto carcerario? Come conoscete la realtà

carceraria? Cioè i luoghi del diritto non sono sempre accessibili a tutti, un grandissimo teorico del diritto Laurence Freeman, uno dei primi che ha ragionato sull'apertura del discorso giuridico, dice che i temi di diritto e letteratura permetto la costruzione di una teoria di conoscenza del diritto a chi non appartiene al "cerchio magico del diritto". Cioè dice Freeman, il cerchio magico del diritto: giudici, avvocati, imputati, tutti coloro i quali usano le norme in maniera specifica, ora che siete esperti del punto di vista interno, ma il punto di vista interno, il punto di vista soggettivo è anche quello nostro, che non siamo nel cerchio magico del diritto, e alcuni luoghi del diritto, alcuni spazi del diritto, sono interdetti allo sguardo. Il carcere è un luogo, un fatto istituzionale, per dirla con Searle, di cui noi non abbiamo una conoscenza diretta, per fortuna, ma il problema qual è? Come abbiamo costruito il nostro immaginario giuridico questa volta? Il nostro immaginario giuridico è totalmente cinematografico, per usare il termine cinematografico in senso lato. Tanti anni fa non so se ve l'ho ne ho parlato già, abbiamo fatto un progetto di ricerca dove siamo andati a ripescare, non tanto i film, ma le locandine dei "prison movies", abbiamo fatto una ricerca enorme nel deposito che stava andando in rovina, che possedeva 60.000 locandine storiche che erano abbandonate, abbiamo rintracciato quasi un centinaio di locandine di cinema carcerario e ne abbiamo fatto una mostra sia a Bari che a Torino, ed è un seminario che vorrei fare con voi perché ragazzi è inutile dire che se guardate il modo in cui il carcere, l'immagine che si è formata in tutti i modi nella società italiana degli anni '60/'70/'80, l'immagine drammatica, che non corrisponde minimamente alla verità della rappresentazione, del fatto istituzionale. Vi consiglio caldamente "Avvocato di difesa" una serie con i temi che abbiamo affrontato oggi, ma c'è per esempio una serie di qualche anno fa che ha completamente rotto l'immaginario sociale-collettivo sulla rappresentazione del carcere: "Orange is the new black" su cui ho fatto un corso di lezioni, non qui, in un'altra università tempo fa, ed è stata proprio una frattura nella costruzione dell'immaginario dell'uomo comune sulla struttura del carcere. Quindi il tema della rappresentazione non è un tema così netto, certo la possiamo usare per ragionare come abbiamo fatto oggi sul processo indiziario, sul ragionamento giuridico, sulla prova visiva, ma fate attenzione perché a volte ci sono e il diritto è uno spazio privilegiato per ragionare in questo modo. Ci sono spazi, luoghi, procedure in cui noi abbiamo avuto conoscenza, noi che non siamo operatori del diritto, solo attraverso i racconti e le immagini, e li è interessantissimo capire come ci è stato fatto conoscere il diritto. Tutti questi studi nascono, per esempio, da Foucault, è lui la radice di tutti questi studi, da Foucault e dall'applicazione delle sue teorie all'interno per esempio del femminismo giuridico, Orange is the new black ha tutta una sua rilevanza perché riguarda la costruzione all'interno del carcere delle tematiche di genere e delle tematiche del femminismo giuridico, è un carcere femminile. Ora ve le sto dicendo per sommi capi, giusto per farvi capire, oggi abbiamo lavorato all'interno di questa metodologia, law in film, ci siamo interrogati sulla rappresentazione del processo in alcuni film, tutti americani. Anche su questo possiamo riflettere, perché oggi abbiamo visto una tradizione, cioè quella Hollywoodiana della rappresentazione del processo, ma ce ne sono tantissime. Per esempio in Italia, una delle cose che più mi ha fatto riflettere, è che non c'è un genere carcerario, non c'è un genere specifico dedicato al diritto. Qui noi oggi abbiamo lavorato con la metodologia law in film, se volessimo ragionare all'americana, con law as film la cosa diventa più interessante, il rapporto tra diritto e cinema è molto più stimolante. Che vuol dire che il diritto è come il cinema, secondo voi?

(intervento): è una rappresentazione.

Esattamente come il cinema anche, scomodiamo i grandi giuristi, non solo del '900, ricordiamo il Leviatano di Hobbes inizia col paragone tra il diritto e il teatro, famosissimo il tema del palcoscenico, è chiaro che il diritto è una forma di messa in scena.

(intervento): il diritto è la rappresentazione di una rappresentazione.

Bravissimo, è una rappresentazione al quadrato, quindi qui il tema è andare ad indagare il diritto in quanto rappresentazione, cioè il diritto funziona come una rappresentazione? E se sì, in che senso? Pensate che come J.D. White diceva che il diritto è un insieme di narrazioni e di storie, anche qui il processo è un insieme in questo caso di storie, quando si va a leggere una sentenza c'è la storia di qualcuno, più o meno romanzata ogni sentenza racconta la storia di qualcuno. Da qui l'idea da parte di questi giuristi, i teorici, anche gli avvocati, perché il movimento law and film come spesso avviene in America, non è un argomento solo di teorici che stanno dietro la cattedra, ma è anche di avvocati, cioè gli studi legali hanno iniziato a ragionare sulla rappresentazione cinematografica del diritto. Molti di questi giuristi, molti di questi avvocati hanno utilizzato per la stesura, la scrittura degli atti processuali, i manuali di sceneggiatura, scrittura filmica scritti da teorici del cinema, sul presupposto alla fine che, le sentenze non siano solo storie di letteratura ma possano anche essere scritte e descritte come la storia di un film. E quindi come ausilio delle loro tecniche argomentative hanno iniziato a ragionare su testi di David Bordwell, di Kristen Thomson, di grandi scrittori e teorici di cinema, cioè il testo giuridico alla fine è la sceneggiatura, e questo perché se tu lo scrivi in quel modo hai maggiore capacità, perché lo sceneggiatore vuole attirare l'attenzione dello spettatore. E allora l'idea geniale, se io voglio attirare al meglio l'attenzione di chi legge forse devo prendere spunto da chi lo fa per mestiere confezionando film, e dunque iniziamo a mutuare all'interno del lessico della scrittura degli atti giuridici le tecniche cinematografiche della scrittura delle sceneggiature. Film as low, il tema del diritto come messa in scena, come spettacolo, sapete che il processo penale americano, il cui tema è fortemente legato dato che il movimento nasce fondamentalmente negli Stati Uniti, si basa sul convincimento della giuria popolare, "La parola ai giurati", fa specie guardando anche rispetto a un film recentissimo, "Giurato numero 2", un film di Clint Eastwood, vi rendete conto di come la composizione delle giurie sia radicalmente mutata nel corso degli ultimi 40 anni, prima erano solo uomini bianchi della "middle class" americana, ora se si dovesse presentare una giuria del tipo si verrebbe accusati immediatamente, perché non si terrebbe conto del tema della differenza sessuale e sociale. In realtà è fortissima l'attenzione della giuria popolare, i teorici del film cosa sono andati a scoprire per essere maggiormente persuasivi della giuria popolare? In giuria chi c'è? Ecco ci siamo noi, ancora una volta Freeman, tutti coloro i quali necessariamente non appartengono al cerchio magico del diritto, la giuria è scelta prorpio tra persone che non sanno nulla del diritto, di diversa estrazione sociale, origine razziale, e quindi occorre saper convincere nel modo più efficiente questi soggetti. Ma la cultura giuridica di questi soggetti come si è formata? Attraverso il cinema e in modo più particolare attraverso le serie televisive, e allora la nascita di alcune figure nei grandi studi americani del consulente cinematografico, che è colui il quale si studia, per esempio, tutte le puntate di casi simili in "Law & Order". Pensate appunto al set di Law & Order per 20/30 anni come ha plasmato, ha formato la coscienza giuridica della "normal people", e suggerisce all'avvocato come si deve muovere, come mettersi in scena, come deve parlare, che schemi di ragionamento deve usare, perché la giuria è abituata a ragionare secondo gli schemi propinati dalle serie televisive ed è con quel diritto che ha familiarità. Uno degli studiosi più interessanti di film and law contemporanei, che si chiama

Richard Shelby, riprendendo Alf Ross, dice che in realtà in questo momento si parla di "visual legal realism", cioè un realismo visivo legale, ovvero la pressione psico-sociale è data non tanto dalla norma, quanto dalla percezione della norma che io ho attraverso le rappresentazioni televisive, cinematografiche e seriali del diritto.

(intervento): come se il cinema diventasse uno strumento di potere.

Esatto, adesso ci arriviamo, da qui proprio l'idea di mettersi in scena, come se fossero i giuristi degli attori, dei protagonisti di una serie cinematografica. Terza, ma non unica, idea del law as film, il tema del montaggio. Il giurista diventa un esperto del linguaggio cinematografico, almeno nel processo penale, considerando che le prove di cui si va a dibattere oggi sono principalmente o prove scientifiche o prove visive. Ci sono tantissimi studi che accertano che la prova scientifica risulta essere una prova schiacciante all'interno dei processi penali americani, non tanto, voi sapete se avete seguito il processo dell'assassinio di Yara Gambirasio che anche le prove scientifiche, la prova del DNA, sono interpretate diversamente a volte. Quindi non è detto che la prova scientifica sia vera al 100%, perché alcuni scienziati possono dare un'interpretazione, altri possono interpretare in maniera diversa. La prova scientifica è divenuta schiacciante nella tradizione processuale statunitense, perché ne hanno, ci fu tanto tempo fa un processo dove un giurista americano presentò questa tesi che diceva che anche qui il tema della percezione della prova scientifica deriva dall'abitudine a vedere le rappresentazioni di serie televisive come CSI, dove evidentemente la colpevolezza era accertata subito senza nessun tipo di appello del serial killer di turno, solo sulla base del riscontro della prova scientifica. Quindi è chiaro che in una giuria popolare a digiuno di cultura giuridica si è formato un convincimento a priori sulla condanna della prova scientifica, così come la prova visiva. Non vi sto a dire quante immagini sono state montate, smontate e rimontate per dire l'opposto di ciò che avevano detto, rinnegando il giudizio precedente. Quindi oggi il tema dell'interpretazione dell'immagine, anche perché le immagini hanno un fuoricampo che non vedete, quindi si relazionano sempre allo spazio e alla cornice dell'inquadratura in primo luogo, in secondo luogo nella maggior parte dei casi sono montate. Quindi non c'è niente di meno ingenuo e meno lineare che l'analisi di una sequenza di immagini che stabiliscono la colpevolezza di qualcuno, ma qui devi avere modo di leggere, di interpretare le immagini. Ancora una volta il tema di law as film, il diritto finisce per essere un cinema, dove le aule processuali proliferano di esterni, proliferano le interpretazioni. Terzo ambito, all'interno dell'ambito di law as film, c'è un altro ambito di ricerca, cioè l'idea per cui all'interno della teoria generale del diritto, molti concetti siano uguali nel linguaggio giuridico dal linguaggio visivo-cinematografico. Il concetto di dispositivo, oggi si parla dell'effettività, dell'efficacia del dispositivo che disinnestano le norme, il tema dello spettatore, che vedremo la settimana prossima, anche lo spettatore vedremo è una forma di soggettività che non nasce in ambito giuridico ma arriva al discorso giuridico dall'ambito dell'arte, della messa in scena. Il tema del montaggio come cuore dei sistemi delle strutture di governance.

(intervento): tutto questo approccio non va a drammatizzare eccessivamente i processi?

Assolutamente si, lo vedremo. Film as law è il cinema che funziona come il diritto, il cinema ha un potere normativo, la capacità di influenzare il discorso giuridico, costruisce l'immaginario giuridico e finisce per influenzare le corti, i giudici, gli avvocati. C'è un film, "Attrazione fatale" che racconta della persecuzione morbosa da parte di un amante nei confronti del suo amante uomo sposato che fa parte della classica famiglia americana medio-alta. In quegli anni ci sono una serie di star, politici,

attori, personaggi di rilevanza che vengono perseguitati dai loro fans, in particolar modo nell'opinione pubblica inizia il tema che noi oggi chiamiamo stalking. Ad un certo punto lo stato della California, Los Angeles, Hollywood, i fenomeni si manifestano principalmente dinanzi ai divi e alle star hollywoodiane, e chiedono. Sulla scia del successo dell'opinione pubblica che inizia a dibattere sui giornali e sui talk show, il governatore della California emana una sua nomina che riguarda finalmente il reato di stalking, ma dov'è il problema? Che la nomina sullo stalking tutto è tranne che una nomina che tutela le vittime di reato di stalking, anzi sembra una nomina riguardante i serial killer, dove chi viene punito deve minacciare fisicamente e produrre danni fisici, mentre lo stalker non lo fa. Questo perché gli atti di produzione legislativa dello stato di California si è utilizzato come caso paradigmatico per un caso estremo. Dato che l'opinione pubblica basava la sua richiesta sulla tutela e sulla giustizia proprio basandosi sul successo commerciale del film, dunque i tecnici governativi hanno pensato di costruire una nomina sullo stalking nella maniera in cui veniva rappresentato nel film di maggior successo in quegli anni, pensando di avere una risposta entusiasta dell'opinione pubblica, dato che questa si immedesimava nella situazione rappresentata nel film "Attrazione fatale", quello per cui lo stalker di una donna che compie una serie di atti di violenza che non rientrano minimamente nel comportamento che presenta lo stalker reale. Ecco che il cinema in questo caso ha stimolato, è stato un mezzo per stimolare il legislatore attraverso la pressione che il cinema ha svolto nei confronti dell'opinione pubblica. Nell'altro verso però il diritto si è costruito non sulla realtà ma sulla rappresentazione della realtà, che tutto era tranne che veritiera rispetto alla realtà, è un gioco meraviglioso l'impostazione del linguaggio giuridico, seppur esso oggi sia cambiato in linguaggio visivo Esempio nostrano in cui mi sono trovato io con altri colleghi che insegnano storia e teoria del cinema, forse alcuni i voi, anche se siete giovani, sapranno che il cinema italiano negli anni 70/80 ha conosciuto la produzione di un genere cinematografico che costituisce un unicum; cioè il poliziottesco, per esempio "Napoli violenta", anche su questi ragioniamo perché sono uno spaccato interessantissimo della nostra cultura negli anni '70. Questi sono dei film che usano quella che un sociologo americano chiamò "Manning strategy", utilizzata in quei film che mostravano che gli uomini potenti potessero fare qualsiasi cosa, raccontavano di bande che rapinavano, stupravano, rapivano le persone, erano bande controllate che imperversavano nell'Italia di quegli anni, questi film avevano sempre un esito grottesco, prima però ci sono una serie di pericoli. Questi film sono anche i più incassati al botteghino, in quegli anni in Italia se ne producono oltre 100, il cittadino vuole giustizia. Tutti questi film, sono film che tendono a generare all'interno della popolazione italiana uno stato di sfiducia nelle istituzioni. Perché e dove nascono questi film? Abbiamo ipotizzato che questo cinema sia nato in Italia dopo la riforma del carcere, dove si introducono una serie di istituti per mitigare la detenzione classica fino a quel punto, immediatamente il cinema attraverso una serie di case di distribuzione, sia da estrema destra, che da estrema destra corre ai ripari svalutando una serie di saperi: psicologia, sociologia aprendo una serie di dibattiti sul sistema di redenzione. Il dibattito termina quando la realtà supera la finzione cinematografica, con gli anni di piombo, e nascono le leggi speciali, eliminando il garantismo degli anni '70 e delle principali riforme carcerarie. Il cinema diventa uno spaccato per conoscere le realtà politica e sociale che non codificheremmo in altra maniera.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 23 DEL 25/11/2024

Searle: X conta come Y in C, X è il fatto bruto, Y è la funzione agentiva che in caso della costruzione di un fatto istituzionale è una funzione agentiva di status. C è il contesto, cioè l'ambito entro cui quella funzione agentiva ne trova applicazione. Il passaggio da X a Y costa di tre elementi costitutivi fondamentali: il linguaggio performativo, l'intenzionalità collettiva, la funzione agentiva di status.

La funzione agentiva di status: sono quelle funzioni agentive che non modificano in nessun modo la struttura o la natura di X, direbbe Searle, la struttura ontologica di X cioè del fatto bruto.

l'intenzionalità collettiva in realtà che cos'è?

Searle utilizza il concetto di intenzionalità collettiva proprio per individuare quella dimensione collettiva nella figura dell'osservatore, cioè intanto possiamo assegnare, riconoscere a un fatto bruto una funzione agentiva di status in quanto siamo collettivamente tutti d'accordo nel riconoscere quella funzione all'oggetto X.

Vi ricordate, non so se l'abbiamo fatto l'esempio, X, questo pezzo di metallo ha il valore di un euro all'interno dell'Unione Europea. La funzione agentiva di status intanto si costituisce se evidentemente c'è l'intenzione da parte di tutti noi di riconoscerla e di assegnarla. Proprio perché a differenza del falegname che scolpisce il pezzo di legno e lo trasforma in un fermacarte, qui la natura di X non cambia, non muta, quindi è chiaro che l'esercizio di poteri, diritti e doveri da parte di X dipende dal fatto che noi collettivamente decidiamo di assegnare, di riconoscere quella determinata funzione agentiva di status. intenzionalità collettiva. E' il concetto per noi più importante perché è il modo in cui Searle definisce la sua figura di osservante partecipante e perché per la prima volta rispetto alle figure che abbiamo visto fino ad ora si tratta di un osservante partecipante che si declina sempre come soggetto collettivo, come soggetto comunitario. L'osservante non è mai un osservante, un singolo osservatore, ma è sempre, se vuole costruire la sua realtà sociale, espressione o portatore di una intenzionalità collettiva.

E che significa essere portatori di intenzionalità collettiva?

Il termine è uno degli elementi più originali e problematici dell'elaborazione teorica di Searle, cioè, più sottoposto a critiche. L'elemento di originalità è evidente, il concetto di osservatore, come soggetto che segue le regole, è attivo, partecipa attivamente, è evidente, no? Il concetto di regola costitutiva mi permette di capire come la realtà sociale prima e la realtà istituzionale dopo, si costruiscano, cioè siamo noi che le costruiamo. Qui la partecipazione è proprio una costruzione dal

basso delle regole, attraverso il concetto di regola costitutiva dell'ordine sociale, che diviene ordine istituzionale, fatto istituzionale attraverso il concetto di regola costitutiva. La volta scorsa abbiamo apposto le regole costitutive alle regole regolative. Sono costitutive quelle regole, la cui esistenza, dipende dalla regola stessa. Sono regolative, invece, quelle regole la cui esistenza è indipendente dalla regola stessa. Quindi l'intenzionalità collettiva ha questo evidentemente di rivoluzionario, no?

L'idea che l'osservatore qui è proprio l'utente, il costruttore, no? Colui il quale attraverso lo sguardo costruisce la propria realtà è un passo avanti rispetto al tema di Hart, no? In Hart ci limitavamo a interpretare. Qui invece noi siamo protagonisti assoluti della costruzione del discorso giuridico. Lo costruiamo attraverso il concetto di regola costitutiva. Punto debole è il tema dell'intenzionalità. Come definire questa intenzionalità collettiva? Qual è la definizione che mi dà Searle, di questa attività coordinata e continuativa verso la realizzazione di un fine comune, questo tendere tutti quanti verso un unico scopo? Il termine intenzionalità è un termine filosoficamente tenso di milioni di significati, no? Dalla filosofia medievale, ma soprattutto nel novecento, in ambito continentale, la fenomenologia ha costruito intorno al concetto di intenzionalità intere teorie da Husserl a Heidegger, il termine intenzionalità è un termine complessissimo, Searle, se ne viene, dicendo che è questa volontà, di costruire, di coordinare le proprie attività partecipando alla costruzione di un fine, di un fine comune. Searle fa un paragone, fa un esempio, l'esempio dei musicisti, ognuno, suonando un proprio strumento e leggendo un proprio spartito…tutti insieme danno origine alla sinfonia. Lui dice che questo è un chiaro esempio di intenzionalità collettiva, cioè ognuno svolge il proprio compito, però il compito è sempre coordinato continuativamente all'interno di un'attività più generale che tende verso la costruzione di un fine collettivo. Il fine collettivo è l'esecuzione della sinfonia. Per usare termini, in questo caso esempi meno aulici di quelli di Searle, immaginate che domani mattina un gruppo di voi va a fare una passeggiata qui a Piazza Cesare Battisti. ogni mattina dopo la famosa colazione si ritrovano in piazza Cesare Battisti per fare una passeggiata intorno alla piazza.

Questo come lo definireste? Che tipo di fatto è questo?

Non è un fatto individuale, è un fatto collettivo.

Che tipo di fatto collettivo è?

È un fatto sociale.

Se però, domani mattina mentre passeggiate vi inserite all'interno di un gruppo di altri studenti, che passeggiano con striscioni e urlando determinati slogan, in questo caso la vostra passeggiata cambia di senso?

Il fatto bruto è lo stesso?

In questo caso il fatto brutto è un fatto sociale, il fatto che state evidentemente passeggiando. Ma date un senso diverso se decidete di aderire alla passeggiata collettiva che si svolge con striscioni, insegne e lo slogan?

Perché quello che diventa da fatto sociale diventa un fatto a cui date una funzione agentiva di status, definendolo sciopero, per esempio, o una riunione collettiva organizzata. Il fatto bruto è lo stesso, però l'intenzione che avete collettivamente cambia nel momento in cui gli assegnate un senso, un significato. Un significato evidentemente diverso. Facciamo ancora un altro esempio. Mettiamo il caso che sempre i cinque della colazione decidano di vedersi, una sera e riuscire tutti quanti insieme al termine dell'ultima lezione che finisce alle 19.30. Decidono di andarsi a bere una birra in un pub qui vicino, uno di quei pub che ha tutti quegli schermi su cui trasmettono eventi sportivi. Mentre

sono al pub, lo schermo trasmette un incontro di box. Nel frattempo, nel tavolo vicino a quello a cui siete voi a bere la vostra birra,

Altri due vostri colleghi iniziano a litigare, tanto litigano che iniziano a prendersi a pugni. Allora avete due fatti bruti che sono radicalmente identici, si prendono a pugni alla vostra destra, si prendono a pugni sullo schermo che state osservando nel pub. Che differenza c'è fra quei due fatti che state guardando?

Cambia la funzione.

Perché cambia la funzione?

Cambia il contesto.

E il cambio di contesto è dovuto a che cosa?

La zuffa sportiva e la zuffa non sportiva, che differenza hanno tra loro?

Quella sportiva è istituzionalizzata e perché è istituzionalizzata? Cosa la differenzia?

Ci sono delle regole

chi assegna quelle regole? E chi ha fatto il regolamento?

La mettiamo in un altro modo. Quelli che si prendono a botte, a cazzotti, in un caso lo fanno seguendo delle regole, in un altro caso lo fanno in maniera selvaggia. E uno è un fatto bruto, è chiaro, è un fatto socialmente bruto. Nell'altro caso potremmo dire che i due che si picchiano hanno un'intenzione collettiva di partecipare a un incontro di box, sono d'accordo a picchiarsi seguendo certe determinate regole che sono espressione della funzione agentiva di status che assegna a quella dinamica di pugni un fatto istituzionale, come un incontro di box. Dunque i due litiganti in un caso hanno due intenzionalità collettive lontane perché ognuno vuole prevaricare sull'altro, nell'altra situazione, invece, pur compiendo delle azioni diverse, ognuno vuole vincere, ma le loro azione si svolge all'interno di un'intenzionalità che è collettiva, che è comune, entrambi svolgono le proprie azioni in funzione del regolamento dello sport della box. Quindi vedete come cambia il tema? il tema è proprio quello dell'intenzionalità collettiva, vediamo lo spirito di collaborazione diverso che c'è fra i soggetti che assegnano, riconoscono una funzione agentiva di status ad un fatto bruto costituendolo come fatto istituzionale.

Allora, adesso avete tutti gli elementi che compongono la formula delle regole costitutive in Searle. X conta come Y in c, X è il fatto bruto, Y è la funzione agentiva, C è il contesto. Come si passa da X a Y? attraverso tre elementi costitutivi, il linguaggio performativo, la funzione agentiva di status, l'intenzionalità collettiva. l'intenzionalità collettiva è per noi l'elemento più importante perché è attraverso l'intenzionalità collettiva che siamo in grado di ricostruire in questo caso la metamorfosi che è la figura dell'osservatore, o meglio, che la figura dell'osservante assume all'interno della teoria di Searle. Prima di procedere a questo punto esaminiamo due critiche che possiamo muovere alla teoria di Searle. Prima questione. Siamo sicuri che la formula, lo schema delle regole costitutive funzioni sempre come dice Searle? Cioè, ve la dico in un altro modo. Nel momento in cui ci sono i tre elementi costitutivi, il linguaggio performativo, l'intenzionalità collettiva e la funzione agentiva di status, noi possiamo riconoscere o assegnare a qualsiasi X, cioè a qualsiasi fatto bruto, qualsiasi funzione agentiva di status? purché ci sia il linguaggio performativo o l'intenzionalità collettiva? oppure la formula di Searle incontra, dei limiti o dei vincoli, nonostante ricorrano tutti gli elementi costitutivi identificati dallo stesso Searle? Domanda che rivolgo a voi. Cioè, se noi formalizzassimo l'intenzionalità collettiva attraverso un atto performativo di linguaggio e questo atto performativo di

linguaggio fosse idoneo ad assegnare una funzione agentiva di status, posso assegnare qualsiasi funzione agentiva di status a qualsiasi x? o ci sarebbe qualche limitazione da parte del fatto bruto rispetto all'assegnazione della funzione agentiva di status? Considerate sempre la definizione di funzione agentiva di status. La funzione agentiva di status è l'assegnazione di quella funzione che non modifica mai la sostanza o la natura di X. Ci sono vincoli secondo voi?

Oppure la formula funziona sempre purché ricorrano questi elementi costitutivi che compongono lo schema di una regola costitutiva?

Ci sono dei limiti? Se sì, quali e perché? Perché pensiamo che vi siano dei limiti?

Searle pensa che non vi siano limiti, quindi la risposta non è così scontata. Fate anche attenzione da questo punto di vista. Per esempio per Searle non ci sono limiti. Searle è un costruzionista, è il tema del costruzionismo versus realismo dal punto di vista filosofico, cioè quanto la realtà resiste o oppone resistenza alla nostra volontà costruzionista, di poterla costruire, modificare, trasformare secondo la nostra volontà assegnando funzioni agentive di status. Vi faccio un esempio paradossale, voi siete molto giovani ma c'era cartone animato che si chiamava Grisù, il draghetto pompiere. Chi è grisù, il draghetto pompiere? Grisù è un draghetto piccolino, verde, che ha un sogno, fare il pompiere. A un certo punto gli assegnano un'azione agentiva di status di pompiere. Dov'è la paradossalità del cartone animato? Che Grisù, quando va a spegnere il fuoco, siccome è un drago, generalmente, piuttosto che spegnere, alimenta le fiamme, perché non riesce a contenere l'idea di sputare fuoco sull'incendio che è già in atto. E qui tutta la battaglia per modificare la propria natura o la propria essenza, e riuscire comunque a realizzare il proprio sogno. A prescindere dalla possibilità che Grisù che possa diventare effettivamente un pompiere, la materialità di X non crea nessun problema, Cioè la materia di cui è fatto il fatto bruto, è sempre irrilevante rispetto all'intenzionalità collettiva e all'assegnazione della funzione agentiva di status. Vi faccio un altro esempio. Un esempio giuridico che si riferisce a un caso giurisprudenziale che si svolge nella Germania della seconda metà dell'Ottocento. C'è un giovanissimo avvocato che viene incaricato di difendere un contadino accusato all'epoca di furto di legna. Qual' è il tema, la questio giuridica? C'è un enorme fondo agricolo di proprietà di un ricco signore vendatario.

questo fondo ha al suo interno un obbligo di servitù, cioè chi si muove, trasporta la legna o trasporta in questo caso beni o servizi attraverso i propri calesse o il carretto, ha il diritto di servitù, cioè il diritto di attraversare il fondo per passare in questo caso da un paese all'altro. Un bel giorno il contadino di turno che sta attraversando il fondo si rende conto che ai margini del sentiero che sta attraversando e quindi ha il diritto di attraversare, c'è della legna per terra. Questa è una legna secca, che si è staccata quindi dagli alberi. I rami sono caduti spontaneamente per terra, il contadino decide di raccogliere la legna e i rami e di metterli sul proprio carretto e di proseguire verso casa sua.

storicamente la legna era un bene pregiatissimo perché insieme al carbone costituiva la fonte energetica e di riscaldamento più importante, sia per chi lavorava sia per chi decideva di riscaldarsi nella propria abitazione. Fatto sta che nel momento in cui stava per uscire dal fondo del signore viene fermato dagli emissari del feudatario che gli chiedono ‘’ma dove hai preso quella legna?”

Il contadino gli dice dove l'ha presa e costoro lo accusano di aver rubato la legna che era di proprietà del fondo, contestando il fatto che il diritto di servitù fosse solo un diritto di passaggio e non anche il diritto di poter raccogliere la legna che invece restava di proprietà del fondo. Il contadino va a giudizio e l'avvocato, il giovane avvocato che inizia a intraprendere la sua difesa, tira fuori una strategia difensiva che per noi è interessantissima rispetto proprio al concetto di regola costitutiva in Searle, perché questo giovane avvocato individua tre tipologie di legna che si possono

trovare all'interno di un bosco. Dice il giovane avvocato, beh, la legna in quante forme si può presentare? Prima forma, attraversate un bosco e vedete gli alberi, ogni albero ha una quantità di legna, di rami, vi siete portati con voi una accetta, prendete l'accetta, iniziate a tagliare quei rami e la legna che staccate ve la caricate sul carretto e proseguite. In questo caso, dice il giovane avvocato, non vi sono i dubbi che si tratti di furto, perché avete fatto che cosa? Avete intenzionalmente, torniamo anche al tema dell'intenzionalità collettiva, agito in modo da staccare la legna che invece è attaccata anche materialmente al fondo, perché gli alberi sono poi una parte della proprietà del fondo, quindi intenzionalmente l'avete staccata e ve ne siete appropriati. In questo caso non ci sono dubbi che si tratti di un furto. Seconda eventualità. attraversando il fondo trovate una legna, rami che sono stati tagliati e ammonticchiati in vari punti del sentiero. anche in questo caso decidete di prendere un po' di questa legna e di caricarla sul vostro carretto e di proseguire. qui la situazione è già diversa, perché la legna non l'avete staccata voi intenzionalmente, l'avete trovata già staccata, però il fatto che sia stata ordinatamente riposta all'interno di una piramide o all'interno di alcuni cespugli fa presumere che quella legna debba essere poi utilizzata da un proprietario e quindi sia stata staccata in funzione poi di un uso futuro da parte di chi è il legittimo proprietario. l'avvocato in questo caso dice beh qui manca proprio l'intenzionalità di andarla a staccare con l'accetta, quindi forse il furto si potrebbe escludere, si potrebbe configurare un caso di appropriazione indebita. Poi dice l'avvocato c'è un terzo caso, il caso in cui la legna è caduta da sopra, perché è seccata ed è a terra, una cosa di nessuno. E qui manca sia l'atto da parte della gente, l'intenzione di staccarla, sia l'intenzione da parte del legittimo proprietario di utilizzarla. E quindi l'appropriazione non reca danno a nessuno, ma non presuppone nessun atto volontario da parte del soggetto. E qui dice, è impensabile sia che si possa costituire il capo o il soggetto un'imputazione di furto, né, tanto meno di un'imputazione di appropriazione indebita, perché tutto sommato la legna si è naturalmente staccata dall' albero che stava marcendo, dunque è chiaro che non servisse a nessuno. L'idea è interessante perché tutta la strategia difensiva parte da che cosa?

Parte ancora una volta dalla natura del fatto bruto di X. il modo in cui si presenta il fatto bruto dice della fattispecie, giuridicamente rilevante, cosa noi possiamo applicare a quel determinato caso concreto. La fattispecie cambia in base alla materialità, al modo in cui materialmente si presenta X ai nostri occhi di osservatore. E dunque, dice l'avvocato, il modo in cui la materia di x si dà non è mai indifferente rispetto alla funzione agentiva di status che noi andiamo a riconoscere

e quindi questo caso ci fa intuire, è chiaro che qui stiamo nell'Ottocento, come in realtà molto spesso il modo in cui è fatto x, già ci esclude o ci dice le funzioni agentive di status che potremmo eventualmente riconoscere o quelle che non potremmo riconoscere nonostante ci sia la nostra intenzionalità collettiva.

cioè la sostanza, meglio la materia di x non è indifferente rispetto al riconoscimento della funzione agentiva di status, proprio perché la funzione agentiva di status non va a modificare x e non può modificare x.

Chi è il filosofo di cui vi sto parlando?

Karl Marx, materialismo dialettico che inizia a manifestarsi già all'interno dell'analisi dei suoi casi giurisprudenziali.

dovete sapere che c'è una corrente filosofica che si chiama" approccio ecologico alla percezione visiva", di un filosofico americano che si chiama James John Gibson che attualizza le teorie fenomenologiche del tema della percezione, che ci dice come la realtà attorno a noi, cioè i fatti bruti, per dirla con Searle, ci invitino al modo corretto di utilizzarli, perciò approccio ecologico alla

percezione visiva, cioè la materia non è sempre indifferente rispetto all'uso che noi dovremmo fare, se volessimo rispettarla nella sua materialità. Si dice infatti che i fatti bruti ci diano delle affordance, cioè un invito a come utilizzarli e quindi a che tipo di funzione, agentiva di status, lessico di Searle, riconoscerli o assegnarli. La posizione è controversa. Nel primo caso (costruttivismo radicale) tutto è costruzione, la realtà si costruisce attraverso modelli che sono in grado di spiegare ogni cosa. Nel secondo caso invece (visione realista) quella costruzione tiene conto di vincoli che sono esterni al modello e che il modello deve comunque rispettare per poterlo conoscere correttamente. La diatriba è tutta qui fondamentalmente.

Seconda questione che vi volevo sollevare, che nasce da una domanda. Se le regole costitutive sono regole che assegnano una funzione agentiva di status all'X, senza modificarne mai la natura, come faccio a sapere che c'è stata l'assegnazione di una funzione agentiva di status? Facciamo un esempio diverso, mettiamo il caso che qui fuori scoppia una rissa e voi state passeggiando, avete necessità di trovare qualcuno che sia in grado di ristabilire l'ordine sociale. Mettiamo il caso che ci trovassimo all'interno dell'universo dei Marvel, a questo punto, individuereste magari un signore che diventa tutto verde, che diventa gigantesco, e immediatamente. Lì cambierebbe l'x del fatto brutto, e capireste che quel signore probabilmente ha i poteri per poter ristabilire l'ordine e immediatamente gli dite ‘’ guarda che sta succedendo, prova ad intervenire lì”

Perché lo riconoscete qui?
perché il signore si è trasformato, è diventato tutto verde, è diventato gigantesco,.

e quindi in questo caso è mutata la X. Quindi quella è una funzione probabilmente agentiva, ma non è una funzione agentiva di status. Mettiamo il caso che fossimo alla fine della nostra lezione, qui fuori mentre stiamo uscendo, si scatena una rissa. Che fate? A chi vi rivolgete? Come individuate il soggetto che può rimettere ordine o che può evitare che la situazione possa ulteriormente peggiorare? E quali sono i tratti distintivi? L'uniforme, quindi per esempio cercate qualcuno in uniforme ovvero un poliziotto o un carabiniere a cui segnalare la situazione. Allora che cosa possiamo dire? I fatti istituzionali, cioè quelli che vengono costituiti attraverso l'assegnazione e il riconoscimento di una funzione agentiva di status, che quindi non cambia mai la natura di X, dunque non i supereroi, ma la funzione agentiva di status assegnata a tutti noi. Come facciamo a riconoscere che sia avvenuta una funzione agentiva di status? Attraverso che cosa? Una serie di simboli che ci indicano che è avvenuta l'assegnazione di funzione agentiva di status. Searle chiama questi segni o questi simboli indicatori di status, proprio perché non cambia la X, per sapere se è stata assegnata o meno la funzione agentiva, Searle dice che la funzione agentiva è assegnata quando è possibile riconoscere l'assegnazione attraverso l'individuazione, di una serie di indicatori di status. Domanda ragazzi, l'assegnazione di un indicatore di status è costitutivo o no della funzione agentiva di status? Se sì perché, se no perché? Facciamo un esempio, allora le funzioni agentive di status le riconosciamo attraverso l'individuazione degli indicatori di status, domanda che vi rivolgo. L’indicatore di status ha funzione costitutiva, cioè essenziale perché si costituisca la funzione, o no? o ha una funzione per esempio veramente cognitiva della funzione agentiva di status? vi faccio l'esempio. se all'uscita del bar qui vicino siccome c'è il vostro compagno che non paga mai la famosa colazione un bel giorno si presenta un signore ben vestito che non ha nessuna uniforme e chiede al vostro amico di seguirlo o di esibire i propri documenti di riconoscimento perché qualcuno nel bar ha segnato che da diverso tempo c'è qualche comportamento poco chiaro circa il pagamento della colazione. qual è la vostra reazione in questo caso? Cosa chiedete al signore del vestito che si avvicina chiedendo di seguirvi o di fargli vedere i propri documenti di riconoscimento? E come fai a sapere se è un pubblico ufficiale? Gli chiedi di esibire il famoso distintivo.

Quindi in questo caso il poliziotto è un poliziotto che non ha visibilmente un indicatore di status evidente, dovete chiedere, nel momento in cui però voi ignorate che quello sia un poliziotto, quindi l'indicatore di status non lo considerate, non è che quello finisce di essere un poliziotto durante tutto questo tempo, continua ad essere un poliziotto. Se lo stesso è chiamato a fare l'infiltrato, cioè infiltrarsi per esempio in un'organizzazione criminale del posto, quello in quanto infiltrato, è proprio quello il quale deve nascondere il fatto che sia assegnata nei suoi confronti una funzione agentiva di status, quindi in realtà lui deve nascondere il proprio indicatore di status per non farsi riconoscere, ma non è che se nasconde il proprio indicatore di status cessa di essere un poliziotto, anzi è semplicemente come un poliziotto che svolge una funzione diversa. ci siamo ancora, la fede, non è che se io smetto di portare la fede o tolgo la fede non sono più sposato, la fede è un chiaro indicatore di status, che mi dice se sono sposato, mi permette di conoscere lo status, ma non è costitutivo del mio status. così come ci sono tante persone in questo caso non sposate che portano fedi perché hanno relazioni non istituzionalizzate, le famose relazioni di fatto, che comunque hanno un simbolo che testimonia dell'esistenza del fatto socialmente rilevante ma non istituzionalmente rilevante quindi, Searle in questo caso ha ragione nell'indicatore di status hanno funzione meramente descrittiva o cognitiva del fatto istituzionale ma non sono costitutivi del fatto istituzionale. il fatto istituzionale, si perfeziona quando c'è l'intenzionalità collettiva, il linguaggio performativo e l'assegnazione della funzione agentiva di status, poi perché io possa conoscere, l'avvenuta assegnazione della funzione oggettiva di status, ci sono gli indicatori di status. Ma l'indicatore di status non è un elemento costitutivo dello schema, della regola. è semplicemente un elemento cognitivo dell'esistenza della regola costitutiva.

Sì, fino a un certo punto. Nel senso che proprio il tema degli indicatori di status è stato oggetto di un dibattito molto interessante che si è svolto negli anni passati tra John Searle e un altro filosofo che però è molto, diciamo, contemporaneo, forse l'ultimo grande filosofo francese che è vissuto in questi ultimi anni, che si chiama Jacques Derrida, il padre del decostruzionismo. Derrida ha criticato aspramente questa idea di Searle, per cui gli indicatori di status siano tutti irrilevanti per assegnare le funzioni agentive di status. Dice Derrida, e sì, va bene, facciamo però un esperimento paradossale, in quanto la forma più provocatoria, è il paradosso che smaschera di solito il problema filosofico (l'abbiamo visto con Ross e Kelsen). E allora Derrida fa un esempio bellissimo.

Poniamo il caso che domani ci svegliassimo tutti quanti privi di memoria. Dice Derrida, se avessimo tutti un vuoto di memoria, nessuno sarebbe in grado di ricostruire le nostre istituzioni, la nostra società istituzionalizzata, a meno che, dice Derrida, i fatti istituzionali, ovvero l'assegnazione delle funzioni agentive di status, non sia stata codificata, cioè registrata all'interno di una serie di documenti conservati in archivi , dice Derrida, non tutti gli indicatori di status sono costitutivi , ma ce ne sono alcuni che sono costitutivi , perché ci sono fatti istituzionali che per conservarsi nel tempo chiedono che vi sia una braccia documentale e dunque, dice Derrida, un conto è assegnare la funzione agentiva di status, un conto è farla vivere all'interno della società cioè assicurarsi, garantirsi che quella funzione sia una funzione che noi possiamo continuamente trasformare, revocare, cambiare attraverso l'intenzionalità ma affinché collettivamente, non tutti, fossimo in grado di garantirne la perpetuità nell'esistenza, è necessario che di quella assegnazione se ne dia traccia in un documento scritto. in questo caso Derrida è il grande filosofo della scrittura, della traccia scritta, l'idea per cui c'è almeno un altro elemento che è essenziale rispetto all'intenzionalità collettiva, il fatto che l'intenzionalità collettiva abbia una sua memoria, sia possibile ricostruire sempre l'assegnazione di quella determinata funzione agentiva di status. D'altronde, oggi questo è un tema importantissimo, interessantissimo. Gli esempi che fa Derrida sono poi esempi anche, tra

virgolette, politici. Dice Derrida, in Francia gli immigrati clandestini si chiamano Saint-Papiers, coloro i quali sono senza carte, quindi senza il documento. Perché

in realtà il documento, il possedere quel documento è costitutivo della possibilità, di esercitare determinati poteri. Quindi dice Derrida, il modo in cui io posso esercitare quel diritto, quel dovere, quando presento che sono un immigrato è l'esibizione immediata della traccia scritta, del documento. c'è un bellissimo libro di un filosofo contemporaneo italiano, molto molto famoso, che si chiama Maurizio Ferraris, che si chiama documentalità, che è proprio, come dire, lo sviluppo della critica che Derrida fa a Searle sul tema degli indicatori di status. Ferraris ricostruisce come in realtà tutti i fatti istituzionali, tutta la nostra realtà istituzionale si formi attraverso documenti, attraverso una documentalità, quindi una traccia che resta in un archivio e che costituisce una memoria collettiva che continuamente dice, afferma, dimostra ciò che abbiamo il diritto, il dovere, la possibilità o l'impossibilità di fare all'interno di un determinato contesto sociale. E quindi io direi che tutto sommato anche qui il Searle ha ragione, sì, ma fino a un certo punto. Cioè ci sono indicatori di status che non hanno sicuramente forza costitutiva, ma ci sono altri che hanno forza costitutiva. E con l'esercizio, con l'esibizione del documento che tu affermi in alcuni casi, l'esistenza della funzione agentiva di status. E quindi abbiamo in tutto il tema della forza documentale degli indicatori e quindi della base documentale dell'assegnazione delle regole costitutive.

domanda ‘’perchè devo seguire le regole?’’

che tipo di risposta vi offre il modello di Searle, rispetto a quelle che abbiamo visto finora? cosa cambia con Searle? qui Searle mi sta dicendo che noi seguiamo le regole perchè noi partecipiamo alla loro costruzione attraverso il concetto di regola costitutiva, e dunque il discorso istituzionale, perciò Searle parla non di diritto ma di istituzione, non di fatti giuridici ma di fatti istituzionali perchè l'istituzione è proprio il tema, l'idea in cui, il discorso normativo è alimentato da una comunitas, da una comunità sociale, l'integrazione fra il discorso giuridico e la comunità sociale dei destinatari

Intervento: A volte le regole le costruisce proprio chi non le rispetta, come Marco cappato

Professore: Marco Cappato, violando intenzionalmente le regole per permetterne di costruirne altre, ha agito secondo le regole che ha costruito? Ha agito riconoscendo quelle regole? la violazione è sempre in funzione della regola. che poi la violazione avesse l'intenzione non di costruire un illecito, ma di sollevare una questione critica rispetto all'esistenza di alcune regole, ha sempre agito rispettando la regola.

È un po' quello che avevamo detto qualche lezione fa, no? Il ladro, mettiamo in caso, è colui il quale comunque agisce in funzione della regola, non devi rubare, agisce in funzione, trasgredendola, non osservandola, ma è sempre una forma di riconoscimento della regola. Colui il quale bara, vi ricordate l'esempio del baro al gioco? Il baro è colui il quale non misconosce la regola, agisce sempre in funzione della regola.

chiaro però che l'idea è quella di produrre una violazione per fare che cosa? Per alimentare un'intenzionalità collettiva diversa rispetto ad un determinato fatto sociale, ad un determinato fatto bruto. Per fare che cosa? Per far riconoscere una funzione agentiva di status qualificando dal punto di vista giuridico diversamente quel fatto bruto. Però lì la cosa interessante del modello di Searle è il tema della governance è proprio questo, l'idea della partecipazione, cioè di una forma di costruzione dell'ordine sociale che parte integralmente dal basso, quelle che si chiamano strategie di costruzione bottom-up, cioè che si costruiscono con la partecipazione collettiva aperta e diffusa e non con la costruzione gerarchica, verticalista, tipica del discorso giuridico del Novecento.

Dunque, la domanda, perché devo seguire le regole? Qui la risposta, è esattamente opposta alla risposta che ci potrebbe dare un giurista kelseniano. Se lì il tema è la forma tipica, quindi l'operazione logico-formale, qui il tema è la partecipazione intesa come costruzione del discorso giuridico, del discorso normativo, attraverso l'intenzionalità collettiva, cioè attraverso una figura di osservante che si declina sempre in maniera plurale, in maniera comunitaria, in maniera collettiva e dunque che tende a estendere massimamente il livello di partecipazione nella costruzione dell'ordine e del discorso giuridico. ora che abbiamo visto ed esaurito tutto sommato il discorso sulle figure dell'osservatore, abbiamo visto l'osservatore punto di vista oggettivo, punto di vista soggettivo, custode dell'osservanza, osservanti. Abbiamo un quadro completo delle figure attraverso cui si seguono le regole del diritto attraverso il processo di osservazione. Bene, la figura dell'osservatore in funzione di quale altro concetto noi l'abbiamo definito? Quando abbiamo detto che l'osservatore può adottare due prospettive dello sguardo diverse tra loro. Vi ricordate che all'inizio abbiamo definito interna e esterna, poi abbiamo arricchito definendo l'oggettiva e soggettiva. L'interno e l'esterno, l'oggettivo e il soggettivo del guardare dell'osservatore, come l'abbiamo fatto a definire? Cioè rispetto a che cosa L'osservatore è interno o esterno? Rispetto a che cosa? È oggettivo o soggettivo Rispetto a che cosa? A che fattispecie? E qual è la fattispecie con cui si relaziona l'osservatore? Quando abbiamo definito le teorie del diritto, quelle che guardano dal punto di vista soggettivo e quelle che guardano dal punto di vista oggettivo, come teorie oggettualiste o oggettualistiche, teorie non oggettualistiche o non oggettualiste del diritto, vi ricordate la differenza? No….

comunque le teorie che guardano dal punto di vista oggettivo si chiamano anche teorie oggettualiste del diritto, cioè il diritto è un oggetto che è possibile conoscere attraverso l'osservazione esterna. Teorie non oggetualistiche: il diritto è un processo a cui noi partecipiamo nel momento stesso in cui lo stiamo osservando. Facciamo un altro esempio, quando abbiamo detto che Hart prende l'architettura concettuale di Peter Winch e la trasferisce al discorso giuridico, Peter Wynch, social idea, idea sociale, fatto sociale, punto di vista interno e punto di vista esterno, partecipazione o meno, quella architettura, abbiamo detto per Hart, la mutuale, la traslata all'interno del discorso giuridico. il punto di vista interno, il punto di vista esterno di Hart, rispetto a che cosa si definisce come interno, come esterno?

Rispetto alla società, che in ambito giuridico, come la chiamiamo?

L'ordinamento.

La vita del diritto è l'ordinamento. Quando abbiamo detto punto di vista oggettivo, punto di vista soggettivo, rispetto a che cosa? Rispetto all'ordinamento. Tutte le figure di osservatore che abbiamo considerato fino ad ora, le abbiamo sempre definite in relazione, in funzione al tipo di relazione epistemologica che intrattenevano con la fattispecie del diritto, con i fenomeni giuridici, con il discorso del diritto. Ma i fatti giuridici, i fenomeni giuridici, le regole giuridiche che sono, sono tutti elementi che appartengono ad un'unica figura, la figura dell'ordinamento. il punto di vista oggettivo è oggettivo rispetto all'ordinamento, è soggettivo rispetto all'ordinamento quando lo riferiamo alla teoria generale del diritto. Dunque, possiamo dire...Che la teoria generale del diritto del Novecento, o l'epistemologia giuridica del Novecento, ha avuto due grandi poli concettuali. ruota intorno a due concetti fondamentali: il concetto di osservatore cioè di destinatario, noi, il soggetto, e una realtà oggettiva che è la realtà dell'insieme dei fatti o dei fenomeni giuridici che è l'ordinamento. che poi questo ordinamento l'abbiamo definito come un sistema gerarchico piramidale come una macchina, come un gioco sociale come un dispositivo, poco importa, l'idea che attraversa tutte, tutte queste teorie è l'idea per cui le teorie si costruiscono su questa bipolarità. il destinatario, il soggetto che è

l'osservatore, custode dell'osservanza o l'osservante, che può essere interno o esterno alla vita del diritto, alla realtà del diritto, ma la realtà del diritto non è nient'altro che l'ordinamento giuridico. Questo per quel che riguarda tutte le grandi teorie del diritto del Novecento.

Cosa accade verso la fine del secolo scorso, in particolar modo verso gli anni 80 del secolo scorso? la teoria generale del diritto il discorso giuridico subisce una metamorfosi radicale, non ancora metabolizzata dai giuristi, anche perché qui stiamo entrando davvero nella contemporaneità, cioè nel diritto dei nostri giorni . si tratta di studiare ciò che accade intorno a noi e dunque se ci confrontiamo con quello che c'è intorno a noi, è chiaro che la fluidità dei concetti e delle teorie è molto maggiore, rispetto a teorie che si sono cristallizzate ormai nel tempo. però la situazione, è decisamente più interessante e più appassionante. Quello che sta accadendo oggi, ha un inizio ben preciso, l'inizio sono gli anni 80 del secolo scorso. Perché? Perché a partire dagli anni a cavallo, dagli anni 70 e gli anni 80 del secolo scorso, l'ordinamento giuridico è il suo volto politico-giuridico, cioè lo Stato-Nazione, perché poi lo Stato-Nazione nel Novecento si identifica con l'ordinamento, l'ordinamento è il braccio armato dello Stato-Nazione che è la realtà politica, entra in una crisi profonda da cui ancora non è uscito e non sappiamo se e come ne uscirà. Nel momento in cui l'ordinamento e lo Stato-Nazione entrano in crisi, beh è chiaro che entra in crisi anche la figura, La soggettività che noi abbiamo utilizzato finora per conoscere e partecipare a quel determinato fatto giuridico, fatto istituzionale che è l'ordinamento. Dunque, i due capisaldi della teoria generale del diritto, così come finora l'abbiamo studiata, subiscono una profonda crisi. Perché l'ordinamento e lo Stato-Nazione entrano in crisi?

Ve ne do due. Una, come dire, storico-giuridica, un’altra squisitamente filosofica. Le due ragioni convengono. La prima, quella storico giuridica. Se nel Novecento le teorie generali del diritto biotecnico sono tutte teorie che mutuano schemi del discorso teologico e lo trasferiscono al discorso giuridico, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, non più il piano teologico incrocia con il piano giuridico, ma diventerà il piano economico o anzi meglio il piano tecnocratico. Questo a cascata modificherà tutti i concetti fondamentali della teoria generale del diritto. Prima questione. dal punto di vista filosofico c'è invece l'irruzione, la fine del moderno e l'inizio del postmoderno. Là post modernità, come esperienza, filosofia del frammentare, del contaminato, dell’ibrido, darà un colpo, assesterà un colpo legale a tutte le teorie del Novecento fondate sulla purezza dei concetti giuridici. Non c'è più nulla di puro, o se continui a conoscere un diritto che è contaminato da mille altri saperi con quelle lenti, finirai per non capirci più nulla.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 24 DEL 27/11/2024

Nella scorsa lezione abbiamo visto che tutta la teoria generale del secolo scorso, cioè del Novecento, si costruisce attorno a due poli. Vi è un rapporto tra osservatore e ordinamento che contraddistingue e che segna gran parte della teoria generale del Novecento. Dove si pone il problema, il problema nasce nel momento in cui uno dei due termini delle funzioni del rapporto entra in crisi, e quindi in quanto strettamente collegati, anche l'altro entra in crisi. *Quale è il concetto che entra in crisi?* L'ordinamento, inteso come il volto giuridico dello Stato-Nazione. Da Kelsen in poi Stato e ordinamento finiscono per sovrapporsi e coincidere tra loro, l'ordinamento è la forma giuridica che assume, che esprime lo Stato. Dicevamo la volta scorsa che ci sono una serie di elementi che mandano in crisi il concetto di Stato-Nazione e il concetto di ordinamento, ci sono elementi giuridici e ci sono elementi storico-filosofici. È interessante notare come questi elementi si influenzino gli uni con gli altri, dunque il giuridico è anche l'esito di un movimento di pensiero che nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso inizia a diramarsi ed a occupare moltissime zone di pensiero e di riflessione. Inoltre il post-moderno è la fine del moderno ed è l'interesse per una nuova era che esprime soprattutto un nuovo apparato concettuale per decodificare il reale o la realtà. Il post-moderno è la celebrazione della fine di quella che Jean-François Lyotard chiama grandi narrazioni del Novecento dei grandi concetti con cui si è spiegata la realtà socio-politica e dunque anche la realtà giuridica nel corso del Novecento. In particolare grande attenzione vi è stata per il concetto di Stato nazione perché la post modernità celebra una società che diviene sempre più complessa e in cui i grandi saperi finiscono per ibridarsi l'uno con l'altro; quindi tutta l'unitarietà e la purezza conquiste della modernità, cessano con la nuova epoca. *Perché il postmoderno celebra la fine della possibilità di conoscere la realtà intorno a noi attraverso modelli o attraverso concetti predefiniti?* Perché la realtà è ormai scomposta in mille derivazioni, mille frammenti, non è più conoscibile soltanto attraverso le ottiche del discorso politico, del discorso economico, del discorso giuridico; il giuridico, l'economico, il politico sono tutti ormai intrecciati all'interno della costruzione di una realtà sociale che appare sempre più complessa, sempre più ramificata. Il tema della ramificazione è molto importante poiché si costruiscono reti tra saperi diversi e dunque è impensabile conoscere un fenomeno solo attraverso le lenti che ci permettono di inquadrare il discorso giuridico, il discorso economico, il discorso politico, infatti, questi discorsi sono intrecciati in una rete tra di loro, dove sono indistinguibili. Questa è la prima grande conquista della postmodernità, da qui poi si ramifica tutto il tema dello scetticismo, anche epistemologico, dell'impossibilità di conoscere i fenomeni attraverso la filosofia postmoderna, che per molti si traduce in un atteggiamento nichilista. Il tema alla base è la **globalizzazione**, ovvero l'idea di una realtà che si è mescolata, intrecciando tutti i saperi giuridici. Dal punto di vista giuridico questa frammentarietà si traduce attraverso una metamorfosi fondamentale. Sino ad oggi abbiamo

conosciuto un discorso giuridico fondamentalmente basato sulla costruzione della teoria del generale del diritto, nel secolo analizzato inizia a mescolarsi con altri saperi, in particolar modo con una forma di sapere di discorso che finora era stato invece l'effetto, il prodotto del discorso economico, ovvero il discorso tecnico-economico, con l'economia. La teoria generale del diritto, anche nelle sue accensioni più radicalmente positiviste del Novecento, pensiamo a Kelsen soprattutto, sia la teoria generale del diritto che nella sua costruzione dogmatica o sistematica/ sistemica, ha guardato fondamentalmente o ha traslato seppur in maniera ovviamente secolarizzata, forme che appartenevano al discorso teologico, una visione teologica, e la possiamo rinforzare nella famosa immagine del "Leviatano" di Hobbes. Quindi l'ascendenza di questo tipo di discorso è ancora una volta teologica, il fine che deve realizzare è quella della costruzione di un sapere giuridico che è in grado di spiegare l'esistenza dei fatti giuridici in assoluta autonomia. Questa prospettiva muta radicalmente nel momento in cui il discorso inizia a contaminarsi con altri saperi. Le lenti dell'osservatore, così come le abbiamo studiato fino ad oggi, sono lenti che non ci permettono più di decodificare, di mettere a fuoco il giuridico, perché il fenomeno giuridico inizia a sgretolarsi, inizia a contaminarsi rispetto alla sua purezza. *E come si contamina? Rispetto a quale sapere si contamina maggiormente?* Al **discorso economico**. Succedono due fenomeni fondamentali che iniziano a sgretolare la costruzione unitaria dell'ordinamento giuridico. *Cosa mette in scacco il concetto di sovranità, il concetto di ordinamento giuridico?* Il tema di una sovranità che inizia ad essere una sovranità limitata. *Che significa una sovranità limitata?* Da Hobbes in poi, passando per Hegel, e poi per Kelsen, l'ordinamento giuridico è quell'oggetto, quel sistema di norme che può normare, legiferare in modo esclusivo, può detenere il monopolio del potere, della forza, del diritto all'interno di un determinato territorio rispetto ai determinati destinatari. Questo tipo di disegno viene messo in crisi a partire dalla fine del secolo scorso, proprio dai processi di globalizzazione, globalizzazione delle persone, quindi tutto il tema dei flussi di persone che costantemente si spostano all'interno dei territori e creano problemi rispetto al riconoscimento dei diritti, dei doveri, al riconoscimento di quelli che Searle chiamerebbe poteri deontici.

Tra gli ultimi studi di filosofia del diritto, per esempio, ci sono studi dedicati alla teoria del riconoscimento. C'è un filosofo contemporaneo tedesco Axel Honneth, allievo di Michel Foucault, che ragiona sul tema della filosofia del diritto come lotta per il riconoscimento delle minoranze, che possono essere minoranze di qualsiasi tipo, di qualsiasi forma. Questo è proprio un tipico esempio di un processo che mette in crisi le dinamiche stabili della costruzione ordinamentale del Novecento.

Ad esempio il fatto di avere pericoli sulle leggi di bilancio si traduce in una limitata capacità di riconoscere diritti e doveri, dunque di costituire status deontici e poteri deontici all'interno del proprio ordinamento giuridico, quindi significa che noi siamo ormai Stati in azione a sovranità limitata.

Pensiamo con le elezioni di Donald Trump, il ruolo che gioca Elon Musk all'interno della costruzione del futuro governo degli Stati Uniti d'America. Elon Musk è uno dei più grandi imprenditori, vediamo qui l'intreccio fra multinazionali, esercizio dell'attività governativa, libertà nella scelta democratica di un determinato candidato, utilizzo del condizionamento attraverso i social media.

Vediamo che la situazione è molto più complessa se pensiamo alle elezioni degli Stati Uniti d'America di vent'anni fa. Questo è un esempio proprio clamoroso di come l'economia sia parte integrante, e detti spesso la propria agenda alla politica e al diritto, perché il diritto è espressione

evidentemente del discorso politico, delle scelte politiche dei legislatori. Quindi la situazione è molto spesso complessa verso l'economia. Ci sono tre fenomeni che sono molto interessanti e che ci dicono di questa contaminazione rispetto al discorso giuridico e al discorso economico. Il primo ha un'origine di carattere storico ed è stato negli anni '80 l'avvento di due governi anglo-americani, che hanno inaugurato la stagione del neoliberismo, il governo Thatcher in Gran Bretagna e il governo Reagan negli Stati Uniti d'America. *Quale era l'idea di questi governi?* L'idea di questi governi era che l'economia subiva forti rallentamenti, forti condizionamenti, quando era sottoposta alle limitazioni di una pianificazione statale. Se avessero lasciato liberi, invece, i mercati di potersi autoregolamentare, questi mercati, poiché in ogni mercato il fine è massimizzare il proprio profitto, avrebbero creato degli utili in misura sempre maggiore e questo avrebbe avuto una ricaduta immediata nei confronti dei destinatari e nei confronti dei governi. Dunque, *qual è il tema?* Il tema è quello di rinunciare a parte dei vecchi ordinamenti giuridici, e dare più spazio a norme riguardanti la materia economica, lo si fa volontariamente, lasciando all'economia la piena libertà di potersi dare le proprie norme. Dietro c'è tutta una tradizione filosofica di pensiero che è quella che si radica nel concetto di **ordine spontaneo**, in un filosofo economista e filosofo del diritto del Novecento che si chiama Friedrich von Hayek, il padre della dottrina liberale. In realtà le teorie di von Hayek, che sono la base del pensiero liberale, sono estremizzate, portate al limite estremo da parte degli economisti liberali, soprattutto statunitensi, quello che si chiama l'anarco-capitalismo, l'idea per cui il capitalismo è anarchico di sua natura e quindi non va mai, normato, regolamentato da parte dello Stato, che lascia il mercato in piena anarchia perché il mercato, massimizza i suoi profitti dunque lo sviluppo capitalistico e industriale se è sempre meno regolato da parte dell'ordinamento giuridico. Bisogna stare attenti a non confondere il liberal classico il liberalismo classico che è una nobilissima visione filosofico-politica dal neoliberalismo che è una tendenza più complessa da decifrare. In realtà è l'ordinamento che abdica a regolare la funzione delle cose. Questi sono tutti limiti che provengono dall'esterno, perché dall'esterno iniziano anche a erodere proprio l'unitarietà del concetto di ordinamento: il territorio, il tema dei flussi migratori, l'esercizio monopolistico del potere legislativo, il tema degli organismi sovranazionali…. Limiti, quindi, alla forza di legge, all'esercizio del potere di normazione, dettato dalla rinuncia a regolamentare il campo economico. Questo tema però ha una duplice sfaccettatura, perché l'economia inizia a frantumare il concetto di ordinamento, sia dall'esterno, nel momento in cui autonomamente si abdica al potere di poter regolamentare il campo economico per un Paese, allo stesso tempo ci sono anche delle spinte interne che iniziano a erodere la capacità dell'ordinamento stesso di definire, di regolamentare giuridicamente il tema economico. C'è un famoso giurista, professore di diritto italiano, che insegna tutto sul tema del diritto romano, Natalino Irti, che è famoso per aver scritto un volume, tra gli anni 70 e 80, che si chiama "L'età della decodificazione". *Che significa l'età della decodificazione?* Con questa espressione definisce una particolare tendenza del legislatore italiano che sotto pressione di vari gruppi economici, che erano gruppi particolarmente interessati a come si muoveva il legislatore italiano, ha deciso di sottrarre alla legislazione del codice civile alcune materie di competenza economica e riaffidarle alla promulgazione di leggi speciali. Anche qui la materia economica inizia a godere di un regime speciale, riservato dai nostri legislatori proprio per l'importanza che inizia ad assumere il discorso economico rispetto al discorso giuridico, tutto questo implica uno sgretolamento dell'unitarietà del sistema, così come l'ha immaginato Kelsen, e questa è l'immagine che dà il titolo al libro "Barocco Giuridico" , ovvero questa proliferazione di norme, di leggi che hanno finito per sgretolare quell'immagine cristallina che noi abbiamo visto con Kelsen dell'ordinamento, trasformandola in una visione difficilmente conoscibile, non più trasparente, agli occhi dell'osservatore. Tornando al tema dell'economia, c'è una trasformazione fondamentale che è alla base del passaggio dalle strutture ordinamentali come costruzioni privilegiate dell'ordine sociale alle strutture di governance come modelli privilegiati per decodificare, per conoscere la costruzione

dell'ordine sociale. Durante quello che si chiama, dal punto di vista economico, il **fordismo**. *Che significa? Che cos'è il fordismo? Come faceva a produrre macchine a prezzi non troppo elevati? Come faceva a regalare, a offrire benessere ai propri dipendenti, per metterli poi in condizioni di acquistare le proprie auto e dunque di realizzare un profitto? Come erano costruite? Ogni operario svolge sempre lo stesso lavoro, e la fabbrica com'è fatta? Come sono costruite queste fabbriche? Qual è la grande innovazione di queste fabbriche?* I nastri trasportatori e la catena di montaggio, ma a livello sociologico, Ford costruisce delle vere e proprie piccole città\fabbriche. Ad esempio la fabbrica della Ferrero ad Alba ci dà l'idea del fordismo, ovviamente trasformato, la Ferrero è una enorme multinazionale adesso, però c'è tutta una parte enorme in cui gli ex dipendenti, pensionati, hanno una serie di benefit dentro, cioè hanno tutto gratis, l'accesso a internet, i giornali, i concerti, la biblioteca, la sala musicale, la sala musicale, possono fare sport, hanno le sale cinematografiche … per i dipendenti gli asili, le scuole, e quindi lì la fabbrica costruisce intorno una specie di piccola città-stato che garantisce un determinato tipo di benessere sociale. L'idea del fordismo era proprio quella della costruzione intorno alla fabbrica di una vera e propria piccola cittadina, cioè le fabbriche si costruiscono durante il fordismo, quando quindi l'industria inizia a svilupparsi, seguendo il modello piramidale kelseniano. Cioè sono delle piccole città-Stato all'interno dello Stato che replicano in piccolo il modello di costruzione dell'ordine sociale che è il modello giuridico, il modello gerarchico piramidale introdotto da Kelsen, ma Kelsen trae ispirazione da Hobbes, cioè è il modello giuridico, teologico, più antico. Questi stati nello Stato sono interamente regolati e regolamentati dall'ordinamento giuridico. *Perché?* Perché si muovono, vivono, producono all'interno del territorio nazionale. Oltre alla Ferrero, altro esempio è il disastro **Fiat**. Anche Torino è una città che nasce interamente intorno alla Ford, ci sono quartieri interi della città di Torino che sono nati come quartieri dormitorio per gli operai degli stabilimenti della Fiat. Ed è un modello che la Fiat ha cercato di replicare, per esempio a Melfi o in altre località italiane. Tutti questi sono modelli di costruzione dell'ordine sociale, ma sono tutti modelli che prendono, ad esempio, il modello giuridico e che sono sottoposti all'ordine politico-giuridico costruito dallo stesso ordinamento come sistema di norme. Quindi qui è il discorso giuridico quello che organizza la società, l'economia prende e dipende dal modello di costruzione dell'ordine sociale che è quello giuridico. *Che cosa accade ad un certo punto?* Ad un certo punto alcuni economisti si rendono conto che grazie all'inizio di quelli che noi chiamiamo processi di globalizzazione, forse la catena di montaggio non conviene più organizzarla tutta all'interno della struttura piramidale nello Stato e nell'ordinamento giuridico dove l'industria, la fabbrica è nata e opera, ma l'imprenditore può prendere una parte della catena di montaggio portarla in un Paese del Terzo Mondo dove la manodopera costa molto meno, non ci sono i sindacati, e dunque si può sfruttare la manodopera come meglio si crede, sganciandosi da qualsiasi laccio normativo del proprio Paese perché si lavora in un altro territorio. L'idea nasce da alcuni economisti che iniziano a contrapporre i costi di produzione e i costi di transazione. È l'inizio di quelle che noi chiamiamo oggi **multinazionali**. *Che succede con tutto questo? Questo processo che cosa innesca?* Innesca una nuova forma di costruzione dell'ordine sociale, dove il costo che deve sostenere l'imprenditore non è più quello di produrre, di produzione delle materie prime nel proprio paese d'origine, ma è semplicemente di vendere, di costruire delle vere e proprie reti dove i pezzi della produzione costano di meno, e poi tutto il prodotto si assembla in un ulteriore fabbrica, in un ulteriore stabilimento e si distribuisce all'interno dei Paesi dove c'è domanda per quel determinato prodotto. Oliver Williamson, è l'economista che per primo ha parlato della differenza tra costi di transizione e costi di produzione, è anche uno dei primi economisti che introduce per definire le nuove strutture economiche, la parola **governance**, che è una parola di chiara ispirazione anglosassone, per identificare il modo in cui queste strutture nuove imprenditoriali funzionano. Questo è un processo meramente economico, mentre prima l'economia aveva preso modelli giuridico-economici e li aveva applicati al discorso

economico, ora accade esattamente l'opposto, che queste strutture ramificate, vengono mutuate dal discorso giuridico come nuovi modelli di costruzione di ordine sociale. In questo caso è il diritto che mutua dall'economia, dal discorso economico, tutto un apparato che costruisce un nuovo modo economico giuridico, di costruire, di interpretare il nostro ordine sociale. *Come avviene, e come si arriva a tutto questo?* Si arriva attraverso la costruzione di enormi reti transnazionali, analoghe alle reti di dislocazione che riguardavano i mezzi di produzione e nelle grandi fabbriche, che riguardano le grandi industrie, che toccano però anche la vita dell'organizzazione sociale e la vita del diritto. L'Unione Europea sono i famosi oggetti giuridici che sono costruiti secondo ramificazioni, in questo caso, comprendono più Stati tra di loro. Tant'è che nell'Unione si parla di governance europea. *Dunque la governance che cos'è?* La governance è in realtà una **struttura reticolare** di costruzione di un particolare ordine che tende a mettere in relazione oggetti eterogeni tra di loro. Nell'Unione Europea, per esempio, sono messe in rete gli Stati Nazioni, le agenzie, le corti europee, tutte contribuiscono alla costruzione, al governo di un territorio che è quanto meno, sempre più ampio e sempre più diffuso. Gli elementi costitutivi di una struttura di governance è una struttura a rete. L'idea della rete ci deriva proprio dalla metamorfosi del modo in cui funzionano le grandi industrie. La Fiat italiana, è proprio un esempio clamoroso di questa metamorfosi del passaggio dal **Fordismo** al **post-Fordismo**. La Fiat è in conflitto perché è un'altra di quelle grandi multinazionali che ha dislocato ormai in tutta Europa, ci sono i maggiori stabilimenti, in Romania e Polonia, per esempio, e non produce più occupazione e ricchezza all'interno del nostro Paese, pur beneficiando di una serie invece di benefit e di legislazione speciale da parte di vecchi legislatori e vecchi governi italiani, da qui il tema, il problema di uno squilibrio forte tra quello che ha ottenuto negli ultimi 30 e 40 anni e quello che non ha restituito in termini di occupazione e di costruzione del benessere all'interno del nostro Stato-Nazione. Lo Stato-Nazione molto spesso ormai è abbastanza impotente rispetto alla costruzione di questi modelli che sono dei modelli extraterritoriali, il diritto statale si ferma ad un certo punto non riesce più a effettuare la pressione psicosociale su questi organismi ormai a rete extraterritoriali, multinazionali, dunque le strutture di governance sono strutture reticolari dove si connettono oggetti che hanno natura e funzione diversa. I vecchi Stati-Nazione sono molto spesso collegati all'interno di una rete in cui sono messi in relazione con le multinazionali, con le corporation, con organi transnazionali, con le agenzie di rating, e dunque sono strutture complesse che noi utilizziamo per governare un mondo che è diventato decisamente più complesso rispetto a quello del secolo scorso e dove la contaminazione tra discorso economico e discorso giuridico e politico è ormai definitiva, si è ormai completata. Il lessico giuridico, governance è un termine non giuridico eppure oggi definisce che cosa è al centro di notevolissimi problemi giuridici perché definisce una nuova struttura di costruzione dell'ordine sociale così come l'ordinamento è stato per il secolo scorso, con la differenza che il concetto di governance non è un concetto giuridico, è un concetto economico, che il diritto mutua dal linguaggio economico con tutta una serie di vantaggi e di svantaggi, perché se dobbiamo governare la complessità, ci serve un modello adeguato che è un modello aperto, reticolare, un modello che si contamina; gli istituti di governance mettono insieme il pubblico e il privato, l'economico e il giuridico, il politico e il sociologico, il basso e l'alto, sono strutture che costruiscono forme di governo cioè forme di controllo da soggetti che sono eterogenei tra di loro, quindi si può considerare che le strutture di governance sono strutture reticolari, *se sono strutture reticolari dunque sono strutture a rete, come si svilupperanno le strutture di governance? che direzione seguiranno? orizzontale o verticale?* Orizzontale, se gli ordinamenti così come li abbiamo studiati conoscono sempre la verticalità, e le strutture di governance invece sono orizzontali, se le strutture piramidali sono strutture gerarchiche perché c'è la piramide, quindi lo sviluppo verticale, le strutture di governance saranno **strutture rizomatiche***, che cos'è il rizoma?* Il rizoma è la radice della pianta o del fiore che nel terreno ha messo radici. Il termine rizomatico è suggerito da due filosofi fondamentali per la costruzione del

concetto di governance, due filosofi francesi che si chiamano Gilles Deleuze e Félix Guattari, che negli anni Ottanta pubblicano un volume che si chiama “Mille Piani, capitalismo e schizofrenia” , loro per primi parlano di una costruzione dell'ordine sociale, che da essere verticale diviene orizzontale, da essere piramidale diviene rizomatica, dunque le nuove strutture di governance seguono uno sviluppo reticolare, uno sviluppo rizomatico. Se la struttura è rizomatica e non è più piramidale, *questa struttura che carattere avrà? come abbiamo definito la piramide kelseniana?* come una struttura gerarchica, piramidale, costruzioni a gradi trascendente o trascendentale. *Perché?* Perché essendo una struttura verticale, la verticalità implica sempre la necessità di un punto di origine, quindi di un'origine trascendente o trascendentale. *Se lo sviluppo della struttura invece è orizzontale, ed è reticolare, le strutture di governance hanno natura trascendente o trascendentale, e che natura hanno?*

In Hobbes c'è un fondamento, trascendente, perché il Leviatano non è altro che colui il quale tiene insieme il potere divino con il potere terreno all’interno della costruzione delle cose, dello Stato, dunque c'è un ideale, una fondazione trascendente, che in Kant diventerà, trascendentale come condizione di pensabilità e di possibilità, che Kelsen riprende. Se, invece, nelle strutture di governance, noi abbiamo uno sviluppo rizomatico, orizzontale, *qual è il filosofo che si contrappone a Hobbes, a lui successivo?* Il grande filosofo che ha rinnegato la trascendenza, ma ha dato un'idea della religione tutta immanente, che ha costruito, ha opposto la trascendenza all'immanenza, *chi è il filosofo dell'immanenza?* Spinoza, filosofia dell'immanenza assoluta, il Deus Sive Natura, l'idea per cui Dio si manifesta non più come entità trascendente, verticale, ma è diffuso all'interno della nostra natura, la differenza fra effetti, sostanze… È tutta un'unica sostanza che si manifesta attraverso gli altri punti della sostanza, quindi la sostanza è una, ma si manifesta attraverso tutta una serie di attributi che si diramano all'interno della costruzione della nostra verità. Ecco, Deleuze e Guattari guardano a Spinoza, quando definiscono la costruzione del nostro ordine sociale come una costruzione che si svolge su un piano di immanenza, lo oppongono alla piramide trascendentale dello Stato novecentesco. Deleuze parla di un piano di immanenza, non c'è più verticalità, c'è solo orizzontalità, con tutto quello che ne discende. Questa idea della dislocazione che nasce come fenomeno economico, finisce per essere un modello politico-giuridico che tende a rileggere la costruzione dell'ordine sociale come una costruzione diffusa, reticolare, rizomatica, fra oggetti normativi diversi che costruisce o costituisce un unico piano di immanenza, dove si incrociano e si mescolano diritto, politica, economica, tutto si ibrida nel post moderno, ma in senso orizzontale, senza alcuna verticalità, senza alcuna gerarchia. Il modello è esattamente l'opposto, una cosa interessante della governance non è solo un modello che si è aggiunto al modello classico, che è quello del modello ordinamentale, è un modello che capovolge completamente il modello ordinamentale. Questa è la cosa interessante, cioè quando il diritto mutua il discorso economico, capovolge i suoi concetti fondamentali, quindi la governance non è soltanto un modello aggiuntivo, è un modello alternativo alla visione, alla costruzione giuridica, ordinamentale, novecentesca, dove c'era la gerarchia c'è il rizoma, dove c'era la verticalità c'è l'orizzontalità. Dove c'era il trascendente o il trascendentale, c'è l'immanente, sono tutti **concetti** che sono proprio **opposti** tra di loro, con tutto quello che ne implica. *Come funziona una struttura?* Funziona esattamente in maniera opposta a come funziona il diritto ordinamentale che abbiamo studiato fino ad ora, perciò è interessantissimo e perciò la soggettività che noi dobbiamo considerare dinanzi ad una struttura di governance non può più essere l'osservatore perché l'oggetto non solo è mutato anzi è radicalmente capovolto e dunque ci serve un agente, un destinatario che abbia caratteristiche esattamente opposte. È importante capire, vedere come si **ragiona per opposizioni**, questo ci deve far riflettere non poco sul fatto che si ragioni per concetti che sono radicalmente opposti tra di loro, cioè il fatto che la governance elimini completamente la gerarchia, il trascendente o il trascendentale, e il tema

della verticalità, è magnifico, è straordinario, però bisogna vedere poi come il piano di immanenza è tutto da guadagnare rispetto ad una struttura trascendente o trascendentale. Però vedremo come in realtà anche questi hanno problemi non da poco. L'idea è straordinaria, ma l'applicazione mostra parecchi lati oscuri.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 25 DEL 27/11/2024

Le strutture di governance funzionano esattamente in maniera opposta rispetto alle strutture ordinamentali: ciò vuol dire che, se le strutture ordinamentali sono piramidali, gerarchiche, trascendenti (o trascendentali), le strutture di governance sono rizomatiche (o reticolari), orizzontali e immanenti. Il piano di immanenza è contrapposto al piano trascendente della logica della costruzione ordinamentale di Kelsen. Questa differenza tra l'immanente e il trascendente implica che, in primo luogo, il piano immanente se è immanente a se stesso non necessita di nessuna legittimazione esterna, questa struttura si autolegittima, e in secondo luogo, se il piano è immanente e tende a ramificarsi continuamente (espandersi costantemente) vuol dire che non ha punto di inizio e di fine; se con Kelsen si presentava il problema del *regressus ad infinitum*, le strutture di governance autolegittimandosi ed essendo sul piano di immanenza che si accresce continuamente e ripetutamente, non solo non necessitano di un principio di legittimazione, ma non lo vogliono: le strutture di governance tendono per loro dinamica costitutiva a espandersi all'infinito, a mettere costantemente in relazione sempre più oggetti e soggetti possibili. Lo scopo di una struttura di governance è costruire un nuovo ordina che permetta di rendere quella struttura il più efficiente possibile (torna nel discorso giuridico il tema dell'efficienza, già affrontato con Michel Foucault per quanto riguardava il passaggio dall'efficacia all'efficienza, del Panopticon e dell'efficacia del dispositivo). Le strutture di governance si espandono sul piano di immanenza in maniera infinita e indefinita tentando di costruire reti sempre più ampie ed efficienti. I primi studiosi della governance hanno rintracciato in un vecchio manuale destinato alla funzione di dirigente di una compagnia telefonica americana del secolo scorso, la Bell Telephone, le modalità attraverso cui funziona una struttura di governance. In uno di questi manuali il cui autore era l'economista Chestern Earnhardt che dice che in una struttura orizzontale, rizomatica d'impresa, la funzione di chi esercita il ruolo dirigente è quella di "decidere di non decidere": si costruisce una rete che sia il più ampia possibile delegando il potere decisionale ad altre strutture. Nel discorso giuridico del '900; Kelsen "se A, deve essere B" (decidere se applicare o meno una data sanzione ad un soggetto); Ross parla di uno schema di decisone rispetto alle decisioni delle corti; Hart quando parla di interpretazione, parla di come noi decidiamo entro le fattispecie delineante dall'ordinamento, come usare quella determinata norma; Schmitt è il padre del decisionismo giuridico: sovrano è chi decide nello stato di eccezione (quando viene meno l'ordine giuridico) come riportare l'ordine sociale. Tutte le teorie giuridiche del '900 individuano la forza del diritto nella sua capacità decisionale di dirimere situazione e conflitti sociali, la forza del diritto è la sua capacità di decidere. La forza della governance è quella di non

decidere, per sviluppare la struttura reticolare bisogna decidere di non decidere, e delegando continuamente le competenze ad altri soggetti: decidere vuol dire recidere, fare una scelta escludendone un'altra. La governance non è però una struttura escludente, il diritto è invece una struttura escludente (ci dice cosa è giusto e cosa non lo è, cosa è valido e cosa non lo è). La governance tende a far partecipare più soggetti possibili alle dinamiche rizomatiche costruite nella rete, per far questo non deve escludere nessuno e non può prendere A ed escludere B, ma deve prendere A e B. Nella governance si integra qualsiasi cosa, costruendo reti che siano infinite nella loro dinamicità e sempre più efficienti e funzionali per il perseguimento degli scopi per cui la rete si è costituita: per questo è necessario per Chestern Earnhardt "decidere per non decidere", decidere di non escludere nessuno. La governance è una struttura che tende a massimizzare la partecipazione, sono quelle strutture di ordine sociale e di governo dette strutture controllate: il discorso giuridico e normativo si costruisce dal basso con una partecipazione massimizzata, più partecipanti possibili. Searle tende a costruire la realtà sociale attraverso il concetto di regola costitutiva, ma il cuore del concetto di regola costitutiva è l'intenzionalità collettiva; Searle e Foucault sono ponti di passaggio tra le vecchie strutture ordinamentali e le nuove strutture di governance. Nelle strutture di governance si massimizza e si rende sempre più efficiente la struttura messa in essere, ma quale potrebbe essere il tipo di potere esercitato dalle strutture di governance? Il filosofo francese Jacque Lenoble dice che all'interno delle strutture di governance sarebbe impensabile l'esercizio di un potere prescrittivo-sanzionatorio alla Kelsen, poiché avrebbe carattere escludente: se l'obiettivo della struttura di governance è raggiungere la massima efficienza possibile, un tipo di potere è il potere di indirizzo continuo, un potere dolce (governance, per Jacque Lenoble deriva dal latino "Governare", dare la direzione del pastore rispetto al gregge: anche nel caso delle pecore nere, al pastore non conviene picchiarle o ucciderle a causa della loro disobbedienza, perché sono una sua forma di sostentamento; il pastore deve cercare di rendere il più efficiente possibile il proprio gregge attraverso un processo continuo e costante di esercizio di un potere disciplinare; il pastore disciplina il gregge, in Foucault questo potere disciplinare era stato paragonato al dressage per i cavalli: se il cavallo è disobbediente, al fantino non conviene fargli del male, ma ha interesse a rieducarlo). Il potere prescrittivo-sanzionatorio nelle strutture di governance mostra il suo lato educativo e diventa un potere disciplinare, l'obiettivo non è reprimere ma è rendere massimamente efficiente e funzionale allo scopo che la struttura vuole perseguire. Accanto a questo potere ce n'è un altro molto particolare: il sociologo norvegese degli anni 90 Thomas Mathiesen si è reso conto, sulla base dell'intuizione panoptica di Foucault, che nelle nuove strutture di governance l'esercizio del potere disciplinare non avviene solamente attraverso il condizionamento derivante dall'essere costantemente osservati, ma c'è anche il condizionamento del potere disciplinare opposto a questo: questa forma di potere è detta Synopticon, dove i molti invisibili guardano l'uno visibile e si lasciano trascinare, si immedesimano con l'uno metabolizzando i comportamenti sperimentali messi inscena dall'uno: è un altro modo di educare che funziona nel modo opposto al Panopticon. (per anni gli studi Hollywoodiani hanno usato le star Hollywoodiane come strumenti di ammortizzazione sociale, le star mettevano in campo comportamenti ideali che si volevano impartire alla popolazione americana. Il cinema è stato uno dei grandi meccanismi per uniformare i comportamenti dei destinatari "*Law as film*"). Il Synopticon è un meccanismo antichissimo di potere disciplinare che si basa su progetti architettonici dove una massa di spettatori guarda un soggetto su un palco immedesimandosi nello stesso e metabolizzandone le idee e i comportamenti. Le strutture di governance nascono con i grandi processi di globalizzazione e con le società dello

spettacolo; il Synopticon è strettamente collegato ad un potere normativo non giuridico che però funziona come meccanismo di costruzione dell'ordine sociale attraverso questi altri canali. Nella governance l'esercizio del potere giuridico è marginale, la governance preferisce tentare di disciplinare in ogni modo rispetto all'esclusione. Panopticon: l'uno invisibile guarda i molti visibili; Synopticon: i molti invisibili guardano l'uno visibile (Es: oggi i Social). L'uno è il capovolgimento dell'altro e sono entrambe forme di esercizio del potere disciplinare. Il diritto inizia a "contaminarsi" con altri saperi. Le strutture di governance hanno molti vantaggi: eliminare le strutture gerarchiche e i fondamenti trascendenti, l'dea di un ordine sociale che si legittima spontaneamente (democrazia costituente di Spinoza, potere orizzontale del demos che riscrive continuamente le proprie regole del gioco partecipando dal basso), l'eliminazione del potere prescrittivo-sanzionatorio. Il nostro mondo è profondamente istituzionalizzato. Le strutture di governance presentano anche delle ombre, degli svantaggi: è vero che si "decide di non decidere" che rispetto al decisionismo del '900 è molto interessante, ma nella rete potrebbe esserci qualcuno, nodi nascosti e veri decisori della rete e del destino di tutti i partecipanti: il meccanismo della delega di competenza (ogni norma deve essere conforme a quella subito successiva) se è un criterio antico individua subito il responsabile della decisione, nella struttura di governance chi decide non solo non è individuabile, ma non è neanche responsabile, la responsabilità è sempre diffusa. Nelle strutture ordinamentali c'è il problema della legittimazione, il potere è esercitato da chi è legittimato democraticamente a poter normare nei nostri confronti. L'esercizio del potere disciplinare della governance è disciplinato in virtù dell'efficienza economica che vuole raggiungere la struttura di governance, e non democraticamente. Da qui l'idea di approfondire le strutture di governance. La ragnatela del paino immanente e orizzontale della governance ha quindi alcuni punti deboli. Si possono passare in rassegna alcune immagini per comprendere meglio queste concezioni.

La rappresentazione del Leviatano di Hobbes per esempio. Schmitt dice che l'illustrazione di Abrham Bosse del Leviatano di Hobbes, esprime molto più dell'intera opera scritta del filosofo. Nell'immagine risalta il corpo del sovrano che tiene in mano la spada, che rappresenta il potere temporale, e il pastorale, egli è il pastore delle anime. Spada e pastorale suggeriscono che il Leviatano racchiude in sé il potere divino e terreno. Sopra la corona c'è una scritta che dice non c'è nulla al di sopra del Leviatano. Il corpo del sovrano spunta dalle montagne, al di sotto delle quali c'è una città con una chiesa, un municipio, delle abitazioni ed è cinta da delle mura: ciò romanda anche a Kelsen, il potere del sovrano si esercita in uno spazio definito (dalle mura) e su una popolazione definita che il sovrano abbraccia. Fuori dalla città ci sono i nemici della città. Schmitt dice che il diritto si fonda sulla logica amico-nemico, è di per sé escludente, l'ordinamento dice ciò che è dentro e ciò che è fuori (punto di vista interno ed esterno, oggettivo e soggettivo rispetto all'ordinamento), tutto ciò che è dentro al Leviatano è amico, ciò che è fuori è nemico, questa è detta logica escludente. Avviene ancora oggi per esempio con lo Ius soli la logica escludente. Proprio la costruzione hobbesiana nasce dalla paura dell'altro: "Homo homini lupus", cedo la mia libertà in cambio della sicurezza da parte del leviatano, perché ho paura dell'altro; Spinoza dirà il contrario. Nell'ultima parte del Leviatano intitolata "Il regno delle tenebre", Hobbes dice che si apre il regno delle tenebre quando non c'è il Leviatano perché tutti possono aggredire tutti; il pensiero di Hobbes è l'esito delle guerre di religione e della Guerra dei Trent'anni dove si sono compiuti grandi massacri ed era necessario stabilizzare l'ordine e mettere fine alla paura di vivere pensando di poter essere aggrediti da un momento all'altra. Nel disegno si nota la piramide, al vertice della quale c'è la corona del sovrano, alla base c'è la popolazione e ai lati le braccia del sovrano. Il corpo del

sovrano è fatto dai sudditi, quelle che da lontano sembrano le scaglie di un'armatura, da vicino sono i corpi dei sudditi che immedesimandosi nel Leviatano chiedono protezione in cambio della cessione della propria libertà. Con Kelsen il discorso giuridico della modernità cambia: al vertice c'è un presupposto logico trascendentale, il corpo dei sudditi si è smaterializzato nell'insieme di quelle norme (stufenbau) che è indifferente ai contenuti: la piramide è diventato un oggetto cristallino: un semplice triangolo. La logica concettuale è la stessa di Hobbes ma con la modernità che produce un livello di astrazione più elevata. Il decisionismo diventa una delega di competenza. Passaggi da un modello all'altro: Fordismo (imprese come piccoli stati con strutture gerarchiche piramidali)→Post-fordismo (imprese che si organizzano in reti di produzione dislocate su un vasto territorio).

Deleuze pensa alle nuove strutture di ramificazione del potere. Le strutture hanno subito l'influenza dell'ammodernamento delle tecniche economiche e tecnologiche. Il Synopticon deriva dall'immaginario teologico: la potenza di una persona che parla ai molti è esperibile dalle architetture delle chiese cristiane: il pulpito pone in posizione sopraelevata chi deve parlare. I teorici americani parlano di Soft Power contrapposto all'Hard Power: l'Hard Power è il classico potere prescrittivo-sanzionatorio, mentre il Soft Power è il potere delle strutture di governance, un potere dolce e disciplinare. Le immagini dei quaderni di Deleuze mostrano i rischi della struttura di governance. Il diritto è aperto, s deve sempre rimodellare rispetto agli ampliamenti costanti ed infiniti. Il potere normativo non è più prevalentemente prescrittivo-sanzionatorio, ma si piega sulle forme dei soggetti che deve disciplinare, un potere più profondo ed efficiente. Nell'immagine barocca, rispetto a quella di Hobbes, ci sono le "pieghe" in cui la realtà diventa impalpabile: la crisi dello stato sovrano deriva da questa piega che ha preso la realtà sociale. Il piegarsi e il ripiegarsi all'infinito della base su cui dovrebbe posare il potere della sovranità dimostra il cambiamento. Più pieghe ci sono più è difficile guardare cosa si nasconde sotto di esse. Sotto le pieghe ci potrebbe anche essere il vuoto, non esserci niente. Nel nostro stato di eccezione, l'eccezione non fa altro che nascondere il vuoto assoluto di potere.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

Lezione 26 **del 02/12/2024**

Ok, allora, andiamo avanti, quindi governance, concetto di governance processo che tende a mettere in relazione, ovvero costruire reti di comunicazione fra soggetti diversi in questo caso, soggetti diversi che hanno fra di loro una natura eterogenea.
Dicevano la volta scorsa che, e questo ve lo suggerisco anche per l'esame, potrebbe essere molto probabile ricerche, no? La domanda che cos'è la governance? Come si definisce? Quali sono i fatti costitutivi di un processo di governance?
La risposta è, che io vi suggerisco, e nel caso in cui voi non vi ricordiate esattamente tutte le caratteristiche della struttura di governance, è di pensare all'antico concetto di ordinamento diritto in Tencent e di ragionare esattamente al contrario, in modo opposto e contrario su tutte le caratteristiche e sulla funzione che svolge in questo caso l'ordinamento e la funzione che svolge la governance.
Diciamo a proposito del processo di struttura di governance, la governance è cosa? È un processo che si svolge immaginando la direzione orizzontale che si procede all'infinito su un piano di immanenza dove si distinguono dalle sfumature trascendenti o trascendentali tipiche dell'ordinamento, e che non ha struttura gerarchica.
Deleuze definisce questo tipo di struttura, l'abbiamo visto anche nelle immagini, come una struttura rizomatica che segue, si sviluppa un piano di immanenza, ricordate dal punto di vista filosofico proprio la differenza fra Hobbes e Spinoza, quindi all'interno della filosofia seicentesca il tema del trascendente potere, la costruzione trascendente del potere è il tema della costruzione immanente del potere, il potere giuridico politico.
Come funziona un processo di governance?
Il tema del processo di governance anche qui funziona in maniera esattamente opposta a come funziona una struttura ordinamentale.
Se una struttura ordinamentale fa che cosa?
Se costruisce il proprio ordine attraverso l'esercizio di un potere prescrittivo-sanzionatorio, la struttura di governance invece tende a fare che cosa? Tende a controllare, indirizzare, in questo caso, che cosa? I comportamenti dei partecipanti all'interno della struttura di governance, rendendoli massimamente efficienti verso il perseguimento dell'idea, dello scopo per cui quella struttura si è costituita, dunque le strutture di governance sono strutture che si vorrebbero/dovrebbero costruire dal basso attraverso la partecipazione di tutti i destinatari che tendono a contendere verso un'unica direzione.
I filosofi del diritto, per esempio tedeschi, che si sono occupati in questi ultimi anni di teoria della governance, invece di chiamarla teoria della governance, per esempio la chiamano steuerungstheorie, ovvero che in tale scuola, letteralmente vuol dire teoria della direzione, proprio per indicare come in realtà all'interno di un processo di governance non c'è mai la decisione prescrittiva o sanzionatoria, ma una decisione che segnala, ossia tutto l'immaginario filosofico giudico moderno o del Novecento, da Hobbes fino a Ross, con il tema delle sentenze, delle decisioni giurisprudenziali, l'applicazione del discorso giudico, l'efficacia del diritto è evidentemente sempre legata a qualcuno che decide qualche cosa, che sia il legislatore, che siano i giudici, che siano noi, sia nella nostra individualità sia come intenzionalità collettiva, c'è sempre un momento decisionale, dal decisionismo giuridico di Carl Schmitt, sovrano che decide lo stato di

eccezione alla decisione delle corti in Ross, il momento della decisione è uno dei momenti, è il cuore regolatore, poi fondamentalmente della costruzione del discorso giuridico del Novecento.
Capovolgimento di prospettiva, nella governance invece si decide di non decidere, perché?
Perché la governance non è un potere che tende a escludere, ma è un potere che tende a includere.
Da qui il tema di un piano di immanenza che si sviluppa in maniera verso l'infinito, cercando di mettere in comunicazione più soggetti diversi, cercando di escludere il meno possibile.
Come faccio a non escludere nessuno? Con l'idea di mediare continuamente, di costruire quello che i teorici statunitensi chiamano un network, il potere che ha la forma di un network, ovvero di una relazione, di una rete di relazione fra soggetti che hanno una natura diversa, pensate in questo caso come siamo lontani, ancora una volta dalla prospettiva Kelseniana, in Kelsen c'è l'ambizione di costruire che cosa?
Un lessico concettuale puro del diritto, la purezza della teoria del diritto.
Qui invece il tema è proprio il contrario, lungo il piano di immanenza mettiamo in relazione i soggetti più diversi tra di loro, il pubblico e il privato, l'economico e il giuridico, il politico e l'ideologico, tentiamo di tenere tutto insieme in modo da eliminare preventivamente qualsiasi forma di conflittualità sociale e di rendere la struttura massimamente efficiente.
Non, dunque, la parità o la legittimità come collante della struttura, della costruzione dell'ordine sociale, ma l'efficienza, torna il tema, un panottico che avevamo già analizzato in Foucault.
E infatti come si mantiene l'ordine sociale in una struttura di governance?
Dicevamo la volta scorsa che l'ordine sociale si mantiene proprio attraverso che cosa? Attraverso il controllo costante, la sorveglianza costante dei partecipanti per un verso e per l'altro verso, attraverso che cosa?
Attraverso il processo di immedesimazione, evidentemente, tra stereotipi sociali individuati all'interno della governance e destinatari, attraverso un meccanismo che è anche qui esattamente l'opposto di quello che noi abbiamo visto lavorando sul concetto di osservatore. Se la forma più estrema di costruire dell'osservanza è paralizzare il dispositivo panottico foucaultiano, qui si ha il capovolgimento partendo proprio dalla teoria di Michel Foucault.
Un sociologo, del Nord Europa, Thomas Mathiesen, elabora il tema del synopticon.
Il synopticon altro non è che nel capovolgimento del panopticon.
Se nel panopticon l'uno invisibile vede i volti invisibili, nel synopticon è esattamente il contrario.
Inoltre, l'uno visibile viene ammirato dai molti invisibili e dunque qui la trasmissione del potere, è proprio la comunicazione di una sorta di gloria, per usare ancora una volta un termine teologico, quindi di immedesimazione all'interno, fra i corpi, fra il corpo della folla che si immedesima nel corpo il quale si trova invece su un determinato palcoscenico ed è, in questo caso, una figura, ha un potere, ne esercita il potere della folla, nei confronti della folla un potere carismatico, crede Max Weber, tutto sommato.

Quindi, c'è l'incrocio di queste due forme in costruzione dell'ordine sociale attraverso il potere, potere panopticon e potere synopticon, che in entrambi i casi rappresentano e costituiscono comunque l'esercizio di un potere, tra virgolette, dolce, non è qui potere decisionale del discorso giuridico tradizionale, è un potere completamente diverso.
Alcuni filosofi del diritto, anglo-americani per esempio, parlano qui di smart power, cioè di un potere intelligente, diciamo, di smart power o di soft power, un potere, in questo caso, dolce, contrapposto al hard power, che è proprio quello invece il prescrittivo sanzionatorio tipico dell'efficacia del discorso giuridico, la pressione psicosociale del discorso giuridico, dove c'è il verso, no?
Quindi, vedete, all'interno della struttura di governance l'esercizio del potere segue queste due diverse traiettorie nello sguardo, non che non ci sia anche il potere giuridico, ma l'ordine sociale è affilato prevalentemente a questo tipo di costruzione, a questo tipo di pressione psicosociale, che ha

una natura diversa rispetto a quella esercitata tradizionalmente dal potere prescrittivo del discorso, del prescrittivo sanzionatorio del discorso giuridico.
Abbiamo visto la volta scorsa luci e le ombre in tutto questo, però ci siamo soffermati principalmente su che cosa?
Proprio sul tema del synopticon.
Perché? Perché questo rovesciamento della prospettiva immediatamente ci suggerisce come all'interno dei processi di governance, no?
Ecco, quando parliamo di synopticon, no?
Come definireste in questo caso il destinatario che ammira, si immedesima, applaude, si emoziona guardando il proprio idolo sul palcoscenico.
Chi sono queste folle? Come le potreste chiamare?
Sono spettatori, no? Si parla evidentemente di un'altra forma di soggettività, ovvero la soggettività spettatoriale.
E qui entra in gioco il secondo tipo di soggettività del discorso giuridico, anzi, qui sarebbe meglio dire discorso giuridico-politico, che è al centro del nostro corso e che conclude con queste ultime due volte o tre, adesso vediamo, il nostro percorso, cioè la figura dello spettatore.
Già l'avevamo considerata, vi ricordate?
Quando abbiamo introdotto il tema dei soggetti nello sguardo, ancora una volta in contrapposizione alla figura dell'osservatore.
L'osservatore che è passivo perché non guarda i fenomeni reali, no?
Anzi, non guarda i fenomeni, ma guarda le loro rappresentazioni, no?
E dunque, come dire, la capacità di incidere sulla realtà fenomenica giuridica fenomenica completamente, o almeno apparentemente, però diciamo che manca completamente alla figura spettatoriale.
Ci siamo?
Come potremmo iniziare a definire lo spettatore? Anche qui il suggerimento è utilizzando un po' il metodo in questo caso dialettico che procede per opposizione rispetto all'altra forma di soggettività che noi abbiamo analizzato fin da ora, che è la figura dell'osservatore.
E che cosa potremmo dire? Ricordate alcune considerazioni che avevamo fatto sulla figura dell'osservatore al di là della funzione di un perché.
L'osservatore è un soggetto dello sguardo attivo e lo spettatore è un soggetto passivo che ha altre caratteristiche che avevamo riconosciuto alla figura o al concetto di osservatore, no?
L'osservatore nasce come soggetto attivo in grado di conoscere la natura e dunque di modificare l'oggetto che conosce attraverso la costruzione di un metodo che ha o non ha in sé.
Quando abbiamo individuato una differenza, una collocazione storica rispetto invece al concetto dell'osservatore? L'osservatore è un concetto recente o un concetto antico? Recente, perché? Quando nasce questo tema il tema dell'osservatore?
Con le scienze sociali, ancora prima delle scienze sociali con il positivismo e, in realtà, per dirla ancora meglio ragazzi, il positivismo affonda le proprie radici in un determinato illuminismo che ha le radici in chi se non in Kant.
È Kant il primo che determina la funzione dell'osservatore distinguendolo da altri soggetti dello sguardo e iniziando a circoscrivere intorno a questa figura alcune caratteristiche epistemologiche di quello che sarà poi l'osservatore in ambito positivista.
Le scienze del diritto non fanno altro che mutare dal positivismo scientifico-scientista questa figura e traslarla all'interno delle coordinate del discorso del diritto e da lì tutto quello che ne segue, ormai con la stessa dei massimi aspetti circa la figura dell'osservatore.
Quindi si tratta di una figura che c'è, è una figura che il discorso giuridico muta dal discorso scientifico, dalle scienze naturali, dal positivismo e dall'illuminismo, ci siamo?
Ragionate un attimo la figura dello spettatore invece, come si pone dal punto di vista storico-filosofico?
È molto più antica e ora vedremo perché.

Giusto per ricostruire delle parti essenziali del concetto lo spettatore è una figura antica che nasce con il teatro greco.
È lì probabilmente la prima vera e propria forma di spettatore.
Hannah Arendt ha fatto una lunga analisi della figura dello spettatore, non so se faremo in tempo a farla.
Comunque spieghiamo questa parentesi riguardo il tema dello spettatore.
Quindi lo spettatore è una delle prime forme di soggettività, ed è una forma di soggettività che deriva, o fonda le sue radici, non nel discorso scientifico, ma in quale tipo di discorso?
Nelle scienze umane, dove all' interno di queste possiamo comprendere la dimensione letterale, la dimensione teatrale, la dimensione più recentemente cinematografica.
Quindi tutta una serie di elementi, di atti della dimensione artistica che nutre, in questo caso, anche l'immagine a livello giuridico.

Adesso andiamo al punto chiave su cui ci dobbiamo interrogare.
Nella differenza fondamentale fra osservatore e spettatore, e sulle teorie che possiamo costruire partendo dall'uno e partendo dall'altro.
Manca un presupposto che è proprio la differenza fondamentale a livello di soggetto epistemico diciamo, o metodologia epistemologica tra l'osservatore e lo spettatore.
Pensate, per esempio, ad Hart e al punto di vista interno.
Che cosa permette il punto di vista interno di Hart rispetto a un fenomeno sociale?
Permette di indagare le ragioni del fenomeno sociale.
Ora, lo spettatore che tipo di approccio ha al fenomeno giuridico?
Non è esterno.
Facciamo l'esempio direttamente, quando guardate una rappresentazione, una finzione rispetto a quella rappresentazione perchè invece vi è piaciuta o non vi è piaciuta?
Se vi ha affascinato o meno, meglio è quello che possiamo dire, perché le emozioni potrebbero farci pensare per esempio a Ross.
Abbiamo detto che in Ross, per esempio, c'è il tema della pressione psicosociale, dunque, delle emozioni che prova il destinatario dinanzi alla pressione psicosociale che esercita l'ordinamento nei propri confronti.
Che tipo di epistemologia ha in questo caso lo spettatore rispetto all'epistemologia di un osservatore?
L'osservatore predilige comunque che cosa?
Le ragioni, quindi, la spiegazione razionale.
Come?
Personale.
Cosa permette la teologia che ha?
Permette di esprimere giudizio personale su quello che tu hai visto; per esempio che tipo di approccio devi avere? un tipo di emotività particolare.
Torniamo al tema del teatro Greco dell'Università di Verna, non la semplice emozione di Ross, ma il pathos.
L'epistemologia dello spettatore è un'epistemologia patetica che parte da che cosa? da un processo di immedesimazione con la finzione con l'oggetto rappresentato.
Il pathos è stato uno dei grandi nemici del diritto moderno se ci pensate, anche qui il capovolgimento è totale.
Pensate a Kelsen, che cosa ha prodotto? Di cosa si è preoccupato?
Di circoscrivere un discorso giuridico che fosse completamente immune da un aspetto di carattere patetico, da qualunque tipo di valutazione personale, da parte di ogni singolo destinatario.
Questo perché si cercava che cosa? Un fondamento del discorso giuridico che fosse il più oggettivo possibile, e allora l'oggettività implica che cosa?

Implica la durezza, no? Dell'epistemologia eliminiamo qualsiasi elemento che possa essere ricondotto, o che possa ricondurre ad una valutazione, o visione soggettiva.
È chiaro che poi qui questa idea di un soggetto del diritto che si avvicina, che approccia, il fenomeno giuridico pateticamente rivela sia orizzonti, come dire, preoccupanti, sia orizzonti di un carattere diverso.
Secondo la visione del fenomeno giuridico vedremo che un approccio di questo tipo non può che essere un approccio sbilanciato.
Il possibilismo giuridico ha sempre cercato di costruire il discorso giuridico in modo che fosse il più oggettivo possibile; dunque, che fosse libero da qualsiasi contaminazione o influenza soggettiva.
Invece, nel momento stesso in cui tu costruisci una epistemologia fondata sul pathos è chiaro che qui l'elemento, il nostro oggettivo torna in gioco; bisogna capire in che modo torna in gioco e se questo tipo di approccio al discorso giuridico è un approccio sempre passivo che relega sempre il destinatario- dunque in una funzione totalmente passiva rispetto alla costruzione del discorso giuridico- o può essere anche particolare capacità di riflettere-, capacità riflessiva, critico-riflessiva rispetto alla costruzione e all'analisi del fatto del fenomeno giuridico.
Vedremo proprio come questa figura, le caratteristiche dello spettatore, spoiler nella prossima lezione. aprano il campo a tutta una serie di concezioni del discorso giuridico che appartengono alle teorie post-moderne del diritto, invece, che leggono il diritto come letteratura, come cinema, come forma d'arte come rappresentazione interna anzi, rintracciano giustamente ragazzi, che cosa? Le origini del diritto con proprio questo approccio epistemologico.
Dal concetto di Schengen, dicemmo la volta scorsa, nel teatro greco, poi l'appropriazione di quel concetto nella cultura giuridica romana, dove la messa in scena del teatro era quasi sempre rappresentazione di vicende, di questioni giuridiche.
Fino per gli appassionati di Omero voi sapete che nei poemi omerici, l'ultima parte della critica letteraria dice una cosa: che i critici letterari reputano, tra virgolette, normali, ma che in realtà agli occhi di un giurista assume una potenza straordinaria.
Molta critica dei poemi omerici dice che i poemi omerici non hanno carattere descrittivo in molte loro parti, ma carattere offusco e prescrittivo.

Perché la realtà funziona in maniera prescrittiva?
(Adesso non entriamo nella questione omerica se sia stato lui o meno l'autore.)
In moltissimi di questi passi c'è che cosa? La costruzione di veri e propri stereotipi sociali, i quali devono essere esempio.
Si devono seguire tutta una serie di azioni, come si devono fare i sacrifici, come si devono costruire le relazioni familiari e allora moltissima critica ha rappresentato proprio i poemi omerici una delle prime fonti del diritto.
E' una fonte letteraria in questo caso del diritto.
Non solo, pensate all'inizio dell'Iliade; l'Iliade che cosa racconta?
Un sentimento forte: l'ira di Achille.
L'ira di Achille ragazzi è il tema tutto nel pathos, è il pathos che muove l'ingranaggio che qui fa scatenare tutta una serie, ma come inizia l'ira di Achille?
Ancora una volta, a ragione di Hobbes, il diritto non si fonda, o non è conoscibile interamente attraverso soltanto la logica, e poi questo è tutto il tema o la razionalità delle ragioni del positivismo giuridico perché il diritto non nasce nel positivismo, il diritto nasce nel teatro, nella rappresentazione teatrale è il concetto di messa in scena quel primo fondamento di legittimità del discorso giuridico è un enorme ravvisamento per l'idea per cui non tutto il diritto Novecentesco abbia escluso tutta la dimensione patetica del discorso giuridico, come se dovesse rinnegato completamente le origini.
È il postmoderno che inizia a recuperare tutte queste origini e ad indagare nuovamente il discorso giuridico partendo dalla considerazione del diritto, come arte della messa in scena e non più semplicemente come un arido discorso logico prescrittivo o sanzionatorio.

Questo discorso che vi sto facendo è uno spoiler sulla seconda parte del tema dello spettatore, però, per farvi già capire come in realtà la dimensione patetica permette di ricostruire un'epistemologia giuridica che non parta soltanto dalla ragione, ma anche della passione che non è la semplice emozione, ma è proprio la costruzione, in realtà, di un approccio completamente diverso al discorso giuridico novecentesco.
C'è un bellissimo romanzo di Friedrich Durrenmatt, che è un autore svizzero degli anni 80, il suo romanzo più famoso si chiama ‘’La promessa’’.
Nel libro il tema della promessa è proprio l'inconoscibilità del fatto di diritto, cioè del fatto giuridico, in tal caso la colpa di un diritto utilizzando soltanto la logica e la razionalità dell’interpretazione del diritto, tipica del positivismo giuridico.
Questo approccio non ci restituisce l'interezza del diritto, anzi a mio modo di vedere finisce addirittura per smarrirla, ma non fosse altro che il diritto nasce un tutt'altro abito, non nasce nelle scienze naturali, ma nasce all'interno delle scienze umane.
Sì, tutto questo è vero, è anche vero, però, che lo spettatore, anche a partire dalla filosofia greca, non ha mai goduto di una concezione particolarmente positiva, torniamo al tema della sua passività, no?
Lo spettatore è sempre stato considerato come chi massivamente conosce, in questo caso neanche la realtà, ma le rappresentazioni della realtà, dunque l'impossibilità di conoscere veramente, di accettare la verità delle cose in sé, perché è costretto a vederne solo ombre e riflessi.
La prima grande figura di spettatore è la Repubblica di Platone, l'invito della caverna, è evidente che lì abbiamo già una prima concezione della spettatorialità, c'è tutta una parte di studi, per esempio di teoria del cinema, che identifica proprio la Platonica, la nascita dello schermo cinematografico, della rappresentazione e delle ombre cinematografiche.
È chiaro che però lì l'accezione è negativa, così come l'accezione sarà negativa anche in filosofi più recenti rispetto a Platone.
C'è un meraviglioso testo poco conosciuto di Jean-Jacques Rousseau, che si chiama ‘’L'Etna sugli spettacoli’’, è un testo molto interessante, perché ragiona e abbraccia parecchie connessioni fra la politica nell'epoca di Rousseau e c'è un ruolo affidato a questi teatranti che viaggiavano di strada, che viaggiavano dall'interno e si esibivano nella Ginevra dell'epoca di Rousseau.
Rousseau, per esempio, criticava le rappresentazioni teatrali e dunque alla figura dello spettatore identificava un'accezione completamente negativa, perché?
Perché queste opere teatrali non facevano altro che denigrare i costumi sociali dell'epoca.
Lo spettatore passivamente recepiva, in questo caso, un messaggio della rappresentazione teatrale e accadeva che cosa?
Si aveva una sorta di denigrazione, in questo caso morale, dei buoni usi e dei buoni costumi che erano celebrati dalla società del tempo.
Lo stesso Hegel parla della coscienza spettatrice, quindi di come il tema della spettatorialità è un tema che attraversa tutta la storia della filosofia occidentale.
La figura dello spettatore è una figura particolarmente interessante, mentre l'osservatore, come dicevamo, è legato alla nascita del positivismo giuridico e alcuni tratti si possono identificare a partire dall'illuminismo, la figura dello spettatore è legata al discorso filosofico e al discorso filosofico-giuridico fin dalla nascita del teatro greco, prevalentemente però con una recensione negativa al spettatore e a chi non può conoscere la realtà, non può conoscere la verità di ciò che accade, perché vive in un mondo di finizioni, in un mondo di ombre, in un mondo di riflessi e la sua conoscenza è una conoscenza totalmente passiva, da qui la sua accezione negativa.
Ed è probabilmente proprio rispetto a questa accezione negativa che poi a partire da Kant si elaborerà un soggetto dello sguardo nettamente contrapposto alla figura spettatoriale che è proprio il concetto del soggetto di osservatore.
Ci siamo? Nell'accezione, in questo caso più recente, qui siamo già, come dire, in epoca postmoderna o adesso alla fine della modernità, il tema dello spettatore viene ripreso da un filosofo

francese che si chiama Guy Debord. Il filosofo che per primo ha parlato di situazionismo e ha pubblicato un libro che è diventato libro celebre, didattico filosofico-politico della fine del secolo scorso, che si chiama ‘’la società dello spettacolo’’.
Oggi quante volte si parla della società, noi siamo ancora nella società dello spettacolo, staremo sempre nella società dello spettacolo.
La società dello spettacolo è proprio quella società in cui la costruzione dell'ordine sociale la si ottiene attraverso la logica della rappresentazione.
Dunque la voglia che l'immedesimazione costante e continua fra spettatori, quindi fra un popolo di destinatari alcuni vengono trasformati passivamente in spettatori, è una serie di rappresentazioni che hanno sostituito, secondo Debord, l'afflizione alla realtà.
Debord ne ha fatto anche un bellissimo film, ne vedremo mercoledì, vi farò vedere alcune immagini, è un film famosissimo in cui si dice tutta una riflessione fra capitalismo, consumismo, vocazione sociale, costruzione del discorso politico e giuridico, tutto attraverso questo tema di una realtà che ormai si è smaterializzata in favore di una serie di rappresentazioni, che nell'ottica di Debord, hanno assunto lo status di vere e propri simulacri, cioè di copie senza l'originale, rappresentazioni senza l'oggetto rappresentato; quindi, hanno messo qualsiasi forma di contatto con la realtà.
In particolar modo, e qui la cosa diventa più interessante per il discorso giuridico perché adesso iniziamo invece a recuperare il concetto di spettatore dopo questa condivisione storico-filosofica all'interno del discorso giuridico del moderno e del post-moderno, nella società dello spettacolo Debord individua due forme di spettacolarizzazione della società. Quella che Debord chiama spettacolare concentrato e spettacolare diffuso o spettacolarizzazione concentrata e spettacolarizzazione diffusa.
Che differenza c'è tra questi due modelli di costruzione della società e dello spettacolo? In primo modo lo spettacolare diffuso implica sempre che cosa?
La riduzione del soggetto a spettatore, questo spettatore è chiamato ad immedesimarsi come la figura di un leader fondamentalmente, che può essere non solo un leader politico, ma per esempio in Debord, c'è tutto il tema delle statue come corpi normativi, quindi come stereotipi da imitare per costruire un determinato ordine sociale nell'America negli anni 50 o negli anni 60 del secolo scorso, quindi in realtà il concetto di spettacolare concentrato lo potete applicare sia alle grandi figure di dittatori, come per esempio il potere carismatico di Max Weber, sia invece a tutta una serie di altre figure che riescono affascinando a controllare, ad addomesticare la condotta di una folla di spettatori.
Il meccanismo, ragazzi, che c'è dietro, è di tipo synopticon, stiamo sempre ragionando intorno, vedete, torna il tema del synopticon, in questo caso c'è un corpo.
È un corpo che catalizza, che concentra su di sé gli sguardi di tutti gli spettatori, ok?
Gli spettatori, grazie al potere, al carisma di questo corpo, innescano un processo di immedesimazione, va bene?
È chiaro che questo processo di immedesimazione è una linea di costruzione di un determinato tipo di potere che riprende il modello synopticon, ci siamo?
Ed è spendibile però, per tutta una serie di corpi carismatici, se ci volessimo fermare soltanto sulla storia del Novecento, potremmo dire che lo spettacolare concentrato in quel modello synopticon, e lo vedremo ragazzi, lo vedremo adesso, prima di concludere la nostra lezione, è quel modello che caratterizza per un verso, per esempio, le grandi figure di dittatore del Novecento, va bene?
Dall'altra parte però, non c'è soltanto il caso estremo del corpo dittatoriale, ma anche, come dire, le star olimpiade hanno funzionato in questo modo, no?
Anche, diciamo, le rappresentazioni cinematografiche, del modo in cui le rappresentazioni cinematografiche, le star olimpiade, e quindi c'è un meccanismo di immedesimazione tra spettatore e star, anche questo indica un rapporto di potere, che è un potere synopticon, nel lessico e nell'ottica di Debord, diventa uno spettacolare concentrato, è chiaro?

Quindi, spettacolare concentrato, prima forma, tutto sommato, è la forma più semplice, in questo caso, di costruzione di immedesimazione nello spettacolo, il rapporto tra spettacolo e, o spettacolarizzazione, e spettatore.

Il tema della spettacolarizzazione del potere, no? E quindi del potere come messa in scena.
È, come dire, lo strumento più antico per esercitare il potere sulle masse e sulle forme, ok? Quello che dice Foucault, a un certo punto, è che accanto a questo potere, la modernità costruisce un altro tipo di potere, il potere della microfisica, quel potere invisibile che è il potere del pratico.
Le strutture di governance, in questo momento, sono strutture che hanno riscoperto, in senso negativo, questa dimensione patetica del potere, la spettacolare rappresentativa, in senso positivo, però, stiamo riacquisendo il senso critico e riflessivo e anche un atteggiamento diverso rispetto al discorso pubblico, che non è più un discorso soltanto burocratico, logico, formale, procedurale, ma che riscopre alle sue vere origini, e le origini del discorso giuridico sono le origini del teatro, sono le origini del teatro pubblico.
È là che nasce il teatro pubblico, il concetto di nomos nasce nei poemi omerici, e ha tutta un'altra origine, che il discorso giuridico della modernità ha completamente cancellato, ha rimosso, va bene?
C'è un autore anglicano, ma di queste cose ne parleremo poi nel seminario, che si chiama James Boyd Weifel, diventa ancora uno dei massimi studiosi di diritto e letteratura, che racconta proprio il tema della dimensione narrativa e letteraria del diritto, come l'inconscio dell'attualismo giuridico moderno.
Cioè, ciò che è stato rimosso nazionalmente, ma che ha continuato, in realtà, a determinare il discorso giuridico, dietro le quinte, cioè tu hai trovato un nuovo metodo, ma le origini del diritto stanno sempre lì, nel bene e nel male.
Nel male, i grandi fenomeni, devo associarlo allo spettacolo e alla passività delle masse dinanzi alla legittimazione, al fondamento di legittimità del discorso giuridico.
Lo studioso recente più acuto, quello più intelligente, ma anche quello, come dire, più pericoloso davvero, Carl Schmitt ha capito tutto di come si costruisce, di come si fonda il discorso politico-giuridico, va bene?
Dimensione critica invece, aspetto critico, è quello che vorrei svolgere con voi.
Hannah Arendt, la grande nemica, poi, di Carl Schmitt.
La Arendt, Foucault e recentemente un filosofo francese, che insegna ancora, Jean Rancière, che ha scritto un libro meraviglioso, che si chiama ‘’Lo spettatore emancipato’’, pensando al tema dell'emancipazione del campo.
Il tema è quello del patetico, del compatibile, e proprio questa è l'idea di riscoprire delle radici diverse per quel che riguarda il discorso giuridico, rispetto a che cosa?
Rispetto alla costruzione di diritto soltanto come linguaggio formale, funzionale, o logico, procedurale.
Il diritto è diventato anche questo, ma il diritto nasce in maniera totalmente diversa e oggi moltissime teorie del diritto tentano delle epistemologie che provano a recuperare quel tipo di dimensione, ok?
Peraltro, questa dimensione sta poi, come dire, abbandonando il positivismo giuridico del Novecento, proprio perché il rischio è quello di degenerare in fenomeni che riguardano il consenso di masse, fenomeni dittatoriali, la demagogia, quello che oggi, ma per certi resti si tratta comunque di un fenomeno diverso, il tema del populismo, per esempio, un
fenomeno che è tornato adesso all'arrivata, i filosofi e i diritti della politica se ne stanno occupando tantissimo del tema, non del consenso populista, ma del tema del rapporto diretto.
Perché poi, ragazzi, il populismo, che cosa è fondamentalmente? È l'idea, no? Di un rapporto diretto tra chi? Tra l'elettore, chiamiamolo così, e il corpo del leader.
E non stiamo sempre qui? E non è sempre vero? Non è quello un rapporto synopticon.
Perché dicono tutti quanti, che i leader devono bucare lo schermo, i leader politici

oggi? Per quale ragione? Perché i corpi intermedi sono saldati come meccanismi di legittimazione, non di costruzione, ma di legittimazione del potere.
In questo caso stiamo parlando di filosofia della politica, non di filosofia del diritto.
Quindi stiamo sconfinando in un'altra area.
Stiamo seguendo i rizomi, in questo caso, il piano di immanenza del nostro discorso è sempre lo stesso, no?
Ma seppur con tratti completamente diversi, e anche perché, diciamo, il populismo che segna alcune democrazie, molte democrazie occidentali, non è paragonabile al vecchio tema delle dittature, per un fenomeno diverso, pur se ha pure mostrato di avere alcuni tratti.

Tutti questi, come dire, paesi sono un unico piano di immanenza e quindi sono tra loro tutti legati e collegati.
Dunque, quei vincoli sono tanti perché, è vero che oggi sono saltati i corpi per me, ma è anche vero che l'esercizio del potere è diventato così reticolare che non c'è più la possibilità, prima volta, per il leader politico di poter esercitare senza vincoli in quel proprio potere, almeno in alcune situazioni.

Il tema è anche quello di riscoprire, in questo caso, però un diritto che non è più confinato al diritto positivo, al diritto scritto, ma che non si connota più come un diritto giusnaturalista così come lo hanno poi questo diritto nel corso del tempo i giusnaturalisti.
Dobbiamo fare attenzione perché poi, alla fine, quando abbiamo parlato dell'Antigone, che cosa dissi?
Dissi che poi, effettivamente, l'Antigone è stata riletta in maniera molto semplicistica, come la contrapposizione tra un ordine naturale e un ordine positivo.
In realtà, questa è una rilettura dei giuristi ancora da parte del Novecento, ma invece lì il tema è radicalmente diverso perché poi non si può parlare dell'ordine positivo e dell'ordine naturale, ma lì il tema del nomos, come dicevo inizialmente, è un tema ed è un concetto molto complesso dove dentro si annoda nel continuo interscambio fra usi, tradizioni, pratiche economiche, il tema della distribuzione del pascolo per esempio, pratiche territoriali e pratiche giuridiche antiliberali, va bene?
Quindi lì in realtà si riscopre un diritto che alcuni giuristi chiamano un diritto rizomatico, cioè ormai un diritto che si costruisce attraverso i montaggi fra piani, in questo caso un unico piano. di pezzi diversi, va bene?
Ma questo, come dire, non è un recupero un ritorno certo con il nostro apparato concettuale sembrerebbe tornare al diritto naturale in senso classico, in realtà quello non è un diritto naturale, in senso classico.
È un concetto ancora diverso perchè il diritto dell'antica Grecia non è un diritto naturale per la tradizione, per la teolologia è un diritto che noi faticheremmo anche a chiamare diritto perchè poi il concetto nasce con ius (il diritto romano), ma proprio in Antigone, perciò, quell'idea è un'idea molto molto molto più complessa e complicata è molto più complicata il concetto di nomos.
Peraltro, quello che su cui mi sono voluto porre io l'accento era sulla riscoperta, non tanto del concetto di diritto naturale e di dittatura, ma sul fondamento del discorso politico che non è più logico nazionale ma riscopre invece una dimensione patetica, rappresentativa, finzionale con cui è nato il concetto di nomos all'interno della cultura greca antica.

Questa è l'idea è che è stata peraltro trattata da Hobbes, ve l'ho detto se leggete il ''leviatano'' di Hobbes vedrete che Hobbes inizia la sua idea con il teatro, con la grande metafora della messa in scena del palcoscenico.

Spettacolare e concentrato chi devolve società dello spettacolo identificazione tra la folla e gli spettatori è il corpo del leader o dello staff, vi dico soltanto la definizione di spettacolare diffuso è

quella più interessante nel modo di vedere di Debord perché ci dà l'idea dell'accezione dello spettacolo, dello spettatore, quello del postmoderno.
L'idea per cui, in realtà, tutta la società si è smaterializzata in una serie di rappresentazioni, di finzioni che altro non sono se non i feticci simulacri della realtà del capitalismo, in questo caso globale.
Quindi il tema qui è l'immedesimazione dello spettatore in destinatario che diviene consumatore passivo di che cosa?
Di marchi, di servizi, di beni molto spesso superflui e noi vogliamo congelare lo spettacolo qui diciamo la passività dello spettatore non è più rispetto al corpo del leader, ma è rispetto ai mille corpi commerciali offerti dalla propaganda industriale capitalistica.
Chiaro che Debord è uno studioso di ascendenze e vocazioni naziste e quindi legge in questo caso tutta la realtà in senso critico ideologico.
Il concetto di corpo senza opera in mille piani; è estremamente connesso con la visione di Debord, quindi, in realtà noi accoppiamo all'interno della tradizione che intravede nella passività dello spettatore un'epistemologia negativa, un'epistemologia dove la passività è solo mera recensione del potere che ci viene imposto due diversità che trovano la loro rifrazione, che si ritraggono in due argomenti del diritto:
Lo spettacolare concentrato e lo spettacolare diffuso.
La prima teoria si origina nel pensiero di Hobbes e trova nel Novecento la sua massima realizzazione nella teoria costituzionale di Carl Schimtt.
La seconda, invece, è stata sviluppata recentemente da un filosofo del diritto francese, tra l'altro oggetto di tantissime polemiche, Pierre Lejeune, che analizzeremo mercoledì prossimo.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 27 DEL 4/12/2024

Un po' come abbiamo visto per il concetto di governance, abbiamo visto che si costruisce in maniera opposta ostinata e contraria rispetto al concetto di sovranità, un concetto politico che ha un corrispettivo dal punto di vista giuridico nel concetto di ordinamento giuridico, uno dei punti cardine della teoria del diritto 900', costruito in maniera antitetica rispetto al concetto di governance, la stessa cosa avviene per lo spettatore, costruito in maniera antitetica rispetto al concetto di osservatore. Se l'osservatore è un soggetto epistemologicamente attivo capace di incidere sulla realtà, lo spettatore l'abbiamo invece costruito come un soggetto passivo capace di conoscere solo rappresentazioni e quindi finzioni della realtà. Questi due concetti si radicano in periodi storico-filosofici radicalmente diversi. L'osservatore, che appartiene alla modernità, comincia a costruirsi concettualmente con l'illuminismo, trovando pieno compimento nel positivismo e quindi con le scienze naturali. Lo spettatore è un concetto antichissimo, che affonda le proprie radici nel teatro greco, e conosce uno sviluppo storico filosofico che dalla caverna platonica alla coscienza spettatoriale in Hegel assume tutta una serie di metamorfosi. La differenza quindi tra questi due concetti risiede proprio nelle loro origini: l'osservatore ha origini scientifiche, lo spettatore ha origini umaniste, stabilendo un collegamento tra il diritto e l'arte della messa in scena.
Ricordiamo anche l'esordio del Leviatano di Hobbes dove il diritto è visto proprio come palcoscenico, come arte della finzione.
Questo rapporto tra spettatore e messa in scena costruisce un'epistemologia non più prevalentemente logico-razionale, ma patetica, che si fonda sul pathos e sulla base dei rapporti di immedesimazione che lega lo spettatore e la messa in scena.
Il tema di un fondamento patetico del diritto, è stato sempre mal digerito, sia dai giuristi sia dai filosofi: basti pensare alla caverna di Platone, dove lo spettatore è lo schiavo condannato a non conoscere mai la realtà in se ma solo infinite rappresentazioni, o a Rousseau, che condanna li spettacoli teatrali perchè colpevoli della dissoluzione dei costumi, fino ad Hegel, dove la funzione spettatoriale non ha più una valenza marcatamente negativa ma comunque passiva, totalmente passiva rispetto alla conoscenza di un fenomeno.
Invece, all'interno del pensiero filosofico francese dello scorso secolo, abbiamo come manifesto della figura dello spettatore, un libro di Deborde chiamato "La Società dello Spettacolo" dove il tema dello spettatore torna ancora una volta con una accezione negativa. La realtà secondo Deborde si è smaterializzata in eventi spettacolari, tutto è rappresentazione, nulla è più reale.
Deborde individua due processi di spettacolarizzazione della realtà:

Lo spettacolare concentrato, dove avviene l'immedesimazione dei molti nel corpo di un singolo, attraverso un processo sinottico, che è lo stesso che ha legittimato il discorso politico delle dittature del 900'. Quindi abbiamo un leader dotato di un grande carisma che permette alla massa di immedesimarsi in lui, e vede legittimato il proprio potere proprio da questo processo di immedesimazione. Quindi, in questo caso il legame tra massa e leader è un legame patetico.
Deborde però si muove nell'epoca della post-modernità, epoca che come abbiamo già visto, è caratterizzata dalla frammentazione e dall'entrata in crisi di quelli che erano i fondamenti novecenteschi, come ad esempio la denuncia del capitalismo senza limiti e la condanna della società dei consumi. Proprio da qui deriva l'idea di un rapporto spettatoriale che prevede non più l'immedesimazione con un leader (spettacolare concentrato), ma prevede l'immedesimazione con dei beni di consumo (spettacolare diffuso), figli della propaganda capitalista. La messa in scena, non è più quella dei leader, ma è quella dei grandi marchi che nascono in questo periodo. Deborde denuncia tutto questo attraverso il concetto della società dell'immagine. In entrambi i casi, spettacolare diffuso e concentrato, l'accezione data allo spettatore da Deborde è ancora una volta negativa, perchè è colui che è destinato a conoscere la realtà passivamente, o attraverso l'immedesimazione in un leader carismatico, o attraverso l'immedesimazione in un corpo merce derivante dal nascente capitalismo globale.
Ora, se volessimo traslare il discorso di Deborde nell'ambito filosofico-giuridico, appartengono allo spettacolare concentrato tutte le teorie che nel 900' prendono il nome di decisionismo giuridico, ad esempio la "Dottrina della Costituzione" di Carl Smith, che riprende ed estremizza proprio il decisionismo giuridico di Hobbes.
Rientra invece nello spettacolare diffuso, il francese Pier Legendre, che attraverso una teoria complicatissima, ha individuato un fondamento del diritto post-moderno proprio nei meccanismi di immedesimazione tra il cittadino passivo e il nuovo mercato globale, divenuto, secondo Legendre, il vero fondamento di legittimità e legalità del discorso giuridico occidentale.
Questa teoria è chiamata Management giuridico.

(Lascia in sospeso questo argomento e ripercorre le due forme di spettacolarizzazione di Deborde attraverso le immagini)

A partire dal 900' la figura dello spettatore si configura soprattutto nelle dinamiche collegate al movimento "law and film", e quindi nel rapporto tra diritto e cinema. Una caratteristica importante dello spettatore è che non è mai singolo, ma si declina sempre al plurale, è sempre una folla. Insomma, va inteso sempre come una collettività.
Visionando poi quelle che sono le immagini del film di Deborde, ci rendiamo conto di come secondo lui, nella società dello spettacolo, il rapporto sociale che si instaura tra gli individui, è un rapporto mediato dalle immagini. Questa società è anche definita società dei simulacri, dove l'immagine si è così smaterializzata e allontanata dalla rappresentazione dell'oggetto concreto, che la realtà è composta da copie senza l'originale.
In un'altra immagine vediamo la popolazione in un cinema che guarda un'occhio, a riprova del concetto di immedesimazione che porta la massa ad omologarsi ed immedesimarsi all'interno di un leader e perdendo difatti la loro autonomia. Questa è la perfetta

rappresentazione delle società sinottiche del 900'. Tutte queste idee che abbiamo analizzato, si basano su un vincolo sinottico che prevede l'immedesimazione patetica della massa nei confronti di un leader carismatico. Questo binomio "leader carismatico-suddito spettatore" trova la sua legittimazione proprio nella teoria costituzionale di Carl Smith e che affonda le sue radici nel diritto romano. Questo avviene soprattutto perchè Smith opera durante la dittatura nazista e in qualche modo, attraverso le sue opere, voleva legittimare la presa di potere di Hitler. Quindi mentre Kelsen, si preoccupa di costruire una dottrina totalmente indipendente dalle contaminazioni politiche quanto piu razionale e oggettivo possibile, Smith dice che la legittimazione del potere non riposa su una ragione trascendentale (norma fondamentale di Kersen), ma su un legame patetico, proprio su quel legame che lega il corpo del leader e la folla che si immedesima in lui, che giustifica le sue azioni e il suo potere attraverso l'acclamazione. Il fondamento del potere giuridico è l'acclamazione secondo Smith, tema recuperato proprio dal diritto romano. Quindi per Smith sovrano è chi ha la forza di sospendere l'ordine sociale, cioè chi è acclamato dal popolo. Costui diventa il custode della costituzione, non la norma fondamentale: se in Kersen l'osservatore è esterno, oggettivo, logico e razionale, dall'altra parte non c'è più l'osservatore, ma l'osservatore, e un potere che all'astrattezza kantiana, oppone la concretezza del corpo del leader. Carl Smith chiama questo potere "costituente".
Questa idea Smith la matura partendo da un'immagine importantissima, cioè il frontespizio del Leviatano di Thomas Hobbes.
Concentrandoci piu da vicino ci renderemo conto della presenza di due colonne di caselle, quella sulla sinistra rappresenta il braccio che muove la spada del sovrano, e tutte le caselle indicano i modi in cui si esercita il potere temporale, cioè di mantenere con la forza l'ordine sociale: Smith era stato il primo a dire che il discorso giuridico si costruisce attraverso il binomio amico nemico: considerare amico chi è dentro l'ordinamento, nemico chi c'è fuori.
Alla fine, il tema è sempre quello, un po' quello che abbiamo detto parlando di punto di vista oggettivo, soggettivo, esterno o interno.
Tutto il discorso giuridico moderno si basa su questo: dentro o fuori.
Anche in Kersen la domanda: "Perche devo seguire le leggi?", si rifà sempre alla logica dell'appartenenza, il dentro o il fuori, rispetto all'ordinamento (basti pensare alla norma fondamentale).
In Smith, quella logica astratta interno-esterno, si concretizza nella logica amico-nemico. Per Smith quindi, l'ordinamento non sono le norme, siamo noi, che componiamo il corpo dell'ordinamento, immedesimandoci nel leader. Questa idea è tutta racchiusa nell'immagine di Hobbes. Il corpo del leviatano è composto interamente dai corpi dei sudditi.
Da lontano il corpo sembra indossare un'armatura. Concentrandoci ci rendiamo conto che i corpi dei sudditi compongono il corpo del sovrano. Quest'idea di Hobbes trova delle assonanze nella comunione religiosa, la compenetrazione del corpo di cristo con i nostri corpi nell'atto della comunione.
I sudditi sono tutti rivolti verso la faccia del sovrano, come un enorme platea che sta osservando lo spettacolo del potere del sovrano. Quindi prima c'è l'immedesimazione, poi una metamorfosi: i corpi dei sudditi sono rivolti verso di noi che guardiamo. Non guardano più il viso del sovrano ma chi guarda l'illustrazione. I sudditi guardano all'esterno in senso di

sfida. Loro stanno dicendo che sono parte del sovrano e sono pronti a sfidare tutto ciò che non ne fa parte.
Un'altra particolarità riguarda il modo in chi è rappresentato il titolo dell'opera, che ricorda un palcoscenico simile a quello dei teatri dei burattini. Questi avevano ai lati piccoli quadretti che raccontavano l'antefatto, e poi il palcoscenico centrale.
I singoli quadretti sono oggetto di molte indagini: non quelli sotto la spada ma quelli sotto la pastorale. Sembrano rappresentare quale sia il potere spirituale che puo esercitare il sovrano: dalle folgori della scomunica, fino al concilio, l'organizzazione della vita monastica e l'interpretazione della bibbia. Secondo altri studiosi ci sono moltissimi riferimenti alla massoneria in questi "scaffali", e quindi non ci rifacciamo ad un potere religioso ma ad un potere esoterico.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 28 DEL 4/12/2024

Questa immagine tanto è potente che è stata ripresa dalle dittature del 900'.
L'iconografia del dittatore (Hitler, Mussolini) è rappresentata sempre attraverso il processo sinottico di immedesimazione tra la massa spettatoriale e il leader carismatico.
Hobbes però non sarà mai un teorico della dittatura, nel Leviatano c'è scritto ben altro. Hobbes è il padre della sovranità moderna, ma quelle di Debord e di Smith sono estremizzazioni dell'immagine hobbesiana. Smith è un pensatore particolare, ha varie fughe nel suo pensiero, e quella che abbiamo visionato è quella peggiore, ideata dirante il Nazismo. Dice anche nella teoria della Costituzione, che il potere del leader è dato dall'acclamazione della folla, come se quest'ultima fosse in uno stadio o stesse assistendo ad una rappresentazione teatrale. Quindi pone letteralmente l'analogia tra lo spettatore che applaude durante uno spettacolo o una partita, e la costituzione del fondamento giuridico-politico.
Ricapitoliamo: abbiamo la figura dello spettatore differente dall'osservatore, ed esattamente come abbiamo individuato le varie figure di osservatore, stiamo facendo la stessa cosa con la figura dello spettatore. All'interno della figura dello spettatore acclamante avremo due categorie: spettacolare concentrato e diffuso. Il diffuso è quello teorizzato da Legendre. Quest'ultimo vuole mostrare visivamente come la struttura della sovranità sia svuotata dall'elemento giuridico, e riempita dall'elemento economico. In questa struttura il corpo del destinatario è un corpo passivo destinato al consumo di merci offerte dalla globalizzazione. Abbiamo su questo l'esempio della pubblicità natalizia della Coca-Cola. Il corpo sociale in questo caso si fonde in un marchio di una multinazionale. La teoria di Legendre è molto complessa, poichè pensa che il fondamento del potere politico sia frutto di un montaggio. Quindi non crede nella norma fondamentale come Kelsen o nel sovrano carismatico come Smith, ma la legittimità del potere è frutto di un determinato montaggio che mette insieme i corpi dei destinatari, i testi fondamentali di legge, permettendo che i singoli destinatari si immedesimino all'interno di questo complesso montaggio di testi, immagini e corpi, che costituisce la base dell'ordinamento. Secondo Legendre, nell'epoca della globalizzazione, l'aspetto più rilevante di questo montaggio è rappresentato dall'elemento economico-capitalistico.
Legendre è stato uno dei primi a decretare il dominio di un certo tipo di economia rispetto al discorso giuridico. Dopo l'analisi di Legendre, termina il riconoscimento dello spettatore come una figura negativa, il cosiddetto spettatore acclamante. Esiste infatti una tradizione diversa della figura dello spettatore. Anche per lo spettatore, come abbiamo fatto per l'osservatore, dobbiamo fare una suddivisione, dettata dalla diversa concezione che noi abbiamo dell'atteggiamento passivo dello spettatore. Lo spettatore resta passivo perché, se fosse attivo sarebbe un osservatore. Lo spettatore non cambia mai la sua natura, resta sempre

un soggetto epistemologicamente passivo. Ma nella sua passività possiamo scorgere una dimensione diversa, che ci permette di recuperare un legame tra diritto e morale, senza però tornare alla costruzione gius-naturalistica del diritto. Questo è possibile attraverso il recupero di una delle opere minori del Kant anziano, "Il Conflitto delle Facoltà".
In quest'opera Kant si interroga sulle differenze delle facoltà universitarie dell'epoca, in particolare quelle di Medicina, di Filosofia e di Diritto, elencandone pregi e difetti. Ad un certo punto Kant si interroga proprio sul progresso della storia degli esseri umani. Quando Kant parla di progresso però non parla del progresso tecnologico, ma del progresso dei costumi sociali e quindi al progresso inteso come evoluzione delle forme sociali del genere umano. Kant si chiede se è possibile constatare con certezza se l'umanità stia progredendo verso il meglio, oppure se è destinato al non progredire verso il meglio. Kant individua tre diverse concezioni che riguardano il meglio morale per l'umanità: c'è la teoria del "terrorismo morale" che Kant ascrive a una parte dei filosofi secondo cui l'umanità è destinata a progredire verso il peggio. Secondo Kant questa teoria non è sostenibile perchè implicherebbe la scomparsa del genere umano; quindi, logicamente non è una teoria attendibile. Poi abbiamo la teoria dell'"avvenirismo morale", secondo cui bene e male avanzano di pari passo. Anche questa teoria secondo Kant è logicamente insostenibile in quanto non è misurabile né il bene né il male.
La terza teoria è quella dell'"eudemonismo morale", secondo la quale il genere umano progredisce sempre verso il meglio. Kant non riconosce che l'umanità cresca sempre verso il meglio, proprio sulla base di quello che sono i fatti storici.
La verità per Kant è che, quando vogliamo misurare il progredire della storia dobbiamo ragionare per un rapporto di causa-effetto, dobbiamo trovare delle prove del fatto che l'umanità sta progredendo. Ma secondo Kant spesso il prodursi della storia è il concatenamento di cause diverse e svariate che generano effetti diversi e svariati. Quindi Kant decide di indagare nel corso della storia per trovare dei segni che ci indichino inequivocabilmente, senza ricorrere al metodo causa-effetto, la tensione costante dell'umanità verso il bene. Kant, quindi, inizia a riflettere sull'importanza storica della Rivoluzione francese. Un popolo che lotta per autodeterminarsi è un segno di progresso verso il bene per l'umanità secondo Kant. C'è però un problema. Se Kant vuole identificare la Rivoluzione francese come segno progressione morale, deve riconoscere però che la rivoluzione è violenza, i rivoltosi sono violenti.
Come si possono conciliare queste due cose, lo slancio verso la libertà e lo spargimento di sangue? Kant dice che la Rivoluzione francese è un segno indubbio di progresso morale nel sentimento che la Rivoluzione francese suscita in chi la rivoluzione non la fa ma la guarda come spettatore, lasciandosi contagiare dall'entusiasmo dei valori propugnati dalla rivoluzione. La rivoluzione, infatti, è un atto brutale, ma solo per chi la fa. Per coloro che assistono allo spettacolo della rivoluzione, abbiamo l'entusiasmo che li travolge assistendo a questo spettacolo, fondato su ideali come uguaglianza, fraternità e libertà.
Il tema è quello di recuperare una dimensione morale per il discorso giuridico, che non è la dimensione gius-naturalistico, ma è il sentimento.
Il discorso va spostato sul pathos, il legame empatico che può essere il meccanismo di riconoscimento in cui la passività può essere la capacità che la rappresentazione ha di suscitare in noi che non vi partecipiamo entusiasmo.

L’entusiasmo per chi lotta per autodeterminarsi e per ambire ad uno stato che ha come fondamento il rifiuto di ogni guerra di aggressione. Kant individua nello spettatore la capacità di riconoscere un diritto eticamente fondato su libertà, uguaglianza e fraternità. Questo è il vero slancio verso il miglioramento. Se in Hobbes c’è la paura in Kant c’è l’entusiasmo. Se in Hobbes lo spettatore è mosso dalla paura per l’altro, in Kant lo spettatore è mosso dall’entusiasmo verso la capacità di costruire un diritto più giusto.
Non è il popolo il protagonista di questo fenomeno, ma chi assiste allo spettacolo della rivoluzione, lo spettatore, immedesimandosi con la rivoluzione ma senza parteciparvi. Se vi partecipasse infatti, non sarebbe più un’azione eticamente sostenibile. Accanto allo spettatore acclamante che si è creato con Hobbes, Smith, Legendre e Debord, abbiamo un’altra figura di spettatore, lo spettatore entusiasta che si origina in Kant. Questo spettatore costruisce sempre un legame patetico con la rappresentazione, senza suscitare la soggezione ad un potere carismatico, ma l’entusiasmo verso chi lotta per la propria autodeterminazione. Anche questa figura ha tre interpretazioni diverse: la prima è la Arendt, con i suoi studi sullo spettatore e quello che lei definisce l’attore, il nostro osservatore. La seconda è quella di Foucault, che riprende l’entusiasmo Kantiano e lo spettatore come figura giuridica. Infine, abbiamo un filosofo allievo di Foucault, che affronta lo spettatore emancipato, e quindi la capacità dello spettatore di costruire un discorso critico rispetto al potere e al suo esercizio.
Diritto e morale trovano un legame morale per coesistere tra di loro, non più logicamente, senno torneremmo alla fallacia naturalistica.
Nella prima interpretazione lo spettatore è una condizione comunitaria ponendo l’accento sulla dimensione molteplice dello spettatore. Lo spettatore si declina sempre al plurale, è sempre un pubblico di spettatori. Questa dimensione comunitaria è la dimensione costitutiva della fondazione del discorso giurodico. La passività produce la costruzione di un gusto comune, secondo il quale li spettatori preferiscono immedesimarsi con determinati spettacoli piuttosto che altri. Questo gusto è espressione del sensus comunis. Secondo Foucault la passività si declina come chi non partecipando costruisce una coscienza critica su quello che assiste. Nell’ultima torna il tema del montaggio: nella sua passività, lo spettatore può interpretare la realtà costruendola e distruggendola a suo piacimento. Questi tre filosofi partono dall’entusiasmo Kantiano e individuano nella passività dello spettatore non più la sottomissione, ma un legame patetico ed empatico che apre porte che prima erano chiuse. Questa scuola di pensiero celebra la potenza critica dello sguardo e proprio qui nascono alcune teorie giuridiche della post-modernità come Law and LItterature o Law and Film.

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 29 DEL 9/12/2024

Per necessità o qualsiasi domanda il professore riceve a partire da Gennaio dal martedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Ma mandare sempre una mail di prenotazione con l'oggetto.
Se ci sono problemi logistici si può effettuare un colloquio online, su teams.
Rispettare scadenze esame, entro 5 giorni prima dell'esame bisogna prenotarsi. La prenotazione può avvenire quando si è chiuso l'appello immediatamente precedente.
Scrivere sulle note se siete frequentanti o non frequentanti.
Subito dopo la chiusura delle prenotazioni per gli esami verrà ricevuta una comunicazione da parte del professore via esse3 sullo svolgimento dell'esame, in cui sarà scritto l'orario in cui si svolgerà il proprio esame (si prega di non venire prima e guardare gli esami degli altri studenti).
L'esame è formato almeno da 3 domande; per i frequentanti ci sarà una domanda iniziale a carattere generale dove si suggerisce di costruire dei discorsi molto ampi e con molti passaggi fra gli argomenti studiati. Si consiglia di rispondere direttamente e allargare il raggio dell'argomentazione in modo da avere "in mano" la discussione riducendo e limitando domande specifiche "a raffica".
Poi ci saranno una serie di domande più specifiche, ma se il discorso è stato costruito bene difficilmente saranno lontane dalle argomentazioni già dette.

ESEMPIO DOMANDE:
teoria della norma giuridica;
teorie dell'ordinamento;
modelli di costruzione dell'ordine sociale;
teorie dell'osservatore;
concetto punti di vista;

O domande più complesse:
luoghi kantiani nella filosofia del diritto del '900 (ricostruire le influenze di Kant, quindi Kelsen e il presupposto logico-trascendentale; lo ius publicum; il concetto di spettatore entusiasta e conflitto delle facoltà; diritto e morale);
luoghi di Hobbes (partire dall'immagine e ragionare su Kelsen e Schmitt con le differenze di sovranità);
perché seguire le regole;
quali sono i modelli di risposta formal-procedurale alla domanda perchè seguire le regole;
dalla sovranità alla governance;
dall'ordinamento alla governance;
metamorfosi del concetto di potere (potere prescrittivo sanzionatorio in Kelsen e quello disciplinare in Foucault);
osservatore e spettatore;
panopticon e synopticon;
costitutività e concetto potere costitutivo (Carcaterra e Searle);

linguaggio (prescrittivo-sanzionatorio e performativo);
diritto e morale (giusnaturalismo e giuspositivismo, fallacia naturalistica, formule di Radbruch);
tema destinatario;
tema validità;
tema sulla giustizia;
custodi dell'osservanza;
osservanti;
teorie dello spettatore giuridico;

Ovviamente successivamente alla prima domande a carattere generale ci saranno quelle specifiche; ad esempio se si parla del tema della norma giuridica verrà chiesto il rapporto tra causalità e imputazione, quindi il fatto qualificato come illecito e la norma come fatto empiricamente osservabile, o la norma come schema di interpretazione.

Ci possono essere anche domande più "fantasiose", come:
metafore della costruzione dell'ordine sociale (quindi il tema della piramide, della macchina, del gioco sociale, del piano di immanenza);
possibili punti di contatto tra diritto e dimensione psicoanalitica (Kelsen e dialogo con Freud, o Ross con la pressione psico-sociale, o Legendre con l'immedesimazione dello spettatore).

Molto importante saper argomentare ampiamente i temi trattati e saper spaziare e differenziare sui vari argomenti.

Durata esame: circa 15/20 minuti ma dipende molto dall'andamento dell'esame

FILOSOFIA DEL DIRITTO

Prof. Siniscalchi

LEZIONE 30 DEL 11/12/2024

Oggi vediamo invece non tanto di ragionare sulla teoria, sulla cornice teorica, quella come dire bene o male l'abbiamo comunque messa a fuoco ma di vedere proprio come operano in concreto alcune di queste metodologie, di queste epistemologie del diritto un po' l'abbiamo già accennato, l'abbiamo già introdotto un paio di settimane fa a proposito del seminario che abbiamo fatto con il professor Mangini oggi quegli ambiti li vedremo come dire più in concreto, li approfondiremo, avremo dei campi di applicazione non so seli vedremo tutti, alcuni li accenderemo, altri li approfondiremo in maniera più dettagliata però secondo me può essere per voi molto interessante capire anche una carrellata, diciamo, di che cosa, degli approcci metodologici che oggi vanno per la maggiore, soprattutto in ambito angolo americano e da qualche anno questa parte anche in ambito europeo in particolar modo nella teoria generale del diritto francese e anche in quella italiana però vedere proprio concretamente come si lavora attraverso questi approcci, perché è chiaro ragazzi, su Kelsen, su Hart, su Ross avete come delle bibliografie ormai sterminate, su questo tipo invece di approcci ci possiamo divertire proprio esplorando la contemporaneità del dibattito giusto filosofico e del dibattito all'interno della teoria generale del diritto lo facciamo proprio esplorando in questocaso le correnti che costituiscono il movimento angolo americano chiamato e denominato l'homme inferno. Non ribadisco, diciamo, questo è un'introduzione al tema diritto al cinema, noi in molte cose ce le siamo già dette. Abbiamo visto come in realtà diritto al cinema per esempio sia due linguaggi, lo spettatore è una delle figure in questo caso emblematiche, paradigmatiche. Per mostrare come due linguaggi presentino notevoli intersezioni tra di loro; Si interpretano i copioni, le sceneggiature e si interpretano in questo caso che cosa? Ci sono gli attori all'interno del processo, il processo è una messa in scena Ricordavamo la volta scorsa per esempio proprio a proposito della figura dello spettatore giuridico: le assonanze, le radici storico-filosofiche del diritto che affondano all'interno delle rappresentazioni teatrali dell'antica Grecia E quindi riscoprono in questo caso una serie di sovrapposizioni, di aderenze, che sono aderenze semantiche, cioè che riguardano anche termini in comune che conoscono e chiamano due linguaggi, e sovrapposizioni di carattere concettuale, va bene? Qui per esempio ho riportato due, come dire, proposizioni, una di Orit Kamir, che è una studiosa israeliana contemporanea che si occupa di Law and Film, e quella di un famosissimo regista francese, il padre della Nouvelle Vague francese negli anni Sessanta, in entrambi i casi ha due prospettive diverse, entrambi sottolineano le assonanze, i possibili incroci linguistici fra il mondo del cinema e il mondo del diritto. Che tipo di rapporto? Cinema e diritto si possono incrociare, si possono contaminare rispetto a diversi tipi, diverse prospettive.

Una cosa interessante, per esempio, all'interno della storia del diritto italiana è il ruolo che uno dei nostri grandi giuristi del Novecento ha avuto all'interno proprio degli incroci tra queste due linguaggi diversi, che èFrancesco Cannellutti. Francesco Cannellutti, imparerete a conoscerlo, è uno dei padri del diritto civile italiano del Novecento, e Cannellutti ha alternato la sua carriera da avvocato, da giurista e da teorico giornale del diritto a quella di colui quale abbia compreso molto bene il ruolo

che il cinema e la televisione successivamente svolgevano all'interno della società italiana. E si era appassionato, c'erano moltissimi convegni degli anni 50 e 60, Di professori studiosi di teoria del cinema che sono introdotti da Francesco Cannellutti. Tanto Cannellutti era appassionato di cinema che ha scritto alcuni dei primi testi che mettono in corrispondenza studi giudici e studi cinematografici, ma soprattutto, negli anni 40 è autore della sceneggiatura di un film noir italiano di quegli anni, con alcuni risvolti anche sociali. Si tratta di una pellicola che era andata dispersa e che poi abbiamo recuperato, io con un altro studio di teoria del cinema, presso un collezionista della Basilicata che possedeva dei vecchi film, quelle che andavano nel proiettore, e siamo riusciti a recuperare questa pellicola. L'abbiamo presentata alla Sapienza un po' di tempo fa, abbiamo le immagini ormai digitalizzate e computerizzate, non ve le ho portate, però è interessantissimo anche in questo caso vedere come Cannellutti abbia utilizzato all'interno della sua scrittura cinematografica tantissime delle tecniche o dei temi o delle istanze di cui si occupava in ambito giuridico, e quindi Cannellutti in realtà è stato un teorico low-and film anti-literal, con 40 anni di anticipo si era preso conto che il rapporto fra cinema e diritto era un campo particolarmente fecondo da analizzare e da esplorare

Passiamo subito al tema invece di low-and film. L'abbiamo visto la volta scorsa, il rapporto tra diritto e cinema non lo dobbiamo indurre, un po' come abbiamo tentato di fare con il nostro seminario, cioè, guardare il film e utilizzare il film soltanto per parlare poi dell'argomento giuridico rappresentato all'interno del film. Certo, questa è una delle modalità più frequenti, più comuni, più semplici, anche più efficaci a volte, per raccontare il diritto, per poter comunicare il diritto, ma è anche una delle prospettive di analisi e di ricerca meno interessanti per quel che riguarda il rapporto diritto cinema.

Nell'ambito, diciamo, delle teorie post-moderne del diritto, e quindi adesso rimettiamo anche qualche concetto e qualche nozione che abbiamo visto a lezione; quindi, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, una delle tante frammentazioni in cui la post-modernità scille la teoria unitaria del diritto del Novecento, la dogmatica giuridica, c'è proprio una sottocategoria che è quella dedicata ai rapporti tra diritto e letteratura. Gli autori principali di questo tipo, i giuristi principali che inaugurano questo movimento, sono James Boyd White, che è uno dei grandi giuristi, filosofi del diritto contemporaneo, James Boyd White è diventato, anzi, lui è stato in Italia, in entrambi i casi, come dire, qual è l'idea che muove questi due teorici del diritto anglo-americani? È un'idea che per noi risulta essere particolarmente interessante, cioè l'idea è che il diritto non sia una tecnica di regolazione sociale, ma sia in realtà che cosa? Sia una forma culturale, è l'idea insieme al modo di ragionare che ho tentato di trasmettervi dall'inizio del corso, del primo giorno in cui ci siamo incontrati, dimenticatevi che il diritto sia solo l'esercizio di una tecnica, il diritto è una forma di cultura che rispetta, è il prodotto di un zeitgeist, è proprio uno spirito del tempo, comprendere un discorso giuridico significa, come dire, immergere in realtà il discorso giuridico attraverso una rete di significati che sono il prodotto della società di un determinato periodo storico, quindi questo non significa fare storia del diritto ma anche questo è stata una delle premesse di questo corso, una premessa viciana del nostro corso, non confondiamo la filosofia con la storia della filosofia, ma per comprendere la filosofia del diritto di una determinata epoca non ci si può limitare semplicemente allo studio della filosofia del diritto come tecnica, che possa essere tecnica di regolazione sociale, tecnica argomentativa, tecnica interpretativa. Va questa tecnica sempre letta all'interno di una rete di significati che sono poi i significati delle forme culturali di cui quel diritto è espressione. Lorenzo Friedman è uno dei più grandi teorici del diritto, che nel corso degli anni 70 e degli anni 80 inaugura questa nuova prospettiva e lo fa attraverso un concetto, ragazzi, che io non l'ho utilizzato nel volume che voi portate nel vostro programma Barocco giuridico, l'ho utilizzato molto nel volume successivo che ho pubblicato l'anno scorso e dedicato proprio al rapporto tra il cinema e il diritto, ma che in realtà è presupposto un po' dagli studi del Barocco giuridico, il concetto di cultura giuridica esterna, che è un concetto determinante e fondamentale per eleggere anche la figura di spettatore.

Che cosa intende Lorenzo Friedman col concetto di cultura giuridica esterna? C'è scritto lì, non lo leggete, proviamo a ragionarci in realtà insieme, no? Cioè Friedman si pone per la prima volta una questione, secondo me cruciale, che ci riguarda, che riflette un po' anche tutto il lavoro che noi abbiamo fatto, come dire, retrospettivamente, no? Friedman dice sì, va bene, noi ci stiamo preoccupando finora di costruire dei modelli di conoscenza del diritto. Questi modelli di conoscenza del diritto, però, dice Friedman, si sono sempre occupati di come sia possibile conoscere il diritto da parte di chi opera con il diritto, no? Facciamo un esempio, la dottrina pura del disordio, per esempio, è quella che noi utilizziamo, come dire, poi per picchiarlo, dottrina pura del diritto, va bene, per contestarlo e criticarlo, ma anche perché è quello più rilevante, no? È sicuramente il modello principale, poi, nel Novecento. La dottrina pura del diritto, che cos'è, poi? È la costruzione, no? Di una teoria del diritto che è un modello di conoscenza che non si occupa, poi, della percezione del diritto da parte delle persone comuni che nel diritto non operano, no? È sempre un modello molto tecnico di costruzione della conoscenza del diritto.

Pensate alla teoria di Hart, alla teoria di Ross che noi abbiamo esplorato: Sono tutte teorie che poiincentrano la costruzione del loro punto di vista. Sempre all'interno di che cosa? All'interno di unaprospettiva di chi ha un minimo di conoscenza già del diritto, un minimo di conoscenza del diritto.

Friedman si pone un altro problema. Come è il problema, se ci pensate bene è la domanda da cui noi siamopartiti il primo giorno che voi siete entrati in quest'aula.
Che cosa vi ho chiesto la prima volta che ci siamo visti? Come percepite l'esistenza del diritto. Cioè, comefate a sapere che il diritto esiste? Domanda successiva. Come fate a conoscere il fenomeno giuridico successivamente? Questo è il problema di Friedman. Cioè, dice Friedman, no? Che tipo di conoscenza delfatto, della vita del diritto, dei fenomeni giuridici hanno tutti coloro non appartengono al cerchio magico del diritto? Che cosa è il cerchio magico del diritto? È quella sfera ristretta di tutti coloro i quali lavorano,operano in ambito giuridico.

Avvocati, giudici, operatori giudiziari, direttori di un carcere, polizia, commissari, pubblici ministeri. Tutti coloro che svolgono una professione legale hanno una conoscenza diversa dalla conoscenza che avevate voiprima di entrare nell'aula di giurisprudenza. La domanda che io vi potrei portare è perché avete scelto di iscrivervi alla facoltà di giurisprudenza, a prescindere dall'idea di non sapere più altro fare e dunque di iscrivervi a giurisprudenza? C'è qualcuno che si è iscritto con convinzione, mi auguro, immagino, in questa facoltà e dunque perché era incuriosito dal diritto o dalla possibilità di svolgere una professione in ambito giuridico.

A meno che voi non abbiate in casa genitori, zio, parenti che svolgano la professione legale, negli anni altri voi come avete maturato questa convinzione? Come avete conosciuto la vita del diritto? Non certo attraverso i testi tecnici del diritto, ma mi auguro che durante gli anni del liceo, la sera prima di andare a dormire non leggevate il torrente, le pagine del torrente per appassionarvi al diritto. Me lo auguro per voi,anche perché in quel caso la passione del diritto vi sarebbe subito scemata, ma questo non fa per me. Ho altri manuali. La passione per le professioni legali l'avete sicuramente intercettata attraverso altri canali.

E qui il tema della cultura giuridica esterna di Friedman. Cioè Friedman si pone in problema, no? Ecco, tolto ilcentro magico del diritto, tolto chi studia tese, tolto chi lavora in un tribunale, il resto della popolazione, ilresto dei desti natali che eravamo noi, eravate voi, ma ora voi non siete più in una posizione di cultura giuridica totalmente esterna perché avete iniziato un percorso di conoscenza del diritto dall'interno, no?
Ma chi invece non opera all'interno della società, le scienze sociali, nella prospettiva delle scienze sociali, daqui la creazione, la costruzione del concetto di cultura giuridica esterna e l'idea di che cosa, l'idea che conoscere il diritto sia anche esplorare tutti i modi in cui il diritto viene raccontato, narrato, rappresentato attraverso la cultura di massa. Fondamentale, cambia completamente la prospettiva e capite bene come questo sviluppo. È chiaro che in questo caso la figura dello spettatore torna a essere il destinatario ideale. Questa costruzione teorica no perché, se il diritto viene percepito né da un punto di vista esterno né da un punto di vista interno ma da un punto di vista di chi poi no e con quel mondo non ci ha direttamente a che fare no, ma si trova all'esterno di quel mondo pur essendo subendone direttamente, molto spesso passivamente, le conseguenze. Qui l'idea di costruire delle epistemologie diverse, peraltro un'idea di Friedman da lì a poco, è un'idea che sarà profetica, perché siamo negli anni '70 del secolo scorso.
Immaginate nei decenni successivi che cosa voglio dire: lo sviluppo tecnologico, le nuove forme di narrazione, le nuove forme di comunicazione no, come aumenteranno, incrementeranno progressivamentei mail sistemi e i metodi di rappresentazione. Ogni narrazione della vita del diritto, da qui nasce l'esigenza tutta postmoderna, vedete, postmoderno è anche tutta quella parte no in cui come dire le grandi narrazioniteoriche del '900 si frantumano attraverso l'affermazione della cultura popolare no, della cultura massmediatica. Ecco, in questo caso anche il diritto è presente di questo tipo di influenza. Friedman e James Boyd White sono i primi che si accorgono e i inaugurano, Lorenz Friedman, il tema dalla cornice teorica a questi nuovi movimenti. James Boyd White è il primo che materialmente inizia a leggere e a costruire, a interpretare il discorso giuridico attraverso

la lettura dei grandi classici della letteratura. È un'operazione, diciamo, interessantissima ora dal punto di vista della didattica del diritto. Dovete immaginare che ci sono corsi ormai di diritto e letteratura un po' ovunque, ci sono anche master ormai che ragionano sul rapporto tra diritto e letterature che quindi seguono questo tipo di epistemologia. Oxford ha

inaugurato qualche anno fa, il corso di retorica giuridica, laddove gli strumenti di argomentazione, gli strumenti retorici da utilizzare nelle aule processuali vengono studiati attraverso le grandi arringhe, per esempio, che ci sono in Shakespeare, come abbiamo visto nel nostro piccolo con il mercante di Venezia no, o ci sono in tantissimi altri grandi classici della letteratura E quindi, come dire, questo apre tutta un'altra dimensione del discorso giuridico. Pensate da dove siamo partiti, no? Rapporto fra giusnaturalismo e positivismo giuridico. Pensate a un concetto pure come la purezza del diritto, come quello che è il segnale. Pensate dove siamo arrivati in questo caso. Quell'idea di leggere, di contaminare il discorso giuridico non tanto quale teologia o con un no, la politica, ma addirittura con la letteratura o con il cinema. È un capovolgimento a 180 gradi della nostra. nasce, costola del movimento, all'era circa, di diritto e letteratura, perché tutto sotto il cinema è una forma di narrazione, è una forma di letteratura che è, piuttosto che processa ovviamente attraverso il testo scritto, procede attraverso i testi del singolo, ma generalmente si raccontano sempre storie. I film sono storie che vengono raccontate attraverso le immagini e non soltanto attraverso i testi. Questo movimento che dicevo la volta scorsa ha però una particolarità che lo rende per noi molto interessante. Adesso vedremo in che senso, perché lo rende molto interessante perché è un movimento che non nasce come movimento teorico, ma nasce dall'interazione fra la teoria generale del diritto e la pratica legale dei grandi studi legali americani, a cavallo fra gli anni '90 e i primi anni del nostro secolo, che iniziano a dedicare vere e proprie aree di specializzazione dei loro studi e dei loro interessi alle tecniche retoriche e argomentative che vengono in questo caso mutuate da film o da serie televisive di successo. Dunque, diviene in questo caso un processo, si chiama movimento e non teoria, una serie di studi e di approfondimenti che hanno un'immediata ricaduta dal punto di vista pratico legale.
Quest'anno abbiamo modo di vedere, è una delle cose più interessanti del movimento, lo infilo cioè di Dio, che non sia soltanto un approccio metodologico o un approccio di teoria generale del delitto, ma si ha un approccio concreto che riguarda l'esercizio, diciamo, un quotidiano della pratica forense. Vi dicevoche i tre approcci metodologici che avevamo esplorato già la volta scorsa sono loro tradizionalmente sono definiti come law and film; nelle successive slide andremo rispetto a questi tre approcci, il diritto nel cinema, il diritto come il cinema, il cinema come diritto, andremo a vedere alcuni casi concreti di possibili applicazioni, diciamo, di queste tre modelli epistemologici al rapporto tra cinema e diritto. Quindi, rispetto alle cose generali che ci siamo dati, entreremo più in profondità all'interno di questi tre modelli epistemologici vuol dire in questo caso come il cinema racconta e può raccontare il diritto in tantissimi modi e l'avete visto concretamente e di modi che possono essere diversissimi. Ci può essere la narrazione del diritto in film di guerra, vi ricordate il film di Kubrick, ci può essere la ricostruzione del diritto in senso paradossale o surreale Vi ricordate Wells, no? L'adattamento del Processo di Kafka diretto da Orson Welles. In questo caso, ci possono essere generi che sono espressamente dedicati alla rappresentazione, alla narrazione del diritto. Penso al dramma in aula, al film finale, cioè il cinema processuale hollywoodiano, la parola ai giurati. Pensate anche a una serie come Suits su Netflix, la vita degli avvocati, no? Quindi la possibilità di conoscere, non tanto le dinamiche processuali, quanto che cosa, purtroppo, le dinamiche che ci sono all'interno degli studi legali, per i grandi studi americani, E quindi anche lì, c'è un cambio di prospettiva. Ma tutti questi casi, il cinema, la televisione, le serie televisive, raccontano il diritto. Ancora abbiamo il thriller, abbiamo le crime story dove molto spesso ci sono elementi giuridicamente rilevanti. Il cinema di guerra l'abbiamo detto, ci sono imprese o muri, per esempio. Il cinema che abbiamo d'ambientazione carceraria, anche quelli sono modi di rappresentare il diritto. Certo, si parla, come dire, dell'aspetto patologico della vita del diritto, no? Ma sono generi cinematografici espressamente dedicati, incentrati sulla rappresentazione della vita del diritto. Come è possibile analizzare che tipo di modelli costruiscono, diciamo, i teorici, di modelli epistemologici, cioè che vantaggi nella conoscenza del fatto giuridico, del fenomeno giuridico, attraverso la rappresentazione cinematografica? Generalmente i modelli epistemologici sono due, ovvero il modello, lo stile empatico cognitivo e lo stile politico ideologico. Che significa stile empatico cognitivo? Qui il cinema rappresenta uno strumento, diciamo, epistemologico molto diverso dall'analisi del testo giuridico, perché vedete, Suits, mobiliti avvocato di difesa, domanda: è facile la risposta. Perché vi piace? Perché vi appassiona? E perché vi appassiona? Perché vi immedesimate

con i

personaggi, no? Perché entrate anche voi all'interno di quei meccanismi che sono e che costituiscono la vitadel diritto, no? Sogniamo di essere in questo caso, come loro, ma in questo, in questa situazione. Questo che significa? Vedete, torniamo al tema dello spettatore. Significa che si costruisce, che cosa si costruisce? Un'epistemologia di carattere empatico, cioè, c'è differenza fra sostenere, conoscere, per esempio, fare un esame di diritto penale. Ancora non l'avete fatto, non lo farete, no? È ragionare sulle tecniche con cui si applica il diritto penale e guardarle rappresentate all'interno di 'Avvocato di difesa'. Sì, sicuramente c'è una differenza ed è una differenza data proprio dal modello di rappresentazione. Il testo non è l'immagine.
L'immagine produce in questo caso, nel destinatario, tutta una serie, evidentemente, di meccanismi che sono meccanismi che il testo legislativo, il testo giuridico, non può trasmettere. In questo caso, l'approccio empatico cognitivo è evidentemente un approccio molto molto valido per poter, come dire, conoscere il diritto attraverso la costruzione di un'altra prospettiva. Lo si fa sempre di più. Quando farete il corso di diritto penale, il vostro professore di diritto penale vi farà vedere tantissimi film di carattere processuale, perché, lui è uno che crede moltissimo, diciamo, nella, nel doppio canale, nella doppia metodologia didattica del diritto, cioè l'approccio tecnico, in questo caso specialistico, e l'approccio empatico cognitivo, in cui gli stessi concetti vengono appresi attraverso un modello epistemologico che non è soltanto logico razionale, ma che è empatico, appunto. Iniziamo a guardare e a commentare però alcune immagini. Va bene? Approccio empatico cognitivo. Che cosa state guardando in questa locandina? Vedrete adesso. Vi faccio questa premessa. Si, vi chiarisco una serie di immagini, questa volta di locandine di cinema, va bene? Che cosa sono le locandine cinematografiche? Perché ho costruito questo seminario passando attraverso la visualizzazione di questo tipo di immagine e non, in questo caso, delle vere e proprie sequenze cinematografiche? In particolar modo, per quel che riguarda i prison movies, la ragione è una ragione sia, come dire, storica personale che teorica. Un po' di anni fa, forse questo ve l'ho già detto, ho, abbiamo appurato con l'università di Torino un progetto di ricerca dedicato allo studio delle locandine dei prison movies, ovvero del cinema carcerario hollywoodiano, e ci siamo resi conto, in realtà, e adesso lo vedremo quando andremo ad a ragionare, ad analizzare il carcere, come questo sia uno strumento molto interessante per comprendere che tipo di immaginario ha costruito un cinema originario sul carcere nel secolo scorso. Prima di intraprendere questo discorso, che è "I am a fugitive from a chain gang", è il primo film carcerario prodotto ad Hollywood. Qual è l'aspetto curioso della locandina? Il film è il primo vero e proprio prison movie hollywoodiano che racconta l'odissea nell'America degli anni '30, dove soprattutto nelSud, nei paesi del Sud degli Stati Uniti, c'era questa pratica che era una pratica, in realtà, come di costruzione dell'ordine sociale, come si imprigionavano grandi masse di immigrati, cittadini messicani, di vagabondi, di persone che non avevano il lavoro, e si utilizzavano, destinandoli ai lavori forzati, quindi, per le opere di pubblica utilità. Ben presto, prima all'interno di spettacoli teatrali, poi attraverso, in questo caso,i primi successi hollywoodiani, si iniziò a denunciare questo tipo di condizioni disumane in cui erano detenuti questi soggetti, e lo si fece ovviamente attraverso alcune pellicole le storie individuali, come sempre accade, alla critica sociopolitica. Ma la cosa interessante, ragazzi, guardate la locandina, poi vi dirò qualcosa in più sull'epistemologia cinematografica del diritto attraverso le locandine. Qual è l'elemento che torna in entrambe le locandine che la rende assolutamente singolare e particolare? Quello disegnato e che cosa? Si è riuscito a vederlo? Che cosa c'è nel quadro che è oggetto dell'illustrazione, non del fotogramma di scena, che cosa, che sequenza, che scena? Qui a destra ci sono i lavori forzati, qui c'è il signore col pigiama classico e sotto, che certificato, non riuscite a vederlo, e una donna che si aggrappa, vedete, all'uomo, quasi piangendo, che sta scappando, no? Questo che cosa vi dice immediatamente? Qual è la dimensione che il film permette immediatamente di introdurre, a differenza, per esempio, di un articolo di denuncia? Empatica cognitiva, no? L'idea per cui dietro tutte queste segregazioni si nascondono poi i drammi di famiglie, di uomini e donne che vengono separate, no? Qui c'è tutta una lettura anche che poi faremo, di carattere politico ideologico. Per ora manteniamoci sull'empatico

cognitivo, Quindi la dimensione del dramma della carcerazione, è tradotta immediatamente e spostata immediatamente su un piano patetico, già dall'immagine della stessa locandina, no? Questo ce lo ce lo risparmia, eh, lo stile critico ideologico o politico ideologico, in questo caso non c'è tanto. È soltanto l'approccio ad essere sottolineato.

Questo lasciatelo, la lettura della slide come di, non potete tranquillamente bypassata, perché sono questioni sui film che non abbiamo trattato. In questo caso la cosa interessante però è che attraverso dei nuovi strumenti metodologici e la contaminazione del discorso giuridico attraverso altre metodologie, la psicoanalisi, la sociologia, la semiotica, la costruzione dei linguaggi filmico e giuridico, e riesci a decostruire,in questo caso, alcune categorie giuridiche e il modo in cui vengono rappresentate dal cinema e dal diritto: il maschio o il bianco, l'eterosessualità, il tema, in questo caso, della, di femminismo giuridico e teoria del femminismo giuridico, che si incrociano in modi in cui quel corpo della donna viene evidentemente rappresentato. è proprio su questo che adesso vi volevo un attimo soffermare. Prima però due parole sul che cosa è, sul perché vi sto mostrando delle locandine. Vi sto mostrando delle locandine carcerarie. L'idea,in questo caso, che il carcere sia uno dei luoghi più interessanti per ragionare sul diritto al cinema, come dire, ve l'ho già accennata, perché e il carcere, fra tutti i luoghi che appartengono al cerchio magico del diritto, è decisamente il luogo meno aperto allo sguardo o alla cultura civica esterna. chi conosce il carcere e chi c'è stato dentro, fondamentalmente, ma non è un luogo aperto allo sguardo o alla conoscenza di chi non ci, di chi non lo frequenta direttamente. Da qui l'idea per cui, che abbiamo una cultura giuridica esterna, alla Friedman, come che idea avete del carcere, come vi siete costruiti l'immagine del carcere, ragazzi, qui il tema dell'immaginario cinematografico diventa determinante, diventa interessantissimo, perché l'immagine che noi abbiamo, 90%, è un'immagine attraverso la proiezione, attraverso il cinema, attraverso la cultura giuridica esterna, e quindi attraverso i modi in cui il carcere è stato rappresentato e andare a capire come è stato rappresentato il carcere ci aiuta a capire anche che immagine ogni società ha voluto costruire o ha voluto trasmettere ai propri destinatari.

Attraverso una ricerca ho scoperto che a Bari ci sono 63.000 locandine depositate nella mediateca regionale pugliese: la più grande collezione, ma la più grande collezione italiana di locandine. E vada lì afare la sua ricerca d'archivio. Noi la supportiamo. Supportiamo il progetto. Da qui, con il mio collega dell'Università di Torino, iniziamo a fare una ricerca d'archivio nella mediateca regionale pugliese.
Individuiamo quasi 200 locandine di film. ne saranno sfuggite tante altre, perché vi dico come abbiamo dovuto procedere: dal titolo, per esempio. Abbiamo trovato anche locandine, molto spesso, e questa è stata una cosa molto interessante, c'era la locandina, il film degli anni '10, degli anni '20, degli anni '30, ma il film corrispondente non esiste più, cioè non ce n'è traccia neanche nell'internet o in database. Infatti, li abbiamo segnalati, ma sono state conservate le locandine di film rumeni, di film bulgari. Perché le locandine che sono, per voi, un oggetto come d'archivio, oggetto d'antiquariato, voi siete nati dopo che le strade, le nostre strade, no, prima erano lastricate. C'erano anche degli angoli in cui c'erano, diciamo, delle bacheche in metallo con tutti i cinema e con tutte le piccole locandine dei film che erano evidentemente in proiezione, oppure c'erano dei manifesti grandi, si chiamavano manifesti elefante, di grandissimi, che c'erano agli angoli delle strade. Forse qualcuno è sopravvissuto in qualche angolo che pubblicizzano i film disuccesso. Oggi la locandina svolge, può, la funzione di quello che oggi è il trailer, fondamentalmente, che vedete su YouTube o che vedete su canali televisivi, no? Qual è lo scopo? Ecco l'idea, no? Qual è lo scopodi una locandina? Lo scopo di una locandina non è lo stesso scopo del film. Il film può avere più o meno, come dire, intenti commerciali, ma avrà anche intenti artistici, per esempio. Non può essere un film d'autore, può essere un film un blockbuster hollywoodiano, può essere un film di genere italiano. La locandina ha sempre lo stesso scopo, cioè lo scopo è quello di convincere qualcuno che guarda la locandinaa pagare un biglietto e a recarsi in una sala cinematografica a guardarsi il film di cui quella locandina è espressione. Dal punto di vista semiotico, si dice anzi, Gerald Genette, che è uno dei grandi semiologi del '900, dice che le locandine cinematografiche, per esempio, sono dei paratesti. Che cos'è un paratesto? Il paratesto, tutte queste cose che vi sto dicendo ovviamente non è che non esiste questa lezione di oggi è fuori sacco rispetto, come dire, all'esame, quindi è solo per incuriosirvi

o per darvi ulteriori informazioni. Il paratesto sono quei testi che dipendono molto logicamente, la cui esistenza dipende dall'esistenza di un testo principale. Vi spiego: la locandina c'è solo se c'è il film di cui la locandina è la pubblicità. Non avrebbe senso una locandina senza film. A spendere dei soldi per andare a vedere un film che è ambientato dove, inuno dei luoghi più sgradevoli che conosca la cultura occidentale, cioè il carcere. E allora che deve fare?

Deve rendere, in un'immagine, il carcere come un luogo cinematograficamente appetibile, in grado di smuovere qualcuno a pagare dei soldi e a vedere un film sul carcere. E dunque vedete come sicuramente l'immaginario cinematografico costruisce una locandina, sarà un immaginario molto probabilmente alteratorispetto, no, alla realtà carceraria, così come poi uno la può conoscere frequentando un carcere, proprio perché la funzione, la finalità della locandina è radicalmente diversa. Eppure, le locandine diventano, nel secondo dopoguerra, uno dei canali di comunicazione più visti, perché sono nelle strade, perché sono sui giornali, nei cosiddetti flani pubblicitari che c'erano nei quotidiani, E dunque sono le immagini che noi osserviamo più frequentemente che ritraggono, dipingono l'istituzione carceraria. Da qui l'idea, allora, ricostruire un'analisi delle locandine cinematografiche, di andare a vedere che tipo di immaginario del carcere. Per esempio, nel secondo '900, Hollywood ha costruito, attraverso il primo 'Bones', un esempio tipico di come fosse alterata, per esempio, l'immagine e l'immaginario collettivo del carcere. È data proprio dalla rappresentazione, anzi dalla costruzione del corpo femminile. Avete visto prima nella precedente locandina che abbiamo analizzato, no? C'era una dimensione patetica. È vero, uno studioso di gender studies vi avrebbe subito fatto un rilievo, un'osservazione: vi siete accorti nella differenza nel modo in cui venivano ritratti del corpo dell'uomo e il corpo della donna? Il corpo della donna era un corpo aggrappato, segno di totale subordinazione, tutto sommato, dipendenza emotiva rispetto al corpo della donna dell'uomo. Il corpo dell'uomo era il corpo protagonista principale dell'illustrazione. Il corpo della donna era sotto, inginocchiato ai piedi del corpo. Guardiamo adesso, ecco, de-costruiamo con un approccio critico ideologico, l'approccio dei film studies americani, proviamo a decostruire le immagini, cioè a capire che tipodi discorso giuridico passa, che tipo di immaginario si è costruito, per esempio attraverso la rappresentazione del corpo femminile nelle locandine dei prison movies hollywoodiani. C'è una rappresentazione veritiera e una rappresentazione equa del corpo femminile rispetto al corpo maschile?
Oppure si è contribuito a costruire una rappresentazione totalmente, in questo caso, inverosimile della realtà penitenziaria delle donne? Guardate alcune di queste locandine: 'Rivolta delle recluse'. Iniziamo daquesto qui. Noteremo subito anche la differenza fra le immagini del film e l'immagine della locandina.
Perché la differenza? Guardate qui: 'Rivolta delle recluse'. Le recluse sono queste. Vi sembra che una reclusa di un carcere negli anni '50, di un penitenziario di massima sicurezza americana, avesse questa scollatura così in giro, con queste scollature, con questi abiti interamente costruiti per gli occhi di un pubblico maschile? Perché la locandina si muove in questo modo, perché vuole indurre che cosa? Un pubblico maschile, diciamo, a recarsi a vedere, probabilmente, dei corpi di donna che sono posti all'internodella narrazione. Nella narrazione, ragazzi, non c'è niente di tutto questo. Questa è la cosa sconvolgente, cioè il film è un film sulla rivolta carceraria di un gruppo di detenute che tutto sono tranne che vestite in maniera scollata, in maniera succinta. Cioè, l'immaginario che produce la locandina è un immaginario, inizialmente, altro anche rispetto all'immaginario della pellicola. Eppure, l'immagine che circola è l'immagine della locandina. Vedete come è interessante, l'analisi in questo caso della locandina rispetto alla realtà cinematografica? Guardate questo: è un capolavoro per me, 'Rivolta al braccio della morte'.
Guardate le donne come sono rappresentate: abito da sera, tacchi a spillo e addirittura schiene scoperte, con questo disegno di una frustata, come esempio. Vedete, tutte venissero frustate all'interno delle carceri dimassima sicurezza americani in quell'epoca, no? Anche qui, ragazzi, il corpo femminile è letteralmente, l'immaginario, della costruzione della detenzione e del corpo femminile all'interno del, dei processi di detenzione penitenziaria, è totalmente alterata. Si restituisce al pubblico, come dire, un'immagine del carcere completamente falsata, completamente falsata. Andate a decostruire questa immagine, comprendete, la società americana di quegli anni, che tipo di immagine si era costruita di cosa avvenisse all'interno di un carcere. Ecco, 'Orange is the New Black', nel 2013, l'immagine si capovolge completamente. Guardate l'immagine di 'Orange is the

New Black' E guardate la disposizione, in questo caso, dei corpi. L'unico corpo maschile qui è laterale. Gli altri corpi femminili sono al centro della narrazione. Ne vedete qualcuno vestito in abiti non appropriati, o qualche corpo femminile che scopre schiena, spalle o ha scollature? Nulla di tutto questo. Anzi, c'è un corpo, diciamo, del protagonista maschileche è ancillare, no? Si ribalta. Pensate alla locandina di 'Io sono un evaso', no, di Mervyn LeRoy, dagli anni

'30 al 2013. La rappresentazione del corpo femminile all'interno dell'immaginario carcerario cinematografico si è ribaltata completamente, completamente capovolta. E 'Orange is the New Black' non èun caso che sia una delle serie televisive che meglio di ogni altra abbia raccontato e continui a testimoniare,no, le condizioni di vita penitenziaria. un'altra serie interessantissima da questo punto di vista che però in Italia non ha avuto lo stesso successo e che e diciamo cioè viene qualche anno prima di Orange New black e pods non so se l'avete mai sentita nominare qui non ha avuto grande visibilità e dice un carcere maschile ed è proprio la vita all'interno di un penitenziario dove c'è tutta una dinamica interrazzialeinteretnica tra diciamo i vari i vari protagonisti. Allora passiamo al secondo approccio, 'law as film', dicevo lavolta scorsa. Che per 'law as film': che dobbiamo attendere, esempio anche quello del cinema carcerario.
Qualche anno fa mi sono trovato a presentare a Torino, con alcuni giudici dell'esecuzione penale. C'erano anche due protagonisti della serie televisiva iniziamo a discutere poi di tutto questo tema e di come anche in Italia si fosse creata tutta una nuova sensibilità. Se guardate, ce ne sono tantissimi ormai di esempi di rappresentazione carceraria all'interno del cinema italiano, della serialità televisiva italiana. C'è anche una serie che è andata, con l'autore di Montalbano, su Sky, interamente ambientata nel carcere. C'è stato il filmdi Leonardo di Costanzo. Ce ne sono ormai molti, ma fino agli anni '80 del secolo scorso, il carcere è stato un tabù per la società italiana e per il cinema italiano. Quindi, come anche su questo è come dire, si potrebbe aprire un enorme spazio di riflessione. Passiamo al secondo approccio, quello di 'Law as a film'. Tema e proprio si riconnette proprio al tema, lo dicevamo la volta scorsa, come le immagini rappresentano e condizionano sia da cultura giuridica esterna che la prassi del diritto, ovvero le strategie e le argomentazioni, il modo in cui all'interno del processo si muovono i protagonisti. Non vi fate trarre in inganno, i protagonisti del processo, cioè coloro i quali, usando sempre il lessico di Friedman, si muovono nel cerchio magico nel diritto, cambiano i loro atteggiamenti e le loro strategie, perché, perché c'è una cultura giuridica esterna su cui vogliono fare presa. E dunque le loro strategie cambiano sempre in tensionedi che cosa? In funzione di quei modelli stereotipati che la televisione, alla cultura di massa, propaga e che e influenzano la cultura giuridica esterna. Il caso delle giurie popolari americane è il caso paradigmatico Checultura giuridica hanno quei soggetti? Si deve trattare, soggetti che non sono né giudici né avvocati, Che non hanno nulla a che fare con il mondo, con l'autore giuridico. E anche lì, vedete, che a parte rari casi, la formazione giuridica che hanno questi soggetti che poi sono chiamati ad esprimere un verdetto, e torna come dire l'idea di Friedman del 'James boyd white: Il tema della costruzione di una cultura giuridica esterna che passa attraverso la formulazione popolare, presentazione popolare della qui. Richard Schweitzer, che è uno dei grandi studiosi teorici del diritto americani contemporanei che si occupano di loroin film, pensando ancora alla teoria del realismo giuridico di Alf Ross, ha come dire pubblicato un manifestoqui. Parla di 'visual legal realism', ovvero di 'realismo visivo legale'. Cioè, il tema per cui oggi la pressione psico-sociale alla Ross passi attraverso questi modelli che vengono proposti dalla cultura di massa, che finiscono per influenzare, dicevamo la volta scorsa, sia le giurie popolari sia chi opera all'interno delle, il giurista come sceneggiatore. Bello, ma è sempre più frequente l'idea per cui la dimensione narrativa, in questo caso del diritto, sia una dimensione in cui la strategia e difensive, le tecniche, le teorie argomentative si costruiscano come delle piccole sceneggiature cinematografiche, attraverso, una narrazione che si compone di sequenze fra immagini e parole. Un vero e proprio 'technique dello storytelling' si dava che è sempre più frequente trovare in alcuni manuali di argomentazione giuridica, soprattutto americani, il riferimento a tecniche, commentati, e/o tecniche interpretative che derivano dagli studi di teoria del cinema. In particolar modo, per esempio, David Bordwell, che è stato uno dei grandi teorici del cinema, che si è occupato di argomentazione e strategie argomentative nell'ambito del film, sia uno degli studiosi più citati dai teorici generali del diritto che studiano la teoria delle argomentazioni e le strategie comunicative e argomentative del diritto all'interno dei processi. Questa è un esempio, per esempio, di 'storytelling', di 'storyboard': È l'idea per cui molto spesso la tecnica

con cui si compone la sceneggiatura di un film, sia ripresa in realtà dall'avvocato o dalla pubblica accusa, per narrare, per raccontare la costruzione della propria strategia o difensiva o della propria strategia accusatoria. E anche qui vedete la sovrapposizione fra linguaggio giuridico e linguaggio cinematografico risulta essere

particolarmente suggestiva. Il giurista come attore, il concetto di 'visual legal commence', che significa 'il giurista come attore', l'avevamo accennato la volta scorsa. In questo caso, il tema è quello per cui i giuristi ormai, quindi coloro i quali vanno in processo, non fanno altro che mutuare molto spesso anche l'atteggiamento posturale, il modo di comunicare da un processo di mimesi con cui fanno che cosa? Mirano in realtà, il modo in cui alcuni attori, protagonisti, questi di serie televisive di successo. Penso allora, a CSI, argomentano all'interno delle loro serie televisive perché 'visual commons' si tratta di schemi di ragionamento pre-intenzionali. Dice che le giurie, i giudici interiorizzano, attraverso la visione di generi cinematografici e serie televisive, torniamo al tema della cultura giuridica esterna che conoscenza ho di come funziona un processo negli Stati Uniti? Da vent'anni guardo CSI, è chiaro che mi sono abituato, come dire, a che cosa? Al modo in cui non solo argomentano, ma al modo in cui si muovono, al modo in cui si rivolgono alla giuria popolare, attore. E allora che faccio? Siccome so che quello schema è uno schema ormai di intelligibilità della pratica giuridica che è stato acquisito dalla giuria popolare, perché quello è il modello di conoscenza del fatto giuridico che la cultura giuridica esterna ha introiettato all'interno del suo pubblico, e la giuria è un pubblico di spettatori, un ex pubblico di spettatori, ripeto quegli schemi per esserepiù convincente possibile, il più convincente possibile rispetto al mio uditorio. Ok? Lo stesso vi dicevo la volta scorsa, il tema della prova scientifica. All'interno dei processi americani, i file non in tutto, però sulla scorta e sulla scia del successo mastodontico di serie televisive come CSI, come Bones, che nel corso degli anni '90, nei primi anni del secolo scorso, no, hanno un finito per influenzare, per condizionare il modo di pensare di chi deve andare lì a prendere una decisione. Non è un caso che oggi ci sia una parte della nuova teoria della teoria delle argomentazioni giuridica che sia proprio quella che riguarda la giurisprudenza visivao la giurisprudenza cinematografica, proprio perché la teoria dell'argomentazione, diciamo da Aristotele in poi, tenta di studiare i modi in cui sia più semplice e più facile convincere l'uditorio delle proprie argomentazioni. Ancora, il giurista come montatore, un altro mestiere del cinema che viene evidentemente, come dire, assorbito e mutuato dal cinema. Avete visto anche l'ultimo omicidio che c'è stato a New York, mi sembra, Quello del corriere, attraverso, no, l'immagine della videocamera l'hanno poi rintracciato. Quello è lo strumento principale ormai, altro che viene utilizzato come strumento di prova, mavi avevo già detto a lezione, attenti anche dall'esempio della bara, le immagini non sono altre evidenze, necessitano poi di essere interpretate e dietro l'interpretazione di ogni immagine si nasconde poi in tutto un ginepraio di ulteriori tecniche e teorie interpretative. Va bene, qui c'è tutta una lezione che avevo svoltonel corso di dottorato sul vedere come in 'Ludovico Einaudi' e sul concetto del 'contagio'. Due esempi soltanto. Il montaggio è un modo in cui si costruisce, che ci dà un senso narrativo alle immagini. Quando si dà un senso narrativo alle immagini, come dire, si già si fa già un'opzione su quello che io voglio mostrare, su come lo voglio mostrare e, soprattutto, su quello che io non voglio evidentemente mostrare.

Film as law il cinema è strumento di normativo (grande linguaggio che è riuscito a costruire stereotipi sociali) per la costruzione di un determinato immaginario collettivo. Fino alla fine degli anni 60 è stato ungrande strumento per stabilizzare la popolazione. La presenza del cinema può influenzare chi lavora
nell'ambito giuridico come giudici e avvocati. L'introduzione del reato stalking è un archetipo letterario di Dracula e Frankenstein che sono stalker delle donne nei romanzi; in ogni caso lo stalker è una figura letteraria antica che noi identifichiamo come tale, stalking non esisteva perché non era una norma che era illecito e quindi non 0revedeva una sanzione. Intorno al reato si è creata una sensibilità tale da trasformarela persecuzione in reato; infatti, i personaggi non erano visti come disturbatori ma come uomini innamorati.

Hollywood anni 80: esce "attrazione fatale" e racconta la strategia persecutoria di una donna che dopo essere stata conquistata da un uomo sposato decide di perseguitare la famiglia di costui. Nello stesso periodo (nomi attori) subiscono attentati e vengono perseguitati da stalker e l'opinione

pubblica mostra una forte sensibilità affinché non si finisca come nel film, sull'onda di ciò lo stato della California emano nel 1991 del penal code la prima norma contro lo stalking " chiunque segue, molesta ecc.. è colpevole di stalking"la dinamica del film non è stalking come lo intendiamo noi poiché restano fuori dalla fattispecie la " stati di

ansia” “fondato timore e cambio di abitudini”, tale legge viene ispirata dall’immaginario cinematografico
piuttosto che dalla realtà sociale. Ciò significa costruire la legge ispirata ai film e non alla realtà.

La figura del giudice nella cimatografia italiana convinti che una figura negativa fosse stata costruita dal berlusconismo. (chiesto da un suo collega,) in realtà non asce con la cultura berlusconiana ma la precede dalla “commedia all’italiana” . con il poliziottesco all’italiana (anni 70): raccontano le scorribande di bandeche non riuscivano ad essere fermata della forze dell’ordine se non aumentando la violenza. Secondo alcuno tale idea proviene dall’immaginario americano ma si è scoperto che proviene dall’immaginario
italiano: tutte le pellicole aumentano la pressione sull’opinione pubblica. Aumentano paura nell’immaginario per giustificare la violenza. Questo cinema cessa quando la realtà sociopolitica italianasupera l’immaginario di queste politiche durante gli anni di piombo.

Considerazione finale: il cinema è stato nel bene e nel male un mezzo per parlare di nuovi argomenti. I prison movies hanno aiutato a formare una coscienza civile e per denunciare ed educare la cultura giuridica.